

<사실상 노무에 종사하는 공무원(우정직)의 근로조건에 우선 적용되는 법규범> **서울고등법원 2024.10.11. 선고 2022누47966 판결**

【판결 요지】

- 사실상 노무에 종사하는 공무원(우정직)이 가입한 노동조합과 정부 사이에 체결한 단체협약에서 정한 근로조건이 국가공무원법 및 국가공무원 복무규정의 근로조건 내용과 서로 충돌하거나 저촉될 경우 법령에서 정하고 있는 내용이 우선 적용되고, 그 범위 내에서 단체협약의 효력은 인정될 수 없다.

I. 사건 개요

- 원고는 2002. 12. 11.에 기능 10급(집배원)으로 신규 임용되었고, 2017. 9. 1.에 우정주사보로 승진하여 우체국 우편물류과에서 집배 업무를 담당하고 있다. 2020. 2. 7.에 00지방우정청장은 원고가 **국가공무원법 제57조**에 따라 소속 장관의 직무상 명령에 복종할 의무가 있음에도 2019. 총 4차례(10. 12.(토), 11. 2 3.(토), 12. 7.(토), 12. 21.(토))에 걸쳐 00우체국장의 근로명령을 거부하였다는 이유로 보통징계위원회에 징계계 의결을 요구하였다. 보통징계위원회는 원고 가 직무상 명령의 복종 의무를 위반한 것으로 보아 2020. 3. 25.에 감봉 1월의 징계처분을 하였다. 2020. 4. 30.에 원고는 인사혁신처 소청심사위원회에 심사청 구를 하였으나, 2020. 7. 22.에 소청심사위원회는 기각하는 결정을 하였다. 2020. 9. 10. 원고는 불복하여 서울행정법원에 제소하였고, 2022. 5. 20. 1심 법원 은 감봉 1월의 처분을 취소하는 판결을 하였다. 2022. 6. 20. 피고 00지방우정청장은 항소하였고, 항소심 법원은 2024. 10. 11.에 원고의 청구를 기각하고 1심 법원 판결을 취소하였다.

II. 쟁점이 되는 법령과 단체협약

1. 국가공무원 복무규정

- 제9조(근무시간 등) ①공무원의 1주간 근무시간은 점심시간을 제외하고 40시간으로 하며, 토요일은 휴무함을 원칙으로 한다.
- 제11조(시간외근무 및 공휴일의 근무) ①행정기관의 장은 민원 편의 등 공무 수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 제9조 및 제10조에도 불구하고 근무시간 외의 근무(이하 시간외근무라 한다.)를 명하거나 토요일 또는 공휴일 근무를 명할 수 있다.

2. 단체협약

- 제116조(연장·야간·휴일근무) 사용자가 연장·야간·휴일근무를 시키고자 할 때에는 조합원의 동의 및 교섭대표노동조합과 사전 협의를 하여야 한다.

III. 1심 법원의 판단

- 1심 법원은 ① 강행규정이란 선량한 풍속 기타 사회질서에 관한 규정으로서 당사자의 의사에 의하여 그 규정의 적용을 배제할 수 없는 것을 의미하지만, 공무원의 근무시간은 직무의 성질, 지역 또는 기관의 특수성에 따라 변경될 수 있고, 원고와 같이 현업기관의 작업 현장에서 종사하는 우정직 공무원의 근무시간 과 근무일은 그 기관의 장이 소속 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 따로 정할 수 있을 뿐만 아니라, 토요일 또는 공휴일 근무를 명하는 것 역시 재량행위로 규정되어 있는 점 등에 비추어 국가공무원 복무규정 제11조 제1항은 선량한 풍속 기타 사회질서에 관한 규정이라거나 당사자들의 의사에 의하여 그 적용을 배제 할 수 없는 강행규정이라고 볼 수 없다고 판단하였다. 또한, ② 국가공무원 복무규정에서 토요일은 휴무일이 원칙이고, 특별한 사정, 즉 민원 편의 등 공무 수행 을 위하여 필요하다고 인정할 때에야 비로소 토요일 등 근무를 명할 수 있기에 이 사건 단체협약 제116조는 근로자의 근로조건 결정권을 보장하고 기본적인 생 활을 보장하기 위하여 사용자가 자의적으로 토요일 등 근무를 명하는 것을 제한하기 위한 최소한의 수단으로 보아야 하므로 국가공무원 복무규정 제11조 제1 항에 배치되는 내용을 규정하고 있는 것이라고 할 수 없다고 보았다.

- 따라서 법원은 이 사건 단체협약에서 토요일 근무를 명하기 위한 요건으로 조합원(공무원)의 개별 동의를 규정하였다고 하여 법률·조례 또는 그의 위임에 따라 규정되어야 하는 내용을 단체협약으로 규정하고 있거나 법률·조례 또는 그의 위임에 따라 규정된 내용에 위배되는 사항을 규정하고 있다고 할 수 없다고 보아 단체협약이 유효하다고 판단하였다.

- 이에 우체국장이 유효한 단체협약에도 불구하고 원고의 동의 없이 원고에게 토요일 근무를 명하는 내용의 근무명령을 하였으며, 원고는 여러 차례에 걸쳐 토요일 근무에 대하여 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였으므로 이 사건 근무명령은 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준을 정하고 있는 규범적 효력 을 지니는 이 사건 단체협약 규정에 저촉되는 것으로서 그 효력을 인정할 수 없다고 보았다.

- 결론적으로 법원은 우체국장의 근무명령이 위법하고 무효이므로 근무명령이 적법·유효하게 이루어졌음을 전제로 한 이 사건 징계 사유는 인정되지 아니 하므로 징계처분은 위법하여 취소되어야 한다고 판단하였다.

IV. 항소심의 주요 쟁점과 판시

1. 집배원인 원고의 근로자 지위 및 근로3권의 보장 범위

- 헌법상 공무원인 근로자는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 갖는다(**헌법 제33조 제2항**). 공무원이란 직접 또는 간접적으로 국민에 의하여 선출 또는 임용되어 국가나 공공단체와 공법상 근로관계를 맺고 공공적 업무를 담당하고 있는 사람들을 가리키는데, 공무원도 각종 노무의 대가로 얻는 수입에 의존하여 생활하는 사람이라는 점에서 통상적인 의미의 근로자적인 성격을 지니고 있다(**근로기준법 제2조 제1항 제1호부터 제3호**).

- **구 노동조합 및 노동관계조정법(이하 노동조합법) 제5조**에서는 근로자에 대해 자유롭게 노동조합을 조직하거나 가입할 수 있도록 하고 있으나 단서에서 공무원과 교원에 대하여는 따로 법률로 정하도록 규정하였다. 이에 따라 공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 공무원노동조합법)이 제정되어 운영 되고 있으나, **공무원노동법 제2조**에서는 사실상 노무에 종사하는 공무원을 법 적용 대상에서 제외하고 있다. 또한, **국가공무원법 제66조 제1항**에서는 공무원은 노동운동이나 그밖에 공무 외의 일을 위한 집단 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하면서 다만, 사실상 노무에 종사하는 공무원은 예외로 규정하고 있다. 그리고 국가공무원 복무규정 제28조에서 사실상 노무에 종사하는 공무원을 과학기술정보통신부 소속 현업기관의 작업 현장에서 노무에 종사하는 우정직 공무원(우정직 공무원의 정원을 대체하여 임용된 일반임기제 공무원 및 시간선택제일반임기제공무원을 포함한다)이라고 규정하면서 ① 서무·인사 및 기밀 업무에 종사하는 공무원, ② 경리 및 물품 출납 사무에 종사하는 공무원, ③ 노무자 감독 사무에 종사하는 공무원, ④ **보안업무규정**에 따른 국가보안시설의 경비 업무에 종사하는 공무원, ⑤ 승용자동차 및 구급차의 운전 등 종사하는 공무원을 제외하고 있다.

- 항소심 법원은 상기 법령들을 종합하여 원고인 우정사업본부 소속의 우체국에 근무하는 집배원의 경우 사실상 노무에 종사하는 공무원으로서 일반 근로자와 마찬가지로 근로관계에 있어서는 노동조합법의 규율 대상이 되고, 단체행동권에 제약이 있는 일반 공무원과 달리 원칙적으로 헌법상 근로자에게 보장된 근로3권을 온전히 누릴 수 있는 기본권 주체성이 인정된다고 판시하였다(같은 취지의 **헌법재판소 2009.7.30. 선고 2006헌마358 결정** 참조).

2. 원고의 일반 근로조건에 적용되는 법률관계 및 단체협약과의 관계

- 사실상 노무에 종사하는 공무원은 헌법상 근로3권이 보장되는 일반 근로자로서의 지위를 갖는다는 점에 한정한다면 근로조건 기준의 최소한의 기준을 정한 근로기준법의 적용 대상일 뿐만 아니라 사용자인 대한민국에게 적극적으로 교섭을 요구하여 유리한 내용으로 근로조건을 자율적으로 형성할 수 있는 완전한 의미의 단체협약 체결권을 갖는 것으로 볼 수 있다.

- 그러나 사실상 노무에 종사하는 공무원이라고 할지라도 여전히 국민 전체에 대하여 봉사하고 책임을 져야 하는 공무원이라는 특별한 지위에 있는 사람이라는 점은 일반 공무원과 다르지 않다. 따라서 일반 근로자와 달리 사용자인 정부와 사이에 특별한 근로관계에 있는 것으로 보아야 하고, 원칙적으로 그 근로조건은 **국가공무원법** 및 그 위임에 따른 **국가공무원 복무규정** 등 독자적인 법률 및 하위법령에 따라 규율되는 것이 원칙일 뿐만 아니라 근로조건에 대해서는

국가공무원법 등이 근로기준법보다 우선 적용된다(헌법재판소 2017. 8. 31. 선고 2016헌마404 결정 참조). 따라서 국가공무원법 및 국가공무원 복무규정 등 법령에 따라 정해진 근무조건에 대해서는 사용자와 노동조합 사이의 자율적인 교섭에 따른 단체협약을 통해 임의로 그 내용을 달리 정할 수 없다고 보아야 한다(유사한 취지의 대법원 2023. 9. 21. 선고 2016다255941 전원합의체 판결 참조).

- 이러한 입장에서 항소심 법원은 공무원의 근무조건은 노무 제공의 환경이나 조건이 근로기준법, 단체협약 등에 의해 규율되는 일반 근로관계와 달리 최소한의 보장이 아니라 적절한 수준의 보장으로 이해해야 한다고 보았다. 또한, 사실상 노무에 종사하는 공무원에 대해서 일반 근로자와 동일하게 근로3권을 보장하려는 취지는 이들의 지위가 전적으로 일반 근로자와 동일한 것임을 인정하려는 것이라기보다는 공무원의 지위에 있음을 전제로 공무원이 담당하는 직무의 성질에 비추어 집단적 노동운동에 관한 권리를 인정하더라도 공공복리에 미치는 영향이 상대적으로 적기 때문이라고 보았다. 나아가 법원은 공무원의 근무조건 향상은 국민 전체의 복지 증진을 부당히 침해하지 아니하고 그 시대의 국가 또는 사회공동체의 경제 수준 또는 담세능력과 조화될 수 있는 범위에서 합리적으로 정해져야 한다는 점에서 그 결정은 주권자인 전체 국민을 대표하는 국회에서 민주적인 절차에 따라 입법과 예산의 심의 의결을 통하여 이루어지는 것이 의회민주주의, 권력 분립원칙 등에 비추어 합목적적이라고 판단하였다(유사한 취지의 헌법재판소 1992. 4. 28. 선고 90헌바27 등 결정 참조).

- 따라서 법원은 원고 집배원인 우정직 공무원에 대해서는 이 사건 쟁점 단체협약 규정보다 법령 규정이 우선 적용되고, 이 범위 내에서 단체협약으로서 효력을 인정할 수 없다고 판시하였다. 또한, 법원은 공무원의 근무조건을 규정한 이 사건 법령 규정이 공무원의 근무조건 중 공휴일 휴무 원칙에 대한 예외를 인정한 것인데, 이는 공익상의 필요를 요건으로 하고 국민 전체의 봉사자라는 공무원 지위의 특수성 및 직무의 공공성과 밀접하게 관련된 근무조건이라고 할 수 있고, 이에 관하여 다른 공무원과 다르게 사실상 노무에 종사하는 공무원에 대해서만 그 적용을 배제할 합리적인 이유를 찾을 수 없으므로 사실상 노무에 종사하는 공무원을 포함하여 모든 공무원에게 일률적으로 적용되는 강행규정인 근무조건이라고 판단하였다.

- 결론적으로 법원은 이 사건 쟁점 법령 규정에 저촉되는 범위 안에서 단체협약의 효력이 배제되는 것으로 보는 것은 사실상 노무에 종사하는 공무원에 대해 국민 전체에 대한 봉사자로서 지위 및 그 직무의 공공성에 따른 합리적인 공무원제도를 보장함과 아울러 주권자로서 국민 일반의 이해관계를 통합·조정하기 위한 것이라 할 것이므로, 이는 헌법 및 국가공무원법령에 따른 것이고 이러한 해석이 사실상 노무에 종사하는 공무원에게 보장되는 기본권인 근로3권 제한의 한계를 넘어 부당한 것으로 보기는 어렵다고 판단하였다.

- 이러한 사유에서 00우체국장이 가을건이 등으로 인하여 소포우편물 등 배달물량이 증가함에 대응하기 위해 토요일 근무가 필요하다는 직무상의 판단에 따라 적법한 직무상의 명령을 발하였고 원고가 토요일 근무의무를 이행하지 아니할 것을 정당화할 만한 특별한 개인적 사정이 있음을 인정할 증거도 없기에 원고의 복종의무 위반의 비위사실이 인정되므로 이 사건 징계 사유는 타당하다고 판단하였다.

V. 검토

- 본 대법판결은 사실상 노무에 종사하는 공무원이 가입한 노동조합과 사용자인 대한민국 사이에 체결한 단체협약이 국가공무원 복무규정과 달리 조합원(공무원)에게 유리하게 규정하고 있을 때 단체협약을 우선 적용할 수 있는지에 관한 문제가 핵심이다.

- 노동조합법 제33조에서는 단체협약에서 정한 근로조건에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분을 무효로 하여 단체협약을 우선 적용하고 있다. 반면 공무원노동법 제10조제1항에서는 단체협약의 내용 중 법령·조례 또는 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서 효력을 가지지 아니한다고 규정하여 법령이 우선 적용된다고 명확하게 규정하고 있다. 대법판결의 결론만 놓고 본다면 법원이 사실상 노무에 종사하는 공무원은 노동조합법에 따라 노동3권을 보장받고 단체협약을 체결하였더라도 체결된 단체협약의 효력은 노동조합법 제33조가 아닌 공무원노동법 제10조제1항이 적용되어 단체협약보다 법령이 우선 적용된다고 단순히 도식화하여 판단하였다고 오해할 수 있다.

- 그러나, 대법판결은 공무원노동법 제10조제1항을 직접 적용하여 사건 쟁점인 단체협약의 효력을 부인한 것이 아니고, ① 사실상 노무에 종사하는 공무원(우정직)도 국민 전체에 대한 봉사자라는 공무원 신분과 적절한 생활을 보장받고 있다는 점, ② 공공성에 따라서 부여된 직무의 특수성, 쟁점된 법령 규정이 직무의 공공성과 밀접하게 관련된 근무조건이라는 점, ③ 다른 공무원과 다르게 사실상 노무에 종사하는 공무원만 관련 법령 적용을 배제할 합리적인 이유가 없다는 점, ④ 사안의 쟁점이었던 토요일근무에 대하여 단체협약 체결 이후에도 토요일 휴무 시행과 중단을 몇 차례 반복한 특수한 상황 등을 종합적으로 고려하여 합목적적으로 이 사건 쟁점 단체협약 규정을 제한하고 국가공무원 관련 법령 규정을 우선 적용해야 한다고 판단하였다.

- 본 대법판결은 기존에 계속 쟁점이 되었던 토요일 근무라는 쟁점에 한정하여 극히 예외적으로 쟁점이 된 단체협약 효력을 제한하여 해석한 것으로 보아야 하며, 일반적으로 사실상 노무에 종사하는 공무원과 국가 간 체결한 단체협약과 공무원 법령 간 적용 순서를 명시한 판결은 아니라고 생각한다. 그러나 사실상 노무에 종사하는 공무원(우정직)은 일반 근로자와 동일하게 노동3권이 보장되고 있으나 원칙적으로 공무원으로서 신분과 지위를 가지므로 노동3권의 보장 범위 및 단체협약 규정의 효력 범위 등이 일반 근로자와 달리 해석할 수 있다는 점을 다루었다는 점에서 의미 있는 판결이라고 생각한다.

<국제근로관계에서 근로기준법이 적용되는 사업 또는 사업장의 판단 기준> 대법원 2024.10.25. 선고 2023두37391 판결, 대법원 2024.10.25 선고 2023두46074 판결, 대법원 2024.10.25 선고 2023두57876 판결

【판결 요지】

- 근로기준법 제11조는, 근로기준법은 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용하고(제1항), 상시 4명 이하의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법의 일부 규정을 적용할 수 있다(제2항)고 규정하여 상시 사용하는 근로자 수를 기준으로 근로기준법의 적용 범위를 달리 규율하고 있다. 외국기업이 국내에서 법인이나 영업소 등을 설립하여 사업활동을 영위하며 근로자를 사용하는 국제근로관계에서는 원칙적으로 국내에서 사용하는 근로자 수를 기준으로 근로기준법이 전면적으로 적용되는 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 해당 하는지 여부를 판단하여야 한다.

- 근로기준법의 적용 단위가 되는 같은 법 제11조 제1항의 사업 또는 사업장이라 함은 경영상의 일체를 이루면서 유기적으로 운영되는 경제적, 사회적 활동 단위를 의미한다. 법인격의 분리 여부가 독립된 사업 또는 사업장에 해당하는지를 판단하는 우선적인 기준이 되므로 법인격이 다른 기업조직은 특별한 사정이 없는 한 하나의 사업 또는 사업장을 구성할 수 없음이 원칙이다. 다만, 별개의 법인격을 가진 여러 개의 기업조직 사이에 단순한 기업 간 협력관계나 계열회사, 모회사 사이의 일반적인 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적, 사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상의 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는 이들을 하나의 사업 또는 사업장이라고 볼 수 있다. 이때 복수의 기업조직이 하나의 사업 또는 사업장에 해당하는 특별한 사정이 있는지 여부는 업무의 종류, 성질, 목적, 수행방식 및 장소가 동일한지, 업무지시와 근로자의 채용, 근로조건의 결정, 해고 등 인사 및 노무관리가 기업조직별로 구분되지 않고 동일한 사업주체 내지 경영진에 의하여 통일적으로 행해지는지, 각 단위별 사업활동의 내용이 하나의 사업목적에 위하여 결합되어 인적·물적 조직과 재무·회계가 서로 밀접하게 관련되어 운영되는지 등과 같은 사정을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단하여야 한다.

I. 사건의 개요

- 대상판결 사안은, 외국적 요소가 있는 근로관계(국제근로관계)에서 대한민국 국적자가 근로계약을 체결하고 이에 따라 노무를 제공하던 중 해고되어 발생한 법률관계에 관한 것이다. 대법원 2024.10.25. 선고 2023두37391 판결(이하 대상판결 1)의 사건은, 해고된 근로자(참가인)가 근로계약의 당사자인 한국법인(원고1)에 대하여 독일법인(원고2)까지 상대로 하여 부당해고구제신청을 하였다. 대법원 2024.10.25. 선고 2023두46074 판결(이하 대상판결 2)의 사건은, 근로자(원고)가 미국법인(참가인1)과 사이에 근로계약을 체결한 다음, 한국에 영업소와 사무실을 두고 있는 다른 미국법인(참가인2)의 서울 사무실에서 근무하다가 참가인1로부터 근로계약만료 통지를 받게 되자, 참가인들을 상대로 부당해고구제신청을 하였다. 대법원 2024.10.25. 선고 2023두57876 판결(이하 대상판결 3)의 사건은, 해고된 근로자(참가인)가 근로계약의 상대방인 외국법인(원고)을 상대로 부당해고구제신청을 하였다.

II. 쟁 점

- 국제근로관계에 대하여 국제사법에 따라 대한민국의 근로기준법이 준거법 내지 강행법규로 인정되고 대한민국 법원에 국제재판관할권이 있음을 전제로, 근로기준법의 적용 단위가 되는 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장을 어떻게 판단할 것인지가 문제된다. 근로기준법 제11조에서 말하는 하나의 사업 또는 사업장을 파악하는 데 외국기업이나 외국법인을 어떻게 취급할 것인지의 문제이다. 대상판결 사건에서 사용자 측은 대한민국 내에 설립된 법인이나 대한민국 내에 소재한 영업소만으로 한정하면 근로자 수가 5명 미만이므로 근로기준법이 적용되지 않는다는 항변을 하였다.

III. 원심의 판단

1. 대상판결 1의 원심

- 대상판결 1의 원심은, 근로기준법 적용 기준이 되는 하나의 사업장인지 여부에 관한 판단 기준을 다음과 같이 제시하고, 이를 기초로 본 건 원고들은 실질적으로 경영상 일체를 이루는 하나의 사업장으로 운영되었다고 판단한 다음, 참가인이 근무하는 사업(장)의 상시근로자 수는 5명 이상이므로 근로기준법 제23조가 적용된다고 하였다. 해당 원심은 다음과 같은 법리를 설시하였다. 근로기준법의 입법취지에 비추어, 사업(장)이 기업체 그 자체를 의미하지 않는 특별한 사정이 있는지 여부, 사업주가 하나의 활동주체로서 활동한 것인지 여부는 형식이 아닌 실질적인 근로관계를 기준으로 판단하여야 한다. 따라서 근로기준법 적용 기준이 되는 하나의 사업장인지 여부는, 근로장소의 동일성과 더불어 제공된 설비의 사용관계, 사업의 목적 및 수행 방법, 조직체계, 인사교류, 업무 수행과정에서의 구체적 지휘·감독관계 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 여러 사업(장)의 경영상 분리·독립성은, 각 목적 사업 사이의 유기적 연관성이나 차별성, 임원이나 근로자 등의 인적 교류 여부, 재정이나 회계의 분리 여부, 업무 장소의 분리·독립 여부, 경영상 의사결정 조직의 분리 여부, 업무상 지휘·감독이나 근태관리의 분리 여부 등을 전체적으로 살펴 판단하여야 한다. 장소적 독립성은 하나의 요소일 뿐, 장소적으로 독립되어 있다고 해서 반드시 경영상 독립된 사업(장)으로 인정할 것은 아니다. 이는 외국에 위치한 본사와 국내에 있는 영업소와 같이 장소적 독립성이 인정되는 경우에도 마찬가지이다. 증명책임은 이를 주장하는 사용자 측에 있다.

2. 대상판결 2의 원심

- 대상판결 2의 원심은, 근로기준법 제11조의 입법취지를 고려할 때 근로기준법이 전부 적용되는 사업(장)인지 여부는 경영상 일체로 평가되는 하나의 사업(장)을 전제로 그 사업(장)이 근로기준법을 전부 적용할 때의 경제적·행정적 부담을 감당할 수 있는지 여부를 기준으로 판단하는 것이 타당하다고 하면서, 이러한 기준에서 볼 때 참가인1은 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업(장)을 운영하는 주체라고 판단하였다. 참가인 1이 외국에서 상시 5명 이상의 근로자를 사용하고 있고, 원고는 대한민국에서 참가인1을 위해 근로를 제공하였으며, 준거법이 대한민국 근로기준법이라고 인정되는 이상, 특별한 사정이 없는 한 근로기준법 제11조의 해석에 관하여 국내 회사와 외국 회사를 달리 볼 이유가 없으므로 설령 참가인1과 근로계약을 체결하고 대한민국에서 근무하는 자가 유일하게 원고만 있더라도 근로기준법 제11조 해석과 관련하여 참가인1은 상시 5명 이상의 근로자를 사용하고 있다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 근로관계에는 근로기준법 제23조 등이 적용된다고 하였다.

3. 대상판결 3의 원심

- 대상판결 3의 원심은, 대상판결 1의 원심에서 제시된 법리를 인용하고 이에 더하여 법인격 등 법적 형식에 따라야 한다는 원고의 주장을 배척하는 논거를 추가하면서, 참가인이 근로를 제공한 사업(장)은 원고 외에 다국적 기업 조직 내에 있는 A사까지 포함하는 것이라고 보았다. 원고와 A는 별개의 독립된 법인의 형태를 취하고 있기는 하나 실질적으로는 경영상의 일체를 이루는 하나의 사업장으로 운영되었으므로, 합산하여 5명 이상의 상시근로자를 사용하는 위 사업장에 대하여 근로기준법 제23조 제1항 등이 적용된다고 판단하였다. 해당 원심이 추가한 법리 실시 부분은 다음과 같다. 근로의 제공과 이를 통해 실현되는 기업의 성과물 사이의 실질적 관련성과 기여도에 따라 근로조건의 적용 대상이 되는 사업(장)의 범위가 확정되어야 한다고 봄이 타당하다. 즉 근로기준법 제11조 제1항의 사업(장)의 범위는, 기업가가 해당 근로자로부터 근로를 제공받아 목적을 달성하고 이익을 얻게 되는 사업의 실체가 무엇인지, 즉 해당 근로자로부터 제공받은 근로라는 요소가 사업에 투입되는 다른 요소(다른 근로자의 근로, 운영자금, 생산설비, 사무실, 영업망 등)와 결합되어 사업적 성과와 이익을 발생시키는 경영상·사업상의 실질적 단위가 무엇인지에 따라 결정되어야 한다. 이를 위해서는 단순히 법적 형식에 기초한 사업의 외형적 조직이나 구성뿐만 아니라, 생산, 판매, 관리, 인사, 노무, 회계를 망라하는 사업 경영활동의 실질적 동일성 내지 단일성 여부가 사업(장)에 해당하는지 여부에 관한 판단의 핵심적 기준이 되어야 한다.

Ⅳ. 대법원의 판단 및 분석

- 대법원은 국제근로관계에서 근로기준법이 적용되는 사업 또는 사업장 판단에 관한 법리를 구체적으로 실시하였다. 근로기준법은 상시 사용하는 근로자가 5명 이상인 사업 또는 사업장에 적용되는데, 외국기업이 국내에서 법인이나 영업소 등을 설립하여 사업활동을 영위하며 근로자를 사용하는 경우, 원칙적으로 국내에서 사용하는 근로자 수를 기준으로 해당 사업 또는 사업장인지 판단하여야 한다는 것이다. 국내에서 사용하지 않는 근로자는 원칙적으로 근로기준법 적용 여부의 판단에 고려하지 아니하고, 예외적으로만 고려된다. 그 이유로 대법원은, ① 근로조건의 규율, 근로자들 간의 의견 교환 및 협의, 경영상 해고를 비롯한 해고의 정당성 판단 등을 위한 기초 단위로서, 근로관계의 각종 규율이 통일적으로 적용될 수 있는 실질적으로 동일한 경제적, 사회적 활동단위라고 볼 수 있는 경우에 한하여 하나의 사업 또는 사업장을 구성할 수 있으므로, **근로기준법 제11조**의 사업 또는 사업장은 대한민국 내에 위치한 사업 또는 사업장을 말한다고 봄이 타당하다는 점, ② 외국기업이 외국에서 사용하는 근로자에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 외국의 노동관계법령이 적용될 뿐이므로, 대한민국 근로기준법이 적용되지 않는 외국에서 사용하는 근로자 수까지 합산하여 **근로기준법 제11조 제1항**의 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 해당하는지 여부를 판단할 수는 없다는 점을 들었다. 이를 기초로 대법원은, 근로기준법 적용 대상 사업 또는 사업장인지에 관한 판단기준을 대법원과 달리한 <대상판결 1>과 <대상판결 2>의 원심을 각 파기하였다. 해당 원심은 위에서 본 것처럼, 법인이 국내에서 설립되거나 영업소가 국내에 소재하는지 여부가 아니라 인적·물적 조직 구성과 운영(지휘·감독, 노무제공)의 태양, 근로기준법상 규제를 경제적·행정적으로 부담할 수 있는지 여부 등을 고려하여 하나의 사업 또는 사업장으로 볼 수 있는 범위를 먼저 판단하였다. 국내 소재 영업소 또는 국내 설립 법인 소속 근로자 수가 5명 미만일지라도 이를 넘어 확정되는 해당 사업 또는 사업장의 상시근로자 수가 5명 이상이 되어 근로기준법 적용을 배제할 수 없다고 하였다.

- 국내에서 사용하는 근로자 수를 근로기준법 적용 여부의 판단기준으로 삼는다는 대법원의 실시는 논리적 법해석이라기보다는 정책적 결정의 배경 설명에 가깝다. 근로관계의 각종 규율이 통일적으로 적용될 수 있는 실질적으로 동일한 경제적, 사회적 활동단위가 법인 설립지 또는 영업소 등이 위치한 국내라는 지리적·물리적 범위로 국한되어야 하는 것은 아니다. 외국기업이 외국에서 사용하는 근로자에 대하여 자국 법령을 적용하는 기준이 무엇인지를 여기서 일률적으로 논할 것도 아니다. 게다가 대법원의 위와 같은 판시만으로는 어떤 경우에 근로자를 국내에서 사용한다고 볼 수 있는 것인지 불분명하여 다시금 해석이 필요해진다. 예를 들어 인적·물적 조직의 상당 부분이 국내에 존재하는데 사업의 중요한 의사결정이 외국에서 이루어지는 경우, 또는 개별 근로자의 모집, 채용, 지휘·감독, 노무 제공과 수령의 장소 등이 국내외 제각각의 장소에서 이루어지는 경우, 이와 관계된 근로자를 국내에서 사용하는 근로자로 볼 것인가. 아니면 외국에서 사용하는 근로자로 볼 것인가.

- 반면에 <대상판결 3>에서 대법원은 국제근로관계에서 하나의 사업 또는 사업장에 해당하는지에 관하여 노동법적 관점에서 대상판결 1, 2보다는 자연스러운 논리 전개와 결론에 이르고 있다고 보인다. 대법원은 먼저, 근로기준법의 적용 단위가 되는 **같은 법 제11조 제1항**의 사업 또는 사업장이라 함은 경영상의 일체를 이루면서 유기적으로 운영되는 경제적, 사회적 활동단위를 의미한다고 정의한 다음, 법인격의 분리 여부가 독립된 사업 또는 사업장에 해당하는지를 판단하는 우선적인 기준이 되므로 법인격이 다른 기업조직은 특별한 사정이 없는 한 하나의 사업 또는 사업장을 구성할 수 없음이 원칙이라고 하였다. 이는 대법원이 일찍이 퇴직금 차등제도 금지에 관한 구 근로기준법 규정에서 말하는 사업에 관하여 특별한 사정이 없는 한 경영상의 일체를 이루는 기업체 그 자체를 의미한다 할 것이고, 따라서 경영상의 일체를 이루면서 유기적으로 운영되는 기업조직은 하나의 사업으로 파악하여야 할 것이라고 판시한 것과 구조와 내용 면에서 대동소이하다. 적어도 전통적인 노동법이 모델로 삼았던 것은 사업과 법인을 동일시하는 모델이었고, 근로관계의 특징인 종속성도 이 모델에 기초해 있다고 볼 수 있다는 점에서 역사적 의의를 지니고 있기도 하다.

- 다만, 사업과 기업은 동일한 개념이라고 볼 수 없고, 사업이 법인으로 환원되지 않으며, 사업과 법인을 동일시하는 것은 법이론적 근거도 약할 뿐만 아니라, 오늘날의 현실에도 더 이상 부합하지 않는다. 보통의 경우에는 하나의 법인이 하나의 사업을 구성할 것이지만 언제나 그런 것은 아니다. 우리 판례상으로도 사업 단위를 법인과 구별하여 취급하는 예가 발견된다. 이에 대법원은 <대상판결 3>에서 별개의 법인격을 가진 여러 개의 기업조직 사이에 단순한 기업 간 협력 관계나 계열회사, 모회사 사이의 일반적인 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적, 사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상의 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는 이들을 하나의 사업 또는 사업장이라고 볼 수 있다는 점을 명확히 하였다. 나아가 **복수의 기업조직이 하나의 사업 또는 사업장에 해당하는지** 여부를 판단하는 구체적인 기준으로, 업무의 종류, 성질, 목적, 수행방식 및 장소의 동일성, 업무지시와 근로자의 채용, 근로조건의 결정, 해고 등 인사 및 노무관리가 동일한 사업주체 내지 경영진에 의하여 통일적으로 행사되는지 여부, 각 단위별 사업활동의 내용이 하나의 사업목적 을 위하여 결합되어 인적·물적 조직과 재무·회계가 서로 밀접하게 관련되어 운영되는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단하여야 한다는 법리를 제시하였다.

- 이를 기초로 대법원은 <대상판결 3>에서 참가인이 근로를 제공한 사업(장)은 원고 회사로 국한되지 않고 A라는 다국적 기업조직을 포함하는 것이라고 포섭 판단한 원심의 결론을 수긍하고 상고기각하였다. 원심은, 참가인이 근로를 제공한 사업(장)에 포함되는 A는 독립적 기업 단위로 인정되지만, 참가인은 회계담당자로서 원고 및 A의 후방지원 업무부서에 소속되어 실질적으로 원고의 국내 영업 및 A의 아시아권 영업을 위해 동일한 내용의 근로를 제공하였고, 참가인이 수행하는 회계업무가 A의 사업목적 및 영업성과 달성을 좌우하는 요소로 작용하였다는 점, A의 설립준거 법령, 본사 소재지, 기업 조직이나 고용관계에 관한 정확한 정보의 부재 등은 위와 같은 판단에 장애가 되지 않는다는 점, 참가인이 해고될 당시 원고와 A의 상시근로자 수를 합산하여 5명 이상으로 인정된다는 점을 판단의 논거로 들었다.

Ⅴ. 판결의 의의와 과제

- 같은 날 선고된 세 건의 대상판결은, 국제근로관계 사건에서 근로기준법 적용 대상인 사업 또는 사업장의 동일성 및 상시 사용하는 근로자 수 산정에 관한 판단 기준을 최초로 판시하였다. 특히, 대상판결 3은 사업장 쪼개기를 통한 탈법행위 시도에 보내는 경고로서의 의미도 크다. 해당 원심이 적절하게 지적인 바와 같이, 이와 같이 해석하지 않으면, 실제 장소적·기능적으로는 동일한 사업(장)에 속하는 근로자들임에도 불구하고, 기업 조직 내지 회사를 중첩적으로 설립·구성하여 근로관계를 파편화·세분화함으로써 **근로기준법 제11조 제1항** 예외조항의 적용을 받아 근로기준법상 중요 규정의 적용 배제 등 근로기준법 적용을 실질적으로 잠탈하는 행동을 유발하게 될 위험이 있다.

- 한편 이와 같은 문제는 근본적으로 근로기준법이 상시 5명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 적용되지 않는다는 것에서 발생하는 측면이 있다. 하지만 상시 5명 미만 소규모 사업체 근로자의 근로조건이 상대적으로 취약하고 노동조합 조직률이 낮으며 취업규칙 관련 규정이 적용되지 않기 때문에 근로기준법에 의한 보호의 필요성이 더 크고, 사업장의 규모가 영세하다고 해서 일률적으로 적용상 예외를 인정하는 경우는 주요 각국의 사례에서도 매우 드물다. 근로기준법의 적용 범위에 관한 입법을 재정비하는 등 노동법적 보호의 공백을 최소화하기 위한 조치가 필요하다.

<유튜브 스태프의 근로자성과 도급근로자로서의 최저임금> 서울중앙지방법원 2024.11.07. 선고 2022가합539881 판결

【판결 요지】

- 원고들은 유튜브 방송 채널의 스태프로서 콘텐츠의 선정, 제작, 방송, 방송 이후의 서비스 등 일련의 과정에 관여하여 노무를 제공하였다. 원고들은 임금을 목적으로 피고로부터 상당한 지휘·감독을 받으며 종속적인 관계에서 피고에게 근로를 제공하여 온 근로기준법상 근로자이다. 또한 원고들이 피고가 지정한 온라인 채팅방(디스코드)에 접속하였던 시간을 원고들의 근로시간으로 인정한다. 나아가 원고들은 도급제로 근로를 제공하였으므로 최저임금법 제5조 제3항 소정 도급근로자에 해당하며, 그 최저임금은 제반사정을 고려하여 법원이 재량으로 결정한다. 그 액수는 원고들이 근로를 제공했던 당시 고용노동부장관에 의해 고시되었던 최저임금액과 같게 산정한다.

I. 사건의 개요

- 피고는 게임 마인크래프트(Minecraft)를 활용한 추리극을 콘텐츠로 하여 유튜브 채널을 운영하는 자이고, 원고들은 해당 유튜브 채널에서 소위 스태프로 업무를 수행하던 자들이다. 원고들은 2020. 4.경~2021. 5.경 사이에 각기 피고에 의해 선발되어 피고의 유튜브 채널 운영을 위해 스태프로 업무를 수행하였다. 원고들은 피고에게 위 추리극의 콘텐츠에 필요한 각종 구성요소를 제작하여 주었고, 유튜브 실시간 방송 중에는 방송을 보조하였으며, 방송 외에도 인터뷰 대필이나 외부인력 섭외 등 콘텐츠 제작 외적인 업무도 수행하였다. 원고들은 2022. 6. 14. 이 사건 소를 제기하면서 주위적으로는 근로기준법상 근로자성이 인정된다는 전제하에 최저임금에서 기지급된 임금을 공제한 차액을 청구하고, 예비적으로는 근로기준법상 근로자성이 부정된다는 전제하에 저작권 침해금지 및 저작권 침해에 따른 손해배상을 청구하였다.

II. 쟁점

1. 제1쟁점:원고들이 피고와의 관계에서 근로기준법상 근로자였는지 여부

- 원고들은 이 과정에서 피고로부터 상당한 지휘·감독을 받고, 취업규칙이 적용되었으며, 제3자와의 업무 대체 가능성이 없었다는 사정 등을 들어 근로기준법상 근로자였음을 주장하였다. 이에 대해 피고는 원고들이 단순히 피고가 도급한 일을 수행한 수급인에 지나지 아니하며, 취업규칙은 없었고, 원고들은 재택근무 형태로 자유롭게 업무를 수행했으며, 기본급이 지급되지 않았고, 원·피고 사이 근로계약서가 작성되지 않았으며 원고들이 근로기준법상 근로자가 아니라고 주장하였다.

2. 제2쟁점:원고들의 근로시간 산정

- 원고들은 피고가 지정한 온라인 채팅방에 접속한 시간을 기준으로 근로시간을 산정하여 주장하였고, 피고는 해당 채팅방에 접속한 시간 중 원고들이 사담을 나누거나 휴식을 취하기도 하였으므로 이를 근로시간이라고 볼 수 없다고 다투었다.

3. 제3쟁점:원고들의 근로 성격과 최저임금 산정

- 원고들은 주위적으로는 원고들이 비도급근로자라는 전제하에 고용노동부장관 고시 최저임금을 받았어야 함을 주장하였고, 예비적으로는 원고들이 최저임금법 제5조 제3항 소정 도급근로자라는 전제하에 법원이 재량으로 최저임금을 결정하여달라는 취지로 주장하였다. 이를 통해 원고들은 최저임금에서 기지급된 임금을 공제한 차액을 청구하였다.

III. 법원의 판단

- 대상판결에서 법원은 우선 유튜브 스태프라는 직업으로 분류된다는 사정만으로 근로자 여부를 일률적으로 판단할 수 없으며, 구체적인 사실관계에 종래 확립된 근로자성 판단 법리(대법원 2006.12.7. 선고 2004다29736 판결, 대법원 2007.3.29. 선고 2005두13018, 13025 판결 등)에 근거해 원고들의 근로자성을 판단해야 함을 설시했다. 이에 대상판결은 원고들이 피고와의 관계에서 종속되어 근로를 제공한 근로기준법상 근로자에 해당한다는 점을 먼저 밝혔다(제1쟁점). 이후 미지급 임금 산정의 기초로서 온라인 채팅방 접속시간을 원고들의 근로시간으로 인정하였다(제2쟁점). 나아가 원고들이 도급제로 근로를 제공하였으므로 도급근로자에 해당한다고 판시한 후, 2020년과 2021년에 고시된 각 최저임금 상당액을 원고들의 최저임금으로 산정하였다(제3쟁점).

IV. 대상판결의 의의

1. 근로기준법상 근로자성에 관한 종전 법리의 계승과 적극적 적용

- 근래 원격 소통 기술이 발달하면서 많은 노동이 디지털화되었고, 코로나19가 유행하면서 많은 근로자들의 근무형태가 재택근무로 전환되기도 하였다. 이에 따라 근무시간이나 근무공간이 엄격하게 지정되지 않는 근로형태가 등장하고 있다. 또한 근로형태가 다변화되고 근로시간이 유연화됨에 따라 기본급이나 고정급 없이 건별이나 성과별로 대가를 지급받는 경우도 늘어나고 있다. 이와 같은 배경에서 대상판결은 종전의 근로기준법상 근로자성 판단 법리를 그대로 계승하여 철저히 적용하면서도 사실관계를 법리에 적극적으로 포섭함으로써 원고들의 근로자성을 인정하였다.

- 대상판결은 원고들이 근로를 제공하였던 과정을 구체적으로 살펴보고 상당한 지휘·감독을 받았다고 판단하였다. 또한 기본급·고정급 여부, 근로계약서 작성 여부는 근로자성 인정에 방해되지 않는다는 종전 법리를 재차 밝히는 한편, 다른 사업장에서의 근로시간과 피고의 업무를 수행했던 근로시간이 겹치지 않았다는 점을 들어 전속성 역시 부정되지 않는다고 보았다. 즉 대상판결은 비록 피고가 원고들에게 근무시간과 장소를 구체적으로 특정하지 않았다고 하더라도 다른 제반 사정을 종합하였을 때 원고들이 피고에게 종속된 근로자임을 인정할 수 있다고 판단한 것이다. 이는 근로자성 인정 기준 중 일부 조건(근무시간과 장소의 구속)이 충족되지 않더라도 나머지 조건들을 종합하여 판단함으로써 근로자성을 인정할 수 있음을 분명하게 밝힘으로써 종래 법리를 충실히 따른 것이라는 점에서 특기할 만하다. 또한 대상판결은 기존 법리를 바꾸지 않고 그대로 계승하더라도 새로운 근로형태에 대해서도 근로자성을 인정할 수 있음을 보여주었다는 점에서도 큰 의미가 있다.

2. 재택근무의 근로시간 산정 방식 제시

- 근무시간과 장소가 엄격하게 구속되어 있지 않은 근로형태의 경우 근로시간을 산정하는 데에 어려움이 생기게 된다. 이에 대상판결은 원고들이 재택근무 형태로 근로를 제공했다는 점을 밝힌 후, 원고들이 업무를 수행하면서 활용했던 채팅방 접속시간이 근로시간으로 인정될 수 있음을 설시하였다. 이에 대해 피고는 원고들이 접속 중 휴식을 취했다는 사정 등을 주장하였으나, 대상판결은 원고들이 잡담을 나누었던 시간 중에도 실질적으로 사용자의 지휘·감독이 있었다고 보고 피고 주장을 받아들이지 않았다.

- 대상판결의 이와 같은 근로시간 산정은 재택근무에 대해서 근로시간을 산정할 수 있는 하나의 방식을 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

3. 도급제 근로자의 최저임금

- 근로자성 인정의 여러 요소를 종합하여 보지 않고 노무제공 대가가 일의 완성을 단위로 지급된 사정에만 집중할 경우 도급계약의 성격이 부각되므로 근로자성을 부인하는 결론으로 나아가기가 쉽다. 그러나 대상판결은 순서상 종래 법리에서 제시하는 여러 사정을 종합해 원고들이 근로기준법상 근로자임을 먼저 확인하였으며, 해당 법리에 의하여 기본급이나 고정급이 지급되지 않았더라도 근로자성을 쉽게 부정할 수 없다는 점을 분명히 밝혔다. 따라서 피고가 도급제로 원고들을 사용했다고 하더라도 그 사정만으로는 원고들의 근로자성이 부인되지 않는다. 원고들은 도급제로 사용된 근로자(도급근로자)가 될 따름이다.

- 도급근로자에 대해서는 고용노동부가 고시하는 최저임금이 곧바로 적용되지 않고 법원이 제반 사정을 종합하여 재량으로 최저임금을 정하게 된다. 대상판결은 유사 직종들(디자이너, IT기획/개발자)의 노임단가, 2020년과 2021년 당시 고시된 최저임금액, 원고들이 피고의 팬으로서 자발적으로 업무에 지원하였

던 사정, 원고들의 업무가 대부분 야간근로 형태로 수행된 사정 등을 고려하여 결과적으로는 원고들이 근로를 제공하던 당시(2020년, 2021년) 고시된 최저임금과 같은 액수를 원고들의 최저임금으로 산정하였다. 즉 대상판결은 도급근로자의 최저임금에 관한 종래의 법리를 따르면서 관련된 제반 사정을 구체적으로 살펴 최저임금을 산정하였으며, 그렇게 산정된 액수는 非도급근로자에게 적용되는 최저임금액보다 낮지 않았다. 대상판결은 도급근로자의 최저임금에 관한 법리를 충실히 적용하였다는 점, 그리고 그 결과 산정된 최저임금이 고시된 최저임금보다 낮지 않다는 점을 분명히 밝혔다는 점에서 의의가 있다.

<레미콘 지입차주의 노동조합법상 근로자 해당 여부> 부산지방법원 동부지원 2025.01.15. 선고 2023고단1327 판결

【판결 요지】

- 레미콘 지입차주 겸 운송기사들은 노동조합 및 노동관계조정법에서 정한 근로자에 해당하고, 피고인들이 파업을 통해 피해회사들 소속 대표들을 압박하여 피해회사들로부터 복지기금을 지급받기로 합의하고 복지기금 명목의 돈을 지급받은 것은 근로자의 적법한 쟁의행위 및 그 결과이며, 피고인들이 주도한 파업은 형법상 정당행위에 해당하므로, 피고인들의 위와 같은 행위에 대하여 공갈죄의 죄책을 물을 수 없다.

I. 사실관계

- 전국민주노동조합총연맹 전국건설노동조합 부산울산경남지역본부 산하 부산건설기계지부 간부들은 2019년 초경부터 부산, 경남 지역의 레미콘 기사들을 조합원으로 가입시키고 2019.5.경 위 부산건설기계지부 산하에 레미콘지회(이하 레미콘지회라 한다)를 설립하였다. 그 후 레미콘지회의 간부인 피고인들은 부산, 경남지역 47개 레미콘 제조회사에 대하여 레미콘지회 간부들의 급여 등으로 사용하기 위해 복지기금을 요구하면서 2019.12.20.경 부산경남레미콘산업발전협의회(이하 발전협의회라 한다) 대표 등에게 협박성 발언을 하였고, 그럼에도 요구안이 받아들여지지 않자 2020.5.14.경부터 2020.5.28.경까지 조합원인 레미콘 기사들이 운송을 전면 거부하게 하고 주차장, 마당 등을 점거한 채 집회를 하면서 타설공, 철근공 등도 연대파업을 하도록 하여 2020.5.28.경 복지기금 지급에 관한 합의를 작성하고 이에 따라 2020.6. 25.경부터 2022.4.25.경까지 레미콘회사들이 합계 3억 4,556만 9,000원을 지급하도록 하였다. 위 복지기금 지급 약정이 종료되자 위와 같은 방법으로 다시 복지기금 지급에 관한 합의를 작성하고 이에 따라 2022.5.25.경부터 2023.1.31.경까지 합계 1억 5,853만 원을 지급받았다.

II. 법원의 판단

- 검사는 위와 같은 행위가 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동공갈)죄 및 업무방해죄에 해당한다고 하여 기소하였으나, 법원은 레미콘 지입차주 겸 운송기사(이하 레미콘 지입차주라 한다)들은 소득을 사실상 전적으로 레미콘 제조회사로부터 받는 수입에 의존하는 점, 운송단가 등의 결정 과정에서 위 회사들의 권한이 상대적으로 큰 점, 레미콘 지입차주들의 업무는 레미콘 제조회사의 영업에 필수적이고 핵심적인 요소이고 레미콘 지입차주들도 레미콘 제조회사를 통하지 않고는 레미콘 운송을 하는 것이 현실적으로 어려운 점, 레미콘 지입차주들은 레미콘 제조회사들에 대한 전속성이 강한 점, 어느 정도의 지휘·감독관계가 존재한 점, 레미콘 지입차주들이 과거 근로계약서를 작성하기도 했던 점, 집단적 합의를 통해 노동3권을 보장할 필요성이 상당한 점을 근거로 레미콘 지입차주를 노동조합 및 노동관계조정법(이하 노동조합법이라 한다)상 근로자에 해당한다고 판단하였다. 또한 복지기금은 근로시간 면제자 또는 노동조합 전임자의 급여에 해당한다고 볼 수 없고, 레미콘지회 간부들의 활동 내용과 복지기금의 금액 등을 고려하면 복지기금은 근로자의 경제적·사회적 지위의 향상을 위하여 필요한 노동조합의 활동 내지 단체교섭의 여건 형성에 필요한 범위 내의 금전으로 볼 수 있어 단체교섭사항에 해당한다고 볼 수 있으며, 쟁의행위의 정당성이 상실되었다고 볼 만한 사정도 없으므로 피고인들의 행위는 정당행위에 해당한다고 판단하였다. 업무방해 부분에 대해서도 법원은 파업이 위력에 해당하지 않거나 쟁의행위로서 형법상 정당행위에 해당한다고 판단하였다. 결국 법원은 공소사실이 범죄로 되지 않는 경우에 해당한다고 하여 형사소송법 제325조 전단에 의해 무죄를 선고하였다.

- 대법원은 과거 레미콘 지입차주는 사용종속관계하에서 노무에 종사하고 그 대가로 임금 등을 받아 생활하는 노동조합법상 근로자에 해당하지 않는다고 판단하였다. 그런데 위 판결은 근로기준법상 근로자 규정과 노동조합법상 근로자 규정에 차이가 있음에도 특별히 구분하여 취급하지 않던 시기에 선고된 판례이다. 그 이후 대법원은 ① 노무제공자의 소득이 특정 사업자에게 주로 의존하고 있는지, ② 노무를 제공하는 특정 사업자가 보수를 비롯하여 노무제공자와 체결하는 계약 내용을 일방적으로 결정하는지, ③ 노무제공자가 특정 사업자의 사업 수행에 필수적인 노무를 제공함으로써 특정 사업자의 사업을 통해서 시장에 접근하는지, ④ 노무제공자와 특정 사업자의 법률관계가 상당한 정도로 지속적·전속적인지, ⑤ 사용자와 노무제공자 사이에 어느 정도 지휘·감독관계가 존재하는지, ⑥ 노무제공자가 특정 사업자로부터 받는 임금·급료 등 수입이 노무제공의 대가인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 하면서, 근로기준법과 달리 헌법상 노동3권 보장을 통해 근로조건의 유지·개선과 근로자의 경제적·사회적 지위 향상이라는 노조법의 목적과 근로자에 대한 정의규정을 고려하면 노조법상 근로자에 해당하는지 여부는 노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 보장할 필요성이 있는지의 관점에서 판단하여야 하고 반드시 근로기준법상 근로자에 한정된다고 할 것은 아니고, 노동3권의 인정 필요성이 큰 경우 전속성과 소득의존성이 강하지 않은 측면이 있다 하더라도 이를 들어 노조법상 근로자임을 부정할 것은 아니라고 판시하는 등 입법목적과의 차이와 노동3권 보장 취지 등을 고려하여 근로기준법상 근로자와 노동조합법상 근로자를 실질적으로 다르게 취급하고 있는 것으로 보인다.

- 위와 같은 판례의 입장에 따르면 근로기준법상 근로자로 볼 수 있을 정도의 종속적 관계가 인정되지 않더라도 노동조합법상 근로자로 인정하는 것이 가능하다. 이러한 레미콘 지입기사를 노동조합법상 노동자로도 인정하지 않은 기존 대법원 판결은 유지되기 어렵다고 보아야 할 것이다. 이러한 점에서 대상판결은 레미콘 지입기사가 노동조합법상 근로자에 해당한다는 점을 분명히 한 것으로 볼 수 있다.

- 최근 경기지방법노동위원회와 중앙노동위원회는 레미콘 지입기사가 노동조합법상 근로자에 해당하지 않으므로 전국레미콘운송노동조합은 노동조합으로서 실질을 갖추지 못하였다고 판단하였다. 그러나 노동조합에 따라 레미콘 지입기사의 성격을 다르게 볼 이유가 없으므로, 대상판결의 취지를 적용하면 전국레미콘운송노동조합 역시 노동조합법상 노동조합으로 인정하는 것이 타당할 것이다.

<운송사업 위수탁계약 체결 후 상품을 슈퍼에 배송하는 지입 화물기사의 노조법상 근로자성> 서울행정법원 2025.05.15. 선고 2023구합78255 판결

【판결 요지】

- 구체적으로 노조법상 근로자에 해당하는지는 노무제공자의 소득이 주로 특정 사업자에게 의존하고 있는지, 노무를 제공받는 특정 사업자가 보수를 비롯하여 노무제공자와 체결하는 계약 내용을 일방적으로 결정하는지, 노무제공자가 특정 사업자의 사업 수행에 필수적인 노무를 제공함으로써 특정 사업자의 사업을 통해서 시장에 접근하는지, 노무제공자와 특정 사업자의 법률관계가 상당한 정도로 지속적·전속적인지, 사용자와 노무제공자 사이에 어느 정도 지휘·감독관계가 존재하는지, 노무제공자가 특정 사업자로부터 받는 임금·급료 등 수입이 노무 제공의 대가인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 한편 노조법의 입법 목적과 근로자에 대한 정의 규정 등을 고려하면, 노조법상 근로자에 해당하는지는 노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 보장할 필요성이 있는지의 관점에서 판단하여야 하고, 반드시 근로기준법상 근로자에 한정되는 것은 아니다(대법원 2019.6.13. 선고 2019두33712 판결 등 참조).

I. 사안의 개요

- ○○글로벌로지스는 개별 운송회사들과 운송도급 기본계약을 체결하여 전국의 ○○슈퍼에 식료품 등 각종 상품을 공급하고 있다. 지입차주들이 개별 운송회사들과 운송사업 위·수탁계약을 체결하고, ○○글로벌로지스가 운영하는 물류센터로부터 상품을 인수하여 전국의 ○○슈퍼 점포로 배송하고 있다.

- 지입차주(지입화물기사)들로 구성되어 있는 ○○글로벌로지스 노조(2021. 9. 30. 설립된 전국단위 노조, 대상판결 사건의 참가인이다)는 위 운송회사들 중 하나인 원고에게 2022년 11월 2일 지입 관리비 정산방식 변경 관련 사항을 의제로 정해 단체교섭을 요구하였다. 그러나 원고는 자신들과 운송사업 위·수탁계약을 체결한 지입차주들이 노조법상 근로자가 아니라고 보아 단체교섭에 응하지 아니하였다. 참가인인 노조는 원고의 교섭거부가 부당노동행위에 해당한다고 주장하며 구제신청을 하였다. 경기지방법노동위원회는 원고가 지입차주 배송기사들로 이루어진 참가인 노조의 교섭요구에 응하지 않은 것은 부당노동행위라며 구제신청을 인용하였다. 이후 원고(개별 운송회사)가 재심을 신청했으나, 중앙노동위원회도 재심 신청을 기각하자 재심판정을 취소하라며 행정소송을 제기하였다. 대상판결은 원고의 청구를 기각하면서 중앙노동위원회 판정을 유지하였다.

II. 대상판결의 의의

- 원고 회사는 이 사건 배송기사들이 원고와 위·수탁계약을 체결하고 위 계약 내용에 따라 노무를 제공하고 있을 뿐 그 소득을 원고에 의존하고 있지 않고, 원고로부터 업무수행에 관한 구체적인 지휘·감독을 받지 않으며, 독립된 사업자로서 다른 운송사와 운송계약을 체결하고 그 업무를 수행하기도 하였으므로, 노조법상의 근로자에 해당하지 않는다고 주장하였다. 아울러 설사 이 사건 배송기사들이 노조법상 근로자라고 하더라도, 그와 경제적, 조직적 종속관계를 이루고 있는 자는 화주사인 소외 회사, 즉 ○○글로벌로지스인바, 원고를 사용자로 볼 수 없다고 주장하였다.

- 그러나 대상판결은 다음과 같이 실시하며 운송사업 위수탁계약 체결 후 상품을 슈퍼에 배송하는 지입 화물기사의 노조법상 근로자성을 인정하였다.

- 먼저 대상판결은 노조법상 근로자의 판단 기준을 실시한다. 노조법상 근로자는 사용자와 사용종속관계에 있으면서 노무에 종사하고 대가로 임금 그 밖의 수입을 받아 생활하는 사람을 말하고, 사용자와 사용종속관계가 있는 한 노무제공계약이 고용, 도급, 위임, 무명계약 등 어느 형태이든 상관없다. 구체적으로 노조법상 근로자에 해당하는지는 노무제공자의 소득이 주로 특정 사업자에게 의존하고 있는지, 노무를 제공받는 특정 사업자가 보수를 비롯하여 노무제공자와 체결하는 계약 내용을 일방적으로 결정하는지, 노무제공자가 특정 사업자의 사업 수행에 필수적인 노무를 제공함으로써 특정 사업자의 사업을 통해서 시장에 접근하는지, 노무제공자와 특정 사업자의 법률관계가 상당한 정도로 지속적·전속적인지, 사용자와 노무제공자 사이에 어느 정도 지휘·감독관계가 존재하는지, 노무제공자가 특정 사업자로부터 받는 임금·급료 등 수입이 노무 제공의 대가인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 다음으로 노조법상 근로자 판단은 노동3권 보장 필요성 관점에서 보아야 함을 실시한다. 노조법의 입법 목적과 근로자에 대한 정의 규정 등을 고려하면, 노조법상 근로자에 해당하는지는 노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 보장할 필요성이 있는지의 관점에서 판단하여야 하고, 반드시 근로기준법상 근로자에 한정되는 것은 아니다(대법원 2019.6.13. 선고 2019두33712 판결 등 참조).

- 다음으로 구체적인 판단을 통해 원고가 노조법상 사용자임을 밝혔다. 즉 ① 이 사건 배송기사들이 이 사건 배송업무와 무관하게 추가적인 노무 제공을 통하여 이 사건 위탁계약에 따라 지급받는 운송비 및 제수당 외에 다른 수입을 거둘 수 있다고 보기는 어려운 등 그 소득은 주로 원고에게 의존하고 있다는 점, ② 과거에는 기본적인 근로조건을 결정함에 있어 배송기사들이 특별한 협상력을 발휘하였다고 보기도 어렵고, 원고가 보수를 비롯한 위탁계약상 후생조건, 근무환경 등의 내용을 일방적으로 결정한 점, ③ 배송기사들은 원고의 사업 수행에 필수적인 노무를 제공하고 원고를 통해 시장에 접근할 수밖에 없다는 점, ④ 배송기사들과 원고의 계약관계는 상당 정도로 지속적·전속적이며, 원고 외 다른 회사와 일부 운송계약을 하고 용역을 수행한다고 하더라도 이는 매우 소액에 불과한 점, ⑤ 배송기사들이 업무 내용과 관련하여 별다른 재량이 없을뿐더러, 원고와 배송기사들 사이에는 소외 회사인 ○○글로벌로지스와 원고 회사와의 운송도급계약상 원고의 책임을 전제로 하여 적어도 일정한 수준의 지휘·감독관계가 형성되어 있었다고 보아야 하는 점, ⑥ 노무수행 대가의 대부분을 차지하는 운송비(용차료)는 기준 운행일수만 채우면 정해진 금액이 지급되는 월 기본 운송비로 고정급 성격을 가지는 등 이들의 수입은 노무 제공의 대가로서의 성격을 가지는 점(일반적 근로관계에서의 노무 제공의 대가로서의 성격과 근본적 차이가 없다), ⑦ 배송기사들은 정형화된 형태로 업무를 수행하고 있음에도 불구하고 개별 배송기사는 원고와 위탁계약을 체결함에 있어 충분한 교섭력을 갖추고 있지 않은 점, 헌법 제33조 제1항이 보장하는 노동3권 보장의 성격과 목적, 노조법상 근로자의 정의 규정이 특정 사업자에 대한 소속을 전제로 하지 아니할 뿐만 아니라 노무제공자까지도 포함할 수 있도록 규정한 점 등을 고려하면, 원고의 사업에 필수적인 노무를 제공함으로써 원고와 경제적·조직적 종속관계를 이루고 있는 이 사건 배송기사들이 집단적으로 단결함으로써 대등한 위치에서 교섭권을 보장받을 수 있도록 할 필요성이 있다는 점 등이 그것이다.

- 한편 대상판결은 원고의 다른 주장, 즉 이 사건 배송기사들이 노조법상 근로자라고 하더라도, 그와 경제적, 조직적 종속관계를 이루고 있는 자는 화주사인 소외 회사, 즉 ○○글로벌로지스로 보아야 한다는 주장에 대해서는 별도의 판단을 하지는 않은 것으로 보인다.

- 대상판결은 노무제공계약의 형식에 불구하고 노조법상 근로자에 해당하는지에 대한 판단기준을 종합적으로 고려하여 근로자성 판단이 이루어져야 한다는 점 및 노조법의 입법 목적과 근로자에 대한 정의 규정 등을 고려할 때 노조법상 근로자에 해당하는지는 노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 보장할 필요성이 있는지의 관점에서 판단하여야 하고, 반드시 근로기준법상 근로자에 한정되는 것은 아니라는 점을 명확히 하였다.

III. 참고 사항

- 지입차주의 경우 노조법상 근로자로 한정되는 것이 아니라 근로기준법상 근로자성도 인정되고 있다. 특히 산재 보험급여 불승인 처분 취소소송 과정에서 근로기준법상 근로자성이 인정, 확대된 경향을 알 수 있다.

- 최근 대법원 2024.1.25. 선고 2020두54869 판결에서는 파쇄 및 운송 업무를 수행한 지입차주가 원도급인과 직접 계약하지 않았고 1차 수급업체(원도급인)와 운송 계약을 체결한 수급인(위탁계약)을 하였음에도 원도급인의 근로자로 보아, 요양급여불승인처분을 취소한 바 있다.

- 세탁물 수거 및 배송 업무를 수행한 지입차주의 근로기준법상 근로자성을 인정한 사례(서울행정법원 2024.8.22. 선고 2024구합52762 판결)도 있다. 동 사안에서 법원은 비록 배송 지입차주가 근로계약을 체결하지 아니하였고, 사업자등록을 하여 운송료에 대한 부가가치세를 납부하는 등 사업주로서의 외관을 갖추기는 하였으나, 이러한 사정들은 실질적인 노무제공 실태와 부합하지 않거나 사용자인 회사가 경제적으로 우월한 지위에서 임의로 정할 수 있는 사항이므로 근로자성을 뒤집는 사정이라고 보기에 부족하다고 보았다. 동 사안도 산재보험급여 신청이 거부당하자 이루어진 취소소송의 사례인데, 동일하게 대법원 2018.10.25. 선고 2015두51460 판결(소위 나라운 화물기사 사건), 대법원 2021.4.29. 선고 2019두39314 판결(삼표 화물기사 사건) 사례도 산재 신청이 거부당하

자 이루어진 취소소송의 사례이다. 이러한 사례들은 결국 운송사업자인 회사가 운송기사의 구체적인 업무 내용을 지정·결정하고, 그 업무 수행 과정에서 상당한 지휘·감독이 이루어졌다고 본 것이다.

<도급인(화물운송회사)과 직접 계약을 하지 않은 운송기사에게 실질 권한 행사시 근로기준법상 관계> **서울고등법원 2024.11.08. 선고 2023누52910 판결**

【판결 요지】

- 비록 타사(원고인 화물운송회사와 화물운송계약을 체결한 화물차주가 실질 대표인 수급인)와 근로계약을 체결한 운송기사(부당해고 구제신청의 당사자)라도 도급인인 화물운송회사가 그에 대한 채용, 근로조건, 지휘·감독, 해고와 같이 근로관계의 핵심적인 사항에 대한 권한을 실질적으로 행사한 경우 도급인인 화물운송회사의 근로자로 볼 수 있다. 어떤 근로자에 대하여 누가 근로기준법 소정의 의무를 부담하는 사용자인가를 판단함에 있어 계약의 형식이나 관련 법규의 내용에 관계없이 실질적인 근로관계를 기준으로 판단하여야 한다.

I. 사안의 개요

- 대상판결은 제1심 판결을 인용하면서 일부 기재 내용을 고친 것에 불과하기에 제1심 판결상 주요 사실관계 등 사안의 개요를 살펴보기로 한다.

- 원고 회사와 주식회사 D는 화물차량 차주 E와 화물운송계약을 체결하고 있었다. 화물차량 차주 E는 원고 회사와 주식회사 D의 대표이사인 P의 아들이었다. 참가인은 일자리를 찾던 중 지인으로부터 원고 회사 소속 차장 G를 소개받고, G의 안내로 원고 회사 사무실에서 원고 회사 직원이 참여한 면접을 보았다. 이후 참가인은 익일인 2019.5.15. 바로 F 주식회사와 화물차량을 운전하는 본 사건 근로계약을 체결하였다. F 법인등기부상 E가 임원은 아니나, E는 F에 이 사건 화물차량을 현물로 출자하고 F로부터 위 차량에 대한 운송사업의 경영을 위탁받으며, F에 운송사업 관리업무 대행의 대가로 매월 위·수탁관리비 22만 원을 지급하기로 하였다. 본 사건 근로계약서에 F 대표자가 E로 기재되어 있었다. 즉 참가인은 원고 회사 및 주식회사 D와 화물운송계약을 체결한 E의 운송업무를 위한 근로계약을 체결한 것으로 비춰질 수 있었다.

- 그러나 참가인의 실질 근로형태를 살펴보면 서류상의 고용주체인 F 주식회사나 E의 역할은 전무하였고, 원고 회사(주식회사 D와 사실상 동일한 경영체)의 지휘감독 아래 근로를 제공한 것으로 평가될 만한 정황이 상당하였다. 먼저 원고 회사에서 입사 서류를 받고 면접을 진행하였으며, 근로계약서도 회사만 다를 뿐 원고 회사 직원이 자필로 작성하였다. 원고 회사는 E에게 지급할 운송료에서 참가인에 대한 급여, 관리비, 보험료, 주유비 등 관련된 비용을 모두 공제한 돈을 E에게 지급하였다. 즉 E는 사용자로서의 역할이 전무하였다. 급여 지급 역시 원고 회사가 E명의 계좌를 사용해 참가인에게 직접 송금하였다. 다음으로 참가인의 근무와 관련하여 배차 등의 구체적 지시 감독은 원고 회사의 직원인 G 등이 행하였다. 안전운행에 관한 지시사항들도 원고 회사가 지시하였다. 참가인은 원고 회사 직원에게 말한 후 휴가를 사용하였다. 운송사고와 관련하여 참가인은 원고 회사에 경위서를 제출하였고, 사고에 대한 손해배상으로 원고 회사에 합의서를 제출하였다(매월 십만 원씩 3년간 급여에서 공제). 마지막으로 본 건 해고 결정과 통보 역시 원고 회사 및 그 직원들에 의해 행해졌다. 원고 회사는 2020.11.6. 참가인에게 전화하여 이 사건 화물차량이 매도되었으니 다음날까지 매도상에 이전하라고 하고 통보를 하였다.

- 한편 참가인은 2020.11. 말경 원고 회사를 피진정으로 하여 퇴직금 미지급 진정을 노동청에 제기하였다. 그러나 노동청은 그 지급 의무가 원고 회사가 아닌 E에게 있는 것으로 판단하여 E를 피의자로 범죄인지해 검찰에 송치하였다.

- 참가인은 2019.5.15. 원고 회사에 입사하여 운전원으로 근무하다가 2020.11.7. 부당하게 해고되었다고 주장하며 2020.11.17. 전남지방노동위원회에 구제신청을 하였다. 전남지방노동위원회는 원고 회사와 참가인 간에 근로관계가 형성되었다고 볼 수 없어 구제신청을 각하하였다. 그러나 중앙노동위원회는 원고 회사가 참가인의 실질적 사용자로 볼 수 있다고 판단하고 해고사유와 시기의 서면 통지가 없어 부당하다고 판정하고 원직 복직의 구제명령을 발하였다. 대상 판결 및 제1심 판결 역시 원고 회사가 참가인의 실질적 사용자로 볼 수 있다고 판단하여 중앙노동위원회의 판정을 유지하였다.

II. 대상판결의 의의

- 원고 회사는 직상수급인(1차 운송회사)으로부터 도급받은 화물량에 대한 운송료 중 6%를 수수료로 취득하고, 나머지는 E 등 지입차주들에게 지급하였으므로 원고 회사는 실질적으로 운송주선업자의 역할을 수행한 것이고, 운송 화물량에 따라 운임을 지급받은 지입차주들은 독립한 운송사업자에 해당한다고 주장하였다. 또 원고 회사는 수급인인 E의 요청에 따라 도급 업무 수행에 필요한 정보를 이행보조자인 참가인에게 제공한 것에 불과하고 지휘·명령을 한 바 없다고 주장하였다. E가 5대 이상의 화물차량을 소유하여 이를 각 다른 회사에 현물로 출자한 후, 5개 이상의 사업자등록증을 가지고 참가인 등 제3자를 근로자로 고용하여 자신의 운송업무를 대행케 하여 E의 계산으로 사업을 영위하였기에 사업주로서 독자성, 독립성이 인정되는 등 원고 회사와 참가인 사이에 묵시적·실질적 근로관계가 형성되어 있지 않다는 것이다.

- 대상판결(및 제1심 판결)은 근로기준법상의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식과는 관계없이 실질에 있어서 근로자가 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다는 점, 누가 사용자인지를 판단함에 있어서도 실질적인 근로관계를 기준으로 여러 요소들을 종합적으로 고려해야 한다는 기존 법원의 원칙적 입장을 명확히 하였다.

- 본 사건에서는 ① 채용과 근로조건, 해고 결정을 원고 회사가 행한 점, ② E 역시 원고 회사의 사내이사 지위에 있었고 원고 회사가 참가인에 대한 운송 및 운송 외 사항에 대해서도 개별적·구체적으로 지휘한 점(이에 따라 참가인은 원고 회사의 사업에 실질적으로 편입된다), ③ 원고 회사는 참가인에게 지급할 급여에서 사고로 인한 원고 회사의 손해액을 공제하기로 직접 합의하는 등 급여 지급 관계에서도 사용자로 볼 수 있는 점, ④ 원고 회사가 참가인에 대한 급여, 4대 보험, 세금 관련 업무 등을 직접 처리한 점, ⑤ 운송 사고와 관련하여도 참가인은 원고 회사에 경위서를 제출하는 등 원고 회사가 사용자임을 전제로 행동한 점, ⑥ F는 이 사건 화물차량의 운송과 관련해서는 그 존재가 형식적·명목적인 것에 지나지 않은 점, ⑦ F 명의로 참가인과 근로계약을 체결하고 소득세 등을 원천징수한 후 E 명의의 계좌에서 참가인에게 임금이 지급된 것, 참가인이 F 소속으로 4대 보험에 가입된 것, 원고 회사의 취업규칙 등이 적용되지 않은 것 등은 원고 회사가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정한 것에 불과할 여지가 크기 때문에 이를 사용자성 인정에 중요한 요소로 보기 어려운 점, ⑧ 참가인은 퇴직금 미지급 진정사건에서 E로부터 합의금을 받고 처벌을 원치 않는다는 의사를 밝혔으나, 실직 상태인 참가인 입장에서 중요한 것은 퇴직금을 지급받는 것이지 이를 누구로부터 지급받았는지는 중요하지 않았던 것으로 보이므로 이러한 사정은 실질 근로관계 판단에 영향을 미치지 않는 점 등을 지적하며 원고 회사의 사용자성을 인정한 것이다.

- 대상판결은 화물운송계약과 관련해서도 운송업무를 수행하는 자의 근로자성을 판단함에 있어 복수의 사업참여자가 관여하는 노무관리의 특성을 고려하여 제반 판단 요소들을 적정하게 적용할 필요가 있다는 점을 명확히 하였다는 의의가 있다고 본다.

- 일부 지방노동위원회나 지방노동청의 경우 여전히 계약의 형식에만 천착하여 근로자성과 사용자성을 판단하는 경우들이 많다. 어떤 근로자에 대하여 누가 근로기준법 소정의 의무를 부담하는 사용자인가를 판단함에 있어 계약의 형식이나 관련 법규의 내용에 관계없이 실질적인 근로관계를 기준으로 판단하여야 한다는 점을 본 대상판결과 같이 명확히 할 필요가 있다. 계약을 맺은 사용자가 형식적으로 급여 지급의 주체나 4대 보험의 주체라는 점만으로 근로기준법상 사용자로 단정해서는 아니 되며, 근로자가 그 사업의 목적에 맞게 실제 조직에 편입되어 있는지, 계약상 사용자가 관련 업무의 주요 내용에 대한 구체적 지휘권을 실제 행사하고 있는지 등을 중심으로 구체적으로 살펴야 할 것이다.

III. 참고할 만한 사례

- 대상판결과 유사한 최근 대법원 판결도 있었다. 최근 대법원(대법원 2024.1.25. 선고 2020두54869 판결)은 파세 및 운송 업무를 수행한 지입차주(이하 파세업무 지입차주)가 원도급인과 직접 계약하지 않았고 1차 수급업체(원도급인과 운송 계약을 체결한 수급인)와 직접 계약(위임계약)을 하였음에도 원도급인의 근로자로 판단한 바 있다. 원고가 지입차주로서 이 사건 차량을 실질적으로 소유하고 있고, 그 유지·관리를 위한 비용도 일부 부담하였다 하더라도, 다음과 같은 이유로 원고는 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 원도급인에 근로를 제공하는 **산업재해보상보험법상** 근로자에 해당한다고 본 것이다. ① 원도급인(회

사 1)은 직영기사와 동일하게 지입차주인 원고에 대한 업무지시를 하고 근태와 업무수행을 감독하는 등 원고에 대하여 상당한 지휘·감독을 하였다고 볼 수 있다. 원고가 수행한 문서파쇄 업무는 회사 1의 사업에서 가장 중요한 업무에 해당하고, 원고가 회사 1의 업무를 수행한 기간은 5년에 이르렀으며, 이 사건 사고가 없었다면 원고는 상당 기간 더 위 업무를 수행하였을 것으로 보인다. ② 문서파쇄 업무에 필수적 설비인 파쇄장비는 회사 1의 소유였고 파쇄장비를 파쇄 현장으로 이동시키는 이 사건 차량만 원고 소유였던 점, 원고는 회사 1이 배정한 업무만을 수행하고 회사 1로부터 매월 고정된 대가를 직접 지급받았으며, 회사 1은 원고가 지출하는 비용 중 큰 비중을 차지하는 주유대금을 스스로 부담하였던 점, 회사 1 소유의 파쇄장비가 설치되고 회사 1의 상호와 광고가 도색되어 있었던 이 사건 차량은 회사 1의 문서파쇄 업무를 위해서만 사용될 수 있었을 뿐만 아니라, 다른 목적으로 사용하는 것이 계약상으로도 금지되었던 점, 원고가 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 할 수 없는 점 등에 비추어, 원고는 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위하였다기보다는 회사 1에 전속하여 노무제공의 대가만을 지급받았다고 볼 수 있다. ③ 원고는 회사 1의 문서파쇄 및 운송 업무를 수행하던 지입차주로부터 이 사건 차량을 직접 구입하였고, 지입회사로서 이 사건 차량의 자동차등록원부상 소유자이던 회사 2는 이 사건 차량의 매매과정에 아무런 역할을 하지 않았으며, 원고는 이 사건 차량을 운행함에 화물자동차 운송사업 허가가 필요하여 회사 2와 이 사건 지입계약을 체결한 것이었다. 이 사건 사고가 있고 난 뒤 회사 1은 이 사건 차량을 원고로부터 매수하기도 하였다. ④ 회사 2는 이 사건 차량의 소유명의자로서 보험료 납부 등 행정적 지원 업무만을 대행하였을 뿐, 회사 1의 문서파쇄 업무를 원고에게 알선하거나 원고의 업무수행을 관리한 바 없는 점, 회사 1은 지입차주들의 요구에 따라 지입료가 낮은 회사로 지입회사를 변경해 주기도 한 점 등에 비추어, 회사 2는 원고와 회사 1 사이의 노무제공 관계의 중간에서 별다른 역할을 하지 않았던 것으로 보인다. ⑤ 원고가 회사 1과 직접 계약을 체결하지는 않았고, 사업자등록을 하는 등 사업주로서의 외관을 갖춘 채 부가가치세를 납부하였으나, 이러한 사정들은 노무제공의 실질에 부합하지 않는 사항이므로 원고의 근로자성을 부정하는 유력한 징표로 보기에는 부족하다.

<균등처우조항에서의 사회적 신분과 비교대상자의 의미와 판단기준> 서울중앙지방법원 2025.02.18. 선고 2023나64678판결

【판결 요지】

1. 사회적 신분이란?

- 사회적 신분이란 사회에서 장기간 점하는 지위로서 일정한 사회적 평가를 수반하는 것인바(헌재 1995.2.23. 선고 93헌바43 결정), 그 지위가 다른 사회적 지위와 뚜렷하게 구별되는 지위로 영구적일 필요는 없으나 상당한 기간 계속되어야 하고, 위 근로기준법 규정에 비추어 근로 내용이나 가치와 무관하게 근로 조건을 차별시키는 사회적 힘을 지녀야 한다.

- 사회적 신분은 후천적 사유에 의한 지위로 반드시 스스로 선택하지 아니하거나 변경할 수 없는 지위일 필요는 없다. (성, 인종 등의 선천적 사유는 스스로 선택할 수 없고 변경할 수 없으나, 후천적 사유는 선택이 가능하고 변경이 가능하다. 국적은 출생과 더불어 결정되는 선천적 사유이나 동시에 국적의 취득과 상실이라는 절차를 통하여 후천적 사유일 수 있고, 이러한 후천적인 국적 취득이 국가의 강요가 아니라 국적 취득신청자가 스스로 선택한 것이고 추후 변경이 가능하다 할지라도 국적이 근로기준법 제6조의 차별적 처우의 사유로 거시되었고, 선택이 가능하고 변경이 가능한 신양도 근로기준법 제6조의 차별적 처우의 사유로 거시되었으며, 최근에는 성조차도 선택이 가능하고 변경할 수 있으나, 이러한 기준들도 위 근로기준법 규정에서 차별적 처우의 사유로 명시되어 있다)

2. 비교대상자 판단기준

- 기간제법 제8조 제1항은 기간제 근로자의 차별적 대우에 대한 비교대상자를 해당 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 규정하고 있는바, 위 동종 또는 유사한 업무라는 판단기준은 근로기준법 제6조의 비교대상에 대한 판단에도 유추적용될 수 있다. 이때 동종 또는 유사한 업무에 해당하는지는 근로자가 실제로 수행하는 업무를 기준으로 판단하되, 업무가 서로 완전히 일치하지 않고 업무의 범위 또는 책임과 권한 등에서 다소 차이가 있더라도 주된 업무의 내용에 본질적인 차이가 없다면, 특별한 사정이 없는 한 동종 또는 유사한 업무에 종사한다고 보아야 한다.

I. 사건 개요

- 이 사건 피고인 A대학교는 관련 법률에 따라 법인으로 전환된 국립대학교이다. 이 사건 원고들 7인은 각각 A대학교 소속 기관인 단과대학 등에서 자체 예산으로 소속 기관의 업무를 위해 채용된 직원(이하 '자체직원')들이다. 이들은 모두 기간제 근로자로 채용되었으나 기간제법에 따라 무기계약직으로 전환되었다. 원고들이 비교대상자로 지정한 근로자들은 A대학교가 법인으로 전환되기 전 공무원이었던 근로자와 법인으로 전환된 후 A대학교 본부에 의해 채용된 직원(이하 '법인직원')들이다.

- A대학교는 법인직원에게는 A대학교 직원보수규정에 따라 정근수당, 정근수당 가산금, 명절휴가비, 정액급식비, 맞춤형 복지포인트(이하 이 사건 각 수당)를 지급하였으나, 원고들 등 자체직원들에게는 이 보수규정을 적용하지 않고, 연봉계약서 내지 근로계약서 등의 내용에 따라 이 사건 각 수당을 지급하지 아니하거나 차등지급하였다. 원고들은 이 사건 각 수당을 더 적게 받거나 지급받지 못한 것이 근로기준법 제6조의 균등처우조항(이하 균등처우조항)에 반하여, 사회적 신분을 이유로 합리적 이유 없이 차별적 처우를 받은 것이라고 주장하며, 이 사건 각 수당의 차액 등을 미지급 임금 혹은 불법행위 손해배상으로 청구하였다. 이 사건의 1심 법원은 원고들의 청구를 기각하였으나, 이 사건의 2심 법원(이하 2심 법원)은 위의 법리에 근거를 두어 원고들의 청구를 인용하였다.

II. 사실관계

- A대학교에서 법인직원과 자체직원은 채용경로에서 차이가 존재한다. 법인직원 중 법인 전환 전 공무원인 근로자들은 필기시험과 면접시험으로 구성된 7급 또는 9급 국가공무원 공개경쟁채용시험에 의하여 채용되었고, 법인 전환 후에는 서류전형, 필기시험(인적성 검사와 논술), 1차·2차 면접(영어인터뷰 포함)을 차례로 거쳐 채용되었다. 자체직원은 소속 단과대학에서 필기시험 없이 서류심사와 면접으로 채용하였다. 법인직원의 경우 필수조건으로 영어성적(토플 697, 토익 840, 토플 99점) 등을 요구하나, 자체직원은 학부학위 외에는 필수조건이 없다. 법인직원과 자체직원은 모두 공개채용절차에 의하여 채용되는데, 자체직원들도 법인 전환 후 채용절차에 지원할 수 있었고, 자체직원 중 법인직원 공개채용절차에 지원하여 채용된 사례들이 있고, 이 사건 원고들 중 일부가 법인직원 공개채용절차에 지원하였으나 불합격하였다.

- 업무와 관련하여 법인직원은 인사 등에 따라 대학 본부 업무나 부속 단과대학 업무를 순환보직으로 두루 담당하나, 자체직원은 처음부터 각 단과대학장이 소속부서 및 담당업무를 특정하여 근로계약서에 명시하여 채용하여, 그 특정업무에 한하여 직무를 수행하는 것이 원칙이다. 법인직원은 1급부터 9급까지의 직급이 부여되어 승진심사를 하여 승진할 수 있으나, 자체직원들은 직급이 올라가는 승진 자체가 없다. 그러나 A대학교는 각 단과대학에서 업무를 수행하는 법인직원과 자체직원들에 대해 명확하게 업무를 구별하지 아니하였고, 자체직원들이 법인직원들이 담당하였던 업무를 인계받아 수행하거나 법인직원들에게 자체직원들이 수행한 업무를 인계하였으며, 자체직원들과 법인직원들이 상호 업무대체자로 지정되었다.

III. 사회적 신분의 의미와 판단기준

- 2심 법원은 위에서 인용한 바대로 사회적 신분의 의미와 판단기준에 대해 기존의 하급심 판례와는 매우 다르게 설시한다. 무기계약직이 사회적 신분에 해당하지 아니한다고 보았던 하급심의 다수는 헌법재판소가 결정한 바와 같이 사회적 신분을 사회에서 장기간 점하는 지위로서 일정한 사회적 평가를 수반하는 것이라고 보면서, 후천적으로 근로자가 상당 기간 동안 차지하고 있고, 개인의 의사로 쉽게 변경할 수 없는 인격적 표지로서 소수자의 차별로 연결되기 쉬운 사회적 지위로 한정하여, 무기계약직이라는 고용형태는 쉽게 변경할 수 없는 고정적인 지위라거나 근로자의 특정한 인격과 관련된 표지라고 할 수 없으므로 사회적 신분에 포함될 수 없다고 보고 있다.

- 이와 비교하면 2심 법원은 사회적 신분을 인격적 표지로 제한하지 않은 것에서 더 나아가 스스로 선택하지 아니하거나 변경할 수 없는 지위일 필요도 없다고 본다. 2심 법원의 이와 같은 법리는 무기계약직이 사회적 신분에 해당한다고 보는 다른 하급심이 제시한 판례법리와 크게 다른 것은 아니다. 그렇지만 2심 법원이 균등처우조항에 명시되어 있는 사유인 국적이나 성도 스스로 선택하거나 변경이 가능한 점을 그 근거로 든 것은 주목할 만하다.

- 이에 더하여 2심 법원은 사회적 신분이 일정한 사회적 평가를 수반하는 점에 주목하여 근로 내용이나 가치와 무관하게 근로조건을 차별시키는 사회적 힘을 지녀야 하는 것으로 본다. 2심 법원은 사업장 내에서 근로조건을 근로 내용이나 가치와 무관하게 부정적인 의미에서 차별화하여, 이미 사회적으로 존재하는 부정적 평가를 강화하게 하는 것일 때 사회적 힘이 있어, 일정한 사회적 평가가 존재하는 사회적 신분으로 본다는 것이다. 이러한 판단법리는 무기계약직이 사회적 신분에 해당한다는 점을 인정하였던 다른 하급심 판례에서 확인할 수 없는 새로운 내용이다.

- 이러한 법리에 근거를 두고, 2심 법원은 자체직원들과 법인직원들이 채용경로의 차이가 있어 법인직원의 공개채용절차에 다른 외부지원자들과 동등한 조건에서 지원하여 합격하지 않는 한 법인직원으로 전환될 수 없는 조건에서 비자발적인 무기계약직으로서 장기간(최소 5년~최대 16년) 근무하였고, 법인직원들은 승진의 기회를 부여받거나 총괄 내지 감독 업무를 담당할 수 있고, 성과상여금을 지급받는 기회를 부여받는 것에 비하여 자체직원들은 승진의 기회가 없으며, 성과상여금을 차등으로 지급받는 것 등을 자체직원들에 대하여 법인직원들보다 열등한 평가를 한 것으로 보았다. 그리하여 2심 법원은 원고들의 자체직원이라는 고용형태상의 지위는 다른 사회적 지위와 뚜렷하게 구별되고, 장기간 점하는 지위로서 고용관계에서 자체직원들 자신의 의사나 능력에 의해서 회피하기 곤란하며 근로조건을 차별시키는 사회적 힘을 지녀 일정한 사회적 평가를 수반하여, 균등처우조항의 사회적 신분에 해당한다고 보았다. 그리고 2심 법원은 자체직원이라는 고용형태상의 지위를 사회적 신분에 해당하지 아니한 것으로 볼 경우, 자체직원들이 근로에서의 차별적 처우로부터 보호받지 못하는 사각지대에 놓이게 되는 점을 고려하여 사회적 약자 보호를 목적으로 하는 근로기준법의 취지상 이렇게 해석하는 것이 타당하다고 덧붙였다.

IV. 비교대상자 판단기준

- 위에서 인용한, 2심 법원이 제시한 비교대상자 판단기준은 상당히 익숙한 것이다. 왜냐하면 이러한 판단기준은 **기간제법**상 기간제 근로자에 대하여 동종 또는 유사한 업무를 수행하는 기간의 정함이 없는 근로자가 비교대상근로자에 해당하는지를 판단하는 기준이기 때문이다. 2심 법원은 **기간제법**상 비교대상자 판단기준에 관한 법리를 근로기준법의 균등처우조항에 유추하여 적용할 수 있다고 보아 위와 같이 실시한 것이다. 한편 대법원은 균등처우조항의 비교대상자 판단기준과 관련하여 헌법재판소의 관련 결정을 참조하여 근로기준법에서 금지하는 차별적 처우에 해당하기 위해서는 우선 그 전제로서 차별을 받았다고 주장하는 사람과 그가 비교대상자로 지목하는 사람이 본질적으로 동일한 비교집단에 속해 있어야 한다라고 실시하였을 뿐, 판단기준을 구체적으로 제시한 바는 없다.

- 2심 법원은 자체직원과 법인직원이 단과대학에서 근무하게 되는 경우 서로 인수인계를 하고, 업무대체자로 지정되는 등으로 법인직원들과 유기적 협업하에 동종 내지 유사한 업무를 수행해왔다고 파악하여 법인직원들이 비교대상자에 해당한다고 판단하였다. 이에 대해 우선 A대학교는 법인직원이 자체직원의 상급자의 지위에서 자체직원의 업무를 감독하였기 때문에 동종 내지는 유사한 업무를 수행할 수 없었다고 주장하였다. 자체직원에게 승진의 기회를 주지 않은 것으로 불합리하고, 모든 법인직원이 상위 직급으로 승진하여 감독 업무를 수행하는 것은 아니라고 보아 2심 법원은 이 주장을 배척하였다.

- 다음으로 A대학교는 자체직원들은 소속 단과대학에서 한정된 업무만을 담당하는데, 법인직원들은 기관 간 순환보직으로 자체직원들이 담당하지 아니하는 다양하고 난이도가 높은 업무를 담당하여 노동가치의 차이가 있어 동종 또는 유사업무에 종사하지 않는다고 주장하였다. 이에 대해 2심 법원은 법인직원이 담당하는 다양한 업무 중에는 A대학교가 주장하는 원고가 아닌 다른 원고들이나 다른 자체직원들이 담당한 업무가 있고, 자체직원들의 소속 단과대학에서는 자체직원이 법인직원과 동등한 업무를 담당하는 것이어서 노동가치가 본질적으로 차이가 있다고 보지 않았다.

- 마지막으로 2심 법원은 A대학교는 채용절차의 차이로 인해 법인직원은 자체직원의 비교대상자가 되지 못한다는 주장을 검토하였다. 이와 관련하여 산업인력공단 사건에서 **대법원**은 균등처우조항의 적용과 관련하여 임용경로의 차이 등으로 인해 무기계약직 근로자들이 정규직 근로자들의 비교대상자가 되지 아니한다고 판시한 바 있다. 이와 달리 2심 법원은 자체직원들이 수행하는 업무를 수행하는 법인직원들은 자체직원과 유기적 협력관계에서 동종 또는 유사한 업무를 수행하였다는 점이 분명하다고 보았다. 더 나아가 2심 법원은 앞에서 본 바와 같이 채용경로의 차이가 사회적 신분을 구분하는 기준이 되는데, 채용경로의 차이를 이유로 비교대상성을 부정한다면, 사회적 신분을 구분하는 기준을 근거로 구분된 사회적 신분이 비교대상이 될 수 없다고 부정하는 것으로, 모든 차별대우의 기준을 이유로 비교대상을 부인하는 것과 마찬가지로 사실상 사회적인 신분에 의한 차별적 처우에 대한 판단을 불가능하게 만든다고 보았다.

V. 합리적인 이유가 존재하는지

- 2심 법원은 합리적인 이유가 있는지를 판단하는 기준으로 강원랜드 사건에서 대법원이 제시한 법리를 그대로 기준으로 제시한다. 이 법리 또한 **기간제법**상 기간제 근로자에 대한 불리한 처우에 합리적인 이유가 없는 경우에 대한 것이다. **대법원**은 균등처우조항과 관련하여 이제까지 합리적인 이유가 있는지에 대한 판단기준을 제시한 바 없다. 다만 국도관리원 사건에서 **대법원의 소수의견과 별개의견**은 2심 법원과 동일하게 차별적 처우의 합리성 여부를 판단할 때 기간제법의 선례법리가 원용될 수 있다고 판단한 바 있다.

- 2심 법원은 이 사건 각 수당의 성격 및 지급목적 등이 상이하여, 이 사건 각 수당을 범주별로 비교하여야 한다고 보았다. 2심 법원은 이 사건 각 수당 즉, 정근수당과 정근수당가산금, 명절휴가비와 정액급식비, 맞춤형 복지포인트가 각 수당의 지급 목적을 감안하면, 자체직원들에게 각 수당을 지급하지 않거나 적게 지급하는 것은 합리적인 이유가 없다고 판단하였다.

VI. 검토

- 앞의 국도관리원 사건에서 대법원의 다수의견이 제시한 법리에 상충되지 않는다. 이 사건에서 대법원 다수의견은 공무원과의 관계에서 무기계약직의 고용 형태가 사회적 신분에 해당하지 않는다고 보면서도, 일반적으로 사회적 신분은 반드시 선천적으로 고정되어 있는 사회적 지위에 국한된거나 그 지위에 변동 가능성이 없을 것까지 요구되는 것은 아니라고 판시하였다. 대법원은 이를 통해 후천적으로 획득되거나 형성된 지위도 사회적 신분에 해당할 수 있는 것으로 보아, 일부 하급직과 달리 선천적으로 고정되어 소수자에 대한 차별로 이어질 수 있는 인적 속성에 한정하지 않고 있다. 또한 다른 일부 하급직 판례에서 요구하는 바와 같이 변동가능성이 없다는 강한 의미에서의 고정성이 필요로 하다고 보지 않는다. 대법원의 이러한 법리는 이례적으로 짧은 한 문장으로 그동안 주목되지는 않았다.

- 위와 같은 점을 고려하면, 이 사건 2심 법원은 국도관리원 사건에서의 대법원 다수의견이 제시한 법리에 배치되지 않으면서도 이를 새로운 내용으로 구체화하고 있다고 볼 수 있다. 특히 2심 법원이 새롭게 제시한 것은 사회적 신분의 개념요소가 되는 일정한 사회적 평가에 대한 것이다. 2심 법원은 근로관계에서 이것의 의미를 구체화하여, 문제되는 고용형태가 근로조건을 차별시키는 사회적 힘이라고 규정하였다. 즉 2심 법원은 문제가 되는 고용형태가 사업장 내에서 근로자집단 사이에 근로조건과 관련하여 차별적 구획을 설정하는 성격이 있는지를 검토하여 사회적 신분에 해당하는지를 판단하여야 한다고 보는 것이다. 이 사건에서는 무기계약직인 자체직원과 정규직인 법인직원 사이에 소속 단과대학에서는 상호 대체가능한 업무를 수행하면서도, 채용경로를 달리 설정하여 자체직원은 순환보직과 승진이 불가능하고, 여러 수당 등에서 근로조건을 달리하여 차별받도록 하고 있어, 자체직원과 법인직원의 구별이 앞에서 설명한 사회적 힘을 갖추고 있어 일정한 사회적 평가가 이루어지는 지위로서 사회적 신분에 해당한다고 보는 것이다.

- 2심 법원이 비교대상자 판단기준으로 제시한 것은 **기간제법**상 판단기준을 유추적용한 것으로 국도관리원 사건에서 대법원 소수의견과 별개의견도 이러한 기준을 제시하였다. 한편 대법원은 산업인력관리공단 사건에서 당시에 이미 기간제법상 판단기준이 확립되어 있음에도 불구하고, 유추적용하지 않았다. 향후 대법원에서 어떠한 판단을 할지 주목할 필요가 있다.

- 비교대상자 판단기준과 관련하여 2심 법원이 새로운 것은 우선 판단순서이다. 균등처우조항과 관련하여 산업인력관리공단 사건에서는 대법원은 비교대상자가 존재하는지 여부를 가장 먼저 판단하였고, 국도관리원 사건에서 대법원 다수의견은 비교대상자인지 여부와 사회적 신분인지 여부를 동시에 판단하였다. 2심 법원은 이와 달리 사회적 신분에 해당하는지를 먼저 판단하고, 그다음 순서로 법인직원이 자체직원의 비교대상자에 해당하는지를 판단하였다. 2심 법원은 이러한 판단순서를 취하여, 자체직원을 법인직원과 구별되는 사회적 신분으로 인정하게 하는 데 핵심적인 기준이 되는 채용경로의 차이가 비교대상성을 부정하는 근거로 될 수 없다고 본 것이다. 특정의 사유를 이유로 한 차별인지가 문제되는 경우, 비교대상자가 되는지의 판단에서 그 특정의 사유와 밀접하게 관련된 것을 배제하는 것이 당연하다. 2심 법원이 이렇게 판단할 수 있었던 것은 판단순서를 달리하였기 때문이다. 이 사건 1심 법원은 비교대상자가 되는지 여부를 먼저 판단하여 부정함으로써 사회적 신분에 해당하는지에 대해 아예 판단할 수가 없었다. 이런 점에서도 일반적인 다른 차별 사건과 동일하게 특정사유에 해당하는지를 먼저 판단하고, 그다음 순서로 비교대상자인지 여부를 판단하는 것이 합당하다.

- 2심 법원은 순환보직에 의하여 법인직원의 수행업무 범위가 더 넓은데도 불구하고, 법인직원이 자체직원의 비교대상자가 된다고 한 것은 앞에서 언급한 근거에 비추어 보면 지극히 타당하다. 설명 업무에서의 차이가 고려되어야 한다고 하더라도, 이것이 비교대상자 선정단계에서 이루어질 필요는 없을 것이다. 2심 법원이 법리로 실시한 **기간제법**의 법리는 본질적인 부분에서 유사한 경우 부수적인 차이는 비교대상자 판단에서 고려되어서는 안 된다고 보기 때문이다. 이러한 부수적인 차이는 실제 합리적인 이유가 있는지를 판단하는 단계에서 달리 처우할 필요성이 인정되는지와 인정된다면 그 방법·정도가 적정한지의 판단에서 고려되면 충분한 것이다. 그렇지만, 이전까지 이와 유사한 사례에 대하여 명시적으로 판단한 바가 없어 대법원에서 이 문제가 다시 검토될 때 쟁점으로 부각될 가능성이 있다. 2심 법원의 판단이 새로운 법리로서 명확하게 확인되기를 기대해본다.

- 마지막으로 합리적인 이유가 있는지에 관한 판단에서 2심 법원이 범주화를 통해 범주별로 비교하였다고 보는 것이 타당한 것인지에 대해서는 의문이 있다. 대법원은 강원랜드 사건에서 양 근로자집단의 임금이 서로 다른 항목으로 구성되어 있거나, 특정항목은 비교 근로자보다 불리한 대우를 받은 대신 다른 특정 항목은 유리한 대우를 받은 경우에 범주별로 구분하여야 한다고 하는데, 이 사건의 사실관계로 보아 범주별로 구별하는 것이 적합하지 않은 것으로 보인다. 자체직원과 법인직원의 임금항목을 비교할 때, 양자가 동일하게 기본급이나 본봉으로 지급한다면, 이 사건 각 수당이 자체직원에게는 지급되지 않거나 차등지급 되는 점으로 보면, 오히려 양 집단이 임금항목별로 비교하는 것이 더 타당하다고 보인다. 무엇보다 2심 법원은 여러 항목을 하나로 묶는 범주화 방식을 취한다고 하면서도 이 사건 각 수당을 각각의 범주로 보아, 이 사건 각 수당을 각각 비교하여 사실상 항목별로 합리적인 이유가 있는지를 살펴보고 있다. 결국 각 수당을 항목별로 판단하여 지급하지 않거나 차등지급한 것이 합리적인 이유가 없다고 보는 점은 2심 법원이 타당하지만, 이를 적용하는 법리 자체는 여기에 맞지 않다고 생각된다.

- 이상과 같이 2심 법원은 균등처우조항의 적용과 관련하여 여러 가지 새로운 시각을 제시하고 있다. 2심 법원이 제시한 법리와 그에 근거한 판단은 조금 더 다듬어져서 더 명확해지고, 세밀해질 필요가 있다. 그렇지만 균등처우조항의 여러 쟁점들에 대해 대법원이나 다른 하급심과는 다른 결론을 내렸을 뿐만 아니라, 그 결론을 균등처우조항의 취지를 충분히 고려하여 치밀하게 해석론으로 도출하였다는 점에서 2심 법원의 법리와 판단은 상당히 주목할 필요가 있다. 상고심에서 2심 법원의 새로운 해석이 더욱 발전되기를 기대해본다.

<기간제 근로계약으로 포장된 시용 근로계약> **광주고등법원 2025.06.12. 선고 2024나23049 판결**

【판결 요지】

- 근로계약에 기간이 정해진 경우 그 계약이 시용근로계약인지 혹은 기간제 근로계약인지는 채용공고, 근로계약서, 취업규칙 및 사용자의 채용 관행 등을 토대로 사용자와 근로자가 해당 기간을 정한 목적과 경위, 해당 기간에 근로자가 수행하는 업무의 내용과 그에 대한 평가 여부, 해당 기간이 종료된 이후 근로자의 지위에 대해 정한 내용 등을 관찰하여, 사용자와 근로자가 기간을 정하여 근로계약을 체결한 진정한 의사가 무엇인지 해석해야 할 것이다.
- 이 사건 근로계약은 피고가 시용 기간 동안 원고의 업무 수행을 평가하여 정식 채용 여부를 결정하는 해약권유보부 근로계약으로서 시용근로계약에 해당한다.

I.쟁점 및 사건 개요

- **대법원 판례**에 따르면, 시용(試用) 근로자에 대한 본채용 거절은 해고에 해당하므로 **근로기준법(이하 '근기법') 제27조**의 해고서면통지 규정이 적용되는 반면, 기간제 근로자에 대한 갱신 거절은 해고와 개념이 다르므로 해고서면통지 규정이 적용되지 않는다.
- **근로계약서에 어떤 기간을 정한 경우, 그것이 시용 기간인지 아니면 기간제 계약 기간인지는 근기법 제27조의 해고서면통지 규정의 적용 여부와 관련하여 중요 쟁점이다.** 대상판결의 쟁점도 이것이다.
- 피고는 P제철소의 하청업체로서 철강제품 제조, 판매 및 가공업 등을 영위하는 회사이다. 피고가 크레인 운전원 채용을 위해 게시한 채용공고에 기재된 고용형태는 기간 정함이 있는 근로계약(6개월, 계약 기간 만료 후 상용직 전환 검토)이다. 원고(크레인 운전원)와 피고가 2021. 7.5. 작성한 근로계약서에 기재된 계약 기간 등은 다음과 같다.
- 계약 기간 및 신분 전환
- 2021. 7. 5. ~ 2022. 1. 4. (6개월)
- 계약 기간 동안의 업무 수행 등에 대한 근무실적을 종합 평가하여 적격자에 대하여 정규직으로 신분 전환시킬 수 있다.
- 피고가 6개월 근무실적을 평가하여 부적격자에 대하여 계약 해지를 통보한 경우 피고와 원고의 계약 기간은 종료한다.
- 이외 정규직으로의 신분 전환 시기는 피고가 정하는 바에 따른다.
- 원고와 같이 입사한 직원들(이하 '인턴')은 2개월마다 멘토, 주임, 팀장 등에 의해 근무성적 등을 평가받았다. 원고는 2021.10. 두 건의 사고(크레인 조작 중 작업장 내의 중추 터치바 및 적치대 안전펜스를 파손하는 사고)를 발생시켰다.
- 원고는 2021.11. 피고의 인사부서에 H로부터 직장 내 괴롭힘 및 성희롱을 당하였다고 신고하였다. 피고는 H의 직장 내 괴롭힘을 인정하고, H를 징계(감봉 1개월)하였다.
- 원고는 2021.12.말경 계약 기간의 총평가 결과 평균 76.7점으로 부적격 평가를 받았다. 한편 원고 외 인턴 8명 중 7명은 평균 80점 이상으로 적격 평가를 받았고, 나머지 1명은 평균 78점으로 부적격 평가를 받았다.
- 피고는 2021.1.4. 사내 게시판에 적격 평가를 받은 7명은 정규직으로 전환되고, 78점으로 부적격 평가를 받은 1명은 인턴 계약 기간을 1개월 연장하며, 원고는 근로계약이 만료되었음을 공지(이하 '이 사건 근로계약 만료 공지'라고 한다)하였다. 피고는 이 무렵 원고에게 근로계약이 만료된 구체적·실질적 사유를 서면으로 통보하지 않았다.
- 원고는 피고를 상대로 해고무효확인의 소를 제기하였는데, 주위적으로 시용 근로자에 대한 본채용 거절은 무효임을, 예비적으로 합리적 없는 기간제 계약 갱신 거절은 무효임을 청구하였다.

II. 대상판결의 내용

- 대상판결은 근로계약에 기간이 정해진 경우 그 계약이 시용근로계약인지 혹은 기간제 근로계약인지는 채용공고, 근로계약서, 취업규칙 및 사용자의 채용 관행 등을 토대로 사용자와 근로자가 해당 기간을 정한 목적과 경위, 해당 기간에 근로자가 수행하는 업무의 내용과 그에 대한 평가 여부, 해당 기간이 종료된 이후 근로자의 지위에 대해 정한 내용 등을 관찰하여, 사용자와 근로자가 기간을 정하여 근로계약을 체결한 진정한 의사가 무엇인지 해석해야 할 것이다.라고 하여, 먼저 시용계약과 기간제계약의 구분 기준을 제시하였다.
- 그리고 대상판결은 이 사건 근로계약 체결 당시 피고는 원고가 이 사건 근로계약에서 정한 6개월의 근무 기간 동안 일정 수준 이상의 평가를 받을 경우 원고를 정규직으로 채용할 의사를 가지고 있었고, 이러한 의사가 대외적으로 표시되었으며, 원고도 6개월의 기간 만료 후 정규직 근로자로 채용되려는 의사로 이 사건 근로계약을 체결한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 근로계약은 피고가 시용 기간 동안 원고의 업무 수행을 평가하여 정식 채용 여부를 결정하는 해약권유보부 근로계약으로서 시용근로계약에 해당한다.라고 판단하였다.
- 따라서 대상판결은 이 사건 근로계약 만료 공지는 해고에 해당하고, 피고가 사내 게시판에 계약만료를 공지한 것은 **근기법 제27조**의 해고서면통지 의무 위반으로 해당 해고는 무효라고 하여(본채용 거절의 실체적 사유는 더 나아가 판단하지 않았다), 원고의 주위적 청구를 인용하였다.

III. 시사점

- 시용 근로자에 대한 본채용 거절이나 기간제 근로자에 대한 갱신 거절의 실체적 사유는 모두 합리적 이유로서 동일하다(합리적 이유는 **근기법 제23조 제1항**의 해고의 정당한 이유보다는 완화된 개념이다). 실체적 사유의 동일성에도 불구하고, 사용자들은 좀 더 편한 길인 기간제 근로계약을 주장하는 경우가 많다. 1단계에서 갱신 기대권이라는 방어벽이 있기 때문이다. 기간제 근로자는 갱신 기대권부터 인정받아야, 2단계에서 합리적 이유 여부를 다룰 수 있다.
- 이런 이유로 사용자들이 기간제 계약을 선호하는 것은 인지상정이다. 그러나 대상판결 사안처럼 시용계약으로 인정되면 실체적 사유를 다루지도 못하고 절차상 하자(해고서면통지 의무 위반)로 곧바로 패소하게 된다(참고로 대상판결의 1심에서는 갱신 거절의 합리적 이유가 인정되어 근로자가 패소하였다.).
- 원고와 피고의 근로계약서의 문구만 보면 기간제 근로계약으로 볼 여지가 크다. 그러나 대상판결은 채용공고, 취업규칙, 업무 내용과 수행 방식, 평가 여부, 채용 관행 등까지도 종합적으로 고려하여, 당사자들의 진정한 의사는 시용계약이라고 판단하였다.
- 채용공고를 비롯한 채용 관행은 모두 실태(실질)이다. 피고 회사에서는 오랫동안 6개월의 평가 기간을 거쳐 정규직으로 채용되어 왔다. 이러한 점을 인식하고 근로자들도 입사 지원을 해 왔다. 이러한 실태를 계약서의 문구 하나로 바꿀 수는 없다.
- 기간제 근로계약이라는 편한 길을 가기 위해, 계약서 문구 하나로 실태에 반하는 기간제 계약으로 포장하는 것은, 실체적 사유를 다루지 못한 채 패소할 위험이 있다는 점이 대상판결을 통해서 확인되었다.
- 실태가 시용계약이라면, 사용자들은 위험하게 기간제계약으로 포장하려 하지 말고, 완화된 고용종료 제도인 시용계약을 제대로 활용할 필요가 있다.

<채용과정에서의 견습과 법적 판단> 서울행정법원 2025.11.06. 선고 2024구합85373 판결

【판결 요지】

- (추가적으로) 참가인의 채용공고에는 전형절차에 관하여 서류접수 > 1차 면접(운행실기) > 2차 면접(면접 실시) > 최종 합격 > 견습 후 정식 채용이라고 명시되어 있다. [중략] 원고 주장을 이른바 채용내정 약정이 성립되었다는 것으로 본다고 하더라도, 최종 합격이 있었다는 원고 주장의 2023.12.29. 면접 결과는 본 채용 전에 채용할 자를 미리 정하는 채용내정에 해당하고, 견습 결과에 따른 해약권을 유보한 것이라 할 것이며, 2024.1.4. 견습 결과 부적합 통보는 채용내정을 취소한 것이라 할 것이다.

I. 사실관계

- 대상판결은 채용내정을 둘러싼 법적 분쟁에 관한 것이다. 사실 관계는 비교적 단순한데, 채용내정을 주장하는 근로자가 2023.12.29. 입사 지원을 한 후, 2024.1.2. 및 1.3. 이틀간 해당 노선 차량에 동승하여 노선을 파악하는 견습을 하였고, 2024.1.4. 실습각서를 체결한 이후 처음으로 노선 운행을 해 봤지만, 노선 숙지 및 운행에 문제가 있어서 회사 측에서 소형 차량으로 당분간 노선 숙지할 것을 권유 받았지만 해당 근로자가 이를 거부하였고, 이러한 사항이 채용평가표에 모두 기재되어 면담 후 채용이 거부되자 해당 근로자가 채용내정의 신분을 주장하면서 부당해고 구제신청을 하였다.

II. 대상판결의 내용

- 경기지방노동위원회(경기2024부해765)는 근로계약이 성립하려면 임금, 근로시간 등 근로조건에 대해 구체적으로 정하고, 이를 확정하는 당사자 간 의사합치가 있어야 하나 ① 사용자가 근로자에 대한 채용 의사를 명확히 통보한 사실을 확인할 수 없는 점, ② 당사자 간 근로조건에 대한 합의가 있었다고 볼 만한 객관적 증거나 정황이 확인되지 않는 점, ③ 사용자는 이 사건 견습 중에 근로자의 운전미숙 등 사유로 대형 대신 소형 차량으로 변경하여 견습할 것을 권고하였으나 근로자가 이를 거부하여 더 이상 채용 절차가 진행되지 않은 점 등을 종합하여 보면, 당사자 간 근로계약이 성립되어 채용이 내정되었다고 보기 어렵다고 판단하였다. 중앙노동위원회(중앙2024부해922) 역시 이러한 초심 결정에 더하여 이 사건에서의 근로자의 견습 과정이 실질적인 근로를 제공한 것이라고 보기 어렵다고 판단하여 초심을 유지하였다.

- 대상판결 역시 이러한 노동위원회의 결론과 의견을 같이 하면서 채용공고에 담당업무, 월 급여, 자격 등이 명시되어 있지만 근로계약의 본질적 사항에 관한 구체적 합의가 성립되었다고 보기 어렵고, 견습일을 근무일로 간주한다거나 대가를 받기로 약정한 바 없고, 채용공고에는 견습 후 정식 채용이라고 명시되어 있는바, 정식 채용 이전에 대형버스 운행능력 부족으로 채용절차를 중단한 것이라고 판단하였다.

- 그러나 대상판결에서는 부차적으로, ... 참가인의 채용공고에는 전형절차에 관하여 서류접수 1차 면접(운행실기) > 2차 면접(면접 실시) > 최종 합격 > 견습 후 정식 채용이라고 명시되어 있다. ... 원고 주장을 이른바 채용내정 약정이 성립되었다는 것으로 본다고 하더라도, 최종합격이 있었다는 원고 주장의 2023.12.29. 면접 결과는 본 채용 전에 채용할 자를 미리 정하는 채용내정에 해당하고, 견습 결과에 따른 해약권을 유보한 것이라 할 것이며, 2024.1.4. 견습 결과 부적합 통보는 채용내정을 취소한 것이라 할 것이다 ...라고 판단하여, 설사 채용내정이라 하더라도 회사의 채용공고에 따라 채용내정을 취소했다고 볼 수 있다는 법리를 제시하였다. 채용내정이 법정(法定) 용어는 아니지만, 기존의 대법원 판례에 따르면 채용내정은 해약권을 유보한 근로계약관계가 성립한 것이므로, 채용내정을 취소하기 위해서는 부당해고의 정당성까지는 아니지만 해약권 실행의 사유에 대한 판단이 필요하다. 즉 애초에 근로계약이 성립하지 않은 것과 조건부 근로계약이 성립하였지만, 이를 해지하는 문제는 본질적으로 차이가 있으므로, 대상판결의 이러한 추가적인 법리가 이 사건에 적용 가능한 것인지 의문이다.

- 이러한 문제가 발생하는 가장 근본적인 원인은 이 사건 회사의 채용 절차에 있다. 구체적 타당성이란 차원에서는 버스 운행의 공공성 등을 고려하여, 이 사건 수습을 채용 과정의 평가로 포섭한 노동위원회 및 법원의 해석론에 공감한다. 그러나 규범적으로는 실습각서까지 쓰면서 최종 합격 > 견습 후 정식 채용이라고 표현한 이 사건 회사의 채용공고에 대한 책임을 부담하는 것이 맞지 않나 하는 의문이 드는 것도 사실이다. 더 나아가 대상판결처럼 채용내정 취소에 관한 법리를 적용하기 위해서는 그 정당성에 관한 별도의 판단을 해야 할 것인데, 이러한 판단 없이 그냥 기존의 법리만 언급한 대상판결의 마무리에 관해서는 비판적인 입장을 갖지 않을 수 없다. 통상적인 범주를 벗어난 용어 사용이, 사실관계에서는 물론 법리적으로도 혼란을 준 사건이다.

<채용비리를 이유로 한 근로계약의 취소> 대법원 2025.07.03. 선고 2025다210741 판결

【판결 요지】

- 이 사건 각 근로계약의 내용에 공정한 채용절차를 거쳐 최종합격자로 선발된 사람들에 한정하여 근로계약을 체결한다는 것이 법률행위의 내용으로 당연히 포함되어 있고, 채용과정에서 부정행위가 있었으며, 원고는 피고들에 대한 그들 피고들이 객관적으로 공정한 채용절차를 거쳐 최종합격자로 선발되었다는 착오에 빠진 상태에서 이 사건 각 근로계약을 체결하였고, 원고의 위와 같은 착오가 법률행위 내용의 중요부분의 착오에 해당하며, 원고의 착오가 원고의 중대한 과실로 인한 것이라고 보기 어렵다.

I. 사실관계

- 원고는 국토교통부의 채용비리 특별점검에 따라 부정채용 대상자 23명에 대한 직권면직 처분을 하였고, 이에 대하여 근로자 9명이 노동위원회에 부당해고 구제신청을 하였다. 중앙노동위원회는 5명의 근로자에 대하여는 직권면직이 부당해고에 해당한다는 판정을, 4명의 근로자에 대하여는 직권면직이 정당하다는 판정을 하였고, 이에 대하여 행정소송이 진행되었는데, 각 행정소송은 최종적으로 직권면직이 징계하고 절차를 거치지 않았다는 이유로 절차상 하자가 존재한다는 취지의 판결이 선고되어 확정되었다. 한편 채용비리와 관련한 형사사건에서 피고 2, 3, 5와 관련하여서는 업무방해죄가 인정되었으나, 피고 1, 4, 6, 7, 8, 9와 관련하여서는 업무방해죄가 인정되지 않았다.

- 그 후 원고는 근로자들에게 부정행위가 존재하지 않는다는 착오에 빠져 근로계약을 체결하였으므로 근로계약을 취소한다는 통지를 한 후, 근로자지위부존 재확인을 구하는 소를 제기하였다. 이에 대하여 피고들은 원고의 착오가 있다 하더라도 동기의 착오에 불과하고, 부정행위가 채용절차에 영향을 미치지 못하였으므로 채용절차의 공정성이 훼손되었다고 볼 수 없어 어떠한 착오가 존재한다고 볼 수도 없으며, 부정행위가 있었다 하더라도 그러한 부정행위와 채용 사이에 인과관계가 없고 채용으로 인해 원고에 경제적 불이익이 발생한 것도 아니므로 채용절차의 공정성에 관한 착오는 중요부분의 착오에 해당하지 않고, 근로계약의 중요부분에 관한 착오가 있었다 하더라도 이는 원고의 중대한 과실로 인한 것이므로 취소를 행사할 수 없다고 주장하였다. 또한 일부 피고들은 근로계약을 취소하기 위해서는 근로기준법 제23조의 정당한 이유가 있어야 한다는 주장도 하였다.

II. 대서판결의 내용

- 이에 대하여 제1심은 피고 1, 4, 6, 7, 8, 9에 대하여는 원고의 근로계약 체결에 있어 중요부분의 착오가 있었다고 보기 어렵다고 하여 원고의 청구를 기각하였고, 피고 2, 3, 5에 대하여는 부정행위로 인해 채용 심사가 왜곡되었으므로 원고의 착오는 중요부분의 착오에 해당한다고 판단하였다. 다만 피고 5의 경우 인사노무팀장이 피고 5의 이모에 대한 이성적 호감으로 특별한 청탁이 없음에도 서류전형 순위를 조작하였을 가능성이 있으므로 피고 5에게 귀책사유가 있다고 볼 수 없고, 원고가 인사담당자에 대한 주의의무를 현저히 게을리한 중대한 과실이 있다고 하여, 피고 2, 3에 대한 원고의 청구만을 인용하였다.

- 그러나 대서판결의 원심은 피고 7을 제외한 나머지 피고들에 대한 제1심 판결을 취소하고 원고의 청구를 인용하였다. 피고 1, 4, 6, 8, 9에 대하여도 근로계약의 중요부분에 착오가 있었던 것으로 판단하였고, 피고 5의 경우 인사노무팀장의 점수 조작은 피고 5의 이모가 채용 사실을 밝혔기 때문에 촉발, 유발된 것으로 볼 수 있으므로 원고에게 중대한 과실이 있다고 볼 수 없다고 판단하였다. 다만 피고 7에 대하여는 부친이 영업본부장에게 전화로 잘 챙겨달라고 한 것에 불과하고 피고 7에 대한 합격 지시나 점수 또는 순위 조작 사실도 인정되지 않아 부정행위의 내용과 정도가 심각하다고 볼 수 없다는 이유로 중요부분의 착오를 인정하지 않았다. 대서판결은 원심의 판단이 정당하다고 보아 상고를 모두 기각하였다.

- 채용비리를 이유로 근로계약을 취소하는 경우, 채용절차의 공정성이 법률행위의 동기에 불과한지 여부가 문제된다. 채용과정에서 부정행위가 있었다 하더라도 채용절차의 공정성이 근로계약 체결의 동기에 불과하다면, 그러한 동기가 표시되거나 상대방에 의해 착오가 유발된 경우가 아니라면 민법 제109조 제1항이 적용될 수 없기 때문이다. 이에 대하여 대서판결의 제1심과 원심은 공개채용은 절차의 공정성을 담당한 전제로 할 뿐 아니라 실질적 측면의 공정성도 전제로 하므로, 그 결과 체결된 근로계약 역시 채용절차의 공정성이 법률행위의 내용이 되었다고 하였다. 또한, 착오를 이유로 취소를 행사하기 위해서는 법률행위의 중요부분에 착오가 있어야 한다. 이와 관련하여 근로자들은 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 이유가 인정되어야 중요부분의 착오로 취소할 수 있다는 주장을 하였는데, 대서판결의 제1심과 원심은 해고는 유효하게 성립한 근로계약을 전제로 근로자의 귀책사유를 이유로 근로계약을 장래에 향하여 해지하는 것임에 반하여, 근로계약의 취소는 의사표시의 하자를 이유로 근로계약 체결에 따른 법률효과 발생의 소멸을 주장하는 것이므로 근로계약의 취소 주장에 근로기준법 제23조가 적용된다고 볼 수 없다고 하였다.

- 각 피고들에 대한 근로계약 취소의 효력과 관련하여, 대서판결의 제1심과 원심은 중요부분의 착오에 해당하는지 여부에 대한 판단을 다르게 하였다. 제1심은 채용절차의 공정을 해할 우려가 있는 행위가 있었으나 점수 조작 사실 등이 확인되지 않는 경우, 채용절차의 공정성에 관한 착오가 없었다면 피고들을 채용하지 않았을 것이라고 단정할 수 없다는 이유로 원고의 착오가 중요부분의 착오에 해당한다고 보기 어렵다고 하면서, 실제 점수 조작 등 부정행위가 채용결과에 영향을 미쳤다는 사실이 명확하지 않은 경우에는 취소의 효력을 부정하였다. 그러나 원심은 채용절차에서의 부정행위는 채용절차의 공정성을 해하거나 해할 우려가 있는 일체의 부정행위를 통틀어 지칭하는 것으로 합격 여부에 직접적인 영향을 미쳤는지 여부를 불문하고, 중요부분의 착오에 해당하는지 여부는 부정행위와 채용 사이에 인과관계가 존재하는지 여부에 따라 판단하여야 하는 것이 아니라 부정행위로 채용의 공정성이 훼손되었다는 사실을 알았더라면 근로계약을 체결하지 않았을 것인지 여부에 따라 판단하여야 한다고 하였다. 그러면서 부정행위의 내용과 정도 등을 고려하여, 근로자 채용에 공식적인 권한은 없다 하더라도 사실상 영향력을 행사할 수 있는 노조위원장에게 금품을 제공한 행위를 하였다면 이 역시 그 자체로 채용의 공정성을 해하거나 해할 우려가 있는 부정행위에 해당한다고 보았다. 제1심은 채용과정에서 부정행위가 있었다고 하더라도 그로 인하여 심사결과가 왜곡되어 채용 결과에 영향을 미쳤다고 인정되어야 근로계약을 취소할 수 있다고 보았다면, 원심은 부정행위로 채용절차의 공정성이 훼손되었다고 볼 수 있다면 점수 조작 또는 순위 조작 등 채용심사가 왜곡된 사실이 인정되지 않더라도 근로계약을 취소할 수 있다고 본 것으로, 원심의 판단은 채용결과와 공정성과 함께 채용절차의 공정성을 강조한 것으로 이해할 수 있을 것이다.

- 강원랜드 채용비리 사건에서 법원은 근로자와 밀접한 관계에 있는 사람이 부정행위에 관여하였다면 근로자에게 귀책사유가 있는 때에 해당하고, 부정행위에 의해 이익을 받아 불공정하게 선발된 이상 직권면직사유가 인정된다고 보았고, 이력서 허위 기재를 이유로 근로계약을 취소한 사안에서 근로계약 역시 사법상 계약이므로 민법 제109조 제1항에 따라 취소가 가능하다고 보았다. 대서판결은 채용비리의 경우에도 근로계약의 취소가 가능하다는 점과, 근로계약을 취소하기 위한 요건을 구체적으로 밝히고 있다는 점에서 의의가 있다고 할 수 있다.

- 한편 근로계약의 취소에 해고의 정당한 이유가 요구되는지 여부가 문제될 수 있는데, 대서판결은 이에 대하여 명확히 언급하고 있지는 않지만 원심의 판단에 법리오해가 없다고 한 점에서 근로계약의 취소에 근로기준법 제23조 제1항이 적용되지 않는다는 입장을 밝힌 것으로 이해할 수 있을 것이다.

<정년연장형 임금피크제의 유효성 판단> 수원지방법원 성남지원 2025.07.15. 선고 2024가합204074판결

【판결 요지】

- 근로자가 근로를 제공하는 근본적인 이유는 근로에 상응하는 임금을 받는 것이고, 정년연장이 근로자에게 이익이 되는 가장 큰 이유는 근로자가 연장된 근무기간 동안 추가적으로 급여를 수령할 수 있기 때문인데, 정년연장과 함께 시행되는 임금피크제의 임금 조정률이 과도할 뿐만 아니라 임금 삭감에 대한 대상 조치도 충분하게 도입되지 않았다면, 정년연장 및 임금피크제의 시행 전과 비교할 경우 연장된 근무기간을 실질적으로 무임금으로 일하는 것과 다름없고, 이러한 정년연장은 근로자의 노동력만을 착취하는 것일 뿐 근로자에게 어떠한 이익을 가져다준다고 보기 어렵다. 이 사건 임금피크제는 **고령자고용법 제4조의4 제1항**에 위배되어 무효이므로, 피고는 원고들에게 이 사건 임금피크제가 시행되지 않았더라면 원고들이 지급받았을 임금 등과 원고들이 이 사건 임금피크제 시행 후 실제 지급받은 임금 등의 차액을 지급할 의무가 있다.

I. 사실관계

- 원고 A·B와 C는 각각 1990년과 2000년에 IM라이프생명보험(현 `DGB생명보험`)에 입사하여 차장 직급으로 근무하다가 정년에 이르러 퇴직하였다. 피고 회사는 정년을 만 60세 이상으로 규정한 **고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진법에 관한 법률**(이하 `고령자고용법`이라 함)이 시행되기 직전인 2016년 11월 30일에 임금피크제를 도입했으며, 당시 정년은 만 58세였다. 노사 합의에 따라 마련된 임금피크제 기준에 따르면, 대상은 만 56세가 되는 전 직원이며, 적용 기간은 만 56세에 도달하는 연도의 1월 1일부터 만 60세가 되는 해당 연도의 월말까지이다. 임금 지급률은 임금피크제 적용 직전 연도 말의 임금을 기준으로, 만 56세에는 75%를 지급한 뒤 매년 10%포인트씩 줄여 만 60세에는 35%까지 삭감된 임금이 지급되도록 했다. 이와 함께 회사는 임금피크제 적용 시점부터 원고들을 기존 부서에서 소비자보호부로 변경하여 민원 처리 업무를 맡겼다. 임금피크제의 적용으로 만 56세부터 삭감된 임금을 받았던 원고들은 정년퇴직 이후 임금피크제가 적용되지 않았다면 받을 수 있었던 임금과 퇴직금 등을 청구하며 회사를 상대로 소송을 제기하였다.

II. 대상판결 내용

- 해당 판단은 임금피크제의 절차적 위법에 관한 쟁점이 아닌, 실체적인 위법에 관한 것이 쟁점인 사안으로, 강행규정인 고령자고용법 제4조의4 제1항의 위반 여부가 다툰졌다. 우선 목적의 타당성과 관련하여 법원은 이 사건의 임금피크제가 고령층 근로자의 고용안정과 청년 일자리 창출을 목적으로 한다며 도입 목적의 타당성을 인정하였다. 그러나 이에 반하여, 근로자들의 입는 불이익 정도가 지나치게 크다고 판단하였는데, 근로자들이 56세부터 60세까지 임금피크제를 적용하여 받을 수 있는 총액은 기존 연봉의 275%에 불과하였다. 이는 정년연장 전 56세부터 58세까지 3년간 지급되던 총액 300%에도 미치지 못한 수준으로, 재판부는 회사가 주장하는 1개월간의 복리후생금품을 최대치로 반영하더라도, 정년연장 및 임금피크제의 시행 전과 비교할 경우 연장된 근무기간을 실질적으로 무임금으로 일하는 것과 다름없고 이러한 정년연장은 근로자의 노동력만 착취하는 것일 뿐 근로자에게 어떠한 이익을 가져다준다고 보기 어렵다고 판시하였다. 다음으로 임금피크제 적용을 받는 대상자들을 소비자보호부로 부서를 변경하여 민원 업무를 수행하게 한 것에 대하여 재판부는 대상 조치의 적정성을 판단하였는데, 민원 업무의 스트레스와 해당 업무는 일반 직원들도 수행한다는 점을 고려하면, 해당 업무가 임금을 줄이는 대신 업무 부담을 덜어주는 조치로 보기 어렵다고 보았다. 마지막으로, 감액된 재원이 고령 근로자의 고용 안정화와 청년 일자리 창출에 사용되었다고 보기 어렵다고 판단하였는데, 실제 회사가 임금피크제를 도입한 이후에 퇴직한 직원은 약 103명(2019~2023년)인 반면에 신규 채용인원은 16명(2021~2022년)에 그쳤다.

III. 검토

- 2022년 5월, 한국전자기술연구원의 정년유지형 임금피크제에 대해 합리적 이유 없는 연령 차별 여부에 관한 판단에서 대법원은 임금피크제의 유효성에 관한 판단기준(① 도입 목적의 타당성, ② 대상자들의 불이익 정도, ③ 대상조치 유무 및 그 적정성, ④ 임금피크제로 확보한 재원이 제도 도입 목적에 맞게 사용되었는지 여부 등)을 제시하였고, 이후 대부분의 하급심 판결에서는 해당 판단기준이 중요하게 고려되었다. 다만, 정년연장형 임금피크제에 대한 하급심 판결은 임금피크제의 유효성 판단기준을 고려하면서도 대체로 정년이 연장되었다는 사실 자체에 주목하여 정년유지형보다는 제도의 정당성을 폭넓게 인정하는 경향이 존재하였다(**서울중앙지방법원 2023.1.19. 선고 2020가합604507 판결**, **서울고등법원 2023.2.19. 선고 2022나2025019 판결**, **서울남부지방법원 2024.3.27. 선고 2023가합110139 판결** 등). 이러한 흐름 속에서 대상판결은 정년연장형 임금피크제라 하더라도 각 판단기준을 구체적으로 살펴보고, 합리적 사유가 있는지 엄격하게 검토해야 한다는 기본을 다시 확인시켜 주었다는 데 의의가 있다.

- 대상판결에 따르면, 정년연장이 근로자에게 주는 가장 큰 이익은 연장된 근무기간 동안 경제적 이익을 얻을 수 있다는 점인데, 근무기간이 늘어났더라도 지급받을 수 있는 임금 총액이 오히려 기존보다 큰 폭으로 삭감된다면 정년연장은 더 이상 이익이 아닌 노동력 착취라는 것이다. 지금까지 고령 근로자에 대한 임금 삭감 문제는 계속 일할 기회를 준다는 명분하에 그 대가로 임금 감액이 당연시되었으며, 그 전제에는 고령 근로자의 육체적 노동의 효율성 저하라는 인식이 자리 잡고 있다. 그러나 언제까지 이와 같은 관점의 타당성이 유지될 수 있을까?

- 평균 수명이 늘어나면서 노동 가능 기간이 연장되고, 고령 근로자가 축적한 경험과 숙련도 역시 중요한 자산이 되고 있다. 따라서 고령이 생산성에 미치는 영향은 단순히 나이만을 기준으로 일반화할 수 없으며, 반드시 업무의 성격에 따라 개별적으로 평가되어야 한다. 실제로 정년 후 재고용에 관한 판단(**서울행정법원 2023.3.30. 선고 2021구합4755 판결**)에서도 법원은 축적적 고령 근로자에 대해 고령이라 하더라도 업무 성과에서 뚜렷한 차이가 있었다고 보기 어렵다고 판시하였다. 이러한 점을 고려할 때, 고령 근로자에게 일할 기회를 부여한다는 이유만으로 임금을 당연히 삭감하는 관행은 지양되어야 하며, 합리적 근거와 업무 특성에 기초한 평가가 선행되어야 한다. 그만큼 임금 감액은 구체적이고 엄밀한 판단이 함께 이뤄져야 하는 쟁점이다.

- 대상판결이 판단기준별 검토를 통해 합리적 사유를 구체적으로 살핀 점은 의미가 크다. 그러나 이 사안과 같이 과도한 임금 감액률도 유효한 것인지에 관한 판단이 이뤄지지 않은 점은 한계로 지적된다. 임금 감액 문제는 임금피크제뿐 아니라 정년 후 재고용 상황에서도 구체적 기준이 부재한 채 법적 분쟁을 통해서만 해결되고 있는 실정이다. 따라서 법원의 엄격한 심사를 통해 임금피크제의 유효성 판단기준을 보다 분명히 확립할 필요가 있다. 동시에, 관련 분쟁을 예방하기 위해서는 1991년 제정된 **고령자고용법**(당시 **고령자고용촉진법**)에 시대 변화에 부합하는 새로운 기준을 반영하는 입법 작업이 필요하며, 이는 곧 본격화될 정년연장 논의와 병행되어야 할 중요한 과제라 할 것이다.

<통상임금의 판단기준에 관한 판례 법리의 변경> 대법원 2024.12.19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결, 대법원 2024.12.19 선고 2023다302838 전원합

의체 판결

【판결 요지】

- 통상임금은 소정근로의 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하기로 정한 임금을 말한다. 근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은 그에 부가된 조건의 존부나 성취 가능성과 관계없이 통상임금에 해당한다. 어떠한 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 소정근로 대가성이나 통상임금성이 부정되지 않는다. 소정근로를 온전하게 제공하는 근로자라면 충족할 근무일수 조건, 즉 소정근로일수 이내로 정해진 근무일수 조건의 경우, 그러한 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 통상임금성이 부정되지 않는다.

I. 2024년 전원합의체 판결에 따른 통상임금 법리 변화와 재직자 조건부 수당의 고정성 검토

- 대법원은 2024.12.19.에 통상임금을 계산하는 방식에 관한 판례 법리를 변경하는 전원합의체 판결을 내렸다. 경총이 새로운 판례 법리대로 통상임금을 산정하게 되면 기업의 연간 인건비 부담이 6조 7,889억 원 늘어날 것이라고 전망했듯이, 통상임금의 판단기준에 관한 판례 법리의 변경은 중요한 이슈이다. 새로운 판례에 영향을 받는 기업은 향후 임금 체계와 근로시간 체계를 정비하여야 할 필요가 등장한다.

- 통상임금은 근로기준법에서 사용하는 기준이 되는 임금인데, 연장근로, 휴일근로, 야간근로의 경우 시급 통상임금의 50%를 할증하여 시간당 150% 이상 임금을 지급하여야 한다(제56조). 그 밖에 해고예고수당(제26조), 연차휴가수당(제60조), 주휴일 등 유급휴일수당의 기준이 된다. 근로기준법은 통상임금이라는 용어를 사용하고 있지만 구체적으로 어떠한 개념이고 여러 임금항목이 그것에 포함되는지에 대해 어떠한 기준으로 판단하여야 하는가에 관해 규정하고 있지 않다. 그래서 법원은 1990년대 이래 소송 사건에서 통상임금의 개념과 판단기준을 제시해 판례 법리를 형성해 왔다.

- 회사에서 취업규칙이나 단체협약에 따라 연장근로수당을 지급하고 있는데, 그것이 판례가 해석하는 근로기준법에 따른 통상임금을 기준으로 1.5배로 계산한 법정수당보다 적게 지급한 것이 된다면, 그 차액을 추가로 지급하여야 한다. 그래서 통상임금에 어떤 임금항목이 포함되는가가 중요해진다. 시급 통상임금을 계산할 때, 통상임금은 기본급뿐만 아니라 각종 수당, 상여금 등이 포함되는 것이 원칙이다. 통상임금은 소정근로(계약상 약속된 기본 근로)에 대한 대가이므로, 소정근로에 추가된 연장근로의 대가는 포함되지 않는다. 개인성과급이나 경영성과급처럼 근로가 제공된 후에 실적을 평가하여 결정되는 경우도 통상임금에 포함되지 않는다.

- 각종 수당, 상여금(정기상여금, 명절상여금 등)을 ① 통상임금에 포함시키지 않는 계산 방식으로 연장근로수당을 계산한 경우와 ② 통상임금에 포함시키는 계산 방식으로 연장근로수당을 계산한 경우, 두 액수의 차이가 매우 크다. 그 차액을 지급하라는 소송이 제기되는데, 회사가 연장근로를 고정적으로 많이 하는 경우이면서, 임금채권의 소멸시효가 3년이므로 3년의 기간에 대해, 재직자들이 집단적으로 소송을 제기하는 경우, 한 소송 사건에서 청구 금액이 수십억, 수백억인 경우도 흔해 왔다. 이처럼 소송 당사자들에게 통상임금이 어떻게 계산되는지가 중요해 왔다. 또한 회사가 각종 수당, 상여금을 통상임금에서 제외하여 연장근로수당 등의 인건비를 계산해 온 경우에는 통상임금을 어떻게 계산하여 판단하는가에 따라 추가 인건비가 커질 수 있다.

- 그리하여 통상임금의 개념 및 판단기준에 관하여 그동안 논란이 많았는데, 2013년 대법원 전원합의체 판결(대법원 2013.12.18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결 및 대법원 2013.12. 18. 선고 2012다94643 전원합의체 판결 : 이하 2013년 전합 판결이라 한다)로 그동안의 논란을 정리했었다. 이른바 정기성, 일률성, 고정성을 갖춘 임금이 통상임금이라고 판단했다. 이 2013년 전합 판결에 따라 그간에 상여금 등에 재직 조건(예컨대 지급기준일에 재직하는 경우에만 정기상여금을 지급한다)이나 근무일수 조건(예컨대 2개월 기간 중 15일 이상 근무하는 경우에만 정기상여금을 지급한다)을 붙인 경우 고정성이 결여되어 통상임금에 포함시키지 않는 판결이 내려졌지만, 그 타당성에 문제가 제기되었다.

- 이번 2024년 대법원 전원합의체 판결(대법원 2024.12.19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결 및 대법원 2024.12.19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결 : 이하 2024년 전합 판결이라 한다)은 통상임금의 개념을 다시 수정했다. 종전과 달리 고정성을 요건에서 폐기하여, 어떤 임금항목에 재직 조건이나 일정 근무일수 조건을 붙였더라도 통상임금에 포함시켰다. 결국 전합 판결은 정기상여금에 재직을 지급 조건으로 하였더라도 통상임금에 해당하고(2020다247190 현대해상 사건), 지급주기가 2개월, 약 6개월, 약 1년인 상여금에 15일 이상 근무를 조건으로 지급하더라도 통상임금에 해당한다고(2023다302838 현대자동차 사건) 판단했다.

II. 통상임금 고정성 요건의 폐기와 2024년 전원합의체 판결의 법리적 전환

- 2024년 전합 판결에 따른 해석은 2013년 전합 판결과 달라 판례 해석이 변경된 것이다. 2024년 전합 판결에 따른 해석을 간략히 살펴보자.

- 통상임금은 소정근로의 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하기로 정한 임금을 말한다. 근로자와 사용자가 소정근로시간에 제공하기로 정한 근로의 대가라는 소정근로 대가성, 임금의 지급 시기와 지급 대상이 미리 일정하게 정해졌을 것을 요구하는 정기성(즉 지급 시기가 미리 일정하게 정해진 것)과 일률성(즉 지급 대상이 미리 일정하게 정해진 것)의 개념을 통하여 통상임금에 해당하는지 여부를 판단한다.

- 근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은, 그에 부가된 조건의 존부나 성취 가능성과 관계없이 통상임금에 해당한다. 임금에 부가된 조건은 해당 임금의 객관적 성질을 실질적으로 판단하는 과정에서 소정근로 대가성이나 정기성, 일률성을 부정하는 요소 중 하나로 고려될 수는 있지만, 단지 조건의 성취 여부가 불확실하다는 사정만으로 통상임금성이 부정된다고 볼 수는 없다.

- 이러한 설명은 종래 판례가 통상임금의 개념에서 요구해 온 고정성 요건을 폐기한 것이다. 고정성이란 근로자가 제공한 근로에 대하여 그 업적, 성과, 기타의 추가적인 조건과 관계없이 당연히 지급될 것이 사전에 확정되어 있어야 한다는 것이다. 2024년 전합 판결은, 고정성 개념은 통상임금의 범위를 법령상 근거 없이 축소시켜, 연장근로 등에 대한 정당한 보상이 이루어지지 못해 연장근로 등을 억제하려는 근로기준법의 취지에 부합하지 않는다고 비판한다. 또한 고정성을 통상임금의 개념적 징표로 삼으면 노사 당사자가 어떤 임금에 재직조건이나 근무일수 조건과 같은 지급조건을 부가하여 쉽게 그 임금을 통상임금에서 제외할 수 있도록 허용하게 되어, 통상임금의 강행성을 잠탈할 위험을 초래한다고 비판한다.

- 구체적으로는 ① <근무일수 조건>이 부가된 임금에 관하여, 2013년 전합 판결은 일정 근무일수의 충족이라는 조건의 성취 여부가 불확실하므로 고정성이 결여되어 통상임금성이 부정된다고 보았다. 그러나 2024년 전합 판결은 소정근로일수 이내로 정해진 근무일수 조건을 충족하여야 지급되는 임금은 그 조건이 소정근로를 온전하게 제공하는 근로자라면 충족할 조건이므로 통상임금성이 부정되지 않는다고 해석을 변경했다.

- 또한 ② <재직 조건>이 부가된 임금에 관하여, 2013년 전합 판결은 지급기준일에 재직이라는 조건의 성취 여부는 불확실하므로 고정성이 결여되어 통상임금성이 부정된다고 보았다. 그러나 2024년 전합 판결은 어떠한 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 소정근로 대가성이나 통상임금성이 부정되지 않는다고 해석을 변경했다.

- 새로운 판례 법리에서 또 하나 유의할 점은 판례 법리가 소급적으로 적용되지 않는다고, 새로운 법리의 효력 범위에 시기적 제약을 둔 점이다. 2024년 전합 판결은 새로운 판례의 관철 필요성과 신뢰보호의 필요성을 형량한 결과로, 새로운 법리의 소급효를 제한했다. 즉 판결 선고일인 2024.12.19. 이후 제공한 연장근로수당은 새로운 법리에 따른 통상임금의 범위를 기초로 지급액을 산정하되, 그날 전까지 제공한 연장근로수당은 종래 법리에 따른 통상임금을 기초로 산정한다. 다만, 이미 소송이 제기되어 법원에 계속 중인 사건은 적극적으로 권리구제를 도모한 당사자의 구제를 위해 새로운 법리가 소급적으로 적용된다.

III. 통상임금 법리의 본질적 회귀와 2024년 전원합의체 판결 이후의 노사 과제

- 법리적인 검토를 한다면, 이번 2024년 전합 판결은 통상임금의 개념에 관해, 소정근로의 대가를 정하였다는 점을 판단의 중심으로 삼고 있다. 즉 통상적인 근로인 소정근로에 대한 대가를 판단기준의 중심으로 다시 소환하였다는 의미를 갖는다. 정기성과 일률성은 소정근로의 대가를 정하였다는 점이 드러나는 징표일 뿐이지 그 자체가 반드시 갖추어야 할 요건이 아니다. 2024년 전합 판결이 고정성을 폐기한 것은 과거 고정성을 반드시 갖추어야 할 요건으로 보면서 그 고정성의 의미를 사전에 확정되어야 한다는 의미로 해석하여 결국 재직 조건, 일정 근무일수 조건 등의 법적 논란만 일으켰다는 반성이다.

- 그럼에도 새로운 판례 법리에서도 통상임금에 관한 법적인 논란이 완전히 종식될지 불확실하다. ① 소정근로의 대가인지 아닌지의 판단이 명확할 수 있는지, ② 정기성, 일률성은 반드시 갖추어야 하는지, ③ 시급 통상임금을 계산할 때 통상임금에 포함되는 임금을 나누는 시간 수에 관해 소정근로시간 외에 간주되는 시간을 포함해왔는데 그것이 새로운 판례 법리의 해석과 어긋나지는 않는지, ④ 판례가 스스로 소급효를 제한하는 것이 법리적으로 타당한지 등등 여러 법리적인 논쟁이 전개될 가능성이 있다.

- 또한 실무적인 관점에서는, ⑤ 효력의 기준일인 2024.12.19. 언저리에서 발생하는 수당이 그 이전 근로의 대가인지, 그 이후 근로의 대가인지 등의 판단이 불명확한 경우도 생길 수 있고, ⑥ 앞으로 새 판례 기준에 따른 인건비의 증가 부담뿐만 아니라, ⑦ 과거 소송을 제기하지 않은 직원들이 불공정하다고 생각하여 발생하는 노사 간의 불화 등이 문제될 수 있다. 이러한 법리적 논란과 실무적 논란이 뒤엉켜 노사 간의 불안을 증폭할 가능성도 우려된다.

- 그러므로 노사는 새로운 판례가 내려져 법적인 판단이 명확해졌으니 그에 따르면 된다는 생각보다는, 노사가 현안이거나 우려되는 문제들을 협력하여 해결해 나가겠다는 지혜가 필요하다. 돌이켜 보면, 2013년 전합 판결이 내려졌을 때에도 마찬가지였다. 과거 행정해석에 따라 상여금(정기상여금, 명절상여금)은 1개월을 초과하는 기간으로 지급되므로 정기성이 결여되어 통상임금에 포함되지 않는다고 여기고 통상임금에서 제외하는 실무를 하였다. 이에 대해 2013년 전합 판결은 상여금이 1개월을 초과하는 주기로 지급되더라도 정기성이 인정되어 통상임금에 포함된다고 판단했다. 그래서 종전보다 연장근로수당의 부담이 증가한 회사가 대응하는 방법으로 상여금에 재직 조건이나 근무일수 조건을 추가하여 고정성을 결여시켜 여전히 통상임금에서 제외시키려 하였다. 이에 대해 2024년 전합 판결은 고정성을 요건에서 제외하여 상여금이 그런 조건에도 불구하고 통상임금에 포함시키도록 기준을 바꾼 것이다.

- 이처럼 노동에 대한 비용 통제의 시각에서 어떤 임금항목을 통상임금에서 제외하려는 대응 방안은 결국 집단적 소송 제기 등 노사관계의 불안 요소가 되어왔다. 따라서 새로운 판례 법리에 대해 임시적인 대응 방안을 찾기보다는 근본적으로 임금 등 보상 체계와 근로시간 체계를 연계한 점검이 필요하다.

Ⅳ. 2024년 통상임금 판결에 따른 직무별 임금·근로시간 체계 개편 전략과 노사 상생 방안

- 앞으로 이에 대해 다양한 학제적·실무적인 연구와 고찰이 전개되기를 바라면서, 대략적으로 다음과 같은 대응 방안을 제안하고자 한다.

- 첫째, 근로시간 제한이 있고 실제 근로시간에 따른 보상이 중요한 직역인 경우(예컨대 생산직, 서비스직, 기술직, 고정OT가 있는 사무직 등), ① 판례 법리에 따라 통상임금을 계산한 기준으로 상응한 보상이 이루어져야 하면서도, ② 회사에 연장근로수당의 부담이 확대되지 않도록 연장근로의 필요에 대해 적절한 통제가 이루어져야 한다. 예컨대 통상임금이 증가한다면 근로시간의 효율적인 배분으로 연장근로 시간을 감소시켜 연장근로수당의 부담을 고정하는 방법도 고려할 수 있다. 나아가 통상적인 근로는 법정 근로시간 제한(1일 8시간, 1주 40시간) 이내로 근로시간을 줄여 연장근로수당의 계산이 법적 논쟁으로 확산되지 않도록 한다.

- 둘째, 실제 근로시간에 따른 보상보다는 성과 및 성과보상이 중요한 직역인 경우(예컨대 외근직, 연구·개발직 등), ① 여러 유연 근무시간 제도를 활용하여 근로기준법상의 근로시간 제한 및 연장근로수당 보상 등의 제약으로부터 벗어나면서, ② 적절한 성과 보상 체계를 구축하도록 한다.

- 셋째, 노사 간에 소통을 강화하고 이해와 협력을 통해 임금 등 보상 및 근로시간 체계를 새로이 형성해 나가야 한다. 임금·보상 체계나 근로시간 체계에 관한 취업규칙의 변경은 대개가 불이익 변경이어서 근로자들의 집단적 동의가 필요하고, 유연 근무시간 제도를 도입하거나 변경하려면 근로자대표와 합의가 필요하다. 앞으로의 임금·근로시간 체계에 대해 노사가 서로 이해하고 수용할 수 있으려면 과거에 대해 다투기보다는 미래에 대한 비전을 공유하면서 상호 간에 신뢰하고 협력해야 한다.

- 2024년 전합 판결로 인해 노사에게 다시 한번 노사관계의 안정과 발전을 도모할 기회가 주어졌다. 노사가 그 기회를 지혜롭게 활용하기를 바란다.

<임금 대리수령 동의의 효력> 대법원 2025.06.12. 선고 2025다209645 판결

【판결 요지】

- [1] 근로기준법 제43조 제1항이 임금을 직접 지급하도록 하는 취지는 임금이 확실하게 근로자 본인에게 지급되도록 하여 그의 자유로운 처분에 맡기고 근로자의 생활을 보장하려는 데 있고, 통화 지급의 원칙이나 전액 지급의 원칙과 달리 직접 지급의 원칙은 법령 또는 단체협약에 의한 예외가 인정되지 아니한다. 따라서 원칙적으로 근로자가 제3자에게 임금 수령을 위임하거나 대리하게 하는 법률행위는 무효이다.

- [2] 다만, 근로자 본인이 직접 수령할 수 없는 사정에 상당한 이유가 있는 경우에는 예외적으로 사자(使者)에 의한 임금의 수령도 가능할 수 있다. 그러나 위와 같은 근로기준법 제43조의 규정 형식이나 취지 등에 비추어 보면, 사회통념상 근로자 본인에게 지급하는 것과 동일시되는 사람 또는 근로자 본인에게 그대로 전달할 것이 확실하다고 판단되는 사람이 임금을 수령할 때에만 그를 사자로 보아야 하고, 이에 해당하는지 여부는 엄격하게 판단하여야 한다.

- 원칙적으로 금전채권의 채무자는 직접 채권자에게 변제하여야 하나 채권자가 제3자에게 변제수령에 대한 대리권을 부여하였거나 채무자가 채권자의 동의를 받으면 제3자에게도 적법한 변제를 할 수 있다. 그러나 임금채권도 금전채권의 일종이지만 근로기준법 제43조 제1항, 선원법 제52조 제1항에 의한 제한이 적용된다. 근로기준법 제43조는 제1항은 임금은 통화(通貨)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다. 다만, 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다.라고 규정하고 있다. 이 규정에 따르면 임금은 채권자인 근로자에게 직접 지급해야 하며, 여기에는 위 판결 요지[1]이 지적하는 바와 같이 법령이나 단체협약에 의한 예외가 인정되지 않는다. 따라서 사용자가 제3자에게 임금을 지급하면서 근로자의 동의를 받거나 혹은 근로자로부터 대리권을 부여받은 제3자에게 임금을 지급하더라도 그 지급의 효력이 인정되지 않는다. 그럼에도 사용자가 위와 같은 방식으로 임금을 제3자에게 지급한다면 임금 지급으로써의 효력이 인정되지 않으므로, 근로자는 여전히 사용자에게 해당 임금의 지급을 청구할 수 있으며 사용자는 임금 미지급에 따른 근로기준법상의 각종 책임을 부담하게 된다.

- 이러한 임금직접지급원칙은 중간착취 등을 금지하여 판결 요지[1]이 언급한 바와 같이 근로자가 근로의 대가인 임금의 지급을 확실하게 보장받고, 이를 통해 자신의 생계를 원만하게 해결할 수 있도록 하는 데 그 취지가 있다. 요컨대, 이 원칙은 임금지급의 확실성을 담보하는 기능을 수행한다.

- 위 판결의 사안은 다음과 같다. 원고들은 팀장 K의 소개로 아파트 신축공사에서 철근, 콘크리트 공사를 하도급받아 시공한 피고 회사와 근로계약을 체결하고, 해당 공사 현장의 거푸집 해체 작업 등에 투입되어 근로를 제공하였다. 이때 원고들은 본인 계좌 사용 불가를 이유로 인력사무소 계좌인 L의 계좌로 임금을 대리 수령한다는 내용의 임금수령 본인동의서(위임장) 또는 임금 대리수령 확인서를 작성하여 피고 회사에 제출하였고, 이에 따라 피고 회사는 L의 계좌로 원고들의 임금을 일괄적으로 지급하였다. L은 자신의 계좌로 입금된 돈을 K 등에게 지급하였는데, K는 어느 시점부터 원고들에게 이를 전달하지 않고 다른 용도로 사용하였다. 이에 원고들은 피고 회사를 상대로 임금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 1심은 이러한 임금지급 방식이 원고들의 의사에 합치된다고 보아 피고가 임금지급의무를 면한다고 판단하여 원고들의 청구를 기각하였다. 이에 반해 원심은 임금직접지급원칙에 대해서는 선원법 제52조 제3항을 제외하고는 근로기준법상 예외가 인정되지 않으므로 원고가 인력사무소 계좌로 임금수령을 위임하는 행위는 무효이고 따라서 피고의 임금 변제의 효력이 발생할 수 없다며 원고들의 청구를 인용하였다. 대법원은 판결 요지[1]과 같이 임금직접지급원칙상 대리수령은 무효라는 원칙을 확인한 다음, 이에 대하여 선원법만을 예외로 인정한 원심과 달리 판결 요지[2]와 같이 근로자 본인이 직접 수령할 수 없는 사정에 상당한 이유가 있는 경우에는 예외적으로 사자(使者)에 의한 임금의 수령도 가능할 수 있다라는 예외를 추가로 인정하였다. 나아가 임금직접지급원칙의 취지를 고려하여 이때의 사자는 사회 통념상 근로자 본인에게 지급하는 것과 동일시할 수 있을 정도로 밀접해야 한다는 기준을 제시함으로써, 예외의 인정에 신중해야 한다는 단서를 달았다. 대법원은 이 사안에 대하여 L의 원고들을 전혀 모르고, K와 피고 직원이 위임장과 신분증을 보내주어 자신의 계좌로 임금이 지급되면 K 등에게 보내주었다는 취지의 법정 증언을 근거로 위 예외에 해당하지 않는다고 판단하여 원심의 결론을 인용해 상고를 기각하였다.

- 이 사건의 쟁점은 임금대리수령에 관한 근로자의 동의가 있는 경우 임금직접지급원칙에도 불구하고 그 효력을 인정할지 여부이다. 1심은 형식적으로 원고들이 작성한 문서를 근거로 유효하다고 보았다. 노동사건의 특수성을 인지하지 못하고 근로자의 의사만으로 강행규정의 적용을 배제하는 오류를 범했다고 평할 수 있다. 한편, 원심은 근로기준법의 문언에 충실하게 해석했다는 점에서 결론적으로 타당하나 기계적 해석으로 인해 임금직접지급 원칙의 취지를 살리지 않아 예외를 협소하게 보았다는 점에서 아쉬움을 남긴다. 이에 대하여 대법원은 근로자의 형식적 동의가 있더라도, 임금직접지급원칙은 중간 착취를 방지하여 근로자의 생존권을 보장하려는 강행규정임을 고려해 그 동의의 효력은 원칙적으로 무효라고 보면서, 이 원칙의 취지가 임금지급의 확실성을 보장하는 데 있으므로 이러한 취지가 훼손되지 않는 경우라면 예외를 인정하여 근로자의 편의를 도모할 수도 있다는 유연성을 발휘하였다. 이에 터잡아 대법원은 대리수령 동의의 효력의 유효성을 근로자 본인과 동일시할 수 있는 사자(使者)를 통한 수령이라는 극히 예외적인 경우에 한정함으로써 근로자의 편의를 빙자한 남용가능성을 제한하였다는 점에서 일리 있는 결론에 도달했다고 볼 수 있다. 앞으로 실무적으로는 형식적으로 임금대리수령동의가 있더라도 사용자는 대리인이 위와 같은 사자라 볼 수 있는지에 대해 엄격한 수준의 확인을 하여야 하며, 이를 게을리한 채 제3자에게 임금액을 지급한다면 그로 인해 발생할 수 있는 임금 미지급 내지 2중 지급의 모든 위험을 스스로 부담해야 할 것이다.

- 과거, 임금은 이른바 노란봉투에 담겨 현금으로 지급되는 경우가 일반적이었다. 그러나 금융거래가 활성화된 오늘날은 임금을 근로자의 예금계좌로 입금하는 방식이 보편화되었다. 금융거래가 활발해지면서 채권자(대표적으로 대출을 제공한 금융기관)는 자기 채권의 만족을 위해 강제집행을 할 때 채무자의 예금계좌를 압류하는 경우가 많다. 채무초과 상태에 빠져 금융기관에 개설한 예금계좌가 채권자들에 의해 압류된 근로자도 있다. 이 경우 만약 임금이 압류된 예금계좌로 입금되면 이를 인출하지 못해 생활에 곤란을 겪는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 위험을 회피하고자 취업 시 임금을 아예 현금으로만 받거나 임금대리수령 동의서 등을 제출하며 제3자의 계좌로 입금해 줄 것을 요구하는 근로자도 있다. 이제 대법판결은 사용자가 근로자 명의가 아닌 제3자 명의의 예금계좌로의 임금지급을 꺼리게 하는 근거로 작동할 것으로 전망된다. 그 결과 채무초과로 예금계좌가 압류된 근로자들은 임금의 현금 지급을 꺼리는 사업장에는 취업이 곤란해질 수 있어 이러한 근로자는 경제적 회생은 고사하고 생계유지 자체가 어려워질 수 있다. 다만 올해 1.31. 민사집행법이 개정되어 생계비계좌를 개설할 수 있게 되었다(제246조의2). 생계비계좌는 1인당 전 금융기관에 1개를 개설할 수 있는데, 이 계좌에는 시행령으로 정하는 생계비를 초과하여 예치할 수 없으나, 생계비계좌에 예치된 금액은 압류가 금지된다(제246조 1항 8호). 다만 생계비계좌 개설과 압류금지효력은 개정법 부칙에 따라 2026.2.1.부터 시행된다. 대법판결이 가져올 실무적 문제점을 해소할 수 있는 제도적 장치가 마련되어 시행이 임박했다는 점에서 다행이라 할 수 있다.

- 한편, 대법판결은 일용직 일자리를 알선하면서 근로자를 대신해 임금 등을 사용자로부터 수령해 소개요금을 선공제하고 근로자에게 지급하는 인력사무소의 소개요금 징수 방법에도 영향을 미칠 수 있다. 직업안정법상 유료직업소개사업을 하는 자는 고용기간이 3개월 미만인 경우 고용기간 중 지급받기로 한 임금의 1% 이하를 구직자로부터, 30% 이하(건설일용의 경우에는 10% 이하)를 구인자로부터 받을 수 있다(제19조 제2항, 국내유료직업소개요금 등 고시). 소개요금은 원칙적으로 구인자와 구직자에게 각각 별도로 징수해야 한다(다만, 위 고시는 일정한 요건하에 구직자가 구인자의 소개요금을 받아 인력사무소에 전달하는 것을 예외적으로 허용한다). 그러나 인력사무소 입장에서 소개요금 징수의 확실성을 보장받기 위해 임금을 대리수령하는 방법을 이용하는 경우가 있었던 것이다. 이 방법은 임금직접지급원칙상 문제의 소지가 있지만 구인자, 구직자, 인력사무소의 편의주의적 카르텔(?)에 의해 특별히 문제가 제기되지는 않았던 것으로 보인다. 그러나 대법판결이 인력사무소를 통한 임금대리수령이 문제된 사안을 배경으로 하는 데다, 판결의 취지에 따르면 인력사무소가 더 이상 임금을 대리수령할 수 있는 사자로 인정받지 못할 여지가 있으므로, 이제 이 카르텔이 깨질지도 모르겠다.

- 대상판결은 법리적으로는 임금직접지급원칙이 중간착취를 배제하고 근로자의 생활보장을 위한 강행규정임을 재확인하고, 이를 바탕으로 임금대리수령동의의 효력유무에 관한 판단기준을 제시하였다는 점을 주목할 필요가 있다. 이에 더해 대상판결은 실천적으로 채무초과상태에 있는 근로자 내지 고용이 불안정한 일용직 근로자 등 취약근로자에게 임금직접지급원칙이 구체적으로 어떤 의미를 지니는지 생각해 볼 계기를 제공한다는 점에서도 의미가 있다.

<당직 및 콜 대기 시간의 근로시간 해당 여부> 대법원 2024.11.14. 선고 2021다220062, 2021다220079(병합), 2021다220086(병합), 2021다220093(병합) 판

결

【판결 요지】

- 통상근무 시간에 수행한 업무의 내용이 무엇이었는지, 통상근무와 당직 또는 콜 대기 근무 사이의 근무 밀도 차이가 어느 정도였는지, 자택에서 당직 또는 콜 대기 중 콜을 받으면 몇 분 안에 출근해야 하는지 등을 알 수 없어, 수술실 간호사, 임상병리사, 방사선기사 등 원고들의 자택에서의 당직 또는 콜 대기 근무 시간 전부가 실질적으로 사용자인 피고의 지휘·감독 아래에 놓여있는 근로시간에 해당하는지, 그중 어느 범위까지 근로시간으로 보아야 하는지를 판단하기 어렵다. 원심으로서 위와 같은 사항들을 심리하여 원고들의 당직 또는 콜 대기 근무가 내용과 질에 있어서 그 근무시간의 전부 또는 일부를 근로시간으로 볼 수 있는지를 판단하였어야 한다.

I. 사안의 개요

- 피고는 근로복지공단, 원고는 근로복지공단 산하 병원에 근무하는 임상병리사, 방사선기사, 수술실 간호사, 운전기사, 전기·기계실 기사 등 다수의 근로자들이다. 원고들은 상여금, 급식보조비, 장기근속수당, 교통보조비, 직급보조비와 직책수행경비, 맞춤형 복지포인트, 임금 소급 인상분이 통상임금에 해당함에도 피고가 이를 통상임금에서 제외하고 시간외수당 등 법정계수당을 산정·지급하였으므로 이를 재산정하여 지급해야 한다고 임금청구소송을 제기하였다. 특히 임상병리사, 방사선기사, 운전기사, 전기·기계실 기사의 당직근무 시간, 수술실 간호사의 콜 대기 시간은 사용자의 지휘·감독하에 근로를 제공하는 근로시간이므로 역시 위 통상임금에 해당하는 금원을 포함하여 시간외근로수당을 재산정하여 지급해야 한다는 취지로 그 차액의 지급을 구하였다. 한편 피고 공단은 당직 및 콜 대기 시간은 업무 강도가 통상근무와 달리 현저히 경미하고, 일부 원고들은 근무장소가 아닌 자택 등에서 사용자의 지휘·감독을 받지 않고 휴식을 취했으므로 당직 및 콜 대기 시간 전부가 근로시간에 포함되지 않는다고 주장하였다.

- 이에 법원은 위 주장 금원의 통상임금 해당 여부를 판단한 후 당직 및 콜 대기 시간의 근로시간 해당 여부에 대해 판단하였다. 본고는 후자에 관한 것이다.

II. 각 심급별 판결

1. 1심 판결 및 원심 판결의 판시 내용

- 1심 재판부는 ① 피고가 원고들에게 복무규정 등에서 정한 당직근무를 명하거나 일·숙직수당을 지급하지 않았던 것으로 보이고, 오히려 시간외·야간·휴일근로수당을 지급하였으며, 당직 및 비상근무 운영세칙에서 정한 업무를 처리한 것도 아닌 점, ② 원고들의 당직 및 콜 대기 근무는 병원이라는 근무지의 특성상 환자들의 생명 및 건강유지를 위해 요구되는 것으로 주로 방사선 촬영, 병리검사, 투약, 긴급 수술 보조 등 진료 내용과 질에 있어 원고들의 통상근무와 다르다고 단정하기 어려운 점, ③ 기계·전기실 및 운전직 근로자들의 경우 노동의 밀도가 피고의 주장처럼 평일 주간근무에 미치지 않는다고 보더라도, 피고가 시간외수당, 야간 및 휴일수당 명목으로 일정한 금액을 지급하였을 뿐 순수한 당직근무의 대가였음에 대한 별다른 입증이 없는 점, ④ 근로시간은 중요한 근로조건으로 근로기준법의 엄격한 규정 및 근로자의 생활에 미치는 영향을 감안하면 초과 근로에 관한 근로기준법의 임금 가산 규정의 적용을 쉽게 배제할 수 없는 점, ⑤ 각 병원에서 진정한 의미의 당직(일·숙직) 근무를 수행하는 직원은 따로 지정되어 있었던 것으로 보이는 점 등을 감안하면, 원고들의 당직 및 콜 대기 시간을 관행적으로 정상적인 업무로 취급되지 않는 일반적인 일·숙직 업무와 같은 정도의 업무로 단정하기 어렵다고 보았다. 결국 당직 및 콜 대기 근무를 통상적인 근로의 연장으로 평가될 수 있다고 보았다.

- 원심 역시 1심 판결을 유지하면서 원고들의 당직 및 콜 대기 근무는 병원의 특성상 환자들의 생명 및 건강유지를 위해 요구되는 것으로, 그 업무내용과 태양이 평일 주간에 행하는 통상근무와 다르다고 할 수 없고, 설령 피고 공단의 주장처럼 원고들 중 일부가 당직 및 콜 대기 시간 대부분을 병원이 아닌 자택 등에서 보냈다고 하더라도 원고들은 야간 또는 휴일에도 평일 주간에 행하는 본래의 업무를 수행하기 위해 상시 대기하는 형태로 근로를 제공한 것이고, 실제로 호출이 있는 경우 곧바로 병원에 도착하여 업무를 수행하여야 했으므로 이러한 대기 시간 역시 실질적으로 사용자의 지휘·감독 아래에 놓여있는 시간이라고 봄이 상당하다는 점 등을 고려할 때 당직 및 콜 대기 시간 전부를 근로기준법상 근로시간으로 보아야 한다고 판시하였다.

2. 대상판결의 판시 내용

- 대상판결은 일반적인 일·숙직 근무가 주로 감시, 경비, 긴급보고 수수 등의 업무를 그 내용으로 하고 있는 것과 달리 당직 업무의 내용이 본래의 업무가 연장되거나 그 내용과 질이 통상근무의 태양과 마찬가지로 인정되는 경우에는 당직근무도 근로시간에 포함된다고 보아야 하나, 당직근무가 전체적으로 보아 근무의 밀도가 낮은 대기성의 단속적 업무에 해당하는 경우에는 본래의 업무에 실제로 종사한 시간만 근로시간으로 보아야 한다고 판시하였다. 또 수행하는 업무의 내용과 질이 본래의 업무가 연장된 경우에 해당하거나 통상근무의 태양과 마찬가지로 인정되는 여부는, 당직근무가 통상의 근무시간의 구속으로부터 완전히 벗어났는지 또는 통상근무의 태양이 그대로 계속되는지 여부, 본래의 업무에 종사하게 되는 빈도 내지 시간의 장단, 충분한 수면시간이 보장되는지 여부 등을 충분히 심리하여 정해야 한다는 기존 판례의 법리(대법원 1995.1.20. 선고 93다46254 판결, 대법원 1996.6.28. 선고 94다14742 판결 등 참조)를 다시 확인하였다. 다만 대상판결은 결론적으로 당직근무 중 수행한 업무 내용 및 통상근무와의 차이가 명확하지 않아 원심이 원고들의 당직 또는 콜 대기 근무가 내용과 질에 있어서 그 근무시간의 전부 또는 일부를 근로시간으로 볼 수 있는지를 판단하였어야 함에도, 이를 간과하면서 당직 또는 콜 대기 시간 전부를 근로시간으로 본 잘못이 있다고 보아 원심을 파기하였다.

- 세부적으로 보면, ① 운전기사와 기계·전기기사나 일부 방사선기사와 임상병리사의 경우 당직근무 중 수행한 업무의 내용이 무엇인지, 통상근무의 태양과는 차이가 있는지, 당직근무 중 자유롭게 이용할 수 있는 시간이 어느 정도 있었는지 등을 알 수 있는 증거가 없다는 점, ② 일부 병원의 다른 방사선기사들이 이 사건 청구기간 중 일부 기간에 평일 야간 및 휴일에 당직 근무를 한 것이 근로시간에 해당한다고 인정된 판결이 선고·확정된 사실은 있으나, 원고들 중 해당 시기에 해당 병원에 근무하였던 방사선기사의 근무 내용 및 태양 등도 이들과 동일하였는지, 위 확정판결 이후 시점의 근무 내용 및 태양에 변화가 없었는지 등을 알 수 있는 자료가 없는 점, ③ 수술실 간호사, 방사선기사와 임상병리사의 경우 콜 건수 등에 관한 자료가 제출되었으나, 이것만으로는 해당 원고들이 통상근무 시간에 수행한 업무의 내용이 무엇이었는지, 통상근무와 당직 또는 콜 대기 근무 사이의 근무 밀도 차이가 어느 정도였는지, 자택에서 당직 또는 콜 대기 중 콜을 받으면 몇 분 안에 출근해야 하는지 등을 알 수 없어, 자택에서의 당직 또는 콜 대기 근무시간 전부가 실질적으로 피고의 지휘·감독 아래에 놓여있는 근로시간에 해당하는지, 그중 어느 범위까지 근로시간으로 보아야 하는지를 판단하기 어렵다고 보았다. 이상에서 원심으로서 위와 같은 사항들을 심리하여 원고들의 당직 또는 콜 대기 근무가 내용과 질에 있어서 그 근무시간의 전부 또는 일부를 근로시간으로 볼 수 있는지를 판단하였어야 한다고 보아, 원심판결을 파기·환송한 것이다.

III. 대상판결의 의의

- 대상판결은 당직근무가 본래의 업무가 연장되거나 그 내용과 질이 통상근무의 태양과 마찬가지로 인정되는 경우에는 근로시간에 포함된다고 보아야 하지만, 이와 달리 전체적으로 보아 근무의 밀도가 낮은 대기성의 단속적 업무에 해당하는 경우에는 본래의 업무에 실제로 종사한 시간만 근로시간으로 보아야 한다고 보고, 병원에 소속된 간호사, 임상병리사, 방사선기사 등의 당직 또는 콜 대기 근무 역시 그 구체적 근무 내용과 태양, 질을 평가하여 근로시간 해당 여부를 판단하여야 한다고 판시하였다. 이러한 점을 감안하면 파기환송심의 구체적 판단에 더 귀추가 주목된다. 파기환송심은 당직 및 콜 대기 시간에 수행하는 업무의 내용과 질이 본래의 업무가 연장된 경우에 해당하거나 통상근무의 태양과 마찬가지로 인정되는 여부와 관련하여, 통상의 근무시간의 구속으로부터 완전

히 벗어났는지 또는 통상근무의 태양이 그대로 계속되는지 여부, 본래의 업무에 종사하게 되는 빈도 내지 시간의 장단, 충분한 수면시간이 보장되는지 여부 등을 충분히 심리할 것으로 보인다.

- 근로기준법 제50조 제3항은 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다고 규정하고 있다. 본조에 규정된 대기시간 등의 근로시간 해당 여부가 쟁점이 되는 경우가 많다. 본래적인 일·숙직 근무의 경우와 달리 상당한 정신적 긴장을 늦출 수 없는 상태에서 근무에 투입될 수 있도록 대기하는 시간이 있을 수 있다. 또한 호출되는 경우 근무에 투입될 수 있도록 하되, 상당한 정신적 긴장이라고 평가되기 어려울 정도로 호출되기 전에는 자유로운 장소(예컨대 자택 등)에서 자유롭게 개인적 삶을 영위하는 경우도 있을 수 있다(소위 호출대기). 즉 근무에 투입되기 전에는 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 시간으로 평가될 수 있을지 모호한 경계가 존재한다. 관련하여 독일과 프랑스의 법제도를 잠시 살펴보면 아래와 같다.

- 독일의 경우 근로시간법(Arbeitszeitgesetz)에 대기근로(Bereitschaftsdienst)와 호출대기(Rufbereitschaft)가 규정되어 있기는 하나, 그 정의의 규정이 존재하지 않아 근로시간 해당 여부나 임금지급 여부에 대해서는 판례 및 해석에 의존하고 있다.

- 대기근로(Bereitschaftsdienst)는 일반적으로 업무에 즉시 투입될 수 있도록 사용자에 의해 특정된 장소(사업장 내외 불문)에 머무는 시간을 의미한다. 예컨대 병원에서 야간에 의사가 업무투입이 가능토록 대기하는 공간에서 쉬는 시간을 들 수 있다. 대기근로는 근로자가 체류장소를 자유롭게 선택할 수 없다는 점에서 호출대기와 다르며, 대기 시간에 체류장소를 벗어나지 않는 한 행동의 자유가 있다는 점에서 호출대기와 유사성도 있다. 독일의 경우 대기근로를 근로시간으로 보지만 그 보수에 있어서는 개별 및 집단계약을 통해 통상의 근로에 비해 낮은 수준의 보수 지급이 가능하다. 호출대기(Rufbereitschaft)는 대기장소를 근로자가 자유롭게 선택하면서 업무호출이 있기 전에는 자유로운 생활이 가능하다는 특징이 있다. 일반적으로 근로자는 핸드폰을 켜 놓고 호출이 있을 경우 업무에 투입된다. 국내에서도 반도체 장비 등의 장애가 발생 시 기술인력이 투입되기 위해 호출대기 상태에 있는 경우가 있다. 국내에서 실무적으로는 실제 업무에 투입되기 위한 이동한 시간, 투입된 시간 등은 시간외근로로 간주하고 있지만 호출대기 시간 그 자체는 근로로 간주하지 않고 별도의 보수도 지급되고 있지 못해 이에 대한 일정한 보수 지급 요구가 있기도 하다. 독일의 경우 호출대기 시간 그 자체는 근로시간으로 간주되지 않는다. 다만 별도의 보수는 단체협약 등으로 정할 수 있다. 한편 10~20분 거리 이내에서 호출대기토록 하고 즉시 투입토록 한다면 이는 대기근로이지 호출대기가 아니다.

- 프랑스의 경우 노동법전 제L3121-9조에서 호출대기에 관해 규정하고 있다. 호출대기시간은 임금노동자가 근무지에 머무르지 않으며 사용자에게 대해 상시적이고 즉각적인 대기상태를 유지하지 않는 시간으로, 임금노동자는 기업을 위하여 업무 완수에 필요한 활동을 개시할 수 있어야 한다. 이러한 활동을 개시하는 시간은 실근로시간으로 본다. 호출대기시간은 금전적 형태나 휴가 형태로의 보상 대상이다. 호출대기시간과 관련이 있는 임금노동자는 적절한 기간 내에 개별 근무시간표를 제공받는다. 호출대기에 들어간 이후 활동을 개시하는 시간은 실근로시간이다. 그러나 대기시간은 실근로시간으로 보지 않는다. 다만, 노동법전 제L3121-9조에서와 같이 금전적 형태나 휴가(휴식) 형태로의 보상을 일반적으로 단체협약으로 정한다. 노동법전 제L3121-11조에서도 기업이나 기관의 협약이나 합의 또는 이러한 협약이나 합의가 없는 경우 산별협약이나 합의에 따라 호출대기를 실행할 수 있다. 호출대기의 조직방법, 정보 제공 방식 및 해당 임금노동자에 대한 사전 예고기간 그리고 호출대기에 따른 금전적 형태나 휴가 형태의 보상에 관한 규정은 이러한 협약이나 합의로 정한다.고 규정하고 있다.

- 대상판결은 당직 및 콜 대기 시간에 수행하는 업무의 내용과 질이 본래의 업무가 연장된 경우에 해당하거나 통상근무의 태양과 마찬가지로 인지의 여부와 관련하여, 통상의 근무시간의 구속으로부터 완전히 벗어났는지 또는 통상근무의 태양이 그대로 계속되는지 여부, 본래의 업무에 종사하게 되는 빈도 내지 시간의 장단, 충분한 수면시간이 보장되는지 여부 등을 충분히 심리해야 한다고 보았다. 간략히 표현한다면 상당한 정신적 긴장을 늦출 수 없는 상태에서 바로 근무에 투입될 수 있도록 대기하는 시간으로 평가될 수 있는지, 아니면 상시적이고 즉각적인 대기상태를 유지하지 않고 업무호출이 있기 전에는 자유로운 생활이 가능할 정도의 대기인지 여부를 심리해야 한다는 것이다.

- 한편으로 대상판결이 충분한 심리를 촉구한 것은 이러한 대기시간들이 근무시간과 자유시간 사이에 존재하는 시간일 수 있는바, 전적으로 근로시간으로 보고 근로기준법상 시간외 보상을 고집할 것이 아니라 노사 자율적 합의에 의한 보상이 가능하도록 법제도 개선이 필요함을 제기하는 것은 아닐까 하는 평가를 해 본다.

<도구 개념으로서의 소정근로시간> **대법원 2024.12.26. 선고 2023다200314 판결**

【판결 요지】

- 소정근로시간은 ... **근로기준법**상 연장근로수당 등을 산정하기 위한 전제가 되는 통상임금의 계산, 최저임금법상 비교대상 임금의 시간급 환산, 근로자퇴직급여 보장법상 퇴직금 제도의 설정의무 준보 결정 등을 위해 필요한 도구 개념의 성격을 갖는다. ... 이러한 소정근로시간의 의의와 기능 등을 고려하면, 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 소정근로시간에 관한 유효한 정함이 없는 경우 법원은 최저임금 미달 여부 및 미달액 판단 등을 위해 근로관계 당사자들의 의사를 보충하여 근로계약을 해석하는 방법으로 유효한 소정근로시간을 확정할 필요가 있다.

I. 쟁점 및 사실관계

- 위 판결 요지의 핵심은 한마디로 도구 개념으로서의 소정근로시간은 반드시 확정할 필요가 있다는 것이다. 대상판결은 택시기사의 소정근로시간에 관한 것인데, 소정근로시간 확정 방법은 근로자의 직종마다 다를 수 있겠지만, 소정근로시간 확정의 필요는 다른 직종에도 적용될 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다. 위 판결 요지는 앞선 **대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다206138 판결**(이하 '부천택시 대법원 판결')이 처음 기본법리로 제시한 후, 대상판결이 재확인하였다. 대상판결의 사실관계와 판단을 본 후, 위 판결 요지의 의미를 짚어본다. A회사(피고)는 진주시의 택시회사이다. 택시기사 甲·乙(원고들)은 A회사에서 정액사납금제 형태로 근무하다 2019년 및 2020년에 퇴직했다. 甲·乙은 법정 최저임금 미달액과 그에 따른 퇴직금 차액을 청구하였다. 최저임금액에 산입되는 임금(이하 '비교대상임금')에 생산고에 따른 임금을 제외한 개정 **최저임금법**이 2010. 7. 1. 진주시에 시행되었다. 이에 A회사와 노동조합은 아래처럼 소정근로시간을 정하는 임금협정을 체결하였다. 한편 법정 최저임금은 매년 인상되었음에도, 2014년부터 2019년까지의 임금협정의 고정급(즉, 비교대상임금)은 그 전 임금협정의 고정급과 동일하였다.

	2010	2014	2017	2019
1일 소정근로시간	3.5시간	3.5시간	2.5시간	2시간

- 원고들은 자신의 1일 소정근로시간은 8시간이라고 주장하며, 최저임금 미달액과 퇴직금 차액을 청구하였다. 최저임금 미달 여부 판단을 위해서는, 우선 비교대상임금을 시간급으로 환산하기 위한 소정근로시간의 확정이 필요하다. 주된 쟁점은 택시기사의 소정근로시간 수이다.

II. 판결 내용

- 1심 판결은 먼저 2019년 전원합의체 판결의 법리에 따라 A회사와 노동조합이 체결한 위 임금협정상 소정근로시간 단축 합의는 강행법규 잠탈을 위한 탈법행위로서 모두 무효라고 하였다. 이 판단 부분은 이견이 없다(대상판결도 이 부분은 그대로 인정하였다). 문제는 임금협정상 소정근로시간 합의가 무효인 경우, 원고들에게 적용되는 소정근로시간 수이다.

- 1심 판결은 2010년 임금협정 이전 합의된 소정근로시간을 기준으로 하여야 하는데, 2010년 임금협정 이전 A회사와 노동조합 사이에 소정근로시간을 정한 단체협약이나 임금협정에 관한 자료가 전혀 제출되지 않았고, 원고들이 주장하는 1일 8시간의 소정근로시간을 인정할 수 없다며, 이 사건에서는 소정근로시간의 확정을 전제로 하는 비교대상 임금을 산정할 수 없어, 피고가 원고들에게 추가적으로 지급하여야 할 금액을 구할 수 없다고 판단하였다. 그 결과 원고들의 청구를 모두 기각하였다.

- 2심 판결(대상판결의 원심)도 1심 판결을 그대로 인정하여 원고들의 항소를 모두 기각하였다. 반면 대상판결은 원심이 원고들에게 적용되는 소정근로시간을 확정할 수 없다는 이유로 원고들의 청구를 기각한 것은 수긍하기 어렵다며, 원심로서는 피고가 그 전의 소정근로시간에 관한 문서들을 보관하고 있지 않다고 주장한다거나 원고들의 증거가 미흡하다는 등의 이유만으로 원고들의 최저임금 청구를 쉽게 배척할 것이 아니라 ... 원고들과 피고의 의사를 보충하여 근로계약을 해석하는 방법으로 원고들에게 유효한 소정근로시간을 확정할 다음, 이를 바탕으로 최저임금 미달액 등을 산정하여야 한다.는 이유로 원심 판결을 파기하였다.

- 앞선 부천택시 대법원 판결도 원고들이 주장하는 1일 소정근로시간(8시간 또는 6시간 40분)을 인정할 수 없어 미지급 최저임금과 미지급 퇴직금 청구를 모두 기각한 원심 판결을 파기하며, 원고들과 피고의 의사를 보충하여 근로계약을 해석하는 방법으로 소정근로시간을 확정할 필요가 있다고 판단하였다.

- 부천택시 대법원 판결과 대상판결은 도구 개념으로서의 소정근로시간은 반드시 확정할 필요가 있다는 법리를 제시하였고, 택시기사의 소정근로시간 확정의 방법으로 근로관계 당사자들의 의사를 보충하여 근로계약을 해석하는 방법을 제시하였다.

III. 소정근로시간의 두 기능 : 본질적 기능과 도구 기능

- 대상판결 사안에서는 최저임금법상 비교대상 임금의 시간급 환산을 위하여 소정근로시간이란 도구가 필요하였다. 이 외에도 소정근로시간은 시간당 통상임금 계산, 1주 소정근로시간 15시간 여부에 따른 퇴직급여·주휴수당·연차수당의 적용 여부 판단 시에도 도구로 사용된다.그러나 유의할 것은, 소정근로시간은 도구 개념이다라는 명제는 성립하지 않는다. 소정근로시간은 크게 두 가지 기능을 갖기 때문이다. 하나는 본질적 기능이고, 다른 하나는 도구 개념으로서의 기능이다.

- 첫째, 소정근로시간의 본질적 기능은 근로계약 당사자 쌍방에게 가장 기본적으로 중요한 의무를 설정하는 것이다. 근로자는 소정근로시간에 대한 근로제공의무를 부담한다. 소정근로시간을 초과하는 근로는 거부할 권리가 있다. 한편 사용자는 임금지급의무뿐만 아니라 소정근로시간만큼의 일감을 제공할 의무가 있다. 사용자의 귀책사유로 일감을 제공하지 못하는 경우 근로제공이 없어도 임금 전액 또는 휴업수당을 지급해야 한다. 이러한 본질적 기능에서 소정근로시간은 그 자체가 근로조건이다.

- 둘째, 소정근로시간의 도구 기능은 다른 근로조건(퇴직금, 주휴수당, 연차수당, 시간당 통상임금액, 비교대상임금의 시간급액 등)을 위한 것이다. 이때 소정근로시간은 그 자체가 근로조건은 아니다. 다른 근로조건을 위한 도구일 뿐이다. 비유하면 다른 근로조건이 몸통이라면, 도구개념으로서의 소정근로시간은 꼬리이다. 유효한 소정근로시간의 명시적 약정이 있는 전형적 근로자의 경우(소정근로시간이 확정되어 있는 경우)에는 주로 본질적 기능과 관련된 분쟁 양상이 나타난다. 부당해고 기간의 임금지급이나 사용자 귀책사유로 인한 휴업 시 수당 지급 여부 등이다. 반면 소정근로시간의 명시적 약정이 없거나 불분명한 비전형적 근로자(특수고용노동자, 호출노동자, 대학시간강사, 택시기사 등)의 경우에는, 다른 근로조건을 위한 도구 개념으로서의 소정근로시간의 확정이 우선적인 쟁점이 된다. 대상판결은 소정근로시간의 도구 기능과 관련된 것이다.

IV. 도구 기능에서 소정근로시간 확정의 필요 및 방법

- 부천택시 대법원 판결과 대상판결의 원심 판결들은 모두 소정근로시간을 확정할 수 없다고 하여 원고들의 청구를 기각하였다. 즉, 꼬리(도구인 소정근로시간) 때문에 몸통(최저임금 미달액과 퇴직금 차액 청구)을 날린 셈이다. 그러나 대상판결은 도구 개념으로서의 소정근로시간은 반드시 확정할 필요가 있다는 법리를 명확히 제시하였다. 이것의 의미는, 도구 개념으로서의 소정근로시간은 없을 수 없다(0시간이 될 수 없다)는 것이다. 이는 도구 개념인 통상임금과 평균임금이 없을 수 없다(0원이 될 수 없다)는 것과 같은 이치이다. 그리고 대상판결은 택시기사의 소정근로시간을 확정하는 방법(근로관계 당사자들의 의사를 보충하여 근로계약을 해석하는 방법)을 제시하였다. 이전에 대법원은 대학시간강사의 소정근로시간은 업무를 수행하는 데 통상적으로 필요한 근로시간 수를 기준으로 판단하여야 한다며 그 확정 방법을 제시한 바 있다. 소정근로시간의 확정 방법은 근로자의 직종마다 다를 수 있겠지만, 대학시간강사가 주휴수당과 연차

수당을 청구한 사건(1주 15시간 미만 여부가 쟁점)에서도 도구 개념으로서의 소정근로시간을 확정할 필요가 있다는 점은 동일하다. 한편 주휴수당·연차수당을 위한 출근율 산정과 관련된 소정근로일도 도구 개념이다. 이와 관련하여 특수고용노동자인 정수기 기사가 퇴직금과 연차수당을 청구한 사건에서, 대법원은 (근로자성 인정 후, 퇴직금은 인용했지만) 소정근로일을 정하여 근로했다는 사실을 인정하기에 부족하다며 연차수당 청구를 기각한 바 있다. 또한 호출노동자인 아이돌보미가 주휴수당·연차수당을 청구한 사건에서, 대법원은 아이돌보미의 근로자성을 부정한 원심 판결을 파기하였으나, 파기환송 판결은 소정근로일을 정하였다고 인정하기에 부족하다며 주휴수당·연차수당 청구를 기각하였다. 이 판결들 역시 꼬리(도구인 소정근로일) 때문에 몸통(주휴수당·연차수당 청구)을 날린 셈이다. 비전형적 근로자(특수고용노동자, 호출노동자, 대학시간강사, 택시기사 등)의 특징은 소정근로시간 등의 명시적 약정이 없거나 불분명하다는 것이다. 그러나 이들도 근로기준법상 근로자인 이상 최저임금액 이상의 임금, 퇴직금, 주휴수당, 연차수당 등의 근로조건이 적용되어야 함은 물론이다. 이러한 근로조건을 위해서 도구 개념으로서의 소정근로시간은 반드시 확정되어야 한다. 비전형적 근로자의 특징은 소정근로시간 등을 명확히 정하지 않는다는 것이므로, 근로기준법 제2조 제1항 제8호의 근로자와 사용자 사이에 정한 근로시간이란 소정근로시간의 정의규정에 지나치게 엄매일 필요 없이, 좀 더 유연한 방법으로 실질적인 소정근로시간을 확정해야 한다. 애초에 비전형적 근로관계에서는 근로자와 사용자가 정한 근로시간이 없거나 불분명하기 때문이다.

<대학교 강사의 강의시간 외 부수업무 시간까지 포함하여 주당 근로시간을 해석한 사례> 전주지방법원 2025.07.17. 선고 2022가합52925 판결

【판결 요지】

- 대학 부속기관인 한국어센터에서 외국인들에게 한국어교육을 하는 한국어 시간강사들의 실제 주당 근로시간은 이 사건 근로계약에서 정한 주당 강의시수만이 아니라, 학사업무처리 및 학생지도 등의 부수업무 시간까지 포함하여 그 1.7배에 해당하는 시간으로 봄이 타당하다. 그 결과가 주당 근로시간이 15시간 이상이라면, 원고들은 해당 기간에 있어서는 초단시간근로자가 아니어서 유급휴일에 따른 수당, 미사용 연차에 대한 수당, 퇴직금을 지급받을 권리가 있다.

I 사안의 개요

- 대상판결의 원고들은 대학의 한국어센터에서 외국인(유학생 등)들을 대상으로 한국어 강의를 하는 강사들로 P대학교 한국어센터에서 근로하다 퇴직한 자들이다. 원고들은 피고에게 유급휴일에 따른 수당, 미사용 연차에 대한 수당, 퇴직금을 청구하였다.
- 피고(P대학교 국제교류원장)와 원고들은 약 10주 단위로 근로계약(이하 이 사건 근로계약이라 한다)을 체결하면서 주당 강의시수를 15시간 미만으로 정하였다. 피고는 이 사건 한국어센터의 한국어강사로 근무하는 원고들을 근로기준법 제18조 제3항, 근로자퇴직급여 보장법 제4조 제1항 단서에서 정하는 초단시간근로자로 보아 유급휴일·유급휴가를 주지 않고, 퇴직급여도 지급하지 않았다. 피고는 원고의 청구에 대해 이 사건 근로계약서에 기재된 주당 강의시수가 모두 15시간 미만이고 원고들이 강의 업무 외에 다른 업무를 수행하였다고 볼 수 없다는 점을 전제로 그러한 돈을 지급할 의무가 없다고 주장하였다.
- 이 사건 근로계약서에는 계약기간, 주당 강의시수, 임금(강사료)은 계약기간 중 실제 강의한 시간에 대한 시간당 강사료를 지급한다는 내용, 강사료는 강의료와 강의를 담당함에 따라 발생하는 학사업무처리 및 학생지도에 대한 보수를 포함한 것으로 본다는 내용, 주휴일과 연차 유급휴가에 대해서는 적용하지 않는다는 내용 등(시기 내지 개인별로 계약 내용에 세부적인 차이는 있으나 위와 같은 취지는 모두 포함되어 있다)이 기재되어 있다.
- 대상판결에서 원고들은 실제로는 강의시수에 따른 강의업무 외에 강의준비, 학생관리, 학생상담, 교재집필, 미니워크숍, 한국어능력시험 대비, 진학 관련, 각종 행사 준비 및 참석 등을 하였고, 그에 따른 추가 업무시간은 강의시간 1시간당 0.7시간(70%) 정도임을 주장하였다.

II 대상판결의 주요 내용과 의의

- 대상판결은 먼저 대법원 2024.7.11. 선고 2023다217312 판결의 아래 판시 내용을 참고할 관련 법리로 들고 있다.
- 대학의 시간강사는 학교가 개설한 교과목의 강의를 담당하면서 그에 수반되는 학사관리업무 등을 수행하고, 그와 같은 업무수행의 대가로 통상 시간당 일정액에 강의시간 수를 곱한 강사료를 보수로 지급받는다. 대학의 시간강사가 초단시간근로자에 해당하는지 여부는 특별한 사정이 없는 한 강의시간 수가 아니라 강의와 그에 수반되는 업무, 그 밖에 임금계약 등에서 정한 업무를 수행하는 데 통상적으로 필요한 근로시간 수를 기준으로 판단하여야 한다. 대학 강의의 특성상 강의 외 업무에 상당한 시간이 필요하기 때문에 강의시간의 정함이 곧 소정근로시간을 정한 것이라고 볼 수 없다. 만약 시간강사가 대학에 근로를 제공할 의무를 부담하는 전체 시간이 강의시간을 초과하는 것이 분명한데도 강의시간만을 기준으로 초단시간근로자 여부를 판단하게 되면, 근로자에게 주휴와 연차휴가를 보장하되 근로시간이 매우 짧아 사업장에 대한 전속성이나 기여도가 낮고 임시적이고 일시적인 근로를 제공하는 일부 근로자에 대해서만 예외적으로 주휴와 연차휴가에 관한 규정의 적용을 배제하려는 근로기준법의 취지가 몰각되기 때문이다.
- 다음으로 대상판결은 대학교 내 부설기관인 한국어센터 한국어 강사들의 근로계약서에 기재된 주당 강의시수에도 불구하고 주당 근로시간을 그 이상으로 인정할 수 있다고 보았다. 그 주된 이유는 첫째, 원고들의 주된 업무는 한국어 미숙련자에게 한국어강의를 하는 것이지만, 피고의 주도로 주요 내용이 정해졌음이 분명한 이 사건 근로계약에 의하더라도 원고들의 업무에는 학사업무처리 및 학생지도 등이 포함되는 등, 원고들의 업무는 한국어강의에 한정되지 않았다는 점, 둘째로 원고들이 수행하였다고 주장하는 부수업무는 원고들과 같은 한국어강사들이 통상 수행하였으리라고 볼 수 있는 것인데, 이는 국내 대학교 부속 한국어교육기관에서 재외동포와 외국인에게 한국어와 한국문화를 가르치는 한국어교원의 근로조건과 실태를 파악하기 위한 연구 결과인 『한국어교원 처우 개선을 위한 법·제도 개선 방안 연구』, 『대학 부속 한국어교육기관 한국어교원의 근로 실태』와도 부합한다는 점 등이다.
- 대상판결은 아래와 같은 사정들을 종합해 보면, 원고들의 주당 강의시수 외 부수업무 시간까지 포함하여 주당 근로시간을 강의시수의 1.7배로 보는 것이 타당하다고 보았다. 즉 부수업무 수행시간은 강의시간 1시간당 0.7시간(70%)으로 산정하였다.
- 첫째, 원고들의 부수업무 수행시간은 사실 인정의 문제인데, 이를 원고 개개인마다 명확하게 확정하는 것은 불가능하고, 법원이 여러 사정을 아울러 참작해 정할 수밖에 없다. 둘째, 『대학 부속 한국어교육기관 한국어교원의 근로 실태』에 의하면, 4시간 수업을 기준으로 강의 외 업무를 처리하는 데 필요한 시간은 평균 2.8시간(70%)으로 나타난다. 위 문헌의 연구 대상은 원고들과 같은 대학 부속 한국어교육기관의 한국어교원이고, 위 문헌에서 언급한 강의 외 업무와 이 사건에서 원고들이 수행한 부수업무의 내용에도 별다른 차이가 없고, 또한 이와 같이 부수업무에 소요되는 시간을 70% 수준으로 파악하는 것은 경험칙상으로도 합당하다고 보인다. 셋째, 피고는 이 법원의 촉구에도 불구하고 별다른 반대 증거를 제출하지 않았다.
- 결론적으로 대상판결은 원고들의 실제 주당 근로시간은 이 사건 근로계약에서 정한 주당 강의시수가 아니라, 그 1.7배에 해당하는 시간으로 보았다. 만일 그 결과가 15시간 이상이라면, 원고들은 해당 기간에 있어서는 초단시간근로자가 아니어서 유급휴일에 따른 수당, 미사용 연차에 대한 수당, 퇴직금을 지급받을 권리가 있다.
- 대상판결은 1심 판결로 이후 항소가 제기되지 않아 확정되었다는 한계가 있지만, 대학교 내 부설기관인 한국어센터 한국어 강사들의 근로계약서에 기재된 주당 강의시수에도 불구하고 주당 근로시간을 그 이상으로 인정할 수 있는지, 그 이상으로 인정할 수 있다면 부수업무 수행시간이 얼마인지, 근로기준법상 초단시간 근로자가 아니어서 유급휴일에 따른 수당, 미사용 연차에 대한 수당, 퇴직금을 지급받을 권리가 있는지 등에 대해 판단하였다는 점에서 관련 유사 사안에 있어 참고할 중요한 선례가 될 수 있다.
- 한편 대상판결은 강사들인 원고들의 부수업무 수행시간은 사실 인정의 문제인데, 이를 원고 개개인마다 명확하게 확정하는 것은 불가능하고, 법원이 여러 사정을 참작해 정할 수밖에 없다고 보았다. 이에 따라 원고들의 주장 내용과 입증자료, 『대학 부속 한국어교육기관 한국어교원의 근로 실태』를 바탕으로 법원이 부수업무 수행시간을 강의시간 1시간당 0.7시간(70%)으로 산정하였다. 한국어 강사들의 근로계약서에 기재된 주당 강의시수만으로는 소정근로시간을 정한 것으로 볼 수 없기 때문에 실제로 기초한 합리적 소정근로시간을 법원이 정한 것 또는 보충적으로 해석한 것으로 볼 수 있을 것이다.

III 이어지는 의문:소정근로시간을 정한 경우

- 대상판결이 실제 근로실태 조사 내용과 한국어 강사들의 주장·입증자료를 종합적으로 고려하여 실제로 기초한 합리적 소정근로시간을 정하거나 또는 보충적으로 해석한 것은 충분히 의미가 있지만, 여전히 이어지는 의문이 있다. 예컨대 주당 강의시수는 9시간, 기타 부수업무 시간은 주당 강의시간의 50%로 하면서 주당 강의시수와 부수업무 시간의 합을 소정근로시간으로 근로계약서에 정한 경우이다. 이러한 경우는 소정근로시간을 주당 13.5시간으로 정하는 당사자간의 의사합치가 이루어졌다는 점에서 소정근로시간을 정한 바 없는 대상판결 사례와는 다르다. 물론 법원은 주당 강의시수의 50%로 정한 부수업무 시간이 그 실질과 비교하여 현저히 적다고 판단되는 경우에는 근로기준법을 참탈하는 것으로 무효로 판단할 수도 있을 것이다. 그러나 일정 수준과 내용의 부수업무 시간 합의는 당사자 간 의사합치이므로 이를 즉시 무효로 보기는 어려울 것으로 보인다. 대학이 강사들의 부수업무 시간이나 부수업무 내용을 실제 축소하고, 근로계약 내용의 취지에 맞게 운영조차 노력하였다면 대학의 상당한 지휘감독 없이 행해진 일부 강사들의 초과된 부수업무 시간으로 인해 당해 계약상 소정근로시간 합의가 근로기준법을 참탈하는 것으로 평가되기는 어려울 수 있다. 결국 한국어 강사의 소정근로시간 문제는 근로계약상 소정근로시간에 대한 합의 여부와 주당 강의시수 외 사용자의 상당한 지휘감독하에 행해지는 근로로 볼 수 있는 통상적인 실제 부수업무 시간 확정 문제라고 하겠다.

<연차유급휴가 시기변경권 행사의 적법성 판단기준> 대법원 2025.07.17. 선고 2021도11886 판결

【판결 요지】

- 사용자가 적법하게 연차유급휴가 시기변경권을 행사할 수 있는 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 해당하지 여부는 근로자가 담당하는 업무의 내용과 성격, 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무인원과 업무량, 근로자의 휴가 청구 시점, 대체근로자 확보의 필요성 및 그 확보에 필요한 시간 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

I. 대법원 판결의 배경

- 사용자는 연차유급휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하지만(근로기준법 제60조 제1항 및 제5항 본문), 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다(제60조 제5항 단서). 원래 근로제공의무가 있던 날에 근로자의 신청에 의해 그 의무를 면제하는 휴가제도의 특성상 근로자가 원하는 날짜에 연차휴가를 사용하게 되면 사업 운영에는 어느 정도 어려움이 있을 수밖에 없으나, 사용자에게는 연차유급휴가의 부여 의무가 있으므로 통상적인 경우라면 이를 수인하여야 한다. 다만 사용자는 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 한하여 그 시기를 변경할 수 있을 뿐인데, 연차유급휴가 시기변경권 행사가 적법한지를 판단하는 기준에 대해서 그간 몇 건의 하급심 판결이 선고되기는 하였으나, 대법원이 구체적인 법리를 직접 제시한 적은 없었다. 그러나 최근 선고된 대법원 2025.7.17. 선고 2021도11886 판결(이하 대상판결)은 연차유급휴가 시기변경권 행사의 적법성을 판단하는 기준을 최초로 제시하여, 학계와 실무의 많은 주목을 받고 있다.

II. 사실관계

- 대상판결의 사실관계와 사건의 경과는 다음과 같다. 피고인인 이 사건 사용자는 상시근로자 300명을 고용하여 부산에서 시내버스 회사를 경영하는 사람으로, 이 사건 회사의 승무운전직은 지정된 노선의 버스를 운전하는 전속승무원 및 전속승무원이 휴무 등으로 결근할 경우 대신 투입되는 예비승무원으로 구성되어 1일 2교대(오전·오후)로 버스를 운행한다. 한편, 이 회사가 속한 사용자단체인 부산광역시 버스운송사업조합과 교섭대표노동조합인 전국자동차노련 부산지역버스노동조합이 체결한 단체협약에서는 '근로자는 휴가신청을 3일 전에 서면으로 제출하여야 한다'라고 규정하고 있었다.

- 전속승무원인 이 사건 근로자는 2019.7.5.(금) 오후 시내버스를 운행하던 중 회사의 관리과장에게 전화하여 '7. 8.(월) 오후 휴가를 사용하겠다'고 말하였으나, 관리과장은 해당 일시에 휴가를 사용할 수 없다고 답변하였다. 이때 회사의 7. 8.차 배차표에는 휴무 등으로 결근이 예정되어 있는 근로자들 외에 예비승무원을 비롯하여 해당 노선 차고지의 나머지 승무원은 모두 버스를 운행하는 것으로 예정되어 있었는데, 근로자는 7. 8. 오후에 출근하지 않았고 결국 해당 노선의 버스 중 1대가 추가로 운휴하게 되었다.

- 이에 검사는 피고인이 단체협약을 근거로 근로자에게 연차유급휴가를 부여하지 아니하였다는 이유로 피고인을 근로기준법 위반죄로 기소하였으나, 1심과 원심은 범죄의 증거가 없을 뿐만 아니라 피고인에게 근로기준법 위반의 고의가 있었다고 단정하기도 곤란하다는 취지로 무죄를 선고하였고, 이러한 원심판결에 대해 검사 측이 상고하여 대법원의 판단을 받게 되었다.

III. 판결의 내용

- 대상판결이 제시한 법리는 크게 세 부분으로 나누어 볼 수 있다. 먼저 연차유급휴가 시기지정권의 성격과 관련하여, 대상판결은 근로자의 연차유급휴가권은 근로자가 시기를 지정하여 청구하면 사용자의 적법한 시기변경권 행사를 해제조건으로 구체적으로 실현되는 것임을 재확인하면서, 근로기준법 제60조 제5항 위반죄는 근로자가 연차유급휴가에 대하여 시기를 지정하여 그 청구를 하였음에도 불구하고 사용자가 적법한 시기변경권을 행사하지 아니한 채 근로자의 연차유급휴가를 방해한 경우에 성립한다는 점을 확인하였다.

- 또한 대상판결은 근로기준법 제60조 제5항 단서에서 말하는 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 해당하지 여부는 ① 근로자가 담당하는 업무의 내용과 성격, ② 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무인원과 업무량, ③ 근로자의 휴가 청구 시점, ④ 대체근로자 확보의 필요성 및 그 확보에 필요한 시간 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다는 법리를 새로이 제시하였다.

- 나아가 대상판결은 이러한 법리를 노선 여객자동차운송사업과 같이 운영의 정시성이 중요한 사업과 관련하여 적용하는 경우에 특별히 고려하여야 할 점을 추가로 제시하였다. 먼저 해당 사업에서는 대체근로자를 확보해야 할 필요성이 크다고 할 것이므로, 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우인지는 근로자가 지정한 휴가 시기까지 대체근로자를 확보하는 것이 객관적으로 어려운 상황인지 여부를 중심으로 판단하여야 한다고 보았다. 나아가 해당 사업과 관련하여 단체협약에서 근로자의 휴가 청구에 관한 기한을 정하고 있는 경우 그 기한은 대체근로자 확보 등에 소요되는 합리적인 기간에 관하여 노사가 합의한 결과물이라고 볼 수 있으므로, 그로 인해 근로자가 불가피한 사유로 그 기한을 준수하지 못한 경우까지 휴가에 관한 권리가 제한된다고 해석되지 않는 이상 가급적 존중되어야 하며, 따라서 근로자가 불가피한 사유 없이 그 기한을 준수하지 않고 휴가를 청구하는 것은 객관적인 관점에서 사용자가 지정된 휴가 시기까지 대체근로자를 확보하는 데에 어려움을 발생시켜 그 사업 운영에 막대한 지장을 주는 경우에 해당한다고 봄이 상당하므로, 사용자는 특별한 사정이 없는 한 근로기준법 제60조 제5항에 따라 적법하게 시기변경권을 행사할 수 있다고 보아야 한다는 법리를 제시하였다.

- 결론적으로 대상판결은 피고인의 연차유급휴가 시기변경권 행사는 적법하므로, 피고인에 대해 근로기준법 제60조 제5항 위반죄가 성립한다고 볼 수 없다고 보아 검사의 상고를 기각하였다. ① 먼저 업무의 내용과 성격 및 대체근로자 확보의 필요성 측면에서 노선버스 운행의 특성상 이 사건 근로자가 지정한 휴가일에 휴가를 부여하면 피고인으로서 배차간격 유지를 위해 대체근로자를 확보해야 한다는 점을 인정하였고, ② 나아가 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무인원과 업무량 및 대체근로자 확보의 객관적 어려움에 있어서 해당 일자에 나머지 승무운전직 중 대체근로가 가능한 사람은 없었고, 연장근로를 통해 대체근로자를 확보하기도 어려웠다는 점을 인정하였다. ③ 또한 근로자의 휴가 청구 시점 및 대체근로자 확보에 필요한 시간과 관련해서는 노사가 단체협약을 통해 설정한 휴가 청구에 관한 기한은 대체근로자 확보에 통상적으로 필요한 기간으로서, 3일이라는 기한은 근로자의 시기지정권을 박탈한다고 볼 수 있을 정도의 장기간이 아니라 사용자가 시기변경권을 적절하게 행사하기 위해 필요한 합리적인 기간이라고 볼 수 있고, 근로자에게 기한을 준수할 수 없었던 불가피한 사정이 있었는지도 확인되지 않는다고 하였다.

IV. 판결의 해석

- 대상판결에서 제시한 법리가 구체적 사건에서 앞으로 어떻게 적용될지는 후속 판결들을 지켜보아야 하겠지만, 여기에서는 우선 몇 가지 사항에 대해 언급하고자 한다.

- 먼저 법 문언상 사용자의 시기변경권 행사가 적법하려면 사업 운영에 막대한 지장이 있어야 하므로, 그 시기변경권 행사의 적법성은 엄격하게 판단되어야 한다. 특히 그 판단요소 중 핵심이 되는 대체근로자 확보의 필요성이란 그에 상응하는 사용자의 대체근로자 확보 의무가 있다는 의미로서, 이러한 의무를 사용자가 이행하는 데 충분한 시간이 주어졌는지를 그 시기변경권 행사의 적법성 판단에 고려하라는 취지로 이해되어야 한다. 그리고 연차유급휴가 시기변경권 행사가 적법하였다는 점에 대한 증명책임은 형사사건이 아닌 이상 이를 주장하는 사용자 측이 부담하여야 하고, 이는 단지 사용자의 주관적 관점에서 막대한 지장이 발생할 개연성이 있다는 정도를 넘어 객관적 관점에서 구체적으로 증명되어야 할 것이다.

- 또한 대상판결은 근로자가 연차유급휴가 시기 지정을 3일 전에 하도록 한 이 사건 단체협약 규정이 강행법규를 위반하여 무효인지에 대해서는 명시적으로 판단하지 않았다. 다만 운영의 정시성이 중요한 시내버스 운송사업의 특성을 고려할 때 노사가 합의한 결과물은 가급적 존중되어야 한다고 하면서, 그 준수 여

부를 대체근로자 확보의 어려움 및 확보에 필요한 시간이 확보되었는지를 판단하는 요소로서 활용하였는데, 이러한 판시가 노사의 합의로 체결된 단체협약이 아니라 사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙에서 휴가 청구 기한을 정하고 있는 경우에도 적용되는지, 나아가 노선버스 운송업이 아닌 다른 사업에서도 고려될 수 있는 것인지는 후속 판결들을 통해 구체화되어야 할 것이다.

- 한편, 대법판결에서 재확인하였듯 연차유급휴가는 근로자가 시기를 지정하여 그 청구를 하면 사용자가 적법한 시기변경권 행사를 해제조건으로 그 구체적 권리가 발생하는 것이지, 사용자의 승인이라는 정지조건이 있어야 효력이 생기는 것이 아니다. 따라서 사업장에서 연차유급휴가 사용과 관련하여 일정 기한 이전에 사용자의 사전 승인을 받도록 하는 규정을 두고 있다고 하더라도, 이는 사용자에게 유보되어 있는 시기변경권을 적절하게 행사하는 데 필요한 사항을 정해둔 것으로만 이해되어야 한다.

- 대법원은 검사 측의 상고제기 후 약 4년 동안 사안의 해결방안에 대해서 고심했던 것으로 보인다. 그 과정에서는 앞서 살펴본 것처럼 법리적으로 검토가 필요한 쟁점도 많았겠지만, 새롭게 제시한 법리가 앞으로 노동현장에 미칠 영향에 대해서도 많은 고민을 했을 것으로 보인다.

- 우리나라 근로자들의 연차유급휴가 소진율은 약 70%로 나타나고 있다. 그 원인이 무엇인지에 대한 최근의 설문조사에서는 대체인력 부족(14.1%), 상사의 눈치와 조직 분위기(12%), 작업 일정에 맞추다 시기를 놓침(10.4%), 업무량 과다(9%), 업무 특성상 협업 필요(7.2%) 등 업무 관련 상황상 휴가를 사용하기가 어렵다는 응답이 전체의 과반수 이상이었고, 원활한 휴가 사용을 위한 조건이 무엇인지를 묻는 설문에서는 직장 내 휴가 사용의 자유로운 분위기가 41.9%로 가장 높게 나타났다. 이처럼 많은 사업장에서 연차유급휴가의 자유로운 사용이 쉽지 않은 실정인데, 이는 많은 기업에서 근로자가 한 명이라도 빠지면 업무가 제대로 돌아갈 수 없을 정도로 유지인력을 최소화하는 경영전략을 취하고 있는 데서 발생하는 문제로 평가할 수 있다.

- 이와 관련하여 대법판결에서 승무운전직 인원이 만성적으로 부족하였는지 여부를 사용자의 시기변경권 행사를 위법하다고 평가할 수 있는 특별한 사정으로서 고려하였다는 점이 눈에 띈다. 만약 사용자가 시기변경권을 수시로 행사해야 할 정도로 만성적인 인력 부족에 시달리고 있는 상황이라면, 이는 사용자가 통상적으로 발생할 수 있는 근로자의 결원에도 대처하기 힘들 정도로 최소한으로 인력을 운용하여 사업 운영의 막대한 지장을 스스로 초래하고 있는 셈이므로, 이러한 경우에만 연차유급휴가 시기변경권 행사가 적법하다고 평가하기는 어려울 것이다. 사업주로서는 이 점을 감안하여 인력 운용계획을 세울 필요가 있고, 인력 확보가 어려운 소규모 사업장에 대해서는 대체인력 활용 지원 등에 대한 정부의 정책적인 대책이 함께 마련되어야 할 것이다.

<취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익한지 여부를 판단하는 방식> **대법원 2025.02.20. 선고 2024다293092 판결**

【판결 요지】

- 취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익한지 여부를 판단할 때 근로조건을 결정짓는 여러 요소 중 한 요소가 불이익하게 변경되더라도 그와 대가관계나 연계성이 있는 다른 요소가 유리하게 변경되는 경우라면 그와 같은 사정을 종합적으로 고려하여야 한다. 근로의 대가인 임금을 구성하는 기본급과 상여수당은 하나의 근로조건을 결정하는 여러 요소 중 비교 가능한 것에 해당하므로 대가관계나 연계성을 쉽게 부정하기 어렵다.

I. 들어가며

- 우리 근로기준법은 사용자에게 취업규칙의 작성 및 신고의무를 부여하고(제93조), 그 작성 및 변경에 대해 근로자들의 의견을 청취하도록 하고 있다(제94조 제1항 본문). 이처럼 취업규칙은 사용자에게 의해 일방적으로 작성되는 것이긴 하지만 일정한 법적 효력이 인정되는데(제97조), 다만 근로조건 대등결정(제4조)의 요청과 기득이익 보호의 필요성 등을 고려하여 취업규칙이 근로자에게 불리하게 변경되는 경우에는 근로자 집단의 동의를 받도록 하고(제94조 제1항 단서), 동의를 얻지 못한 취업규칙의 불이익변경은 원칙적으로 무효가 된다고 본다.

- 이때 취업규칙의 변경이 일부 근로자에게는 유리하지만 일부 근로자에게는 불리한 경우라면 이를 불이익변경으로 볼 것인지(인적 판단), 또한 취업규칙의 여러 규정이 동시에 개정되어 일부 항목은 유리하게 변경되고 일부 항목은 불리하게 변경된 경우에는 어떻게 판단할 것인지(물적 판단)가 문제된다. 전자의 경우에는 전체적 유불리를 객관적으로 평가하기 어려운 이상 불리한 것으로 취급하여 근로자들 전체의 의사에 따라 결정하게 하는 것이 타당하다는 판례법리가 확립되어 있다. 그러나 후자의 경우에는 취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익한지 여부를 판단할 때 근로조건을 결정짓는 여러 요소 중 한 요소가 불이익하게 변경되더라도 그와 대가관계나 연계성이 있는 다른 요소가 유리하게 변경되는 경우라면 그와 같은 사정을 종합적으로 고려하여야 한다는 판례법리가 제시되어 있기는 하지만, 구체적 사건에서 대가관계나 연계성을 검토하여 유불리를 판단하는 것은 결코 쉽지 않은 문제이다. 대법판결은 상여수당이 삭감된 반면 기본급이 인상된 경우, 불이익변경 여부의 물적 판단기준을 어떻게 적용할 것인지가 문제된 사건이다.

II. 사건의 개요와 당사자의 주장

- 피고 학교법인은 A대학교를 설치·운영하여 왔는데, 법인의 정관에서는 대학교원의 보수는 자격과 경력 및 직무의 곤란성과 책임의 정도에 따라 이사회 의결을 거쳐 따로 규칙으로 정한다고 규정하고 있고, A대학교의 교직원 보수규정은 교직원의 보수월액은 별도로 정한다라고 규정하여 피고 법인은 매 학년도에 기간제 교원 기본급 표 및 수당 표(이하 보수표)를 마련하여 기간제 교원에게 보수를 지급하여 왔다.

- 피고 법인은 원고를 비롯한 기간제 교원에게 매년 7월과 12월을 제외한 나머지 달의 보수지급일에 기본급의 30%(연간 300%)를 상여수당으로 지급하여 왔으나, 2012학년도에는 보수규정과 보수표를 변경하여 3월과 9월 보수지급일에만 기본급의 50%(연간 100%)씩 상여수당을 지급하였고, 2013학년도부터는 보수표의 상여수당 항목을 삭제한 다음 상여수당을 지급하지 않았다. 다만 피고 법인은 2012학년도 보수표를 변경하면서 2010년과 2011년에 동결되었던 기본급을 약 344만 원에서 약 454만 원으로 인상하였다. 그러나 2013학년도부터는 매년 2012년과 동일한 기본급 표를 작성, 즉 기본급을 동결하였다.

- 원고는 A대학교에서 기간제 교원으로 일해오다가 2021년 정년퇴임한 사람으로, 피고 법인의 2012년과 2013년 보수표 변경은 취업규칙의 불이익변경에 해당함에도 근로자 집단의 동의를 받지 않아 무효라고 주장하면서 종전의 유효한 취업규칙인 2011년 보수규정과 보수표에 따라 지급되어야 하는 상여수당 상당액을 청구하였다. 이러한 원고의 주장에 대해 피고 법인은 2013년 보수표 변경의 경우 취업규칙의 불이익변경에 해당함을 자인하면서도, 2012년 보수표 변경의 경우 상여수당을 감액하는 대신 기본급을 크게 인상하여 원고에게 실제 지급된 임금총액은 오히려 종전보다 증가하였으므로, 이는 근로자 집단의 동의를 받지 않아도 유효하다고 주장하였다.

III. 법원의 판단

- 그러나 이 사건 원심은 2012년 보수표 변경이 특별한 사정이 없는 한 취업규칙의 불이익변경에 해당한다고 판단하였다. 그 근거로는, 먼저 피고 법인의 보수규정에 따르면 기본급(봉급)은 호봉별로 지급되는 것인 반면 수당은 직무의 책임성 및 난이성에 의하여 지급되는 부가급여로 구별되어 있어 이 사건 기본급과 상여수당은 연계되어 있다고 보기 어렵다고 판단하였다, 또한 피고 법인의 경우 2010년과 2011년에는 2008년 개정 공무원 보수규정상의 대학교원 등의 봉급표[별표 12]에 따라, 2012년에는 2012년 개정 공무원 보수규정상의 국립대학 교원 등의 봉급표[별표 12]에 따라 기본급을 정한 것으로 보이므로, 2012년의 기본급 인상은 공무원 보수규정에 따른 봉급이 인상됨에 따라 같이 이루어진 것으로 보이고, 이와 달리 상여수당을 삭감하면서 그에 대한 보상으로 기본급을 인상하였거나 기본급 인상과 상여수당 삭감 사이에 대가관계가 있다고 볼 만한 자료가 없다고 판단하였다.

- 반면 대법판결은 원심의 판단에 취업규칙 불이익변경에 대한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않아 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아, 원심을 파기환송하였다. 즉 2012년 보수표 변경이 불이익변경에 해당한다고 단정할 수 없으므로 파기환송심에서 이를 다시 심리하라는 것인데, 그 논거는 다음과 같다. 먼저 대법원은 취업규칙 불이익변경의 물적 판단기준에 대한 기존 판례법리를 재확인하면서, 근로의 대가인 임금을 구성하는 기본급과 상여수당은 하나의 근로조건을 결정하는 여러 요소 중 비교 가능한 것에 해당하므로 대가관계나 연계성을 쉽게 부정하기 어렵다고 하였다.

- 또한 대법판결은 원심이 기본급 인상과 상여수당 삭감 사이에 대가관계나 연계성이 없다고 판단하면서 제시한 근거는 충분하지 않다고 보았다. 원심이 지적인 것처럼 A대학교의 보수규정에서 봉급과 수당의 성격을 구분하고 있기는 하지만, 이 사건 상여수당은 기본급 금액에 일정 비율을 적용하는 방식으로 산정되는 것이므로 기본급 인상에 따라 상여수당 산정에 적용되는 비율을 낮춘 것으로 평가할 수 있고, 또한 상여수당은 기간제 교원을 모두에게 같은 비율을 적용하여 산정하는 것이므로 직무의 책임성이나 난이성 등에 따라 차등을 두고 있다고 보기도 어렵다는 점을 들었다. 또한 피고 법인의 정관이나 보수규정은 기간제 교원의 기본급을 해당 연도의 공무원 보수규정에서 정한 봉급액과 연동하도록 정하고 있지 않으므로, 공무원 보수규정의 봉급액 인상에 따라 기간제 교원의 기본급도 같이 인상된 것이라고 볼 수는 없다고 판단하였다.

- 이처럼 대법판결은 원심의 판단을 수긍하지 않고 사건을 파기환송하면서, 피고와 소외 대학교 교직원들 사이에 기본급과 상여수당을 별도로 취급한다는 점에 관한 의사 합치가 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 이상, 상여수당을 감액한 2012년 취업규칙 변경이 근로자에게 불이익한 변경에 해당하는지 판단함에 있어서는 기본급 인상이 함께 이루어진 경위와 그 대가관계 여부 등을 검토하고 임금 수준이 전체적으로 감소하였는지를 살피는 등으로 기본급이 근로자에게 유리하게 변경되었다는 사정까지 종합적으로 고려하여야 한다고 하였다.

IV. 대법판결에 대한 분석

- 서두에 간략하게 언급하였듯 불이익변경인지 여부의 물적 판단기준에 대한 기존 판례법리는 하나의 근로조건을 결정짓는 여러 요소가 변경되는 경우, 그 요소들 간에 대가관계나 연계성이 있는 경우라면 어떤 개별 요소만을 놓고 불이익변경이라 단정 짓지 말고, 다른 요소까지 종합적으로 고려하여 판단하라는 취지로 이해할 수 있다.

- 이 법리를 적용한 선례로는 퇴직금 지급률을 낮추면서 그 산정의 기초가 되는 기초임금에 산입되는 임금의 범위를 확대한 급여규정의 개정은 불이익변경에 해당한다고 본 사례가 있으나, 명예퇴직수당의 지급률이 낮아져 그 자체로는 불리해졌다고 하더라도 그 산정의 기초가 되는 기초임금이 인상된 사안에서 보수체계의 개편으로 기초임금이 변화하자 이에 맞춰 지급률을 낮춘 것으로 짐작되므로 이를 반드시 불이익한 변경이라고 단정할 수 없다고 본 사례도 있고, 최근에는 방송국 기술직 근로자들의 근무형태를 교대근무제(4조 3교대)에서 병합근무제(4조 3교대제와 3조 3시차제 병행)로 변경한 것은 근무형태가 크게 불규칙

해졌다거나 업무부담이 증가하였다고 보기 어렵고, 설령 일부 근로조건에서 다소 저하된 부분이 있다고 하더라도 밤샘근무가 대폭 축소되는 등 근로조건이 향상된 부분도 있어 종합적으로 고려해보면 불이익변경에 해당하지 않는다고 본 사례도 있다.

- 대상판결은 이에 대한 기존 판례법리를 재확인하면서도, 근로의 대가인 임금을 구성하는 기본급과 상여수당은 하나의 근로조건을 결정하는 여러 요소 중 비교 가능한 것에 해당하므로 대가관계나 연계성을 쉽게 부정하기 어렵다는 점을 새로이 언급하였다. 또한 대상판결은 피고와 소외 대학교 교직원들 사이에 기본급과 상여수당을 별도로 취급한다는 점에 관한 의사 합치가 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 이상 종합적 고려가 필요하다는 점을 새로이 언급하였다. 이를 종합하면, 대상판결은 종전의 법리에 따라 변경되는 요소들 사이에 대가관계나 연계성이 있는지를 판단하는 경우 변경되는 요소들 사이에 객관적 관련성(유기적 관련성 내지 동종적 관련성)이 있으면 원칙적으로 대가관계나 연계성이 있다고 추정하여 관련 요소를 모두 고려하는 종합적 판단을 하도록 하고, 다만 이를 뒤집을 만한 특별한 사정, 예컨대 대가관계나 연계성이 없다는 점에 대한 당사자들의 의사 합치가 확인되면 그 추정이 복멸된다고 보아 종전의 법리를 보다 구체화하고자 한 것으로 평가할 수 있다. 다만 취업규칙의 경우에 사용자가 주체가 되어 작성·변경하는 것이므로, 이 과정에서 변경되는 근로조건 요소들이 대가관계나 연계성이 없다는 점에 대해 당사자들의 명확한 의사 합치가 이루어지기는 사실상 불가능하다. 따라서 이 경우에는 취업규칙 변경의 경위와 당사자들의 관행 등을 종합하여 대가관계나 연계성에 대한 추정을 복멸시킬 만한 특별한 사정이 있는지를 판단하여야 할 것이다.

- 파기환송심에서는 이러한 특별한 사정이 있는지를 두고 중점적으로 심리가 이루어질 것으로 보이는데, 특히 공무원 보수규정과 이 사건 보수표의 관계에 대해서 면밀히 검토가 이루어질 필요가 있다. 원심과 달리 대상판결은 피고 법인의 보수규정과 보수표가 공무원 보수규정과 연동되어 있지 않다고 보았는데, 피고 법인 외에 일부 사립대학에서는 소속 교원의 보수를 공무원 보수규정과 직접 연동해 온 사례들이 발견되고, 원심판결에서 언급되었듯 피고 법인은 2012년에는 2012년 공무원 보수규정에 따라서, 2010년과 2011년에는 2008년 공무원 보수규정에 따라 기간제 교원의 기본급을 정하였는데, 2008년 금융위기로 인해 공무원 보수규정이 2010년까지 동결되었던 점을 고려하면 공무원 보수규정에 따라 기본급을 인상하여 온 관행, 즉 기본급 인상은 이에 따른다는 특별한 사정이 존재하였을 가능성을 배제하기 어렵기 때문이다. 따라서 2008년 이전 기간을 포함하여 이 사건 보수표와 공무원 보수규정의 관계는 어떠하였는지, 2011년 공무원 보수규정 개정의 취지가 기본급 인상에 맞추어 상여수당을 함께 조정하고자 한 것으로 볼 수 있는지 등에 대한 추가적인 검토가 필요하다.

V. 판결의 시사점

- 최근 대법원 전원합의체 판결을 통해 통상임금 산입범위가 확대되었고, 이에 맞추어 새로이 통상임금에 산입되는 수당을 폐지하고 다른 수당을 신설하는 방안 등 임금 및 수당체계 변경에 대해 논의가 활발하게 전개되면서 대상판결도 많은 주목을 받고 있는 것으로 보인다. 그러나 대상판결은 어디까지나 변경 후 임금총액이 명백히 증가한 경우이면서 기본급 인상과 함께 사실상 기본급화되어 있는 정률형 정기상여금의 감액이 같이 이루어진 사안에 대한 것이므로, 대상판결의 취지를 임금 총액만 감소하지 않는다면 일부 수당을 그 지급목적과 무관하게 임의로 축소 내지 불리하게 변경하여도 된다고 본 것으로 오해되어서는 안 된다.

- 또한 근로기준법은 근로자에게 유리한 취업규칙의 변경이라고 하더라도 사용자가 근로자들의 의견을 청취하도록 하고, 변경된 취업규칙을 행정관청에 신고할 때 근로자 집단의 의견을 들었음을 증명하는 자료를 첨부하도록 하고 있다(법 제94조 제1항 본문 및 시행규칙 제15조; 위반 시 과태료). 따라서 사용자는 취업규칙 변경에 대한 근로자들의 의견을 청취하는 과정에서 그 변경 내용과 취지를 설명할 것이 요구된다는 점에도 유념할 필요가 있다.

- 나아가 사용자로서는 이러한 변경이 불이익변경인지 여부 및 그 유효성을 둘러싼 사후적 분쟁을 예방하기 위하여 사전에 근로자 집단의 동의를 받기 위해 노력하는 것이 바람직하다. 만약 근로자들의 입장에서조차 이러한 취업규칙의 변경이 불이익하지 않은 것으로 보인다면 그 변경에 동의할 것이라고 기대해볼 수 있고, 근로자들의 동의를 얻기 위한 절차적 노력을 다해두어야만 만약 차후에 이것이 불이익변경으로 판단된다고 하더라도 근로자들이 그 집단적 동의권을 남용한 것이어서 이것이 예외적으로 유효할 수 있음을 다투어 볼 여지가 생기기 때문이다.

<부당인사명령의 판단 구조> 서울행정법원 2025.03.20. 선고 2023구합86690 판결

【판결 요지】

- 근로자에 대한 대기발령, 직위해제, 배치전환, 전직 또는 전보처분 등의 인사명령은 원칙적으로 인사권자인 사용자의 고유권한에 속하고, 따라서 이러한 인사명령에 대하여는 업무상 필요한 범위 안에서 사용자에게 광범위한 재량을 인정하여야 하며, 이것이 근로기준법 등에 위반되거나 권리남용에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한 위법하다고 할 수 없다. 사용자의 인사명령이 정당한 인사권의 범위 내에서 이루어진 것인지 여부는 업무상의 필요성과 그에 따른 근로자의 생활상 불이익과의 비교·교량하고, 근로자와의 협의 등 인사명령을 하는 과정에서 신의칙상 요구되는 절차를 거쳤는지 여부를 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

I. 사건의 개요

- 피고보조참가인(이하 참가인이라 한다)은 1993년경 농협에 입사한 뒤 2016년 원고 A농업협동조합에 전입하여 이사회 의결을 거쳐 임기제 전무 보직을 받았고, 2019년 및 2021년 2차례 재임용되었다. 2023년 재임용 여부를 결정하는 이사회를 앞두고 참가인은 다면평가에서 우수 등급을 받았으나, 원고의 조합원 및 임원들과 수차례 불화가 있었고, 이로 인해 조합원 약 1,250명 중 약 140명이 참가인의 재임용 안건 부결을 요구하는 건의서를 제출하였다. 2023.3. 17. 이사회에서 참가인의 재임용 안건은 부결 4명, 가결 2명, 기권 1명으로 부결되었다. 이에 따라 참가인은 2023.4.5. 보직이 기획역으로 변경되고, 같은 날 A농협 주유소장으로 배치되었다.

- 참가인은 위와 같은 보직변경 및 전보조치(이하 이 사건 인사조치라 한다)에 대하여 부당보직해임 및 부당전보구제신청을 제기하였다. 전남지방노동위원회는 보직해임의 업무상 필요성이 인정되지 않고, 전보조치는 부당한 보직해임의 후속 조치에 해당한다는 이유로 구제신청을 인용하였다. 원고가 재임을 신청하였으나 중앙노동위원회는 원고의 재임신청을 기각하였고, 원고가 재임판정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하였다.

II. 대상판결의 내용

- 대상판결은 근로자에 대한 대기발령, 직위해제, 배치전환, 전직 또는 전보처분 등의 인사명령은 원칙적으로 인사권자인 사용자의 고유권한에 속하고, 따라서 이러한 인사명령에 대하여는 업무상 필요한 범위 안에서 사용자에게 광범위한 재량을 인정하여야 하며, 이것이 근로기준법 등에 위반되거나 권리남용에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한 위법하다고 할 수 없다. 사용자의 인사명령이 정당한 인사권의 범위 내에서 이루어진 것인지 여부는 업무상의 필요성과 그에 따른 근로자의 생활상 불이익과의 비교·교량하고, 근로자와의 협의 등 인사명령을 하는 과정에서 신의칙상 요구되는 절차를 거쳤는지 여부를 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.라고 한 대법원 2013. 5. 9. 선고 2012다64833 판결을 인용하면서, 참가인에 대한 전무 재임용 거부는 정당한 인사권의 범위 내에 있고 주유소장으로 전보한 조치 역시 참가인의 직급에서 가능한 보직을 새롭게 부여한 것으로 부당 전보에 해당한다고 볼 수 없음에도, 이 사건 인사조치를 부당하다고 판단한 재심판정은 위법하다고 하여 재심판정을 취소하였다.

- 대상판결은 이 사건 인사조치가 참가인의 보직을 박탈하는 것이 아니라 전무 보직을 다시 부여하지 않는 것으로 침익적 성격이 크지 않고, 전무의 지위를 고려하면 사용자의 재량이 넓게 인정된다고 하였다. 또한 전무 보직의 재부여에 대한 관행이나 기대권을 인정하기도 어렵고, 참가인이 사회적 물의를 일으켜 이사회 논의 결과 재임용이 부결된 것이므로, 다면평가 결과 우수 등급을 받았다는 이유만으로 이사회 의결이 현저히 부당하다고 보기도 어렵다고 하였다. 이 사건 인사조치로 인한 생활상 불이익에 대해서도 참가인은 여전히 가장 높은 직급에 해당하는 점, 이 사건 인사조치 전후의 보수액에 현저한 차이가 없는 점을 근거로 생활상 불이익이 현저히 크다고 보기도 어렵다고 하였다.

III. 대상판결의 해석

- 전무의 업무와 지위를 고려하였을 때, 참가인이 농협의 조합원 및 임원과의 지속적인 불화로 물의를 일으켰다면 참가인을 전무로 재임용하지 않은 것이 정당하다고 본 대상판결의 결론 자체는 수긍할 수 있을 것으로 보이지만, 그러한 결론에 이르는 판단 구조에는 의문이 있다. 대상 판결은 이 사건 인사조치가 권리남용에 해당하지 않으므로 정당하다고 판단하였고, 대상판결 외에도 그와 같은 구조로 인사명령의 정당성을 판단하는 경우가 많은 것으로 보인다. 그런데 근로기준법 제23조 제1항은 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌을 하지 못한다.라고 규정하고 있다. 전직은 근로자의 직무 내용이나 근로 장소를 변경하는 인사명령을 의미하는데, 전직의 개념을 고려하면 근로기준법 제23조 제1항이 그 밖의 징벌이라는 표현을 사용하고 있다 하더라도 위 규정이 징계처분 또는 그에 준하는 처분에만 적용되는 규정이라고 보기는 어렵다.

- 권리남용금지원칙은 신의성실의 원칙에서 파생되는 원칙으로, 신의성실의 원칙과 같이 명시적인 규정이 없는 경우에 보충적으로 적용되어야 한다. 일본과 같이 해고나 인사명령의 효력을 규율하는 법률의 규정이 없다면 권리남용을 근거로 하여 부당한 인사명령의 효력을 제한할 필요가 있을 것이지만, 이를 제한하는 명시적인 법률 규정이 존재함에도 권리남용론에 따라 인사명령의 효력을 판단할 필요는 없다. 이와 같은 취지에서 서울고등법원 2018.2.1. 선고 2017누70153 판결은 근로기준법 제23조 제1항을 근거로 사용자는 인사권자로서 원칙적으로 근로자에 대해 인사발령을 할 수 있는 권한을 가지고 있으나, 다른 한편으로 근로계약관계의 당사자가 계약 내용을 일방적으로 변경하는 것에 한계가 있으므로 정당한 이유가 인정되는 범위 내에서만 인사권을 행사할 수 있다. 근로자에 대한 전직이나 전보는 근로자가 제공하는 근로의 종류·내용·장소 등에 변경을 가져오는 것으로서 당초 근로계약의 범위를 벗어나거나 근로자가 예상하지 못한 상당한 불이익한 처분이라면 정당한 인사권의 행사라 보기 어렵다. 따라서 전보발령이 정당한 인사권의 범위 내에 속하는지 여부는 당해 전보발령의 업무상의 필요성과 전보에 따른 근로자의 생활상의 불이익을 비교·교량하고, 근로자가 속하는 노동조합(노동조합이 없으면 근로자 본인)과의 협의 등 그 전보발령을 하는 과정에서 신의칙상 요구되는 절차를 거쳤는지 등을 종합하여 결정하여야 한다고 판시하였다.

- 근로기준법 제23조 제1항에 따라 인사명령의 정당성을 판단하더라도 업무상의 필요성 여부와 근로자의 생활상 불이익의 비교·교량, 신의칙상 요구되는 절차의 준수 여부 등 권리남용 여부의 판단에서 고려하는 사항들이 구체적인 판단 기준이 될 수 있고, 정당한 이유는 해고와 같이 침익적 성격이 큰 처분에 비해 다소 넓게 인정될 수 있을 것이다. 그러나 권리남용론에 따른 판단과 근로기준법 제23조 제1항에 따른 판단은 증명책임의 소재가 달라진다는 점에서 차이가 발생하게 된다. 권리남용은 예외적인 사정에 해당하므로 인사명령이 권리남용에 해당하는 특별한 사정에 대해서는 이를 주장하는 근로자가 증명책임을 부담하게 되지만, 근로기준법 제23조 제1항은 정당한 이유에 대하여 사용자에게 증명책임을 부담하는 규정으로 해석이 되므로 사용자가 인사명령의 정당한 이유에 대하여 증명책임을 부담하여야 한다. 따라서 인사명령의 정당성 여부가 불분명하여 법관이 확신을 가지지 못하는 경우에는 동일한 사안에 대해서도 증명책임에 따라 다른 결론이 내려질 수 있다는 점에서 근로기준법 제23조 제1항에 따른 판단이 실질적인 의미를 가질 수 있다. 또한 근로자가 인사명령의 필요성 등과 관련된 사실관계를 파악하고, 이에 대한 증거를 수집하는 것이 현실적으로 쉽지 않은 상황에서 근로기준법 제23조 제1항에 따라 인사명령의 효력을 판단하게 되면, 사용자가 인사명령의 정당성을 인정받기 위해 증거를 제출하도록 하는 효과를 기대할 수도 있을 것이다.

<노동조합의 사전합의권 남용 법리와 근로계약 변경에 대한 개별 동의권 배제> 서울고등법원 2025.07.11. 선고 2024나2030688 판결

【판결 요지】

- [1] 노동조합이 사전합의권을 남용한 경우란 노동조합 측에 중대한 배신행위가 있고 이로 인하여 사용자 측의 절차 흠결이 초래되었다거나, 인사처분의 필요성과 합리성이 객관적으로 명백하며 사용자가 노동조합 측과 사전 합의를 위하여 성실하고 진지한 노력을 다하였음에도 노동조합 측이 합리적 근거나 이유 제시도 없이 무작정 인사처분에 반대함으로써 사전 합의에 이르지 못하였다는 등 사정이 있는 경우를 의미한다.

- [2] 원고들의 근로계약서는 원고들의 근무장소와 근무내용을 한정하는 취지로 보인다. 그러나 이 사건 사업장 소속 근로자 51명 중 원고들을 포함하여 35명이 담당하는 N사의 고객만족도 조사 업무가 종료되어 이 사건 사업장의 규모가 대폭 축소되고 위 업무를 담당하는 근로자들이 더 이상 이 사건 사업장에서 근무할 수 없는 상황이 되었고, 이러한 상황에서 다른 사업장으로 배치전환을 하는 것에 대해서까지 근무장소와 근무내용 변경에 대한 원고들의 개별 동의가 있어야 한다고 볼 수 없다.

I. 사실관계

- 원고들은 피고 회사에서 N사의 고객만족도 조사 업무를 담당하던 정규직 근로자들이며, A노조에 가입해 있었다. N사가 2021. 11.말, 수원사업장(이하 이 사건 사업장) 위탁 업무를 2021. 12. 31.자로 종료함을 통보하자, 피고는 경영설명회를 개최하여 근로자들에게 노사협의를 제안했다. A노조는 원고들을 포함한 근로자 35명으로부터 고용안정 논의 관련 권한을 위임받았다. 이후 피고와 A노조는 여러 차례 협의했으나 합의안을 도출하지 못했다. 피고는 근로자들에게 희망퇴직과 전직지원을 안내했지만, 근로자 24명은 이를 거부했고, 피고는 이들에게 이 사건 사업장 내 대기발령을 통지했다. 이후 피고는 2022.1. 부천사업장으로의 전환배치를 위한 개별면담과 특별교섭을 시도했으나, 근로자들과 노동조합은 이에 불응하고 전환배치에 동의할 수 없다는 입장을 고수했다. 이에 피고는 2022.2.17. 이 근로자들에게 2.21.자로 부천사업장으로 전환배치하는 내용의 인사명령을 하였다. 그러나 전환배치 대상자들은 2.21. 전환배치에 불응해 부천사업장 출근 대신 이 사건 사업장에 출근해 사업장을 점거하였다. 피고는 출근을 촉구하며 징계를 경고했으나, 2022.3.17. 노사 간 합의는 이루어지지 않았다. 결국 피고는 3월 말과 4월 초에 걸쳐 인사명령 불응, 무단결근(15일), 업무명령 불복 및 단체행동을 이유로 원고들을 징계해고하였다.

- 원고들은 노동위원회에 구제신청을 했으나 초심과 재심에서 모두 기각 판정을 받았다. 원고들은 민사소송을 제기하였으나, 제1심인 서울서부지방법원도 원고들의 청구를 기각했고, 항소심에서도 대상판결과 같이 항소를 기각하였다.

- 한편, 피고와 A노동조합 사이에 체결된 단체협약 제15조 제2항은 업무의 배치전환은 사전에 조합 및 본인과 충분히 협의해야 하며, 불이익하게 전환할 때는 합의하여 시행한다.라고 규정하고 있으며, 원고들의 근로계약서에는 업무장소와 소속에 관하여 소속팀/ACC : 사업5팀/P수원, 근로장소 : 수원센터라고 기재되어 있었다.

II. 대상판결의 해석

- Pacta sunt servanda! 법학을 처음 배울 때 가장 먼저 접하는 법언이다. 계약은 지켜져야 한다는 말을 구태어 라틴어로 표현해서 소개한다는 사실이 이 법언의 무게를 짐작하게 한다. 이 사건에서는 두 개의 pacta가 문제된다. 단체협약과 근로계약서가 그것이다. 이 둘은 노사관계를 규율하는 가장 강력한 규범적 기준이다. 피고가 원고들에게 한 징계해고의 사유는 직접적으로 원고들의 전환배치 불응에 기인한다. 그런데 원고들의 입장에서는 이 전환배치는 피고가 두 개의 pacta를 어긴 것에 기인한 부당한 명령이므로 이를 따를 의무가 없다고 보았을 수도 있다. 결국 이 사건 징계해고의 당부는 전환배치명령이 정당한 명령인지 여부에 달려 있다.

- 전환배치명령의 정당성이 문제되는 사건에서 사용자는 일반적으로 전환배치는 경영상 판단, 즉 재량권이라는 주장을 한다. 이에 대해 판례는 전직처분 등이 정당한 인사권의 범위 내에 속하는지 여부는 당해 전직처분 등의 업무상의 필요성과 전직에 따른 근로자의 생활상의 불이익을 비교·교량하고, 근로자가 속하는 노동조합(노동조합이 없으면 근로자 본인)과의 협의 등 그 전직처분을 하는 과정에서 신의칙상 요구되는 절차를 거쳤는지 여부에 의하여 결정되어야 한다고 하면서, 전보처분 등을 함에 있어서 근로자 본인과 성실한 협의절차를 거쳤는지 여부는 정당한 인사권의 행사인지 여부를 판단하는 하나의 요소라고 할 수 있으나, 그러한 절차를 거치지 아니하였다는 사정만으로 전보처분 등이 권리남용에 해당하여 당연히 무효가 된다고 볼 수는 없다.는 법리를 제시한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2010다52041 판결 등).

- 다만, 위 법리가 모든 사건에 그대로 적용되는 것은 아니다. 노사관계에서는 일반적으로 근로자가 사용자의 명령에 따라야 하지만, 거기에는 현대적 계약관계가 요구하는 한계가 존재하기 때문이다. 현대에 들어와서도 신분관계적 성격이 완전히 일소되지는 못했지만, 그래도 노사관계는 법적으로 그 본질이 계약관계이다. 따라서 계약법의 법리가 적용된다. Pacta sunt servanda를 필자가 구태어 언급한 이유도 여기에 있다. 이 법언의 이면에는 계약이란 정당한 것임이 전제되어 있다. 그리고 계약의 정당성은 그것이 자유의사에 의해 체결되었다는 점에 근거한다. 자유로운 의사로 체결된 것이므로 당사자는 그 책임을 져야 하고 국가는 그 이행을 강제할 수 있다. 근로기준법 제4조의 근로조건 자유결정 원칙이 이러한 법리를 노동법 차원에서 재확인한 것이다.

- 이 사건의 단체협약은 불이익한 배치전환에 노동조합은 물론이고 본인의 합의가 필요하다고 규정한다. 하여, 사용자인 피고는 이를 준수해야 한다. 한편, 이 사건 근로계약서에도 근로장소가 특정되어 있다. 하여, 사용자는 이를 보장해야 하며, 계약의 내용인 근로장소를 변경하기 위해서는 당사자 합의가 필요하다. 따라서 이 사건에서 전환배치의 정당성을 인정하기 위해 요구되는 신의칙상의 절차는 이러한 단체협약상의 사전합의 및 근로계약서의 내용을 변경하는 합의의 정도에 이르는 것이어야만 한다. 사용자가 스스로 자신의 의사에 의해 구속되기를 희망한 pacta의 내용을 준수해야 하는 것이다. 따라서 합의가 존재하지 않는 한 이 사건은 원고들의 주장이 더 타당하다고 볼 수 있다.

- 그러나 판례는 일찍이 판결요지[1]과 같이 노동조합의 사전합의권 남용의 법리를 제시한 바 있다. 그 근거는 민법 제2조의 권리남용이다. 그런데 소유권 행사를 두고 다투는 일반 민사사건에서는 권리남용이 매우 엄격하게 적용되는 경향이 있는데, 이와 달리 노사관계에서는 근로자측의 권리행사에는 상대적으로 느슨하게 적용되는 느낌이다. 이 사건도 그러한 예라 할 수 있다. 대상판결이 인용한 1심판결에서는 노동조합이 제시한 조건에 대해 과도한 요구조건이라거나 피고로서는 받아들일 수 없는 안이라 평가한다. 대상판결에서도 업무가 종료되어 유급 대기기간이 한 달 반 넘게 계속되는 상황에서도 한사코 다른 사업장으로의 배치전환을 거부하였다는 설시가 눈에 들어온다. 재판부가 마치 피고의 입장에서 사건을 이해하고 있음을 드러낸 것이다. 그런데 이 사건에서 합의권은 원고 측이 행사하는 권리이다. 권리의 행사는 최대한 보장되어야 한다. 다만 사회적 수용 한계를 초과하거나 구체적 타당성을 도모하기 위한 필요가 현저히 높은 경우에 권리남용으로 보아 그 효력을 부인할 수 있을 뿐이다. 그런데 사업장 규모의 대폭 축소 및 위탁업무 종료라는 사정은 사용자의 경영상 사정에 불과하다. 근로자는 성실히 근로를 제공했다면 충분하다. 따라서 근로자에게 경영상 위험의 공유를 제안하려면 신중한 검토가 필요하다. 즉, 이 사건에서 원고 측의 합의권을 무력화하고 그들을 납득시키기 위해서는 원고들의 행위가 권리남용에 해당한다는 점을 판결요지[1]이 제시한 기준에 맞추어 상세하게 포섭하고 그 이유를 설시했어야 한다. 나아가 이 사건은 결과의 면에서 정리해고와 동일하다는 점에서 피고가 정리해고의 실체적·절차적 요건을 우회하기 위해 징계해고에 나아간 것이라는 의심도 든다. 대상판결은 이 점 역시 고려했어야 한다. 즉, 노동조합의 사전합의권은 정리해고에서의 절차적 요건의 성격도 지니는 것이다(근기법 제24조 제3항).

- 한편, 이 사건에서는 근로계약서 내용의 효력도 중요한 쟁점이 된다. 참고로, 사용자가 일반적으로 임금을 감액한 경우 그 효력이 인정될 수 없다는 점에 대해서 의문의 여지가 없을 것이다. 그렇다면 근로장소의 경우에는 어떨까? 대법원 2013.2.28. 선고 2010다52041 판결은 근로계약에서 근로 내용이나 근무장소를 특별히 한정한 경우에 사용자가 근로자에 대하여 전보나 전직처분을 하려면 원칙적으로 근로자의 동의가 있어야 한다.는 판시를 한 바 있다. 즉, 근로장

소 변경도 원칙적 동意的 대상이다. 임금과 비교할 때 근로장소는 중요성이 덜 하다고 볼지도 모르겠다. 그러나 근로장소는 명목적 임금에는 산입되지 않는 출퇴근시간과 관련이 있다. 수원에서 부천으로의 근로장소 변경은 통근시간을 2시간가량 증가시키는데, 이는 근로자의 입장에서 임금의 실질적 가치를 하락시켜 임금 삭감과 다를 바 없다. 이런 점에서 근로계약상 근로장소의 변경의 경우에도 개별 근로자의 동의를 요한다고 봄이 상당하다. 그런데 판결요지[2]의 설시는 이 문제를 사전합의권 남용과 동가치한 것으로 취급한다는 점에서 수긍하기가 어렵다. 사전합의권은 노동조합 등에 의한 사용자의 인사권 제한으로서의 효력이 있다면 근로계약상 근로장소는 개별 근로자의 생활 근거지 보장을 위한 본질적인 계약 내용으로서 양자는 논의의 평면을 달리한다. 대상판결은 개별 근로계약의 핵심요소인 근로장소 특성의 효력마저 노동조합의 집단적 사전합의권 남용 법리에 흡수시켜, 개별 근로자의 동의권을 최종적으로 무력화하였다는 점에서 비판을 면하기 어렵다.

- 대상판결의 결론대로라면 사용자는 사전합의권을 존중하지 않아 노사 간 진지한 교섭은 좌절될 것이고, 근로계약상 근로장소 특성은 근로자를 유인하는 미끼로 활용될지 모르겠다. 자유의사로 계약을 체결한 자에게 법원이 계약에 따른 책임을 묻지 않는다면 도리 없이 나타날 현상이다.

<용역업체 간 고용승계 시 적용되는 근로조건> 수원지방법원 안양지원 2025.02.20. 선고 2023가단113982 판결

【판결 요지】

- 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체, 즉 인적·물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 것이 영업양도로서, 영업 일부만의 양도도 가능하고, 이러한 영업양도가 이루어진 경우에는 원칙적으로 해당 근로자들의 근로관계가 양수하는 기업에 포괄적으로 승계된다는 법리(대법원 1991. 8. 9. 선고 91다15225 판결, 대법원 2001. 7. 27. 선고 99두2680 판결 등 참조)에 비추어, 근로관계가 승계된 근로자들에 대하여는 그 근로조건 또한 승계된다고 볼 수 있다.

I. 판결 내용

- 대상판결은 ○대사관의 보안·경비업무 용역업무를 위임받은 신규 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자들의 고용관계를 승계한 때 적용되어야 할 근로조건이 무엇인지가 쟁점이 된 사례다. 고용이 승계된 근로자들은 신규 업체가 종전에 적용받던 근로조건에 따라 임금을 지급해야 한다고 주장했고, 해당 법원은 근로자들의 청구를 인용하였다.

- 근로자들이 청구한 여러 미지급 임금항목 중 휴게시간 미정산분이 고용승계 시 적용되는 근로조건인지 여부가 문제된 임금이다. 매일 1시간의 휴게시간을 근로시간에 포함하여 임금을 지급해 온 종전 용역업체와 달리, 신규 용역업체는 휴게시간을 무급으로 정함으로써 임금 차액이 발생한 것이다. 해당 법원은 휴게시간 1시간을 근로시간에 포함하여 산정한 임금은 위와 같은 노동관행에 따라 지급의무가 있는 근로의 대상에 해당하고, 피고는 종전 업체들과 근로자들 사이의 노동관행으로 확립된 근로조건을 승계한 사용자로 보아야 한다고 판시하였다. 대상판결의 신규 용역업체는 종전에 용역업체 소속 근로자들의 고용관계를 승계하면서 새롭게 근로계약을 체결하였다. 새 근로계약서는 휴게시간을 무급으로 하는 내용으로 작성·체결되었으나, 해당 법원은 새 근로계약서가 아니라 휴게시간을 유급으로 인정하던 형성된 종전의 노동관행을 적용해야 한다고 판단했다. 영업양도 시 포괄승계 법리가 용역업체 간 고용승계 시에도 그대로 적용된다고 본 것이다.

II. 고용승계 시 근로조건에 대한 단상

- 대법원은 2021년 용역업체 변경 시 고용승계 기대권을 명시적으로 인정하는 판결을 하였다. 이후 이 판례 법리에 따라 용역업체 간 고용승계가 인정된 사례가 점점 늘고 있지만, 신규 업체가 종전 용역업체의 근로조건 역시 승계할 의무가 있는지에 대한 판시내용은 거의 눈에 띄지 않는다. 2021년 고용승계 기대권 판결 이전에도 용역업체 간 고용승계를 인정한 판결들은 있었는데, 승계를 인정한 논거는 판결마다 달랐다. 업무위탁계약을 제3자를 위한 계약으로 보거나, 신규 용역업체들 간에 묵시적 영업양도 계약이 성립하였다고 보아 신규 업체에 고용승계 의무를 인정하기도 하였다. 이후 2021년 대법원은 제3자를 위한 계약이나 묵시적 영업양도 법리가 아닌 승계를 기대할 수 있는 여러 요소들에 대한 종합적 고려 방식으로 고용승계 기대권을 인정했다. 고용승계 기대권 법리는 묵시적 영업양도가 아닌 기간제 근로자의 갱신기대권 법리를 원용하고 있다고 해석된다.

- 고용승계 기대권이 인정되는 근로자에게 적용되어야 할 근로조건은 어떤 기준으로 결정되는 것이 타당한가. 원용해 볼만한 몇 가지 예시를 생각해보자. 첫째, 근로계약의 당사자가 변경되는 경우의 근로조건에 대하여 명시적으로 규정한 법규정으로는 **파견근로자 보호 등에 관한 법률 제6조의2**(고용의무)를 들 수 있다. 사용자업주가 파견근로자를 직접 고용할 경우, 동종 유사 업무에 종사하는 직접 고용 근로자의 근로조건을 적용해야 하며, 동종 유사 업무 종사자가 없다면 기존의 근로조건보다 낮아서는 안 된다고 정하고 있다. 둘째, 기간제근로자가 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된 이후 근로조건에 대하여 **대법원**은 (**기간제법 제8조 제1항**) 문언상으로는 기간제근로자에 대한 차별적 처우만을 금지하고 있지만, 규정 취지와 공평의 관념 등을 함께 고려하면, **기간제법 제4조 제2항**에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 간주되는 근로자의 근로조건은 다른 특별한 사정이 없는 한 동종 또는 유사 업무에 종사하는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자에게 적용되는 근로조건보다 불리하여서는 아니 된다고 해석된다.고 판시한 내용을 들 수 있다. 우리 노동법이 계약당사자 또는 고용형태의 변화가 있더라도, 기존의 근로조건은 유지되어야 하고 나아가 차별적 대우가 발생해서는 안 된다는 원칙을 유지하고 있다는 점을 알 수 있다.

- 합병, 양도, 분할 등 기업변동 시 고용관계 및 근로조건에 대해서 노동법상 명문의 규정 없이 해석을 통해 고용안정을 도모해 오고 있다. 대상판결은 영업양도 시 포괄적 근로관계 승계 법리를 통해 기존 근로조건보다 하회하는 근로계약의 효력을 부인했는데, 근로계약의 일방 당사자가 변경되는 고용승계 시에도 고용안정과 근로조건 보호를 위한 법해석을 한 것이라 추측해 본다. 하지만 대법원이 제시한 고용승계 기대권 법리가 영업양도 법리를 원용하지 않음에도, 대상판결이 승계 후 근로조건 보호를 위하여 영업양도 시 근로조건 승계 원칙을 그대로 적용한 것은 쉽게 납득하기 어렵다. 또 한편 기업변동에 따른 근로관계의 변화는 물론 용역업체 간 고용승계가 이루어진 경우에도 여전히 해석론으로 고용불안의 문제를 해소해야만 하는지 아쉬움도 든다. 고용노동부는 **용역근로자 근로조건 보호지침**을 통해 공공부문에 종사하는 용역 근로자의 고용안정과 근로조건 보호를 꾀하고 있다. 법적 강제력은 없으나 용역업체 변경으로 인한 근로자들의 고용불안을 상당히 해소하고 있다고 평가된다. 이처럼 법적 강제력은 별론으로 하더라도, 명징한 기준을 제시함으로써 노사 모두에게 예측 가능성이 있는 기준을 마련하는 것이 필요한 시점이다.

<노동위원회 등에 제출하기 위해 상대방 동의 없이 녹음한 행위의 위법성 여부> 대법원 2025.10.16. 선고 2025다204730 판결

【판결 요지】

- 이 사건 녹음행위가 원고의 동의 없이 이루어진 것이기는 하나, 녹음 시 상대방이 명시적으로 반대의를 표시하였음에도 기망 또는 협박하여 녹음하였다는 사정이 없다는 점, 근로계약 기간 종료에 따라 근로자가 실제로 근로계약 갱신을 기대하고 있었는지 여부를 명확히 하여 분쟁을 예방할 필요가 있었던 사안으로 대화 내용 자체가 개인의 내밀한 영역에 관한 것도 아니며 피해의 정도도 크지 않은 점, 녹음파일 및 녹취록도 근로계약에 관한 법적 분쟁과 관련하여 노동위원회나 법원에 제출하는 방식으로만 사용하여 피해의 정도는 수인할 수 있는 정도인 점을 고려하면 이 사건 녹음행위는 위법성이 없어 불법행위로 보기 어렵다.

I. 사안의 개요

- 대상판결은 노동위원회나 법원에 증거자료로 제출하기 위해 대화참여자인 상대방의 동의 없이 녹음한 행위가 불법행위에 해당하는지 여부에 대해 판단기준을 제시한 대표적 사례이다. 사안의 개요를 살펴보면 아래와 같다.

- 원고는 집합투자증권의 판매업무, 투자자문업무 등을 목적으로 하는 피고 회사(피고 1)에 2020.9.4. 단기 계약직으로 입사, 부산 및 경남 지역 고객들에 대한 집합투자증권 등의 오프라인 판매 등을 위하여 부산 지역 영업소에서 근무하였다. 원고와 피고 법인의 최종계약은 2021.10.20.부터 2022.7.31.까지였다. 피고 법인의 본사 마케팅부서장(피고 3)은 2022.7.22. 원고에게 2022.8.31.부터 이 사건 영업소를 폐점할 예정이라는 사실을 통지하면서 원고와 더 이상 근로계약을 체결하지 않겠다는 의사를 표시하였다. 피고 3은 2022.7.22.14:13경 이 사건 영업소 사무실에서 원고 외 1인과 대화를 나누면서 원고의 동의 없이 원고와의 대화 내용 일체를 녹음하였고, 이후 2022.7.22.14:35경 재차 원고 외 1인과 대화를 나누면서 원고의 동의 없이 원고와의 대화 내용 일체를 녹음하였다.

- 이에 원고는 기간제 근로자인 원고에게 피고 회사에서 계속 근무할 기대관계가 형성되었음에도 피고 회사는 합리적 이유 없이 새로운 노동계약 체결을 거절하는 형태로 원고의 갱신기대권을 침해하였기에 손해를 배상할 의무가 있고, 피고 회사의 직원인 피고 3은 대표이사인 피고 2의 지시하에 원고의 동의 없이 2차례에 걸쳐 원고와의 대화를 녹음하였던바, 이 사건 녹음행위는 원고의 인격권을 침해하는 불법행위이므로 공동하여 원고에게 위자료를 지급할 의무가 있다며 손해배상 청구의 소를 제기하였다.

- 한편 피고들은 위 녹음에 따른 녹음파일과 녹취록을 원고와 체결된 근로계약에 관한 법적 분쟁과 관련하여 노동위원회나 법원에 제출하는 방식으로만 사용하였다.

II. 대상판결의 주요 내용과 의의

- 대상판결은 음성권 침해에 대해 실시하면서 상대방의 동의 없이 녹음한 행위는 어떠한 경우 위법성이 인정되어 불법행위에 해당되는지 다음과 같이 판시하고 있다.

- 음성권은 헌법적으로 보장되는 인격권에 속하는 권리로 상대방의 의사에 반해 그의 음성을 녹음하거나, 녹음을 방송, 배포하는 등의 행위는 원칙적으로 음성권에 대한 침해가 될 수 있다. 한편 민사소송에서 대화 상대방의 동의 없이 대화를 녹음하였더라도 그 녹음한 파일이나 녹취록을 증거로 사용할 수 있고(대법원 2009.9.10. 선고 2009다37138, 37145 판결 등 참조), 실제적 진실 보존 또는 자기 방어를 위하여 상대방 대화의 녹음이 필요한 경우가 있음을 고려하면, 상대방의 동의 없이 대화를 녹음하였다는 사실만으로 그러한 녹음행위가 음성권을 위법하게 침해하는 불법행위에 해당한다고 볼 수는 없다. 그러나 상대방의 명시적인 반대 의사에도 불구하고 상대방을 기망 또는 협박하여 녹음을 하는 등 침해방법이 부당한 경우, 또는 녹음행위 자체는 부당하게 이루어지지 않았더라도 녹음한 음성을 상대방의 동의 없이 방송, 배포하는 등의 경우에는, 이로 인하여 달성하려는 이익의 내용과 필요성, 상대방이 입게 되는 피해의 성질과 정도 등에 비추어 위법성이 인정되면 불법행위에 해당할 수 있다.

- 대상판결은 아래 사정들에 비추어 이 사건 녹음행위는 원고가 수인하여야 하는 범위에 속하는 것으로서, 위법성이 없다고 판단한 원심 및 1심 판결에 잘못이 없다고 보았다. 첫째, 녹음하는 과정에서 원고가 명시적으로 녹음하면 안 된다는 반대의를 표시하였음에도 불구하고 원고를 기망 또는 협박하여 녹음하였다는 사정은 발견할 수 없다. 둘째, 이 사건 녹음행위의 목적은 영업소 폐점에 관한 원고의 반응을 확인하여 근로계약 갱신을 기대하고 있었는지 여부를 명확히 하여 분쟁을 예방하고자 함에 있다. 셋째, 대화 내용 자체도 근로계약 종료 통지에 불과하지 개인의 내밀한 영역에 관한 것이 아니어서 원고가 입게 되는 피해의 정도가 크지 않다. 넷째, 이 사건 녹음행위로 인한 녹음파일 및 녹취록은 노동위원회나 법원에 제출하는 방식으로만 사용하였을 뿐이다. 분쟁에서 증거자료를 제출하여 합리적인 해결을 도모할 필요가 있었고, 공적 판단기관인 노동위원회나 법원의 성격과 판단 절차에 비추어 녹음파일 등의 제출로 인하여 원고가 입을 수 있는 피해의 정도는 수인할 수 있는 정도로 보인다.

- 대상판결은 상대방의 동의 없는 녹음행위가 음성권에 대한 부당한 침해로서 민법상 불법행위를 구성하는지와 관련하여 여러 사정을 고려한 이익형량을 통하여 침해행위의 위법성을 가려야 한다는 점을 실시한 최초의 대법원 판결로 보인다. 즉 녹음 과정.경위에서 상대방이 명시적 반대의를 밝혔음에도 상대방에 대한 기망 또는 협박으로 녹음을 하는 등 그 방법이 부당하지 않은지, 녹음을 통해 달성하려는 목적이 적정한 것인지, 녹음 내용 그 자체도 개인의 내밀한 영역에 관한 것이 아니어서 원고가 입게 되는 피해의 정도가 크지 않은지, 녹음 결과물의 사용처 및 사용내역에 비추어 피해의 정도가 수인할 수 있는 정도인지 여부를 종합적으로 고려하여 사회통념에 비추어 용인될 수 있는 행위라고 평가할 수 있는 경우에는 사회상규에 위배되지 않은 행위로서 그 위법성이 조각된다고 보아야 한다.

III. 녹음행위와 관련한 기타 쟁점

1. 민사소송에서의 증거능력

- 자유심증주의를 채택하고 있는 우리 민사소송법하에서 상대방 부지 중 비밀리에 상대방과의 대화를 녹음하였다는 이유만으로 그 녹음테이프나 이를 송기사에 의하여 녹취한 녹취록이 증거능력이 없다고 단정할 수 없고, 그 채증 여부는 사실심 법원의 재량이다.

2. 녹음행위에 대한 형사적 제재

- 상대방 동의 없이 녹음을 하는 것이 통신비밀보호법 제3조 제1항에서 규정하고 있는 타인 간의 대화를 녹음한 것인지 여부에 대해 법원은 이를 부정하여 형사처벌의 대상으로 보지 않는다. 다만, 집단 대화에서 녹음하는 경우 대화 참여자 전체의 동의가 없는 한 타인 간의 대화로 보고 형사처벌의 대상이 된다고 본다.

3. 녹음행위에 따른 징계권 행사

- 원고가 직장내 괴롭힘에 대한 증거를 확보하기 위해 휴대전화를 이용하여 피신고인들과의 대화 내용을 휴대전화로 녹음하고, 피신고인 등과 업무를 수행하는 건강진단실에 배치된 자신의 컴퓨터에 마이크를 연결하여 6회에 걸쳐 매회 2시간에서 3시간가량 그곳에서 이루어지는 근무자들의 모든 대화를 녹음한 사안에서, 설사 직장내 괴롭힘에 대한 증거를 수집할 목적으로 녹음행위를 하였다고 하더라도, 장기간에 걸쳐 무작위하게 이루어졌고, 업무공간에서 이루어지는 모든 내용의 대화가 녹음되었는데, 업무공간에서 이루어지는 대화라도 충분히 내밀한 영역이나 사생활과 관련된 것이 있을 수 있다는 점을 고려하면, 이 사건 녹음행위가 사회상규에 위배되지 않은 행위로서 위법성이 조각된다고 보기 어렵고, 정직 3월의 징계는 정당하다고 보았다. 다만, 동 사안에서 직장내 괴롭힘이 인정되지 않았고, 피징계자가 과거에 성희롱 및 폭행과 사문서 위조 등으로 정직 3월의 징계처분을 받은 전력이 있었음이 고려되었다.

- 대법원 1995.10.13. 선고 95다184 판결은 원고에 대한 해고사유로 된 품위손상행위 및 의무위반행위 가운데에는, 원고가 동료직원들의 대화 내용을 비밀리에 녹음하여 이를 토대로 그들이 다른 직원을 비방하였다는 내용의 진술서를 작성하여 그 직원에게 교부함으로써, 그 진술서가 동료직원들에 대한 형사고소 사건의 자료로 제출되도록 한 일련의 행위가 포함되어 있다고 보여지고, 사실관계가 원심이 확정한 바와 같다면 원고의 위와 같은 행위는 사생활의 비밀과 자유를 침해하고 직원 상호 간에 불신을 야기하여 직장 내의 화합을 해하는 것이라고 보았다. 동 사안에서 해고처분의 사유 중에 비밀녹음행위가 포함되어 있다고 보았다.

<경영상 이유에 의한 해고자에 대한 우선재고용의무의 요건인 '같은 업무'의 판단기준> 서울중앙지방법원 2024.11.15. 선고 2023가합86650 판결

【판결 요지】

- 경영상 이유에 의한 해고자의 업무와 신규채용 대상 업무가 같은 업무에 해당하는지는, 취업규칙이나 근로계약 등에 명시된 업무내용이 아니라 근로자가 현실적으로 수행하는 업무를 기준으로 판단하여야 하고, 같은 업무에 해당한다고 보기 위해서는, 그 업무의 내용 및 권한과 책임 등이 완전히 동일하지는 않다고 하더라도, ① 담당하는 직책이나 직위의 성격, ② 권한·책임의 범위, ③ 현실적으로 수행하는 업무의 내용 등이 사회통념상 상당히 유사하다고 인정될 정도에는 이르러야 한다.

I. 사안의 개요

- 피고는 외국 법인으로서 국내에 영업소를 설치하고, 국내외 항공운송업 등의 사업을 영위하는 회사이고, 원고는 1993년에 입사하여 여객부서 부장으로 탑승수속, 탑승서비스, 수화물 관리, 민원 관리 등의 업무를 수행하였다. 피고는 2020년경 경영난을 이유로 2021.11.25.자로 원고를 해고하였다. 피고 회사는 2022.12.26.자로 정규직 회계담당직원 1명을 신규채용하였다.

- 원고는 피고에 대해, 원고에 대한 해고일로부터 3년 이내에 원고가 담당하였던 업무와 같은 업무를 할 근로자를 채용하려고 하였으므로, 근로기준법 제25조 제1항(이하 '이 사건 규정')에 따라 원고를 우선 고용할 의무가 있다고 주장하면서 ① 고용의 의사표시를 하고, ② 2023.1.1.부터 고용의 의사표시를 할 때까지 일정한 금액의 돈(임금 상당의 손해배상금)을 지급할 것을 청구하였다.

II. 판결 내용

- 판결은 원고가 해고될 당시 담당하였던 업무와 신규채용 직원이 담당하는 업무가 이 사건 규정의 같은 업무에 해당하지 않는다고 판단하여 원고의 청구를 기각하였다.

1. 법리

- 해고 근로자가 해고 당시 담당하였던 업무와 사용자가 채용하려고 하는 근로자로 하여금 담당하게 할 업무가 이 사건 규정에서의 같은 업무에 해당하는지는 근로자가 현실적으로 수행하는 업무를 기준으로 판단하여야 한다.

- 이 사건 규정에서의 같은 업무에 해당한다고 보기 위해서는, 그 업무의 내용 및 권한과 책임 등이 완전히 동일하지는 않다고 하더라도, ① 담당하는 직책이나 직위의 성격, ② 권한·책임의 범위, ③ 현실적으로 수행하는 업무의 내용 등이 사회통념상 상당히 유사하다고 인정될 정도에는 이르러야 한다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 규정 취지

- 해고 근로자의 보호를 위해 재고용 기회를 보장하는 것이 목적이므로 같은 업무의 의미를 내용과 범위, 권한과 책임 등에 있어 완전히 동일한 업무 등으로 협소하게 해석할 수 없다.

(2) 이 사건 규정의 문언적 해석 한계 등

- 이 사건 규정은 기간제법 제8조 제1항이나 파견법 제21조 제1항과 달리 동종 업무, 같은 종류의 업무, 유사한 업무와 같은 문언이 아니라 같은 업무라는 문언을 사용하고 있는데, 해석의 확장을 막고 사용자의 채용의 자유를 보장하기 위한 의도로 해석된다.

(3) 이 사건 규정의 입법연혁 등

- 국회의사록 등에 의하면 우선재고용의무가 인정되는 범위가 지나치게 확장되어 사용자의 채용의 자유가 침해되는 것을 방지하고, 정리해고 근로자의 보호와 사용자의 영입의 자유 내지 채용의 자유 존중 사이의 균형을 도모하였던 것으로 보인다.

(4) 업무 내용의 유사성과 함께 고려될 요소

- 같은 업무에 해당하는지를 판단함에 있어서는 현실적으로 수행하는 업무의 내용이 유사한지는 물론이고, 담당하는 직책이나 직위의 성격, 권한·책임의 범위가 유사한지도 함께 고려될 필요가 있다. 같은 업무라는 동일한 문언을 채택하고 있는 남녀고용평등법 제19조 제4항과 이 사건 규정의 해석이 유사하여야 할 필요성도 있다(대법원 2022.6.30. 선고 2017두76005 판결).

(5) 배치전환 시 재배치될 수 있었던 업무인지 여부 관련

- 해고 회피를 위한 배치전환 시 수행할 수 있었던 업무라고 하여 같은 업무에 해당한다고 볼 수는 없다. 해고 근로자에게 우선재고용의무를 부여하는 것과 배치전환을 통한 고용 유지 노력은 구별해야 한다.

2. 사안의 경우

- 위 법리에 따라서 보면 이 사건에서 원고가 해고 당시 담당하던 업무와 신규채용된 직원이 담당하는 업무가 같은 업무에 해당한다고 보기 어렵다. ① 원고의 근무 장소(공항 사무실)와 신규채용 직원 근무 장소(서울 사무실)는 물리적 위치뿐만 아니라 기능과 역할에서도 차이가 있다. ② 여객부서는 탑승수속, 수화물 관리 등 고객 서비스 업무를 담당하고, 경리부서는 회계 관련 업무를 수행하므로, 주된 업무 내용이 다르다. ③ 원고와 신규채용 직원은 직급(부장과 대리), 직책(부장장과 부서원), 급여 수준 등에 있어서도 큰 차이가 있어, 권한과 책임 범위도 상이할 것으로 보인다. ④ 직무유형 내지 채용절차의 행정적 처리를 근거로 두 업무가 같은 업무라고 볼 수 없고, 피고가 과거 여객부서 직원을 경리부서로 전환 배치한 사례가 있더라도, 원고가 수행하던 업무와 신규채용 직원의 업무가 같다고 볼 수는 없다.

III. 대법판결의 의의

- 대법원은 2020.11.26. 선고 2016다13437 판결을 통해 경영상 이유에 의한 해고자에 대한 우선재고용의무에 관한 법리를 최초로 판시한 바 있다. 그러나 해당 사건에서는 해고 직원과 신규채용 직원의 업무가 같다는 점에 별다른 의문이 없었기 때문에 같은 업무를 판단하는 방법이나 기준에 대한 판시는 없었다. 위 판결의 환송 후 판결(서울고등법원 2021.10.26. 선고 2020나56426 판결)에서는 해고자가 담당하였던 생활부업무 담당 생활재활교사 업무와 신규채용 대상 업무인 사무행정업무 담당 생활재활교사 업무가 같은 업무인지가 쟁점이 되었는데, 동 판결은 특별한 법리를 판시하지는 않고 구체적인 업무, 근무장소, 구분 채용 여부 등에 관한 사실관계를 바탕으로 같은 업무에 해당한다고 판단하였다.

- 본 대법판결은 우선재고용의무의 발생요건인 같은 업무를 판단하는 기준에 관한 법리를 판시한 최초의 판결이라는 의의가 있다. 같은 업무를 협소하게 이해하면 해고자가 재고용되기 어려울 것인데 아무 귀책사유 없이 일자리를 잃은 해고자의 권리를 좁게 이해할 수는 없다. 그러나 한편 같은 업무를 넓게 이해하면 사용자의 영입의 자유나 채용의 자유가 제한될 수 있다. 경영상 이유에 의한 해고를 할 정도의 긴박한 상태에 있었던 사용자에게 지나친 부담을 지우는 것이 정책적으로 바람직하지 않다는 의견도 있을 수 있다. 대법판결은 절충적인 입장을 취하되 같은 업무라는 문언을 우선적으로 고려하여 담당하는 직책이나 직위의 성격, 권한·책임의 범위, 현실적으로 수행하는 업무의 내용 등이 사회통념상 상당히 유사할 것을 요구하는 입장을 취한 것으로 보인다. 향후 상급심에서 어떤 판단이 내려질지 지켜보아야 할 것이다.

<복직명령과 금전보상명령의 구제이유> 대법원 2025.03.13. 선고 2024두54683 판결

【판결 요지】

- 근로자가 재심판정일 이전에 금전보상명령을 신청하였고, 사용자가 임금 상당액 이상의 정당한 금전보상을 하지 아니한 이상 금전보상명령의 구제이유이 소멸되었다고 볼 수 없고, 복직명령과 근로자의 금전보상명령 신청의 선후 관계, 복직명령에 진정성이 있는지 등은 그 구제이유에 영향을 미치지 않는다.

I. 사건의 경과 등

- 대법판결은 사용자의 복직명령(해고의 취소 또는 철회)에도 불구하고 근로자가 금전보상명령을 구할 구제이유가 있는지가 쟁점이 된 사안이다. 구제이유이란 부당해고나 부당노동행위 등에 관해 노동위원회의 공권적 판단(구제명령)을 구하기 위해 가지고 있어야 하는 구체적 이익 내지 필요를 말한다.

- 근로자는 사용자와 근로계약(2021.5.7.~2022.5.6.)을 체결하고, 사용자가 운영하고 있는 E의원에서 직업환경의학 전문의로 근무하였다. 사용자는 2021.6.29. 06:45 근로자에게 문자 메시지로 해고를 통지하였다. 근로자는 다른 병원에 취업하여 2021.7.20.부터 근무하였는데, 이와 관련하여 근로자는 사용자에게 퇴직처리가 안 되어 구직활동에 방해가 된다는 내용의 문자 메시지를 보낸 사실이 있으며, 사용자도 근로자가 해고에 대한 법적 대응을 하겠다는 의사를 밝히고 다른 병원에 취업한 사실을 알고 근로자의 후임자를 고용하기도 하였다.

- 근로자는 2021.9.10. 충남지방노동위원회에 부당해고 구제신청을 하였다. 사용자는 문자 메시지로 해고를 통보한 것은 절차 위반이 명백하다고 판단하여 적법한 절차를 거쳐 근로자를 다시 해고하기 위해 2021.9.30. 18:26 근로자에게 카카오톡 메시지 등으로 2021.10.1.자 복직 및 출근명령을 하였다. 근로자(대리인 노무사)는 2021.9.30. 21:11 충남지노위에 금전보상명령을 신청하였고, 충남지노위는 2021.10.1. 사용자에게 금전보상명령 신청 사실을 알리며 금전보상액을 계산하기 위한 근거자료를 요청하였다.

- 사용자는 2021.10.1. 근로자에게 2021.10.8. 개최되는 인사위원회에 출석할 것(출석요구서: 징계혐의(인사명령 거부, 근무지 이탈 등의 사유)로 징계에 회부되었고, 민·형사 책임을 물을 수 있다는 취지)을 통보하였다. 이에 근로자는 2021.10.1. 금전보상명령을 신청하였으므로 복직 및 출근명령, 인사위원회 출석요구에 따른 의무가 없다.라는 내용의 문서를 사용자에게 보냈다.

- 충남지방노동위원회는 2021.11.18. 사용자의 복직명령은 원상회복 조치로서 진정성을 인정하기 어렵다고 보아 금전보상명령을 하였다. 사용자는 이에 불복하여 재심 신청을 하였고, 중앙노동위원회는 2022.2.28. 사용자가 충남지노위로부터 금전보상신청명령서를 송달받기 전에 복직명령을 하여 해고를 취소하였고, 복직명령에 진정성이 없다고 보기 어려우므로 근로자의 구제신청은 구제이유가 존재하지 않는다며 초심 판정을 취소하였다.

- 한편 근로자가 재심 판정에 불복하여 제기한 행정소송에서 서울행정법원(2023.9.21. 선고 2022구합60820 판결)은 구제이유가 있고, 해고의 서면통지를 위반한 부당해고라며 재심 판정을 취소하였으며, 서울고등법원(2024.8.21. 선고 2023누60218 판결) 역시 1심 판결을 유지하였다. 고등법원이 사용자의 복직명령에도 금전보상의 구제이유가 있다고 판단한 주요 논거를 보면, 부당해고 구제명령제도는 부당한 해고를 당한 근로자에 대한 원상회복, 즉 근로자가 부당해고를 당하지 않았다면 향유할 법적 지위와 이익의 회복을 위해 도입된 제도로서, 근로자 지위의 회복만을 목적으로 하는 것이 아니고, 근로자가 해고 기간 중 받지 못한 임금을 지급받기 위하여 민사소송을 제기할 수 있음은 물론이지만, 그와 별개로 신속·간이한 구제절차 및 이에 따른 행정소송을 통해 부당해고를 확인받고, 부당해고로 입은 임금 상당액의 손실을 회복할 수 있도록 하는 것이 부당해고 구제명령제도의 취지에 부합한다.라는 대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 판결을 인용하며, 근로자는 해고의 정당성을 다투면서 원직복직 의사에 유무에 따라 원직복직명령 및 임금지급명령을 신청하거나 금전보상명령을 신청할 수 있는 것이며, 그럼에도 근로자가 금전보상명령 신청을 하기 전에 사용자의 원직복직명령이 있었다는 사정만으로 구제이유가 소멸한다고 보게 되면, 근로자가 당초부터 원직복직을 원하지 아니함에도 금전보상명령 신청과 원직복직명령의 접수 또는 송달의 선후라는 우연한 사정에 의하여 부당해고에 대한 구제신청 절차에서 해고의 부당 여부에 관한 판단도 받지 못한 채 다시 임금청구소송 등 민사소송절차를 통해서만 해결하여야 하고, 해고 기간 중의 미지급 임금과 관련하여 강제력 있는 구제명령을 얻을 이익을 누릴 수 없게 되는 부당한 결과를 초래한다.라고 판단하였다.

- 대법원은 근로기준법 제30조 제3항은 노동위원회는 부당해고에 대한 구제명령을 할 때에 근로자가 원직복직을 원하지 아니하면 원직복직을 명하는 대신 근로자가 해고 기간 동안 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액(이하 임금 상당액이라 한다) 이상의 금품을 근로자에게 지급하도록 명할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 금전보상명령은 원직복직명령을 대신하는 것이고, 그 금액도 임금 상당액 이상의 금액이므로, 부당해고 구제신청 후 사용자가 해고를 취소하여 원직복직을 명하고 임금 상당액을 지급하였더라도 특별한 사정이 없는 한 근로자가 금전보상명령을 받을 구제이유가 소멸하는 것은 아니다.라는 기본 법리를 제시하면서 위 【판결요지】와 같이 판단하였다. 타당한 결론이다. 그리고 구제이유의 존부는 구제명령을 할 당시를 기준으로 판단하여야 하므로, 중앙노동위원회는 재심 판정 당시를 기준으로 구제이유가 있는지를 판단하여야 한다.

II. 평석과 확장 적용 가능성 등

1. 대법원과 원심의 공통점과 차이

- 중앙노동위원회를 제외한 모든 심급에서, 복직명령(해고의 철회)에도 불구하고 금전보상명령에 대한 구제이유를 인정하였다는 점은 공통된 결론이다. 그러나 지노위는 복직명령이 진정성이 없다는 논거로, 행정법원과 고등법원은 금전보상제도의 취지 외에도 근로자가 사용자의 복직명령에 따를 의무가 있다고 볼 수 없다는 논거로 구제이유를 인정하였다. 한편 대법원은 위 【판결요지】에서 보듯이 근로자가 금전보상명령을 신청하였다면 복직명령(해고의 철회)의 진정성 여부나 시기는 구제이유에 영향을 주지 않는다고 판단하였다. 즉 복직명령의 시기에 따른 유효성 내지 진정성을 따질 필요가 없다는 점을 분명히 하였다.

2. 확장 적용 가능성

(1) 논의의 전제

- 근로자의 해고고지이든 사용자의 해고이든 근로자 또는 사용자의 일방적 의사표시에 의해 근로관계를 종료시키는 형성권의 행사로서, 단독행위에 해당한다. 따라서 그 의사표시가 상대방에게 도달한 이상 상대방의 동의 없이는 이를 철회할 수 없다. 해고고지 또는 해고가 유효하게 철회되었다고 보기 위해서는 철회 또는 취소에 대해 상대방이 동의하거나 추인했는지 여부가 핵심이다.

- 그동안 사용자의 복직명령에 대해서는 그 의사표시 자체의 유효성(즉, 해고제한규정의 적용을 피할 의도로 진정성 없이 형식적으로 이루어진 것인지 여부)만이 문제되었을 뿐, 해고의 의사표시가 적법하게 철회되었는지, 다시 말해 근로자의 동의 또는 추인이 있었는지 여부는 법적 쟁점으로 다루이지 않았다. 왜냐하면 원직복직을 구하는 부당해고 구제신청은 그 자체가 사용자의 해고 철회(복직명령)에 대한 동의 또는 추인으로 해석될 수 있으므로, 구제신청의 목적이 이미 달성된 것으로 보기 때문이다. 그러나 근로자가 해고의 정당성을 다투면서 원직복직명령 대신 금전보상명령을 신청할 수 있는 현행 구제명령제도(2007. 1. 26. 개정된 근로기준법 제30조 제3항)에서는 달리 판단해야 한다. 더 나아가 사용자가 일방적으로 해고를 한 후 다시 일방적으로 이를 철회하는 방식의 복직명령은 근로자의 명시적 동의 없이는 효력을 발생시킬 수 없으므로, 근로자는 이에 따를 법적 의무를 부담하지 않는다.

(2) 부당해고 구제신청 후 사용자의 해고 철회(복직명령)와 근로자의 금전보상명령 신청(구제신청 당시 또는 신청 후)이 있는 경우(대법판결의 사안)

- 앞서 보았듯이 사용자의 복직명령과 근로자의 금전보상명령 신청 간의 선후 관계와 무관하게 구제이유는 인정되며, 복직명령의 진정성 여부를 따질 필요도 없다. 근로자가 원직복직을 선택하지 않고 금전보상명령을 신청한 것은 사용자의 해고 철회 또는 취소(복직명령)에 대해 동의하지 않았다는 명시적인 의사표시로 볼 수 있으므로 해고는 적법하게 철회되지 않은 것이다.

- 다만, 사용자가 금전보상액(임금 상당액 이상 : 지노위 경우 초심 판정 시까지의 임금 상당액 + α , 중노위 경우 재심 판정 시까지의 임금 상당액 + α)을 지급하였다면 근로자로서는 금전보상명령을 구할 이익은 소멸(구제신청의 목적이 달성됨)하였다고 볼 수 있다. 그런데 여기서 사용자가 임금 상당액만을 지급한 경우는 어떻게 볼 것인가? 위 대법원 판단(사용자가 임금 상당액 이상의 정당한 금전보상을 하지 아니한 이상 금전보상명령의 구제이익이 소멸되었다고 볼 수 없고, 부당해고 구제신청 후 사용자가 해고를 취소하여 원직복직을 명하고 임금 상당액을 지급하였더라도...구제이익이 소멸하는 것은 아니다.)에 따르면 근로자는 α (즉 임금 상당액을 초과하는 금전보상)를 구할 구제이익이 있다고 해석해야 한다.

[3] 부당해고 구제신청 이전에 사용자가 해고를 취소하거나 철회(복직명령㉠)했음에도 근로자가 구제신청(원직복직명령 또는 금전보상명령)을 한 경우

- 사용자가 해고를 철회했음에도 근로자가 노동위원회에 부당해고 구제신청을 하는 이유는, 첫째, 사용자의 복직명령이 진정성이 없다거나 형식적이어서 여전히 해고되었다고 주장하며 원직복직명령 내지 금전보상명령을 구하는 경우이다. 둘째, 비록 사용자의 복직명령이 유효하게 이루어졌다고 하더라도, 근로자가 금전보상명령을 구하는 부당해고 구제신청을 제기함으로써 해고의 철회에 동의하지 않는다는 의사를 명시적으로 표명하는 경우이다.

- 먼저, 사용자가 해고를 철회했음에도 근로자가 원직복직을 구하는 구제신청을 하는 경우이다(초심 판정 시까지 신청 취지를 변경하지 않고 원직복직명령을 구하는 경우). 이러한 경우는 원직복직을 구하는 구제신청 자체가 일응 ㉠행위에 대한 동의나 추인을 한 것으로 볼 여지도 있으나, 위에서 언급하였듯이 사용자의 ㉠행위의 유효성을 다투는 경우이다. 따라서 이와 같은 경우는 사용자의 복직명령이 유효하며 진정성을 갖추었는지 여부에 따라 구제이익의 존부가 판단된다. 만약 사용자의 복직명령이 유효하고 진정성이 인정된다면, 근로자가 원직복직을 구하는 구제신청은 사용자의 해고 철회에 대한 동의로 해석될 수 있으며, 이에 따라 구제신청의 목적이 이미 달성된 것으로 보아 구제이익이 없다고 판단할 수 있다. 이와 관련하여, 근로자가 구제이익이 없다는 초심 판정에 불복하여 재심을 신청하면서 금전보상명령을 구하는 사례가 있을 수 있다. 근로자가 해고 철회에 대해 동의한 것으로 볼 수 있는 경우에는 이후 이를 번복할 수 없으므로 재심 판정 시에도 여전히 구제이익은 존재하지 않는 것으로 보아야 한다. 반면 사용자의 복직명령이 유효하지 않거나 진정성이 결여되었다고 판단되는 경우에는 해고가 실질적으로 철회된 것으로 볼 수 없으므로 근로자에게는 여전히 구제이익이 존재한다.

- 다음으로, 사용자가 해고를 철회하였음에도 근로자가 금전보상명령을 구하는 취지의 부당해고 구제신청을 제기하는 경우이다(최초 구제신청 이후 금전보상명령을 구하는 경우도 포함된다). 이는 근로자가 복직명령의 유효성을 다투거나, 복직명령이 진정성이 있더라도 이에 대해 명시적으로 동의하지 않으며(해고의 부당성을 전제로) 금전보상명령을 구하는 경우이다. 이는 주로 근로자가 해고 기간 동안 받았을 임금 상당액을 사용자로부터 지급받지 못하거나, 복직명령 불응에 따른 무단결근 처리로 인한 임금 손실이나 징계 등의 불이익이 발생하는 사례일 것이다. 비록 이 사안은 복직명령이 구제신청 이전에 이루어졌다는 점에서 대법판결의 사안과 차이가 있으나, 이러한 차이만으로 대법판결과 달리 판단할 이유가 없어 보인다. 따라서 근로자가 금전보상명령을 신청한 것은 대법판결의 사안과 마찬가지로 사용자의 해고 철회(복직명령)에 대해 (원직복직 대신에) 금전보상을 신청한 것이므로 복직명령에 대해 명백하게 동의하지 않음을 밝힌 것으로 구제이익이 있다고 보아야 한다. 즉 사용자의 진정성이 있는 복직명령이 있더라도 근로자가 이에 동의하지 않은 이상 이를 따를 의무가 없다고 보아야 한다.

3. 금전보상명령의 신청 시기와 관련하여

- 근로기준법 제30조 제3항은 노동위원회는 부당해고에 대한 구제명령을 할 때에 근로자가 원직복직을 원하지 아니하면 원직복직을 명하는 대신 금전보상명령을 할 수 있도록 규정하고 있다. 이 규정의 취지를 고려하면 금전보상명령은 구제명령이 내려지기 전까지, 즉 판정하기 전까지 신청하면 족하다고 보아야 한다. 그리고 노동위원회는 실질적으로 근로자의 원직복직 의사를 확인하여 금전보상명령을 할 수 있는 것이지, 형식적으로 금전보상명령 신청서가 제출된 경우나 구제신청 당시 이미 그 취지를 명시한 경우에 한하여 금전보상명령을 할 수 있는 것은 아니다(원심 판결 등 참조). 따라서 금전보상명령을 신청하고자 하는 근로자는 심문회의 개최일을 통보받기 전까지 금전보상명령신청서를 제출하여야 한다고 정한 노동위원회규칙 제64조 제3항은 개정할 필요가 있어 보인다. 노동위원회규칙이 행정규칙임을 감안하더라도, 이 규정은 근로자의 입장에서 심문회의 개최일 통보 시점을 예측하기 어렵고, 결과적으로 신청기한을 노동위원회의 재량에 맡기는 형상이 된다. 또한 모법인 근로기준법 제30조 제3항과 부합하지 않으며, 판례의 입장과도 배치될 뿐 아니라, 실무상 행위기준으로서의 기능조차 제대로 수행하지 못하고 있다는 점에서 더욱 개정할 필요가 있다.

<근로자파견관계 판단의 판단기준> 대법원 2025.06.12. 선고 2022다166, 2022다173(병합), 2022다180(병합) 판결

【판결 요지】

- 구 파견근로자 보호 등에 관한 법률(2006.12.21. 법률 제8076호로 개정되기 전의 것, 이하 구 파견법이라고 한다) 제6조제3항 본문의 직접고용간주 규정은 사용자주와 파견근로자 사이에 발생하는 법률관계와 이에 따른 법적 효과를 설정하는 것으로서 그 내용이 파견사업주와는 직접적인 관련이 없고, 위와 같은 법률관계의 성립이나 법적 효과 발생 후 파견사업주와 파견근로자 사이의 근로관계가 유지되고 있을 것을 그 효력존속요건으로 요구하고 있다고 할 수도 없다. 따라서 사용자주와 파견근로자 사이에 직접고용관계의 성립이 간주된 후 파견근로자가 파견사업주에 대한 관계에서 사직하거나 해고당하였다고 하더라도, 이러한 사정은 원칙적으로 사용자주와 파견근로자 사이의 직접고용간주와 관련된 법률관계에 영향을 미치지 않는다.

Ⅰ. 사실관계 및 법원 판결 경과

- 피고 ○○전자서비스는 ○○전자가 생산한 전자제품의 수리, 판매(부품, 액세서리), 유지보수 등을 목적으로 설립된 회사이고, 원고 A는 ○○전자서비스와 서비스업무계약을 체결한 사내 협력업체(GPA: Great Partnership Agency, 이하 협력업체라 한다) 소속 근로자로서 ○○전자 제품에 대한 수리를 주된 업무로 하는 서비스기사이다.

- 당초 2013년 7월 원고 A를 포함한 협력업체 서비스기사 1,335명이 ○○전자서비스를 상대로 협력업체는 사업 경영상의 실체가 없으며 ○○전자서비스의 노무대행기관으로서 역할을 하는 것에 불과하여 ○○전자서비스와 협력업체 서비스기사들 사이에 묵시적 근로계약 관계가 성립하고, 설명 묵시적 근로계약관계가 인정되지 않는다고 하더라도, ○○전자서비스와 협력업체 사이에 체결된 도급계약은 그 실질에 있어서는 근로자파견계약에 해당하므로 근로자지위확인 및 고용의사표시를 할 의무가 있다.며 소송을 제기하였다.

- 소송 과정에서 피고 ○○전자서비스는 협력업체들은 사업경영상, 인사·노무상의 독립성을 가지고 운영되는 별개의 사업주이며, 독자적으로 소속 근로자인 서비스기사들에게 업무상 지휘·명령권을 행사하고 있으므로 서비스기사들과 ○○전자서비스 사이에 묵시적 근로계약관계가 성립하였거나 근로자파견관계가 성립하였다고 할 수 없다.고 주장하였다.

- 그런데, 소송을 제기한 협력업체 서비스기사 대부분은 2017.1.12. 1심에서 패소한 후 항소심(2심) 진행 중 소송을 취하하였고, 원고 A를 포함한 단 4명만이 소송을 이어가 항소심(2심)에서 원고 승소 판결을 받았으나, 이 중 3명이 대법원 심리 과정에서 소를 취하해 원고 A만 남게 되었다.

- 1심은 ○○전자서비스와 서비스기사들 사이에 묵시적 근로계약관계가 성립했다고 단정할 수 없고 근로자파견관계에 해당한다고 보기도 어렵다.고 판단하였으나, 항소심(2심)은 협력업체에 고용된 서비스기사들이 ○○전자서비스 사업의 핵심 업무인 ○○전자 제품의 수리, 유지보수 업무에 관하여 ○○전자서비스로부터 직·간접적으로 상당한 지휘·명령을 받으면서 ○○전자서비스를 위한 근로에 종사하였다고 판단된다. 따라서 근로자파견관계가 있었다고 충분히 인정할 수 있다.라면서 1심을 뒤집고 원고 A를 포함한 서비스기사들의 주장을 인용하는 판결을 하였다. 그리고 최종적으로 2025.6.12. 대법원이 원고 A가 ○○전자서비스와 근로자파견관계에 있었다고 본 항소심(2심)의 결론은 정당하다고 판결하여 장장 12년에 걸친 소송은 확정되었다.

Ⅱ. 근로자파견관계 판단의 판단기준

- 근로자파견관계의 판단기준(근로자파견과 도급의 구별 기준)은 대법원 2015.2.26. 선고 2010다106436 판결 등 2015년 대법원 판례 법리에 근거하고 있다. 대법원 판례 법리가 제시하고 있는 근로자파견관계의 판단기준은 ① 원청기업이 상당한 지휘·명령을 하는지, ② 원청기업의 사업에 실질적으로 편입되었다고 볼 수 있는지, ③ 협력업체가 인사권을 독자적으로 행사하는지, ④ 도급계약 내용이 확정되고 구별되며 협력업체에 전문성·기술성이 있는지, ⑤ 협력업체가 사업독립성을 갖추고 있는지의 5가지이다(대법원 2015.2.26. 선고 2010다106436 판결, 대법원 2015.2.26. 선고 2010다78316 판결, 대법원 2015.11.26. 선고 2013다14965 판결 등 참조).

- 다만, 대법원은 근로자파견관계를 판단하기 위한 5가지 기준을 제시하면서 그 판단기준들 사이에 비중이나 우열관계를 언급함이 없이 병렬적으로 나열한 다음 이를 바탕으로 근로자파견관계를 판단하고 있다. 2015년 대법원 판결 이후 법원은 이와 같은 대법원의 근로자파견관계 판단기준에 따라 근로자파견관계를 판단하고 있다.

- 대상 대법원 판결은 항소심(2심)의 결론이 정당하다고 판단하였는데, 항소심(2심) 판결을 살펴보면, ○○전자서비스의 사업과 협력업체의 수행업무로 정한 업무가 동일하여 ○○전자서비스의 필수적이고 상시적인 업무라는 표현으로는 부족할 정도이고, 실제 협력업체들은 ○○전자서비스가 수행하는 수리 물량의 98%가량을 처리하였으며, 이에 ○○전자서비스는 협력업체 서비스기사의 업무수행 결과뿐 아니라 수행 방법, 수행 태도 등 구체적인 수행 내용에 대하여 상당한 지휘·감독을 해야 할 필요성이 분명하였고, 실제 협력업체 서비스기사들에게 전산시스템을 통해 업무를 수행하게 하고 업무매뉴얼을 제공하는 등 상당한 지휘·감독을 하였음을 인정하면서 근로자파견관계를 인정하였다.

- 항소심(2심)은 ○○전자서비스의 사업내용 및 사업목적, 도급계약(도급업무)의 내용, 도급업무 과정 및 수행방법 등을 살펴보고 도급계약에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 실제 ○○전자서비스가 상당한 지휘·명령을 하였는지, ○○전자서비스의 사업에 실질적으로 편입되었는지의 순서로 근로자파견관계를 판단하였는데, 이와 같은 검토 및 판단 순서는 근로자파견관계 판단의 논리적 연계성에서 적절하다고 판단된다.

- 근로자파견관계 판단의 핵심 판단기준이 원청기업이 사용자로서 상당한 지휘·명령을 하는지 여부라는 것에는 이견이 없다. 다만, 도급지시권과의 관계에서 원청기업이 사용자로서 상당한 지휘·명령을 하는지 여부에 대하여 판단하기 쉽지 않다.

- 이에 근로자파견관계 판단의 핵심 판단기준인 ① 원청기업이 상당한 지휘·명령을 하는지를 판단하기 위해 (i) 원청기업의 사업 및 사업목적이 무엇이고 도급계약의 내용이 무엇인지, (ii) 어떤 절차와 방법으로 도급업무가 수행되는지, (iii) 도급업무가 원청기업의 목적사업을 위한 상시적으로 필요한 주된 업무인지, (iv) 도급업무 수행절차, 작업내용, 속도, 배치, 작업조건 등에서 원청기업의 개입 및 구속이 있는지 등을 살피고, ④ 도급업무의 확정성·구별성 및 협력업체에 전문성·기술성이 있는지와 ② 원청기업의 사업에 실질적으로 편입되었다고 볼 수 있는지를 보완적인 지표로서 종합적으로 검토하여야 할 것이다.

- 물론 ③ 협력업체가 인사권을 독자적으로 행사하는지와 ⑤ 사업독립성을 갖추고 있는지에 대한 판단기준을 무시하자는 것은 아니지만, 협력업체가 사업독립성도 없고 인사권도 독자적으로 행사하지 못한다면 묵시적 근로계약관계 성립을 인정할 수밖에 없을 것이다.

<임원수행기사 도급 업무의 파견 해당 여부> **서울고등법원 2025.01.10. 선고 2024나2008315 판결**

【판결 요지】

- 근로자파견의 성립 여부는 실제로 그 업무가 운영된 모습과 구체적인 작업방식에 비추어 판단되어야 하고, 수행한 업무에 따라 구체적인 지휘·명령의 형태가 다르게 나타나므로 수행한 업무의 특성이 반영되어야 한다. 임원 수행 운전기사의 업무형태 특성은 상시로 운행 또는 대기하면서 일정과 행선지가 특정되어 있지 않은 불특정한 구간을 운행하는 것이다. 도급인은 도급계약의 내용에 따라 수급인의 이행보조자 등에게 일의 완성을 위한 지시를 할 수 있는 경우도 있으며, 도급인의 지시권에는 일의 완성에 필요한 정보를 제공하는 것이 포함되므로 도급인은 당연히 급부의 종류, 범위 및 내용 등을 특정할 수 있는 권한이 있다. 임원 수행기사인 원고들은 그 수행 업무의 특성상 구체적인 운행 장소 및 시간 등을 전달받아야만 업무를 수행할 수 있고, 특히 임원은 행선지와 일정이 유동적인 측면이 있어 그때그때 변동되는 사항에 관한 정보를 운전기사에게 직접 전달할 필요성이 있다. 임원이나 그 비서의 카카오톡 메시지, 문자 메시지 등은 출발시간, 도착 장소 등 운행 일정을 공유하거나 확인하는 내용으로, 피고(도급인)가 이를 통해 원고들에게 직접 운전 업무수행 그 자체에 관한 구속력 있는 지휘·명령을 하였다고 보기는 어렵다.

I. 서 언

- D사에 소속되어 D사가 C사와 체결한 차량운전 및 관리도급계약에 따라 C사의 임원 수행기사 업무를 수행한 원고 A, B는 자신들이 행한 도급 업무의 실질은 법적으로 불법파견이며, 이에 따라 원고들은 피고 C사가 원고들에게 직접 고용의 의사표시를 하여야 하며, 더불어 직접 고용의무 불이행으로 인한 손해배상을 하여야 한다고 소를 제기하였다. 1심 판결은 기존 대법원이 제시한 근로자파견 판단 요소 5가지를 바탕으로, 원고들은 피고 C사의 파견근로자에 해당하지 않으므로 피고가 원고들에게 고용의 의사표시를 할 의무도, 손해배상의 의무도 없다고 보았다. 원고들이 1심 판결에 대해 항소를 제기하여 서울고등법원에서 치열한 법리 다툼이 전개되었고 본 건 대상판결이 선고되었다. 대상판결 역시 근로자파견 판단 요소 5가지를 바탕으로 판단하였으며, 1심 판결이 유지되었다. 원고 A, B는 상고를 미제기하여 본 대상판결은 최종 확정되었다.

- 한편 과거 다수 사례에서 법원은 임원 수행기사 도급 업무에 대해 이를 불법파견으로 판단한 바 있다. 본 대상판결은 이와 결론을 달리하고 있어 살펴볼 필요가 있다.

- 이하에서는 대상판결에서의 적법 도급 판단 이유를 살펴보고, 그 의의를 간략히 개진코자 한다.

II. 근로자파견 판단 요소별 대상판결에서의 적법 도급 판단 이유

1. 도급인의 구속력 있는 지시 등 상당한 지휘·감독의 존부

- ① 대상판결은 도급사의 임원이나 비서가 카카오톡 메시지, 문자 메시지 등을 통해 운행 일정 등을 알리는 것이 구속력 있는 지시인가에 대해 이를 부정하면서 아래와 같이 판시하였다. 근로자파견의 성립 여부는 실제로 그 업무가 운영된 모습과 구체적인 작업방식에 비추어 판단되어야 하고, 수행한 업무에 따라 구체적인 지휘·명령의 형태가 다르게 나타나므로 수행한 업무의 특성이 반영되어야 한다고 하며, 임원 수행 운전기사의 업무형태 특성은 상시로 운행 또는 대기하면서 일정과 행선지가 특정되어 있지 않은 불특정한 구간을 운행하는 것이라고 보았다. 또 도급인은 도급계약의 내용에 따라 수급인의 이행보조자 등에게 일의 완성을 위한 지시를 할 수 있는 경우도 있으며, 도급인의 지시권에는 일의 완성에 필요한 정보를 제공하는 것이 포함되므로 도급인은 당연히 급부의 종류, 범위 및 내용 등을 특정할 수 있는 권한이 있다고 보았다. 결론적으로 대상판결은 원고들은 그 수행 업무의 특성상 구체적인 운행 장소 및 시간 등을 전달받아야만 업무를 수행할 수 있고, 특히 임원은 행선지와 일정이 유동적인 측면이 있어 그때그때 변동되는 사항에 관한 정보를 운전기사에게 직접 전달할 필요성이 있다고 하면서, 카카오톡 메시지, 문자 메시지 등은 출발시간, 도착 장소 등 운행 일정을 공유하거나 확인하는 내용으로, 피고가 이를 통해 원고들에게 직접 운전 업무수행에 관해 지휘·명령을 하였다고 볼 증거가 부족하다고 하였다.

- ② 1심 판결은 피고 C사의 총무팀에서 매주 임원들의 외부 일정을 표시한 주간운행작업지시서를 작성하여 D의 확인을 받은 후 운전기사들의 휴게실에 비치한 것은 자동차 운행 도급 업무의 지시권을 행사한 것으로 볼 수 있다고 하였다. 금번 대상판결은 주간운행작업지시서는 업무에 관한 기본적인 정보를 제공한 것이라는 전제하에 도급의 외형을 작출하기 위해 형식적으로 작성된 것이라는 원고 측의 주장을 배척하였다.

- ③ 기타 원고들이 특정 임원 차량을 장기간 운전했다는 사정만으로 피고가 운전기사 배치권을 행사했다고 보기 어렵고, 배차요청 메일도 수행 기사를 특정하지는 않았다고 보았다. 피고 C사가 운전기사들의 휴가 사용 이력 등을 전달받기는 했으나 달리 근태상황 등을 직접 보고 받았음을 인정할 증거가 없고, 임원이 허락한 경우에만 휴가를 사용할 수 있었다고 보기에 부족하다고 보았다. 현장관리인의 부재 내지 형식성과 관련해서는 운전 업무에 필요한 정보가 D에 전달되었으므로 현장관리인이 상주할 필요성이 있다고 보기 어렵거나 D의 현장관리인이 OT근무확인서를 작성하거나 운전기사 평가업무 등을 수행하였기에 이를 형식적인 것이었다고 평가하기 어렵다고 보았다. 또한 OT근무확인서, 운행일지 등을 피고 C사가 제출받은 것은 도급사무의 결과에 대한 확인에 불과할 뿐 상당한 지휘·명령권 행사로 보기는 어렵다고 보았다.

2. 하나의 작업집단으로 구성되어 직접 공동 작업을 하는 등 도급인 사업에의 실질적 편입 여부

- 대상판결에서 원고들은 피고 소속 근로자들의 업무 역시 임원 차량 운전 또는 업무차량관리로서 동일하다고 주장하였다. 그러나 대상판결은 운전 업무량이 증가하는 예외적인 상황에서 일시적으로 같은 업무를 한 정도로 보이며, 원고들이 피고 소속 운전기사들과 동일한 업무를 수행하였음을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다고 판단하였다. 피고 소속 근로자 G 명의의 이메일 계정을 피고 소속 근로자와 D 소속 운전기사들과 함께 공용으로 사용하긴 하였으나 이는 운전 업무 진행 내역을 공유한 것에 불과하고, 피고 총무팀이 D 소속 운전기사들을 직접 배차한 것은 아니어서 하나의 작업집단으로 공동 작업을 수행했다고 할 수 없다고 보았다. 또 D(수급업체) 소속 근로자의 부탁으로 피고 소속 운전기사가 대신 근무를 한 사실이 있더라도, 이는 운전기사들의 개인적 사정에 따라 일회적으로 업무를 도와준 것에 불과하여 대체근로를 인정할 수 없고, 기사 대기실을 함께 사용한 것만으로 동일한 작업집단을 이루었다고 볼 수 없다고 판단하였다.

3. 도급인이 채용·교육·훈련, 휴가 등에 관한 권한을 독자적으로 행사하였는지 여부

- 원고들은 피고 C가 D 소속 운전기사들에 대해 직접 채용 면접을 실시하였다고 주장하나 이를 그대로 믿기 어렵고 달리 인정할 증거가 없다고 보았다. D의 현장대리인은 D 소속 운전기사들을 평가하기도 하였다. 피고가 D사를 통해 운전기사들의 휴가 사용 이력 등에 대한 내용을 전달받기는 하였으나 달리 휴가를 직접 관리하였음을 인정하기도 어렵다고 보았다.

4. 계약의 목적이 구체적으로 범위가 한정된 업무의 이행으로 확정되는지 여부

- 도급계약서, D의 차량도급 업무매뉴얼에 도급 업무와 관련된 제반 사항이 규정되어 있는바, 대상판결은 다소 추상적이고 일반적인 내용으로 구성되어 있으나, 이는 운전업무의 특성에 기인한 것으로 보이고, 서버버스가 아닌 임원 수행 운전기사 업무는 그 업무의 특성상 운행 횟수나 노선 등이 사전에 구체적으로 특정될 수 없는 것이므로, 도급계약서에 운행 횟수나 노선이 특정되지 않았다고 하여 도급 업무가 특정되지 않았다고 볼 수 없다고 판단하였다. 한편 도급 대가와 관련하여 비록 운전업무의 수행 정도가 아닌 1인당 도급액을 정하고 있더라도, 임원의 신속한 이동을 위하여 운행시간 및 대기시간을 확보하기 위한 필요성이 있을 것으로 보이는 점, 임원 운전기사의 특성상 운행시간이나 운행거리의 변동 폭이 클 것으로 보이지 않는 점을 고려 시 파견관계가 성립한다고 보기는 어렵다고 보았다.

5. 수급인(D)이 독립적 기업조직이나 설비를 갖추고 있는지 여부

- 대상판결은 운전업무 자체는 고도의 전문성과 기술성이 필요하다고 보이지는 않으나 수급사인 D가 기업의 임원 수행업무를 위한 노하우를 관리하기 위해 차량도급 업무매뉴얼도 제작하고 있는 것으로 보이는 점 등에 비추어 특화된 전문성과 기술성을 가지고 있지 않다는 사정만으로 파견관계가 성립한다고 보기는 어렵다고 보았다. 한편 원고들은 D사가 기사 대기실 임대차계약을 C사(피고)와 맺고 있지만 임대료가 시세보다 저렴하고, 피고가 사고 발생 시 그에 따른 처리를 담당하도록 정하고 있는 점에서 D가 독립적인 기업조직을 갖추고 있지 못하였다고 주장하나, 이는 업무수행 편의를 위한 내용으로 볼 수 있고, 자동차가 피고(C사)의 소유이므로 피고가 부담하여야 할 절차나 비용이 발생하며, 자동차 보험 보장액을 초과하거나 보험적용을 받을 수 없는 변상액의 경우 D가 배상하도록 정하고 있는 점에서 파견관계가 성립한다고 보기는 어렵다고 보았다. 아울러 D는 14개 이상의 다양한 고객사를 상대로 계약관계를 유지하는 사업체로 독자적인 근태, 인사관리 시스템을 갖추고 있는 것으로 인정된다고 보았다.

Ⅲ. 대상판결의 의의

- 임원 수행기사 도급과 관련하여 불법파견으로 판단했던 과거 사례들의 경우, 도급사의 비서나 임원이 행하는 운행 일정(장소, 시간 등) 통보는 수급사 운전기사의 운행업무 그 자체에 관한 구속력 있는 지시로서 상당한 지휘·감독을 행한 것으로 평가하였다.

- 그러나 대상판결은 도급인은 도급계약의 내용에 따라 수급인의 이행보조자 등에게 일의 완성을 위해 지시를 할 수 있는 경우도 있으며, 도급인의 지시권에는 일의 완성에 필요한 정보를 제공하는 것이 포함되므로 도급인은 당연히 급부의 종류, 범위 및 내용 등을 특정할 수 있는 권한이 있다고 보았다. 이에 따라 피고 회사의 임원이나 비서의 카카오톡 메시지, 문자 메시지 등은 출발시간, 도착 장소 등 운행 일정을 공유하거나 확인하는 내용으로, 피고가 이를 통해 원고들에게 직접 운전 업무수행에 관해 지휘·명령을 하였다고 보기 어렵다고 보았다.

- 다만 본 대상판결은 원고들의 상고 미제기로 인해 확정되어 대법원 판결을 받지 못한 한계가 있다. 이와 같이 언급하는 이유는 과거 직접 제조공정 하도급 사례이기는 하나, 원심에서 도급인의 지시권 내지 검수권을 인정하여 불법파견이 아니라고 판단하였으나 대법원에서 이를 부정하고 업무수행 그 자체에 대한 구속력 있는 지시로 본 사례가 있기 때문이다.

- 임원 수행기사 도급 업무가 불법파견인지 적법도급인지 여부를 판단함에 있어 도급인이 수급인 소속 운전기사들에 대해 업무수행 그 자체에 관한 구속력 있는 지시로서 상당한 지휘·감독을 하였는지를 구체적으로 파악하여야 할 뿐만 아니라, 임원 수행기사 업무의 특수성이 감안되어야 할 것이다. 대상판결은 임원 수행기사 업무는 행선지와 대기 일정 등이 유동적인 측면이 있고, 임원의 일정에 따른 구체적인 요청에 따라 운행을 해야 하는 특수 성격이 충분히 감안될 필요가 있음을 시사하고 있다.

<체험형·채용형 인턴에게 성과급을 미지급한 것이 차별적 처우인가> 서울중앙지방법원 2024.10.24. 선고 2022가합557780 판결

【판결 요지】

- 원고들은 피고(한국조폐공사)의 체험형·채용형 인턴 제도를 통해 계약직 또는 정규직으로 전환된 근로자들이었는데, 피고는 그 기간에 근로자들에게 성과급을 지급하지 않았다. 법원은 채용형 인턴 기간 성과급을 지급하지 않은 것은 비교 대상 근로자인 정규직 근로자들과 달리 합리적인 이유 없이 차별한 것으로 판단하였다. 다만, 체험형 인턴은 정규직 근로자와 비교 대상 근로자에 해당한다고 보기 어렵다고 보아 기간제법 제8조 제1항의 차별적 처우를 인정하지 않았다. 한편, 법원은 인턴 또는 계약직이라는 지위가 성, 국적, 신앙에 준할 정도의 고정적인 지위라거나 사회적 평가를 수반하는 것으로 보기에 어렵다고 보아 근로기준법 제6조의 사회적 신분에 해당하지 않는다고 판단하였다.

I. 사실관계

- 피고는 한국조폐공사법에 따라 설립되어, 은행권, 주화, 국채, 공채, 각종 유가증권 및 정부·지방자치단체 등이 사용할 특수제품의 제조와 그 밖에 이와 관련된 사업을 하게 함으로써 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 하는 법인이다.
- 피고는 2009년부터 2013년까지 체험형 인턴 제도를 도입하여 운영하였다. 체험형 인턴을 거친 자들 중 실제 정규직 채용이 가능할 정도의 평가를 받은 자들은 별도의 절차를 거쳐 피고의 정규직 근로자로 채용되었다. 피고는 이 시기에 체험형 인턴 제도와 별도로 신입직원을 정규직 근로자로 채용하여 수습 직원으로 발령한 후 일정 기간을 거친 후 정식 발령하였다.
- 피고는 2014년부터 정부 지침에 따라 채용형 인턴 제도를 도입하여 운영하였다. 채용형 인턴 제도에 따라 신입직원을 채용형 인턴으로 채용한 후, 일정한 기간을 거친 후 그중 상당수를 정규직 근로자로 전환하였다. 이 시기에 피고는 채용형 인턴 제도와 별도로 신입직원을 정규직 근로자로 채용하는 절차를 운영하지 않았다.
- 원고는 피고의 인턴으로 채용되어 인턴 기간을 거쳐, 계약직 또는 정규직 근로자로 전환된 자들이다. 피고는 원고들이 인턴 내지 계약직 근로자로 근무한 기간에 성과급을 지급하지 않았다. 원고들은 피고가 성과급을 지급하지 않은 것이 정규직 근로자들과 비교하여 차별적인 처우를 한 것으로서 근로기준법 제6조 또는 기간제법 제8조 제1항을 위반한 불법행위를 한 것이므로 손해배상을 하라고 청구하였다.

II. 대상판결의 쟁점

1. 인턴의 지위가 근로기준법 제6조의 사회적 신분에 해당하는지

- 근로기준법 제6조에서 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성별, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다고 규정하고 있으며, 근로기준법 제114조에서 위 규정을 위반한 자에 대하여 500만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다. 위 조항에서 사용된 사회적 신분이라는 용어는 헌법 제11조 제1항 후문과 국가인권위원회법 제2조 제3호에도 사용되고 있다.
- 헌법재판소는 헌법 제11조 제1항의 사회적 신분에 대하여 사회에서 장기간 점하는 지위로서 일정한 사회적 평가를 수반하는 것이라고 정의한 바 있다(헌법재판소 1995. 2. 23. 선고 93헌바43 결정 참조). 법률을 해석할 때 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석 방법에 따라서 근로기준법 제6조의 사회적 신분에 대한 해석도 헌법과 갈래 해석해야 할 것이다.
- 근로기준법 제6조 위반에 대하여 형사적 처벌을 전제로 한 벌칙조항이 있는 만큼 예측 가능성이 있도록 해석해야 하므로 성별, 국적, 신앙과 달리 사회적 신분은 그 포섭하는 범위가 명확하지 않으므로 사회적 신분이라고 보려면, 같은 조항에서 차별의 근거로 들고 있는 다른 항목들과 대등하다고 할 수 있을 정도의 특성, 즉 쉽게 변경할 수 없다는 의미에서 고정성이 전제되어야 한다.
- 인턴 또는 기간제 근로기간이 2개월부터 12개월까지로 1년을 초과하지 않는 점, 피고의 인턴 내지 계약직 근로자가 되기 위하여 일반적인 채용 절차에 필요한 자격 기준을 넘어서는 특별한 자격 기준을 요구하지 않는 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 원고들의 인턴 또는 계약직이라는 지위가 성, 국적, 신앙에 준할 정도로 사회에서 쉽게 변경할 수 없는 고정적인 지위라거나 근로자의 특정한 인격과 관련된 표시로서 일정한 사회적 평가를 수반하는 것이라고 보기 어려워 인턴의 지위는 근로기준법 제6조의 사회적 신분에 해당하지 않는다.

2. 체험형 인턴에게 성과급을 지급하지 않은 것이 기간제법 제8조 제1항의 차별인지

- 피고는 체험형 인턴의 취업을 지원하기 위하여 체험형 인턴이 수험표 등으로 확인할 수 있는 각종 취업 시험에 응시할 때 특별휴가를 부여하였다. 또한, 체험형 인턴이 노동부 주치 취업박람회 참가하고 이를 입증할 때 출장으로 처리하여 근무시간으로 인정하였다. 나아가 체험형 인턴의 평가 결과가 우수한 경우에는 해당 대상자가 타 회사에 지원할 때 최대 10회까지 추천서를 발행하였다. 이러한 점은 원고가 인턴 기간이 종료한 이후에 피고에서 계속 근무할 것이라는 점에 관한 합리적 기대가 존재하지 않는다는 점을 보여주는 것이다.
- 또한, 피고의 인턴 운영 지침에 인턴의 근태와 근무 명령을 정규직과 같게 하고 경력관리를 위한 적절한 업무 부여를 하라는 내용이 있으나, 이는 인턴들이 취업을 위한 경력을 쌓을 수 있도록 적극적으로 기회를 부여하라는 취지이지 정규직 근로자와 같은 수준으로 업무 부여를 하라는 취지로 볼 수 없다.
- 또한, 법원은 원고들의 체험형 인턴 근무 기간 업무분장표에 추상적으로 업무 내용이 기재되어 있었고, 피고 전산시스템의 직접적인 접근이 불허되었고, 업무 수행상 필요한 경우에 체험형 인턴의 멘토를 통하여 데이터가 제공되었다는 점 등을 보아 정규직 근로자를 체험형 인턴들에 대한 비교 대상 근로자로 보기 어렵고, 기간제법 제8조 제1항에서 금지하는 차별적 처우가 존재한다고 보기 어렵다고 판단하였다.

3. 체험형 인턴 후 계약직 근무 기간 성과급을 미지급한 것이 기간제법 제8조 제1항의 차별인지

- 체험형 인턴과 계약직 경력을 가진 원고들은 계약직 근로자로 근무하였던 시기에 성과급을 지급하지 않은 것이 차별이라고 주장하나, 계약직 근로자로 근무한 기간 수행한 구체적인 업무 내용과 근무 상황을 확인할 증거가 없어 체험형 인턴·계약직 근로자의 비교 대상 근로자가 피고의 정규직 근로자라고 인정하기 어렵다.
- 체험형 인턴·계약직 경력 원고들은 매월 정기적으로 지급되는 임금(본봉, 직책수당, 통근수당 등)과 부정기적으로 지급되는 임금(정기상여, 성과상여, 하계휴가비, 맞춤형 복리비 등)이 월 임금에 포함되는 포괄임금제 형식의 근로계약을 체결한 사실이 인정되므로, 피고가 성과급을 지급하지 않은 것이 정규직 근로자들과 비교하여 차별적 처우를 한 것이라고 인정하기 어렵다.

4. 채용형 인턴에게 성과급을 지급하지 않은 것이 기간제법 제8조 제1항의 차별인지

(1) 비교 대상 근로자의 확정

- 피고의 채용형 인턴 제도는 채용형 인턴이 그 인턴 기간을 마치면 특별한 사정이 없는 경우에 정규직 근로자로 전환되는 것을 전제로 한 제도이다. 실제로 2014년부터 2022년까지 채용형 인턴 제도를 통해 입사한 자들 가운데서 피고의 정규직 근로자로 전환되기를 희망한 자는 2018년 1명을 제외하고 497명 모두 피고의 정규직 근로자로 전환되었다.
- 채용형 인턴들은 입사하여 정규직 근로자와 마찬가지로 독자적인 업무를 부여받았고 일부의 경우에는 채용형 인턴 원고들을 지원하기 위한 보조 인원이 배치되기도 하였다. 또한 채용형 인턴들은 정규직 근로자로 전환된 이후에도 기존과 같은 부서에서 같은 업무를 수행하였다. 원고들이 채용형 인턴으로 근무하면서 직무교육 또는 멘토링 프로그램을 받았고, 체험형 인턴과 함께 비밀취급 인가 금지, 중요시설·지역 출입 통제, 중요문서·자재 취급 금지, 대내외 비

밀 및 중요정책과 관련된 업무 위임 금지 등을 통해 보안상 책임 있는 업무 부여를 금지당하여 정규직 근로자의 업무 내용과 다소 차이를 보이기는 했지만, 원고들이 실제 수행한 주된 업무의 내용, 범위가 정규직 근로자가 수행하는 업무와 본질적인 차이를 보인다고 할 수 없다.

- 피고는 채용형 인턴이 수습 기간에 해당하는 기간에 인턴이라는 명칭을 사용한 것이므로 기간제 근로자로 볼 수 없다고 주장하나, 공고문에 원고들의 신분이 기간제 근로자임을 분명히 하였고, 채용형 인턴과 체결한 근로계약서에도 계약기간을 명확히 정하였으므로 원고들은 기간제 근로자 신분이었으며, 비교대상 근로자는 피고의 정규직 근로자이다.

[2] 차별적 처우가 존재하는지

- 피고의 정규직 근로자들은 성과급 중 경영평가 성과급, 내부 평가 성과급은 근무 성과에 대한 평가를 거쳐 지급되고, 기타 성과급(고정상여금)은 피고의 정규직 근로자로 재직하기만 하면 지급 시기 및 개인별 지급액 산정에 관한 세부 기준에 따라 산정하여 지급되었다. 피고의 정규직 근로자들은 평가 대상 연도에 근무한 전체 기간에 대하여 성과급을 받았지만, 채용형 인턴 경력 원고들에게는 채용형 인턴으로 근무한 기간을 제외하고 지급하여 차별적 처우가 존재하였다.

[3] 차별에 합리적인 이유가 존재하는지

- 피고는 정규직 채용을 전제로 채용형 인턴을 채용하였고, 채용형 인턴도 2014년 이전의 피고의 정규직 근로자 신규 채용과 마찬가지로 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 채용 절차를 진행하였다.

- 채용형 인턴은 실질적으로 정규직 근로자와 마찬가지로 특정 직무·직렬의 업무를 수행하였고, 대부분 정규직으로 전환되어 근무하였기에 채용형 인턴과 정규직 근로자 간 별다른 차이가 없다.

- 이 사건 성과급은 법령, 피고의 보수 규정 등에 따라 매년 반복적으로 실제 근무 일수에 비례하여 지급되어 온 근로의 대가인데, 채용형 인턴에게는 지급하지 않는 방식으로 차별하는 것은 정당하다고 보기 어렵다.

5. 손해배상책임의 범위와 소멸시효

- 피고가 채용형 인턴 기간 원고들에게 미지급한 경영평가 성과급, 내부 평가 성과급, 기타 성과급이 손해배상책임 범위이다. 이에 대하여 피고는 불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기 소멸시효의 3년이 적용된다고 주장하나, **민법 제766조 제1항**의 손해 및 가해자를 안 날이라 함은 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생과의 사이에 상당 인과 관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 대하여 현실적이고 구체적으로 인식하였을 때를 의미한다고 할 것이다(**대법원 2008.1.18. 선고 2005다65579 판결 등 참조**).

- 기간제 근로자와 정규직 근로자 사이에 임금 격차가 존재한다는 사실만으로 사용자에게 위법행위가 성립한다고 단정할 수 없고, 사용자가 정규직 근로자와 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간제 근로자에 대하여 합리적 이유 없이 불리한 처우를 하는 경우에 비로소 기간제법이 금지하는 차별적 처우에 해당하여 위법행위로 평가될 수 있는 점, 비록 피고의 차별적 처우가 공개적으로 행해졌거나 그로부터 상당한 기간이 경과하였더라도 채용형 인턴 경력 원고들이 피고의 처분 내용을 구체적으로 검토하여 불법행위의 성립을 확인하였다고 볼 만한 자료가 없는 점 등에 비추어 보면, 채용형 인턴 경력 원고들이 피고 정규직 근로자들만이 이 사건 성과급을 받았을 당시부터 피고가 채용형 인턴 경력 원고들에 대하여 차별적 처우를 하였음을 알고 있었다고 인정하기 부족하다.

- 또한 원고들이 청구원인을 불법행위에 의한 손해배상채권이라고 명시하였으므로 그 소멸시효 기간은 원칙적으로 불법행위의 소멸시효에 관한 **민법 제76조**가 적용된다. 피고가 원고들에게 배상해야 하는 손해의 범위가 임금 차액 상당액이라 하더라도 근로관계에 기초한 임금채권과 불법행위를 원인으로 한 손해배상채권은 그 법적 성질을 달리한다. 따라서 원고들의 불법행위로 인한 손해배상청구권에 **근로기준법 제49조**의 임금채권의 소멸시효 규정을 적용할 수 없다.

III 시사점

- 신규 채용된 근로자들은 회사에 입사하여 근로를 제공하고 정규직 근로자로 고용 안정을 얻기까지 인턴, 계약직 등 명칭은 다양한 근무 평가 기간을 거치는 것이 일반적이다. 신규 직원으로 다양한 직무를 담당하고 있음에도 불구하고, 인턴 또는 계약직이라는 사유로 정규직 근로자와 달리 성과급 등 근로조건에서 차별을 겪는 경우도 많이 존재함에도 인턴 또는 계약직이라는 이유로 권리를 주장하지 못하고 참고 인내하는 경우가 대부분이다.

- 이번 판례는 채용형 인턴이라는 계약직 기간을 거쳐 정규직으로 전환된 근로자들이 인턴 기간 성과급 미지급을 청구한 사건으로 법원이 **기간제법 제8조 제1항**의 차별적 처우를 인정하였다. 다만, 체험형·계약직 인턴의 경우에는 정규직 전환이 예정되어 있지 않고 정규직 근로자와 달리 담당 업무가 구체적이지 못하다는 이유 등으로 차별을 인정하지 않았다. 후자의 예외가 있지만, 신규 채용자에 대하여 정규직 전환 전 계약직 근무 기간에도 정규직과 달리 근로조건에서 차별적 처우를 하지 말아야 한다는 기간제법상 차별적 처우 금지 법리를 재확인하여 의미 있는 판결이라고 생각한다.

<직무상유족연금과 손해배상의 조정 : 공제 후 상속 → 상속 후 공제로 변경> **대법원 2024.11.21. 선고 2021다255853 전원합의체 판결**

【판결 요지】

- 퇴직연금을 받을 수 있었던 사람이 타인의 불법행위로 인한 직무상 재해로 사망함에 따라 발생하는 망인의 일일 퇴직연금 상당 손해배상채권은 상속인들에게 각자의 상속분 비율에 따라 공동상속된다. 그 후 수급권자가 지급받는 직무상유족연금은 그 수급권자가 상속한 일일 퇴직연금 상당 손해배상채권을 한도로 하여 그 손해배상채권에서만 공제된다. 이와 달리 망인의 일일 퇴직연금 상당의 손해배상채권 전체에서 직무상유족연금을 먼저 공제한 후 그 나머지 손해배상채권이 상속인들에게 각자의 상속분 비율에 따라 공동상속된다고 볼 것은 아니다.

<1> 대상판결은 사립학교교직원 연금법(사학연금법)상 유족연금과 손해배상채권 간에 조정하는 방법이 문제가 된 사건이고, 공제 후 상속(중전 판례)에서 상속 후 공제로 변경한 전원합의체 판결이다. 그런데 이러한 입장을 취한 것은 대상판결만은 아니었다. 지난 2009년 산업재해보상보험법(산재보험법)상 유족급여와 손해배상의 조정에 대한 대법원 전원합의체 판결(대법원 2009.5.21. 선고 2008다13104 전원합의체 판결, 2009년 전합 판결)이 그것이다.

- 이 글에서는 핵심 쟁점과 관련된 사실관계를 축약하여 살펴보고서 이해를 돕기 위해 손해배상액은 각색하여 살펴본다.
- 사학연금법의 적용을 받는 대학교수가 직무 중 가해자(택시운전기사)의 불법행위로 인한 교통사고로 사망하였다. 망인에게는 사학연금법상 3명의 유족(배우자A, 자녀B1·B2, 원고들)이 있고, 이들 유족 중 배우자A가 사학연금법이 준용하고 있는 공무원 재해보상법에 따른 직무상유족연금의 수급권자가 되어 사학연금공단으로부터 위 유족연금을 수령하였거나 기대여명 종료일까지 수령할 예정이다. 한편 위와 같이 사망이 타인의 불법행위로 이루어진 경우 망인의 상속인(배우자A, 자녀B1·B2)은 일일 퇴직연금일시금 상당의 손해배상을 청구할 수 있다.
- 직무상유족연금은 유족(또는 수급권자)의 생활안정과 복지향상을 도모하기 위한 목적과 성격을 가질 뿐만 아니라 재해보상·손실전보로서의 성격을 가지는 급부이므로 손해배상과의 기능적 중복성이 인정되기 때문에 청구권 상호 간에 조정문제가 발생된다.

<예시> 손해배상채권(사망 당시로 계산한 금액, 일일 퇴직연금일시금 상당액 8,750만 원)

- 직무상유족연금(사망 당시로 계산한 금액, 44,000만 원)
- ○공제 후 상속:원심은 전체 손해배상채권에서 직무상유족연금을 먼저 공제하면 그 후 원고들에게 상속되는 일일 퇴직연금일시금 상당의 손해배상채권이 없다고 판단하였다.
- [공제 후 상속]
- (공제 단계) 손해배상금(8,750만 원) - 유족연금(44,000만 원) = 0원
- (상속 단계) 상속할 손해배상금 없음
- ○상속 후 공제:대상판결과 1심은 망인의 일일 퇴직연금일시금 상당의 손해배상채권은 상속인(배우자A, 자녀B1·B2)에게 각자의 상속분 비율에 따라 공동 상속되고, 직무상유족연금은 수급권자인 배우자A가 상속한 손해배상채권에서만 공제된다. 따라서 직무상유족연금의 수급권자인 배우자A는 청구할 손해배상채권이 없으나, 자녀B1·B2는 상속받은 손해배상액을 청구할 수 있게 된다.
- [상속 후 공제]
- (상속 단계) 전체 손해배상금(8,750만 원)
- 배우자A가 상속받은 손해배상액:8,750만 원 × 4/7 = 5,000만 원
- 자녀B1·B2가 상속받은 손해배상액:각 8,750만 원 × 2/7 = 각 2,500만 원
- (공제 단계) 배우자A:5,000만 원(상속받은 손해배상액)-유족연금(44,000만 원) = 0원
- 자녀B1·B2:각 2,500만원(상속받은 손해배상액)-유족연금(0원) = 각 2,500만원

- 대상판결의 전원합의체는 아래와 같은 논거로 공제 후 상속된다고 판단한 원심을 파기·환송하여 상속 후 공제로 변경하였고, 대상판결의 견해와 배치되는 종래의 판례 등을 변경하였다.

- 첫째, 직무상유족연금은 재해보상·손실전보로서의 성격과 수급권자의 생활안정과 복지향상을 도모하기 위한 목적과 성격을 가지는 급부이다. 이러한 직무상유족연금의 수급권자가 손해배상채권까지 상속하게 된다면 같은 목적의 급부를 이중으로 지급받게 된다. 따라서 수급권자가 지급받는 직무상유족연금은 수급권자가 상속한 손해배상채권에서 공제하는 것이 형평의 이념에 부합한다. 그러나 수급권자가 아닌 상속인들은 손해배상채권을 지급받더라도 같은 목적의 급부를 이중으로 지급받는다 볼 수 없으므로, 수급권자가 아닌 상속인들이 상속한 손해배상채권에서 직무상유족연금을 공제할 것은 아니다.
- 둘째, 수급권자가 아닌 상속인들이 상속한 망인의 손해배상채권과 직무상유족연금 수급권은 귀속주체가 서로 상이하여 상호보완적 관계를 인정할 수 없으므로, 직무상유족연금의 지급으로 수급권자가 아닌 다른 상속인들이 상속한 손해배상채권에 대하여 전보가 이루어졌다고 볼 수 없다.
- 셋째, 종전의 공제 후 상속 방식과 같이 손실전보의 중복성을 강조하여 손해배상채권에서 직무상유족연금의 공제 범위를 넓게 인정한다면, 사회보장제도를 유지하는 차원으로 가해자의 책임을 면제시키는 결과가 되고 수급권자의 생활안정과 복지향상을 위한 사회보장법률의 목적과 취지가 물갈릴 수 있다.

<2> 산재보험법 관련 2009년 전합 판결의 경우에도 타인의 불법행위로 인한 손해배상채권과 산재보험법상 유족급여 간 조정이 문제가 된 사건이다. 일부 사실관계를 보면, 타인의 불법행위로 사망한 망인의 사실상 혼인관계에 있는 배우자C는 산재보험법상 유족급여를 받는 유족급여 수급권자(현 산재보험법 제63조)이다. 한편, 자녀D1·D2는 배우자C(유족급여 수급권자)를 제외한 망인의 공동상속인으로서 손해배상채권을 상속받는 사람들이다. 이 사례는 유족급여 수급권자와 상속인이 완전히 다른 경우에 해당한다. 이 경우에도 종래 판례 입장(공제 후 상속)에 따른 원심은 전체 손해배상채권에서 유족급여를 공제하고 남은 금액이 없다는 이유로 망인의 공동상속인들(자녀D1·D2)의 청구를 배척하였다.

- 대법원은 산재보험법상의 보험급여의 대상이 된 손해와 민사상의 손해배상의 대상이 된 손해가 서로 같은 성질을 띠는 것이어서 보험급여와 손해배상이 상호보완적 관계에 있는 경우에는 중복전보에 의한 부당이득을 방지하기 위하여 그 보험급여 금액의 한도 안에서 보험가입자의 손해배상책임을 면제하는 취지로 해석된다. 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 위와 같은 상호보완적 관계는 보험급여의 대상이 된 손해와 민사상 손해배상의 대상이 된 손해의 각 항목 사이에서 존재하여야 할 뿐만 아니라, 보험급여 수급권과 민사상 손해배상채권의 귀속주체 사이에도 존재할 것이 요구된다고 보아야 할 것이다.라고 판단하였다. 즉 대법원은 손해배상과 유족급여의 상호보완적 관계는 사유의 동일성뿐만 아니라 보험급여 수급권과 민사상 손해배상채권의 귀속주체 사이의 동일성이 요구된다고 보았고, 그 귀속주체가 서로 상이한 경우에는 상호보완적 관계가 인정되지 않으므로 유족급여의 수급권자가 아닌 다른 상속인에 대한 손해배상책임을 소멸되지 않는다고 판단하였다. 이와 같은 판례의 변경은 현행 생명침해에 대한 손해배상법리와 상속의 법리 등에 부합하고, 산재보험급여가 가지는 사회보장적 성격에 비추어 유족의 생활을 두텁게 보호(물론 상속인의 손해배상채권 포함)하는 것으로서 타당한 결과이다. 대상판결도 이와 마찬가지로 평가할 수 있다.

<3> 사망재해인 경우 유족급여(산재보험법, 공무원연금법, 사학연금법 등)와 손해배상채권 간 조정하는 방식은 2009년 전합 판결과 대상판결로 공제 후 상속에서 상속 후 공제로 변경됨으로써 이를 둘러싼 논란은 일단락되었다. 이와 같은 소송은 산재보험법 및 사학연금법상 유족급여 수급권자와 손해배상청구권의

상속인이 불일치하기 때문에 발생하는 것으로, 최우선 순위의 수급권자가 되지 못한 손해배상청구권의 (공동)상속인은 언제나 손해배상을 청구할 이익을 갖게 된다. 차체에 대가족 제도를 전제로 설계된 산재보험법, 공무원연금법, 사학연금법 등 유족급여 지급체계를 유족의 유형별(배우자연금, 자녀연금, 부모연금 등-유럽의 예)로 개선하여 각각 독자적인 수급권을 부여함으로써 유족을 두텁게 보호할 필요가 있다. 이와 같이 개선된다면 민사상 손해배상과도 상호조정을 조화롭게 할 수 있을 것으로 보인다.

<원하청교섭 시 원청사의 단체교섭의무 판단방법, 그리고 노란봉투법> 서울행정법원 2025.07.25. 선고 2022구합69230 판결, 서울행정법원 2025.07.25 선고 2023구합55658 · 56231 판결

【판결 요지】

【판결 요지:대상판결 1】

- 원고 회사는 이 사건 의제를 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있다고 인정되므로, 이 사건 의제에 대하여 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에게 해당한다.

【판결 요지:대상판결 2】

- 원고 회사는 사내하청업체 근로자의 근로조건과 관련된 제1, 2, 4 의제에 대하여 이를 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있으나, 제3, 5 의제에 대하여는 그러한 지위에 있다고 볼 수 없으므로, 원고 회사는 제1, 2, 4 의제에 대하여 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에게 해당한다.

I. 사건 개요 및 판결 요지

- 하청근로자로 조직된 노동조합(이하 '하청노조')의 교섭요구에 대하여 원청회사가 단체교섭의무를 부담하는지 여부는 오랫동안 논란이 된 쟁점이다. 이 쟁점에 대해 같은 날(2025. 7. 25.) 같은 재판부에 의해 일정한 교섭의제에 대하여 원청회사가 교섭의무를 부담한다는 두 개의 판결이 선고되었다.

- 한편 노란봉투법(사용자 범위 확대 등의 내용을 담은 노동조합 및 노동관계조정법 제2·3조 개정)이 2025. 9. 9. 공포되었고, 2026. 3. 10. 시행을 앞두고 있다. 대상판결들은 기존의 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법')하에서의 해석이기 때문에, 노란봉투법 시행 이후의 해석 기준이 될 수는 없으나 중요한 참고 사례는 될 것이다.

- <대상판결 1>의 사안은 전국금속노동조합 충남지부 현대제철비정규직지회가 현대제철 주식회사에 단체교섭을 요구한 것이다. 하청노조가 요구한 교섭의제는 ① 산업안전보건, ② 차별시정, ③ 직접고용 원칙 및 불법파견 정규직 전환, ④ 자회사 채용 중단이다. 현대제철이 교섭요구사실을 공고하지 않자, 하청노조는 단체교섭거부의 부당노동행위에 해당한다며 노동위원회에 구제를 신청하였다.

- 충남지방노동위원회는 현대제철을 노동조합법상 사용자로 보기 어렵다며 구제신청을 기각하였다. 그러나 중앙노동위원회는 2022. 3. 24. 네 가지 의제 중 산업안전보건에 대해서는 현대제철이 노동조합법상 사용자 지위가 인정되므로 단체교섭거부의 부당노동행위에 해당한다고 판정하였다.

- 현대제철(원고)은 위 재심판정의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 대상판결 1은 재심판정의 위법이 없다며 원고의 청구를 기각하였다. 한편 <대상판결 1>은 원청사의 단체교섭의무가 인정되는 산업안전보건 의제 외에 나머지 세 가지 의제에 대해서는 별도로 판단하지 않았다. 노사 당사자가 행정소송에서 다투지 않았기 때문이다.

- <대상판결 2>의 사안은 전국금속노동조합 거제통영고성 조선하청지회가 한화오션 주식회사(변경 전 상호 : 대우조선해양 주식회사)에 단체교섭을 요구한 것이다. 하청노조가 요구한 교섭의제는 ① 성과급 지급, ② 학자금 지급, ③ 노동조합 활동 보장, ④ 노동안전, ⑤ 취업방해 금지이다. 원청회사가 교섭요구사실을 공고하지 않자, 하청노조는 단체교섭거부의 부당노동행위에 해당한다며 노동위원회에 구제를 신청하였다.

- 경남지방노동위원회는 원고 회사는 이 사건 단체교섭 요구에 응할 지위에 있지 않다는 이유로 구제신청을 기각하였다. 그러나 중앙노동위원회는 2022. 12. 30. 원고 회사는 사내 협력업체 소속 근로자의 노동조건에 대해 실질적 지배력을 행사하는 범위에서 사내 협력업체와 함께 단체교섭에 응할 의무가 있으므로, 이 사건 단체교섭 요구에 응하지 아니한 것은 단체교섭거부의 부당노동행위에 해당한다고 판정하였다(다만, 교섭요구사실을 공고하지 않은 행위는 부당노동행위가 아니라고 판정하였다).

- 노동조합과 원청회사 모두 위 재심판정에 대해 행정소송을 제기하였다. <대상판결 2>는 원청회사는 5가지 의제 중에 성과급 지급, 학자금 지급, 노동안전에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있으나, 노동조합 활동 보장, 취업방해 금지에 대하여는 그러한 지위에 있다고 볼 수 없으므로, 원청회사는 성과급 지급, 학자금 지급, 노동안전 의제에 대하여 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에게 해당한다고 판단하였다.

II. 대상판결들의 판단 방법

- 대상판결들은 먼저 노동조합법 제81조 제1항 제3호의 사용자에는 같은 항 제4호의 사용자와 마찬가지로 근로조건 등을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 포함된다고 하였다. 즉, 지배개입 주체로서의 사용자와 단체교섭상 사용자는 동일하다는 것이다. 그리고 그 이론적 논거를 매우 상세히 제시하고 있다. 마치 노란봉투법의 국회 본회의 통과를 예견한 듯한, 영원히 깨질 수 없는 아름다운 논거이다.

- 다음으로 원청회사가 단체교섭의무를 부담하는 사용자에게 해당하는지 여부에 대해 총론적 사용자성 판단과 각론적 교섭의제 판단의 방법을 제시한다. 총론적 사용자성 판단과 관련해서는 교섭의제에 대한 실질적·구체적 지배·결정, 사업 편입, 단체교섭 필요성·타당성 등의 판단기준을 제시하였다.

- 그리고 각론적 교섭의제 판단으로 들어간다. 하청노조가 요구한 교섭의제에 대해서 그 의제 하나 하나씩 원청회사가 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는지 여부를 판단한다. 그 결과 <대상판결 1>은 산업안전보건 의제에 대해, <대상판결 2>는 성과급 지급, 학자금 지급, 노동안전 의제에 대해 원청회사의 지배·결정력을 인정하였다. 구체적인 각 의제별 판단에 대해서도 대상판결들은 매우 상세한 논거를 제시하고 있다(참고로 CJ대한통운 판결은 ① 배송상품 인수시간의 단축, ② 집화상품의 인도작업 대기시간의 단축, ③ 택배기사 1인당 1개의 하차장 보장 등 작업환경 개선, ④ 휴일, 휴가 및 주5일 근무제 실시, ⑤ 지급수수료 인상, ⑥ 사고 부책 개선 등의 의제에 대해 모두 원청회사의 단체교섭의무를 인정하였다).

III. 대화촉진법으로서의 노란봉투법

- 고용노동부 장관은 2025. 7. 29. 노동조합법 2·3조 개정 관련 브리핑(안)에서 노란봉투법(안)을 대화 촉진법, 상생의 법, 진짜 성장법으로 명명하였다. 우선적으로 주목할 것은 노사 간의 대화 촉진법이다.

- 불법파업 관련 사용자 측의 막대한 손해배상 청구를 제한하는 것이 노란봉투법의 배경(2009년 쌍용차 파업과 2022년 대우조선 하청노조 파업)이다. 기존 법하에서 구조조정 반대 파업은 쟁의행위 목적의 정당성이 부정되었고, 하청노조 교섭요구에 대한 원청의 사용자성이 인정되는 판례가 없는 상황이었다. 그래서 사용자는 단체교섭 자체를 거부하였고, 노조는 공장 점거를 수반한 강력한 파업에 돌입하였다. 기존 법이 단체교섭의무를 부정하였기에 대화는 실종되고 노사 간의 극한 대립으로 치달았다.

- 개정 노동조합법 제3조 및 제3조의2는 손해배상 청구를 직접 제한한다. 같은 개정법 제2조는 사용자 개념(제2호)과 노동쟁의 개념(제5호)을 확대하여 손해배상 청구의 원인(즉, 불법파업의 원인)을 제거한다. 사용자의 단체교섭의무를 확대하여, 기존의 점거 파업과 같은 극단적 대립이 아닌, 노사 간의 단체교섭 등의 대화를 촉진해야 할 것이다.

- 따라서 노란봉투법 시행 후의 해석 기준은 개정 법률의 문언과 함께 위의 노사 대화 촉진을 위한 법 개정 배경과 취지를 충분히 고려해야 한다.

IV. 노란봉투법 시행 후의 해석 방향

- 대상판결들은 총론적 사용자성 판단의 기준과 함께 구체적인 각론적 교섭의제 판단 방법을 보여줬다. 이것을 참고하면 향후 노란봉투법 시행 후의 원청회사의 단체교섭의무 여부의 판단 방법은 대략 세 가지가 있을 수 있다. ① 설은 총론적 사용자성 판단과 각론적 교섭의제 판단을 모두 하는 것이다(이른바 모두 판단설). 판단이 오래 걸릴 것이므로 신속한 대화 촉진에는 걸맞지 않다. ② 설은 총론적 사용자성 판단만 하고 각론 판단은 생략하는 것이다(이른바 총론 판단

설). 교섭의제에 대해 일일이 판단하게 되면 교섭은 요원해질 것이기 때문에, 원포인트로 사용자성만 판단하여 원청회사에 교섭의무를 부담시키자는 방향이다. ③ 설은 각론적 교섭의제 판단만 하고 총론 판단은 생략하는 것이다(이른바 각론 판단설). 결국은 교섭의제 판단으로 귀결될 것이므로, 총론 판단은 생략하고 판단된 교섭의제에 대해 신속히 원청회사에게 교섭의무를 부담시키자는 방향이다.

- 사내 하청과 같이 원청회사의 전반적인 지배와 통제력이 강한 경우에는 ② 설의 장점이 발휘될 것이다. 구체적인 교섭의제는 노사자치에 맡기는 것이 바람직할 수 있다. 반면 모자기업이나 사외협력업체의 경우에는 총론적 사용자성 인정이 쉽지 않으나, 특정 의제에 대한 지배·결정력이 인정될 수 있으므로 ③ 설의 장점이 발휘될 것이다. 어떤 방향이든 노사 대화를 촉진시킬 수 있는 실용적 방안이 필요하다고 본다.

<백화점·면세점의 입점(판매)노동과 단체교섭 상대방> 서울행정법원 2025.10.30. 선고 2024구합72896 판결

【판결 요지】

- 단체교섭 의무를 부담하는 노동조합법상 사용자로 인정되는지는 (중략) 근로조건 등에 관한 실질적 지배력을 행사하는지를 기준으로 판단하여야 하고, 이는 근로계약을 체결하지 않은 사업주가 반드시 원사업주에 비해 우월적 지위에 있을 것만을 요건으로 하지는 않는다. (중략) 다면적 노무제공관계의 특성상 일부 근로조건에 관하여는 원사업주가, 다른 일부 근로조건에 관하여는 근로계약관계 없는 사업주가 실질적 지배력을 행사하는 것이 충분히 가능하므로, 실질적 지배력의 유무는 참가인들과 이 사건 입점업체 및 원고 조합원 근로자들 사이에 형성된 노무제공관계의 전체적인 모습에 기초하여 참가인들의 거래상 명백한 우월적 지위 유무에 따라 확립적으로 결정하는 것이 아니라, 이 사건 각 의제와 연관되는 각각의 근로조건별로 따로 판단하여야 한다. (중략)

- 상품매입거래계약에 임대차계약의 성격이 혼합되어 있음을 충분히 고려하더라도 참가인들이 영위하는 사업은 기본적으로 참가인 백화점·면세점 내에서의 상품판매에 해당함은 명백하고, 이는 대부분 이 사건 입점업체 등의 납품업체가 파견한 판매사원들이 개별적인 상품판매 업무를 수행함으로써 이루어지는 것이며(중략), 참가인들이 판매사원들에게 직접적인 업무상 지휘·명령을 내리지 않는 것은 이 사건 입점업체별로 고유의 상품 특성을 고려한 독자적인 상품 판매전략을 수립·실행하여 매출이 극대화될 수 있도록 하기 위한 측면도 있다고 보인다. 이러한 점을 고려하면 판매사원들이 상품판매 업무에 관하여 제공하는 노무는 참가인들의 사업 수행에 상시적·필수적인 것은 물론 구조적으로 참가인들의 사업체계에 직접 편입되어 있다고 충분히 인정할 수 있고, 앞서 본 바와 같이 이는 참가인들이 이 사건 입점업체에 비해 거래상 명백히 우월적 지위에 있는지 여부와 직접 관계되는 것이 아니므로, 참가인들이 단지 판매장소만을 제공할 뿐 판매사원들의 노무제공 자체를 받지 않는다는 주장은 받아들이기 어렵다.

I. 사실관계

- 대상판결의 사실관계를 살피면 다음과 같다. 백화점과 면세점에 입점하여 화장품을 판매하는 업체들 및 이들과 공급·판매대행 계약을 체결한 업체들에 소속된 판매사원들은 초기법률 노동조합인 백화점면세점판매서비스노동조합을 조직한 후, 근로계약의 상대방이 아닌 백화점·면세점을 상대로 단체교섭을 요구하였다. 교섭 의제는 ① 영업시간·연장영업·정기휴점 등 공동 휴식권 보장, ② 고객응대노동자 보호를 위한 보호매뉴얼의 일원화 및 책임 부여, ③ 휴게실·화장실·락커 등 시설물의 이용 및 확충 등 근무환경 개선에 관한 사항이었다. 이에 대해 백화점·면세점은 자신들이 입점업체 근로자들의 임금·근로시간 등 기본적인 근로조건을 지배·결정하는 지위에 있지 않고, 단지 판매장소를 제공하는 시설관리자에 불과하며, 입점업체와의 계약관계 역시 임대차적 성격을 갖는다는 이유로 단체교섭 요구에 응하지 않았다. 이에 노조는 단체교섭 거부가 노동조합 및 노동관계조정법(노조법) 제81조 제1항 제3호의 부당노동행위에 해당한다고 주장하며 노동위원회에 구제신청을 제기하였다.

- 서울지방노동위원회와 중앙노동위원회는 백화점·면세점이 판매사원들의 근로조건에 대해 실질적·구체적 지배력을 행사한다고 보기 어렵다는 이유로 노조의 주장을 받아들이지 않았으나, 노조는 이에 불복하여 행정소송을 제기하였다. 이 사건의 법적 쟁점은 ① 근로계약관계가 없는 제3자도 근로조건에 대한 실질적·구체적 지배력을 행사하는 경우 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자로 인정될 수 있는지, ② 다면적 노무제공관계에서 사용자성 판단이 거래상 우월관계에 따라 일률적으로 이루어져야 하는지 아니면 교섭 의제와 연관된 개별 근로조건별로 판단되어야 하는지, ③ 이 사건에서 백화점·면세점이 노조가 제기한 각 교섭 의제(공동 휴식권, 고객응대노동자 보호, 시설물 이용·확충)에 대해 실질적 지배력을 행사하는지 여부였다. 원고 노조는 판매사원들의 노무가 백화점·면세점의 사업 수행에 구조적으로 편입되어 있고, 영업시간·매장 운영·보안 및 시설 관리 등 핵심적인 근로조건이 참가인들에 의해 사실상 결정·통제된다고 주장한 반면, 참가인들은 지휘·명령관계나 경제적 우월관계가 없고 각 의제는 경영권 또는 입점업체의 책임 영역에 속한다는 점을 들어 사용자성을 부인하였다.

- 위 쟁점에 대한 대상판결의 가장 중요한 의의는, 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자의 판단 기준을 거래상 우월관계나 전형적인 원하청 구조에서 분리하여, 다면적 노무제공관계 속 의제별 실질적 지배력으로 재정식화했다는 점에 있다. 법원은 단체교섭 의무를 부담하는 사용자인지 여부는 근로조건 등에 관한 실질적 지배력을 행사하는지를 기준으로 판단해야 하며, 이때 근로계약을 체결하지 않은 사업주가 반드시 원사업주에 비해 거래상 우월적 지위에 있을 것을 요하지는 않는다고 명확히 판시하였다. 더 나아가, 다면적 노무제공관계의 특성상 일부 근로조건에 대해서는 원사업주가, 다른 일부 근로조건에 대해서는 근로계약관계 없는 제3의 사업주가 실질적 지배력을 행사하는 것이 충분히 가능하므로, 사용자성은 거래상 지위에 따라 확립적으로 판단할 것이 아니라 이 사건 각 의제와 연관되는 각각의 근로조건별로 따로 판단해야 한다고 설시했다. 이러한 판단은 경제적 우월관계나 전형적인 도급·사내하청 구조가 존재하지 않는 경우에도 사용자성이 성립할 수 있다는 것을 인정했다는 점에서 의의가 크다.

II. 대상판결의 내용

- 대상판결은 단체교섭 당사자로서 사용자 개념에 대한 위 이해를 기초로 백화점·면세점의 장소 제공자 주장을 배척했다. 판결은 먼저 상품매입거래계약에 임대차적 성격이 혼합되어 있음을 인정하면서도, 참가인들이 영위하는 사업은 본질적으로 백화점·면세점 내에서의 상품판매이며, 이는 대부분 입점업체 등이 파견한 판매사원들이 개별적인 상품판매 업무를 수행함으로써 실현된다고 본다. 나아가 참가인들이 판매사원들에게 직접적인 지휘·명령을 하지 않는 점 역시, 판매사원 노무와 무관하기 때문이 아니라, 입점업체별 상품 특성에 맞는 판매 전략을 존중함으로써 전체 매출을 극대화하려는 사업 구조상의 선택이라고 평가했다. 나아가 판매사원들이 제공하는 노무는 참가인들의 사업 수행에 상시적·필수적일 뿐 아니라, 구조적으로 참가인들의 사업체계에 직접 편입되어 있다고 보았다. 앞서 보았듯 백화점이나 면세점의 단체교섭 상대방으로서의 사용자성 판단에 있어 입점업체에 대한 거래상 지위 우월성이 필요한 것이 아니므로, 참고인 측의 주장, 즉 판매장소만을 제공할 뿐 판매사원들의 노무제공 자체를 받지 않는다는 주장을 기각했다.

- 이러한 일반 법리에 터잡아 대상판결은 백화점·면세점의 3개 교섭 의제별 사용자성을 인정했다. 첫째, 공동 휴식권 보장(영업시간·연장영업·휴점 등)과 관련해서는 백화점·면세점의 영업시간, 연장영업 여부, 휴점일 지정은 입점업체나 판매사원이 독자적으로 결정할 수 있는 사항이 아니라, 참가인이 사실상 최종적으로 결정·통제하는 영역이라는 점에 주목해 사용자성을 인정했다. 둘째, 고객응대노동자 보호 의제에 대해 대상판결은 고객응대매뉴얼 마련과 관련해 입점업체와 백화점·면세점 모두의 책임을 긍정했다. 이를테면 상품 설명, 환불 정책, 브랜드 민원 대응 등은 입점업체의 영역일 수 있으나, 폭언·폭행·위협 등 고객응대 과정에서 발생하는 신체적·정신적 위험에 대한 예방 및 대응 문제는 보안요원 배치, 현장 통제, 매장 운영 매뉴얼, 시설·장비 운용 등 백화점·면세점의 운영·관리 영역에 속한다고 보았다. 셋째, 시설물 이용·확충(휴게실·화장실·락커 등) 의제와 관련해서는 판매사원의 노무가 참가인의 사업 체계에 구조적으로 편입되어 있다는 점을 재차 강조하며, 근무 장소와 시설의 이용 여부를 사실상 결정·통제하는 주체가 백화점·면세점이라는 점에서 사용자성을 부정할 수 없다고 판단했다.

- 대상판결은 한화오션·현대제철 판결이 전형적인 제조업 사내하청 구조에서 공정 통제, 산업안전, 복지재원 조성 등 원청의 직접적 관여를 중심으로 사용자성을 인정한 데 비해, 백화점 판결은 지휘·명령이나 공정 관리가 거의 없는 상황에서도 사용자성이 성립할 수 있음을 분명히 했다는 점에서 차별화된다. 즉, 이 사건에서 사용자성은 지휘·감독의 강도나 거래상 우월관계가 아니라, 판매사원 노무가 백화점·면세점의 핵심 사업(상품판매)에 상시적·필수적으로 결합되어 있고, 특정 근로조건에 대해서는 참가인이 사실상 결정권을 보유하고 있다는 구조적 관계에 주목했다. 유통·서비스업에서 단체교섭 당사자/상대방으로서 사용자 개념이 어떠한 근거와 방식으로 확장될 수 있는지를 보여준 의미 있는 판결이다.

<과거 근로조건에 대한 단체교섭의 유의미성> **대법원 2025.07.03. 선고 2023다251718 판결**

【판결 요지】

- 소외 1 노동조합은 단체교섭권을 비롯한 노동3권을 향유할 수 있는 주체인 노동조합으로서의 지위를 가지지 않으므로, 소외 1 노동조합이 이 사건 대상기간에 체결한 단체협약 및 임금협약은 노동조합법상 단체협약으로서의 효력이 없다. 원고는 피고의 사업장 내에 단체교섭권을 행사할 수 있는 유일한 노동조합으로서 피고에 대하여 이 사건 대상기간 동안 적법하게 단체교섭을 요구하였음에도, 소외 1 노동조합이 2011년 단체협약 등을 먼저 체결하거나 2013년부터 교섭대표노동조합이 됨에 따라, 원고의 단체교섭권이 보장되지 못하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있다. 따라서 피고가 이 사건 교섭사항에 대하여 단체교섭 의무를 부담한다.

I. 사건 개요

- ① 피고(삼성물산 주식회사)의 근로자들은 2011.7.13. S노동조합을 설립하였고, S노동조합은 조직형태 변경을 통해 원고(전국금속노동조합)에 가입하여 경기지부 S지회가 되었다. 원고는 2011.8.경부터 2021.1.경까지 매년 피고에게 단체교섭을 요구하였다. ② 피고는 2011.6.29.경 설립된 소외 1 노동조합(에버랜드노조)과 2011년 단체협약 및 임금협약을 체결한 이후, 2020년까지 2년 단위로 단체협약을, 1년 단위로 임금협약을 각 체결하였다. ③ 소외 1 노동조합은 2013년부터 2020년까지 원고와 교섭창구단일화 절차를 거쳐 교섭대표노동조합이 되었다. ④ 피고 회사의 노사문제 총괄 책임자들은 소외 1 노동조합을 설립하여 지배하였다는 등의 혐의로 기소되어 유죄판결이 2022.3.17. 확정되었다. 그리고 소외 1 노동조합은 원고의 설립을 방해하고 지배하려는 사용자의 부당노동행위에 의해 설립된 노동조합으로서, 실질적 요건을 갖추지 못하였으므로 노동조합 설립은 무효하다는 판결이 2022.6.1. 확정되었다. ⑤ 원고는 2020.4.24. 피고를 상대로 2011년부터 2020년까지 기간(이하 이 사건 대상기간)에 관하여 아래의 단체교섭사항(이하 이 사건 교섭사항)에 대하여 성실하게 단체교섭에 응할 것을 구하는 이 사건 소를 제기하였다. ⑥ 원고는 이 사건 소 계속 중이던 2021.2.25. 피고에게 2021년 단체교섭을 추가로 요구하였고, 피고가 단체교섭에 응하여 2022.4.14. 임금협약(적용기간:2021.3.1.~2022.2.28.) 및 단체협약(유효기간:2022.4.1.~2024.3.31.)을 각 체결하였다.

▶ 단체교섭사항

1. 2011년, 2013년, 2015년, 2017년, 2019년 각 임금 및 단체협약에 관한 다음 사항

- 총칙, 조합활동, 인사, 고용안정, 임금(기본급, 제수당, 상여금, 성과급 등), 노동시간(교대제 등), 휴일, 휴가, 남녀평등과 모성보호, 산업안전보건, 복리후생, 단체교섭, 노사협의회, 노동쟁의

2. 2012년, 2014년, 2016년, 2018년, 2020년 각 임금협약에 관한 다음 사항

- 기본급, 제수당, 상여금, 성과급 등. 끝.

II. 판결 내용

- 대상판결의 1심은 원고의 청구를 기각하였다. 주요 근거는 다음과 같다. ① 과거 기간에 대한 이 사건 교섭사항은 새로운 단체협약을 체결하더라도 이를 소급하여 준수한다는 것은 불가능하다. ② 임금협약 요구사항은 이미 근로를 제공하고 임금을 지급받은 과거 법률관계를 사후적으로 변경하여 달라는 청구에 불과하여 법률상 근거가 없는 이상 허용될 수 없다. ③ 원고가 과거 단체교섭의무 불이행에 대하여 피고에게 손해배상을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 피고가 과거 기간에 대한 단체교섭청구에 응낙할 의무는 없다.

- 반면 대상판결의 원심은 원고의 청구를 인용하였다. 주요 근거는 다음과 같다. ① 과거 기간의 근로조건 등에 관하여 교섭할 수 없다고 볼 근거가 없고, 노동조합이 사용자와 근로조건 등을 결정하는 기준에 관하여 소급적으로 동의·승인하는 단체협약을 체결하는 것이 가능하다. ② 원고는 단체교섭을 통하여 기존의 단체협약보다 유리한 단체협약을 새로 체결할 수도 있으므로, 이 사건 대상기간의 임금협약 및 단체협약 체결을 위한 단체교섭을 요구할 실익이 있다.

- 대상판결은 원심의 결론은 정당하다며 피고의 상고를 기각하였다. 대상판결의 주요 내용은 다음과 같다. ① 사용자는 특별한 사정이 없는 한 과거 기간의 근로조건 등 가운데 기존의 단체협약이 이미 정한 사항에 대하여 단체교섭의무를 부담하지 아니한다. ② 소외 1 노동조합과 같이 실질적 요건을 갖추지 못한 노동조합이 체결한 단체협약은 효력이 없다. ③ 기존 단체협약이 무효라고 주장할 만한 상당한 근거가 있고, 그에 따라 적법하게 단체교섭을 요구한 노동조합의 단체교섭권이 보장되지 못하였다는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는, 해당 노동조합은 신의성실의 원칙에 반하지 않는 범위 내에서 기존 단체협약의 개정, 폐지, 승인 또는 새로운 단체협약의 체결을 위한 단체교섭을 요구할 수 있다. ④ 이때 사용자는 교섭요구사항이 과거 기간의 근로조건 등에 관한 사항이라는 이유만을 내세워 단체교섭을 거부할 수 없다. ⑤ 따라서 이 사건 대상기간 동안 원고의 단체교섭권이 보장되지 못하였다고 볼 만한 특별한 사정이 있으므로, 피고는 이 사건 교섭사항에 대하여 단체교섭의무를 부담한다.

III. 과거 근로조건에 대한 교섭사항의 범위

- **판례**에 따르면, 근로계약이 무효 또는 취소가 되더라도 근로계약에 따라 그동안 행하여진 근로자의 노무 제공의 효과를 소급하여 부정하는 것은 타당하지 않으므로 이미 제공된 근로자의 노무를 기초로 형성된 취소 이전의 법률관계까지 효력을 잃는 것은 아니다. 마찬가지로 단체협약이 무효가 되더라도 단체협약에 따라 이미 근로를 제공하고 임금을 지급받은 과거의 법률관계가 효력을 잃는 것은 아니다.

- 그렇다면 과거 기간에 대한 단체교섭은 어떤 의미를 갖는가? 우선적으로 생각할 수 있는 것은 과거 기간의 임금 인상에 대하여 협약을 체결하여 소급하여 적용하는 것이다. 임금 인상분의 소급 적용은 통상적인 단체교섭 상황에서도 흔히 벌어지는 일이므로, 과거 기간에 대한 단체교섭에서도 충분히 가능하다.

- 대상판결은 피고에게 단체교섭의무 자체가 있다는 점은 분명히 하였지만, 구체적인 교섭사항에 대해서는 언급하지 않은 채, 피고가 이 사건 교섭사항에 대하여 단체교섭의무를 부담한다고만 하였다.

- 대상판결 이후 실제로 원고와 피고가 단체교섭을 진행할 때 그 교섭사항의 범위에 대해 논란이 제기될 수 있다. 예컨대, 징계절차의 경우는 현재 적용되는 단체협약의 규정에 따라야 하고, 또한 이미 지나간 과거 기간의 징계처분에 적용할 수도 없으므로, 징계절차에 대해 원고와 피고가 단체교섭을 진행하는 것은 무의미할 수 있다.

- 구체적인 교섭사항에 대해 대상판결은 아무런 언급을 하지 않았지만, 이에 대해서는 대상판결의 1심과 원심에서 살짝 드러났다. 1심은 이 사건 교섭사항은 새로운 단체협약을 체결하더라도 이를 소급하여 준수한다는 것은 불가능하다고 하였다. 이것은 어느 정도 일리 있는 말이다. 원고가 제시한 이 사건 교섭사항은 단체협약 전반에 관한 사항이기 때문이다. 반면 2심은 근로조건에 관하여 소급적으로 동의·승인하는 단체협약 체결은 가능하다고 하였다. 아마도 2심은 임금 인상분의 소급 적용을 염두한 것으로 보인다.

- 과거 근로조건에 대한 교섭사항의 범위를 일률적으로 말하기는 어려우나, 임금과 같이 금전으로 보상할 수 있는 근로조건은 충분히 가능하다고 본다. 이러한 금전 보상이 과거 기간에 대한 단체교섭이 갖는 중요한 의미일 것이다.

- 사용자 주도로 설립되어 실질적 요건을 갖추지 못한 노동조합(이른바 어용노조) 때문에 원고의 단체교섭권이 10년간 침해되었음은 분명하다. 원고가 피고에게 과거 단체교섭의무 불이행에 대해 손해배상을 청구할 수는 있겠지만, 이러한 손해배상은 위자료에 그칠 수 있어 충분하지 않다. 원고가 과거 기간의 임금 인상 등에 대해 단체협약을 체결하여 조합원들이 소급 적용받을 수 있도록 할 필요가 있다. 이것이 과거 근로조건에 대한 단체교섭의 유의미성이다.

<복수노조에 대한 차량 지원 관련 사용자의 공정대표의무> **대법원 2025.05.15. 선고 2022두64693 판결**

【판결 요지】

- 원심의 판단 중 원고가 사용자로서 참가인 지회에 대하여 공정대표의무를 부담한다는 부분은 정당하지만, 이 사건 차량 지원이 합리적 이유 없는 차별에 해당한다는 부분은 수긍하기 어렵다. 원고가 이 사건 각 노동조합에 임차비용 지급 방식으로 차량을 지원하면서 2019년 10월 일괄공제 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 차량 사용기간을 배분한 것에는 합리적인 이유가 있다고 볼 여지가 크다.

I. 사건의 개요

- 포스코노동조합(이하 포스코노조)과 포스코지회(피고보조참가인, 이하 포스코노조와 포스코지회를 통칭하여 이 사건 각 노조)는 2019년 교섭창구 단일화 절차에 참여하였고, 그 결과 2018.11.16. 포스코노조가 교섭대표노동조합이 되었다.

- 포스코노조는 2017년 단체협약의 유효기간 중인 2019.1.2. 원고 회사에게 기존 근로시간 면제 한도를 조정해 달라며 교섭을 요구하였고, 같은 해 2.11. 근로면제시간을 이 사건 각 노조의 합의에 따라 배분하되, 합의되지 않으면 노사합의일인 2.11. 기준 노조별 조합원 수에 따라 임시로 배분하고, 이 사건 노사합의일의 조합원 수는 체크오프 내역 및 조합원 명부, 조합비 내역 등을 근거로 결정하고, 이 사건 각 노조에서 필요한 증빙을 갖추어 조합원 수를 통지하지 아니하는 경우 교섭 요구 노동조합 확정공고일 당시 조합원 수를 노사합의일의 조합원 수로 보기로 합의하였다(이하 이 사건 노사합의).

- 원고 회사는 2019.3.7. 포스코지회에 이 사건 각 노조 간 합의가 없으면 2019년 2월 체크오프 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 근로면제시간을 배분할 예정이니 이의가 있다면 조합비 납부내역 등 추가자료를 제출해 달라고 통보하였고, 포스코지회는 추가자료를 제출하지 아니하였다.

- 이후 원고 회사는 2019.6.24. 이 사건 각 노조에 2019.6. 체크오프 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 2019.7.1.부터 1년간 근로면제시간을 배분할 예정이니, 이의가 있다면 조합비 납부내역 등 추가자료를 제출해 달라고 통보하였고, 포스코지회는 추가자료를 제출하지 아니하였다.

- 한편, 원고 회사는 2019.10.21. 이 사건 각 노조에 차량 3대를 임차비용 지급 방식으로 지원하기로 하고, 2019.10. 체크오프 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 포스코노조와 포스코지회에 차량 사용기간 11:1의 비율로 배분하였다(이하 이 사건 차량 지원).

- 이 사건 차량 지원에 대해 포스코지회는 원고 회사를 상대로 이 사건 차량 지원에 관한 공정대표의무 위반 구제신청을 하였고, 경북지방노동위원회는 이 사건 차량 지원 행위는 공정대표의무 위반이라고 판정하였다. 중앙노동위원회도 이 사건 차량 지원 행위는 공정대표의무 위반이라고 판정하였다.

- 이에 원고 회사는 재심판정에 불복하여 행정소송을 제기하였는데, 제1심은 원고 회사도 (단독으로) 이 사건 차량 배분에 관한 공정대표의무의 주체가 되지만, 이 사건 차량 배분에 합리적인 이유가 있어 원고 회사의 공정대표의무 위반이 인정되지 않는다고 판단하였다.

II. 원심판결의 판시 내용

- 원심은 (i) 이 사건 차량 지원 기준에 관한 합의가 없는 상황에서 이 사건 각 노조의 조합원 수를 기준으로 차량을 배분한 것은 합리성을 인정할 수 있으나 이 사건 차량 지원의 합리적인 배분 기준은 교섭창구 단일화 절차 참여 시의 조합원 수라는 점, (ii) 포스코지회의 지회장, 사무장 등이 부당해고됨에 따라 조합원들이 불이익처분에 대한 염려로 체크오프 신청을 하지 않았을 가능성이 높으므로 공정대표의무를 부담하는 원고 회사로서는 객관적인 제3자로 하여금 체크오프 내역 외에 CMS 내역을 확인하게 하는 등 포스코지회의 조합원 수를 파악하기 위해 노력하여야 한다는 점, (iii) 원고 회사의 주요 사업장들이 원거리에 분산되어 있으므로 노조활동을 위하여 차량 지원이 필요하고, 특정 기간에만 사용하는 등의 방식으로는 포스코지회가 차량을 실질적으로 사용할 수 없다는 점을 들어 원고 회사가 이 사건 차량 지원에 관하여 합리적 이유 없이 포스코지회를 차별함으로써 공정대표의무를 위반하였다고 판단하였다.

III. 대법판결의 판시 내용

- 대법원은 ① 노동조합법 제29조의4 제1항의 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합 또는 조합원이라는 문언은 공정대표의무의 상대방을 정한 것이지 근로면제시간이나 시설·비품 등을 배분하는 기준 시점을 교섭창구 단일화 절차 참여 시로 정한 취지라고 볼 수 없고, 이 사건 노사합의에서 정한 근로면제시간 배분 기준도 근로시간 면제 한도가 증가되어 근로면제시간 배분이 가능하였던 시점인 이 사건 노사합의일이며, 이 사건 차량 지원은 교섭창구 단일화 시점으로부터 약 1년 후에 있었고 그 사이에 이 사건 각 노조 조합원 수에 상당한 변동이 있었던 점에 비추어 원고 회사가 2019.10. 조합원 수를 기준으로 이 사건 차량 지원을 한 것은 합리적이라는 점, ② 이 사건 노사합의에서 체크오프 내역 및 조합원 명부, 조합비 내역 등을 근거로 조합원 수를 결정하도록 하면서 이 사건 각 노조가 필요한 증빙을 갖추어 통지하도록 하고 있는데, 포스코지회가 원고 회사가 거듭 요청하였음에도 포스코지회가 증빙자료를 제출하지 않았고 실제 조합원 수의 확인 방법에 대한 합리적 대안을 제시하면서 협의를 요청하였다고 볼 만한 자료도 없는 상황에서 원고 회사가 체크오프 내역에 따른 조합원 수를 기준으로 한 것이 불합리하다고 볼 수 없다는 점, ③ 차량은 노조사무실과 달리 노조가 스스로 임차하는 데에 특별한 제약이 없으며, 이 사건 차량 지원도 차량 임차비용을 지원하는 방식으로 이루어졌으므로 원고 사업장의 특성을 고려하더라도 포스코지회가 특정 기간에만 차량을 사용할 수 있었다는 사정을 들어 이 사건 차량 지원의 합리성을 부정하기는 어려운 점을 종합하면, 이 사건 차량 지원은 합리적인 이유가 있다고 볼 여지가 크다고 판단하였다.

IV. 대법판결의 의의

- 대법판결의 주된 쟁점은 두 가지인데, 첫 번째 쟁점인 이 사건 차량 배분과 관련된 공정대표의무에 대하여 사용자인 원고 회사가 단독으로도 그 의무 주체가 될 수 있는지 여부에 대해서는 제1심부터 상고심까지 일치하여 사용자가 단독으로 공정대표의무 주체가 될 수 있다고 보았다. 노동조합법 제29조의4 제1항에서 사용자를 공정대표의무의 주체(수범자)로 명시하고 있고, 사용자의 독자적인 공정대표의무 위반 성립을 배제하고 있지 않으므로 타당한 판단이라고 생각된다.

- 두 번째 쟁점은 사용자가 부담하는 공정대표의무의 내용이 무엇인지 즉 적극적으로 차별 방지를 위해 노력할 적극적 차별금지의무가 인정되는지 아니면 중립적·소극적인 차별금지의무를 부담하는 데 그치는 것인지 여부이다. 대법판결에 대해, 대법판결을 통해 사용자의 공정대표의무는 중립적인 태도를 유지하는 소극적 의무라는 점이 재확인되었다고 볼 수 있다는 분석도 있지만, 위 주장이 언급하는 대상판결 이전의 대법원 판결은 사용자의 공정대표의무가 중립적인 태도를 유지하는 소극적 의무라고 판시한 고법 판결에 대한 상고를 심리불속행 기각한 사안이므로 대법원이 명시적으로 사용자의 공정대표의무는 소극적 차별금지의무라고 판단하였다고 볼 수 없다. 뿐만 아니라 사용자에게 소수노조가 받는 불합리한 차별을 제거하기 위하여 적극적인 노력을 하여야 할 의무가 있다고 판단한 고법 판결이 심리불속행 기각으로 확정된 사례뿐만 아니라 사용자의 적극적 차별금지의무를 인정한 하급심 판결들이 존재한다는 사실에 비추어 보면, 법원이 일률적으로 사용자의 공정대표의무가 적극적 또는 소극적이라는 판단을 내렸다고 보기는 어려울 것이다. 대법원이 구체적 사안에 따라 사용자의 공정대표의무의 내용을 달리 볼 것인지, 사용자의 공정대표의무의 내용을 일반적으로 정리하는 법리를 제시할 것인지는 이후 판례의 추이를 지켜보아야 할 것으로 보인다.

- 개인적 단상을 덧붙이자면, 노동조합법 제29조의4 제1항의 문언상 공정은 합리적 이유 없이 차별하지 않음을 의미한다. 노동조합법은 차별에 대해 별도로 정의하고 있지 않으므로, 위 조항에 의하여 금지되는 차별에는 차별의 일반 법리에 따라 직접차별뿐만 아니라 간접차별도 포함된다고 해석해야 할 것이다. 즉 차별금지의무의 성격을 갖는 공정대표의무의 수범자 중 하나인 사용자는 직접적으로 교섭대표노조와 소수노조를 차별하지 않을 뿐만 아니라, 일견 중립적으로 보이는 조건을 적용하였지만 그에 따라 소수노조와 그 조합원에게 불합리한 결과를 초래하는 간접차별도 하지 않을 의무가 있다고 볼 수 있다. 교섭대표노조와 소수노조가 이 사건 차량 지원의 배분에 대해 합의에 이르지 못하였더라도 겉으로 드러난 배분 시점의 체크오프 신청 조합원 수를 기준으로 각 노조에 차

량 지원을 배분할 경우 특정 노조에게 불리한 결과가 초래되고, 원심 판결이 지적인 바와 같이 체크오프 신청 숫자가 아닌 다른 방식으로 이 사건 각 노조의 조합원 수를 확인하는 것이 아예 불가능하지는 않다면 체크오프 신청 조합원 수에 따라 차량 지원을 배분하는 조건의 정당성(또는 합리성)이 증명되었다고 하기 어려울 수 있다. 외견상 중립적인 기준에 의한 형식적 평등을 배제하고 실질적 평등을 실현하려는 간접차별의 규율 취지가 사용자의 공정대표의무(차별금지의무)의 범위와 내용을 해석하는 데에도 감안되어야 할 것이다.

<징계위원회 구성에 대한 공정대표의무의 효력> 대법원 2025.07.18. 선고 2023두61370 판결

【판결 요지】

- [1] 단체협약에서 징계위원회를 노사 동수로 구성하고 근로자측 위원을 노동조합이 지명·위촉하도록 규정(이하 이 사건 규정)하고 있는 경우, 사용자와 교섭대표노동조합이 소수노동조합 소속 조합원에 대한 징계 절차에서 소수노동조합의 조합원들을 배제하고 교섭대표노동조합의 조합원들만을 근로자측 위원으로 선임하였다면, 이는 다른 특별한 사정이 없는 한 징계 절차에서 소수노동조합 등을 합리적 이유 없이 차별한 것으로 공정대표의무에 위배된다고 봄이 타당하다.

- [2] 그러므로 사용자와 교섭대표노동조합은 소수노동조합 소속의 조합원에 대한 징계 절차에서 이 사건 규정에 따라 근로자측 위원을 선임할 경우, 다른 특별한 사정이 없는 한 소수노동조합 소속의 조합원을 1인 이상 근로자측 위원으로 선임함으로써 이 사건 규정에 따른 소수노동조합 등의 참여권을 실질적으로 보장하여야 한다.

- [3] 이 사건 규정은 근로자의 근로권과 그 방어에 영향을 줄 수 있는 중요한 절차에 관한 사항에 해당한다. 사용자가 공정대표의무를 위반하여 구성된 징계위원회의 의결을 거쳐 징계처분을 하였다면, 그러한 징계권의 행사는 징계사유가 인정되는지 여부와 관계없이 이 사건 규정을 위반하여 해당 근로자의 방어권 행사를 제약하여 이루어진 것으로 절차상 중대한 하자가 있어 무효라고 보아야 한다.

- B회사는 시내버스운수업을 영위하는 회사로 복수 노조가 존재하고 있는데, 다수노조인 갑노조가 교섭대표노동조합(이하 교대노조)으로 소수노조인 을노조보다 조합원 수가 13배 이상 많다. B회사의 버스기사로 근무하던 원고 A는 을노조 소속으로, 2020.4.8. 출근 후 관리과장과 다툼을 벌인 뒤 버스를 운행하지 않고 조퇴하였다. 단체협약에 따르면 이 사건 규정은 상벌위원회는 사용자측 위원 3인과 근로자측 위원 3인으로 구성하며 사용자측 위원은 대표이사가 위촉하고, 근로자측 위원은 노동조합에서 지부장이 위촉한다라고 명시하고 있다. 회사는 갑노조에게만 상벌위원회 개최를 통지하고, 근로자위원을 갑노조 측으로만 구성해 상벌위원회를 개최하였다. 상벌위원회는 A에 대하여 위 일자의 배치지시 불이행을 이유로 승무정지 5일의 징계처분을 내렸다(이하 이 사건 징계처분). A는 이에 불복하였으나 상고심 전까지 노동위원회와 법원은 회사의 이 사건 징계처분이 정당하다고 판단하였다. 그러나 대법원은 이 사건 징계처분에 절차상 중대한 하자가 있다고 판단하며 원심을 파기하였다.

- 대법판결은 그 근거로 공정대표의무 위반을 제시하였다. 노동조합 및 노동관계조정법 제29조의4 제1항은 공정대표의무에 관하여 교섭대표노동조합과 사용자는 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합 또는 그 조합원 간에 합리적 이유 없이 차별을 하여서는 아니 된다라고 규정하고 있다. 공정대표의무는 헌법이 보장하는 단체교섭권의 본질적 내용이 침해되지 않도록 하기 위한 제도적 장치로서, 교대노조와 사용자가 체결한 단체협약의 효력이 교섭창구 단일화 절차에 참여한 다른 노조에게도 미치는 것을 정당화하는 근거가 된다. 이러한 공정대표의무의 취지와 기능 등에 비추어 보면, 공정대표의무는 단체교섭의 과정이나 그 결과물인 단체협약의 내용뿐만 아니라 단체협약의 이행과정에서도 준수되어야 한다(대법원 2018.8.30. 선고 2017다218642 판결 등). 단체협약에 명시된 이 사건 규정을 적용하여 상벌위원회를 구성하는 것은 실체적 공정대표의무의 적용 영역인 단체협약의 이행과정과 관련이 있다.

- 대법판결은 이 사건 규정의 취지를 징계에 대한 노동조합과 근로자들의 참여권을 보장함으로써 절차적 공정성을 확보함과 아울러 사용자의 징계권 남용을 견제하기 위한 것이라는 점을 확인한 다음(대법원 2009.3.12. 선고 2008두2088 판결 등 참조), 이를 바탕으로 이 사건 규정의 효력이 소수노조에 미치는 것을 정당화하기 위해서는, 소수노조 소속의 근로자에 대한 징계 절차에서 이 사건 규정에 따른 참여권을 소수노조 등에 대하여 실질적으로 보장할 필요가 있다고 보았다. 그리고 사용자와 교대노조가 이 사건 규정에 따라 근로자측 위원을 선임하면서 소수노조를 배제한 채 오로지 교대노조의 조합원만을 선임하는 경우, 소수노조는 독자적으로 단체교섭권을 행사하지 못하는 것을 넘어, 소속 조합원의 근로조건에 관하여 중대한 영향을 미치는 징계처분에 관하여 이 사건 규정에서 보장한 참여권조차 실질적으로 행사하지 못하게 되는 결과에 이르게 되며, 노동조합 간에 조합원 확보 등을 위하여 단순히 경쟁하는 차원을 넘어 반목·갈등하는 경우가 많은 현실을 고려할 때, 교대노조의 조합원만을 근로자측 위원으로 선임할 경우, 징계의 절차적 공정성을 확보함과 아울러 사용자의 징계권 남용을 견제하고자 한 이 사건 규정의 취지가 제대로 달성되지 못할 우려도 크다는 점을 지적하였다.

- 나아가 대법판결은 판결 요지[2]와 같이 이 사건 규정을 적용하는 경우 공정대표의무 준수 여부를 판단하는 기준으로 소수노조 소속 조합원에 대한 징계 절차에서 근로자측 위원을 선임할 경우 다른 특별한 사정이 없는 한 소수노조 측을 1인 이상 근로자측 위원으로 선임하여야 하며, 이와 달리 소수노조 조합원을 배제한 채 오로지 교대노조 측으로만 근로자측 위원을 선임한다면 징계 절차에서 소수노조 등을 합리적 이유 없이 차별한 것으로 공정대표의무에 위배된다고 판시하였다.

- 끝으로, 대법판결은 판결 요지[3]과 같이 회사가 이와 같이 공정대표의무를 위반하여 소수노조의 참여권을 보장하지 않은 채 소수노조 소속 A를 징계한 것은 절차상 중대한 하자에 해당하므로 이 사건 징계처분은 무효라고 판단하였다.

- 실체적 공정대표의무의 경우 그동안 조합사무실 제공, 근로시간면제 배분, 게시판 사용, 차량 배정 등 단체협약에 따라 이루어지는 물질적 급부를 대상으로 문제제기된 경우가 많았는데, 대법판결은 징계위원회 구성을 통한 노동조합의 절차적 참여권 부여에 있어서 공정대표의무 위반 여부를 다른 것이라는 점에서 의의가 있다. 특히, 징계는 근로자의 신분에 직접적인 불이익을 야기한다는 점에서 근로자의 입장에서 공정성을 담보 받고 충분히 소명할 기회를 보장받을 필요가 크다. 이 사건 규정과 같이 징계절차에서 노동조합의 참여를 보장하는 단체협약 규정은 근로자의 이러한 필요에 대응함은 물론이고, 더 나아가 징계대상자가 조합원(특히 조합간부)인 경우 노동조합 활동을 보장한다는 의미도 있다. 그런데 이러한 취지에도 불구하고 이 사건과 같이 상벌위원회를 구성함에 있어 다수노조의 참여만이 인정된다면 노조갈등이라는 현실적 상황상 소수노조 및 그 조합원의 입장에서는 다수노조 측보다 불리할 수밖에 없다. 그런 점에서 대법판결은 소수노조의 징계절차 참여권 보장 필요성 및 현실적 문제를 고려하여 소수노조에게 최소한의 숨길을 열어주었다는 점에서 긍정적이다.

- 그런데 실체적 공정대표의무는 통상 사용자가 제공하는 물질적 급부의 배분과 관련하여 논의되어 왔고, 이 경우 법원은 대체로 조합원 수에 따른 비례적 적용을 중요한 기준으로 삼는 경향을 보여왔다. 대법판결의 경우에는 조합원 수를 비교하지는 않았지만 근로자위원 임명 시 전면배제가 아니라면(즉, 단 한 명만 참여해도 충분) 공정대표의무 위반이 아니라고 보았다는 점에서 간접적으로 13배 이상의 조합원 수 차이를 고려하였다고 볼 수 있다. 즉 엄격하게 비례성을 따진 것은 아니지만 근로자위원의 의석수를 배분하는 방식으로 최소한의 참여권만 인정하였다는 점에서 여전히 비례적 배분이라는 큰 틀은 유지하고 있는 셈이다.

- 그러나 대법판결에서 문제된 징계절차 참여권은 추상적이고 계량할 성질의 것이 아니라는 점에서 물질적 급부 중심의 종래 사안들과 구분되는 특수성이 있다. 따라서 조합원 수에 따라 배분하던 기존의 사례와는 다른 방식의 접근이 가능하다. 이를테면, 소수노조 조합원이 징계대상이거나 징계에 있어 중요한 이해관계가 있는 자라면 소수노조만으로 상벌위원회를 구성하는 방법도 있는 것이다. 상벌위원회는 통상 다수결에 의해 의사결정을 하는 경우가 일반적이는데 이러한 다수결에 의한 결정구조하에서 소수노조 측 근로자 1인의 참여를 보장하는 것만으로는 징계대상자의 입장을 실질적으로 대변하기가 어렵다는 한계가 있다. 차치 절차에 참여시켜 줬다는 명분만 제공해 소수노조를 둘러리로 전락시키면서 소수노조 조합원의 소명기회를 부당하게 제약하거나 소수노조의 조합활동을 위축시킬 위험이 있는 것이다. 엄밀히 보면 소수노조가 차별받는 지점은 바로 이것이다. 즉, 근로자위원 의석수 하나가 중요한 것이 아니다. 이러한 차별은 소수노조 조합원의 징계가 문제된 사안에서 전체 근로자위원을 소수노조 조합원으로 총원할 때에만 시정이 가능하다. 그리고 그렇게 하더라도 배분의 한계가 있어 제로섬(zero-sum) 관계가 형성되는 물질적 급부가 아니므로 교대노조를 역차별한다고 보기도 어렵다. 근로자 및 노동조합 보호의 취지에서 불이익의 직접상대방인 노동조합 측이 각자 징계절차에 온전히 관여하게 하는 것이 가장 차별과 거리가 멀다.

- 공정대표의무는 교섭창구 단일화를 통해 소수노조의 단체교섭권을 박탈하는 것을 정당화하기 위한 장치로 고안되었다. 따라서 창구단일화 제도의 정당성은 공정대표의무의 실질적 보장 여부에 달려있다. 그러나 법원은 그동안 물질적 급부를 대상으로 하는 실체적 공정대표의무를 판단하며 조합원 수에 따른 비례 배분 원칙을 적용하는 경향을 보여왔고, 이는 노조 간의 제로섬 관계를 강제하고 고착화하는 데 기여해 왔다.

- 징계절차 참여권은 모든 노조에게 충분히 기회를 부여하더라도 많지 않는다. 그러나 대상판결은 이와 같은 추상적 권리마저 근로자위원 의석수라는 계량적 문제로 환원하고, 자기 조합원 사건에 한해 최소 1인의 참여만으로 차별이 해소될 수 있다고 판단함으로써 비례적 배분이라는 기존 해석의 관성에서 벗어나지 못했다. 즉, 사안의 특수성을 고려하여 차별 시정 방법을 유연하게 모색할 수 있었음에도 그러지 못했다는 아쉬움이 남는다. 생각건대 이러한 한계는 소수노조의 교섭권을 원천적으로 제약하고 노조 간의 경쟁을 제로섬 게임으로 변질시키는 교섭창구 단일화 제도의 태생적 모순에서 비롯된 것으로, 법원 역시 이 굴레에 포획된 것은 아닌지 의문이 든다. 창구단일화 제도에 대한 위헌론이 끊이지 않는 근본적인 이유도 여기에 있지 않을까.

<업무복귀 의사표시 이후에도 유지된 집화중단조치(직장폐쇄)의 위법성> **춘천지방법원 2025.07.09. 선고 2024나33324 판결**

【판결 요지】

- 피고들은 D노조 측과의 회의에서 원고들이 조기출차를 하는 경우 발생하는 대체배송에 과다한 비용이 소요되고 다른 택배기사들도 조기출차를 요구하면 감당하기 어렵다는 등의 의견을 밝히기도 하였는데, 이러한 사정들까지 더하여 보면, 오히려 피고들은 이 사건 집화중단조치, 즉 직장폐쇄가 원고들의 총파업에 대항하여 이미 개시되어 있었음을 기화로 당일배송에 관한 피고들의 주장을 관철시키기 위하여 직장폐쇄를 유지하였다고 볼 여지가 있다.
- 결국 진정으로 업무에 복귀할 의사를 표시하였음에도 피고들이 이 사건 집화중단조치를 유지한 것은 원고들의 당초의 쟁의행위(총파업)에 대한 방어적 목적에서 벗어나 공격적 직장폐쇄의 성격으로 변질된 것이고, 원고들의 쟁의행위(조기출차 주장)에 대한 방어수단으로서의 상당성을 갖추었다고 볼 수도 없어 정당성이 없다.

I. 당사자와 사실관계

- 피고 A는 CJ대한통운과 택배집배점계약을 체결하고 CJ대한통운으로부터 위탁받은 택배운송업무를 수행하는 춘천남대리점을, 피고 B는 소양대리점을 운영하는 대리점주이다. 원고들은 피고들과의 사이에 각 집배점 영업구역 내 담당구역에 관한 택배 집화 및 배송업무를 수행하고 수수료를 지급받기로 하는 위수탁계약을 체결한 택배기사들이다. 원고들은 전국택배노동조합(이하 택배노조라 한다)에 가입한 조합원들이다.
- 택배노조와 피고들은 2021년 배송상품 인수 시간의 단축, 조합원 휴가, 주5일제 실시, 집배송 업무 외 분류작업 금지 등의 사항에 관하여 수차례 단체교섭을 진행하였으나 합의에 이르지 못하여 강원지방노동위원회에 노동쟁의조정신청을 하였고 2021.5.27. 조정중지결정을 받았고, 이와 같이 단체교섭이 결렬되자 택배노조는 2021.12.28.경 총파업을 실시하였고 원고들도 파업에 동참하였다. CJ대한통운은 피고들의 요청에 따라 2021.12. 말경부터 2022.3.22.까지 원고들의 담당구역에 관한 집화중단조치를 하였고 피고들은 대체배송기사 등에게 해당 구역 내 집화 및 배송업무를 수행하게 하였다.
- 택배노조는 2022. 3. 2. CJ대한통운택배대리점연합(이하 대리점연합이라고 한다)과의 사이에 조합원들이 파업을 종료하고 현장에 복귀하기로 하면서 모든 조합원은 서비스 정상화에 적극 참여하고 합법적 대체배송을 방해하지 않는다. 다만 대리점연합과 택배노조는 복귀 즉시 부속합의서 논의를 개시하여 6. 30. 까지 마무리되도록 한다는 내용을 담은 공동합의문을 작성하였고 2022. 3. 3.경 피고들에게 조합원인 원고들이 파업을 종료하고 2022. 3. 7.부터 업무에 복귀한다는 의사를 표명하였다.
- 피고들은 원고들의 업무복귀 의사표명을 전달받고도 2022. 3. 22.까지 CJ대한통운에 집화중단조치의 해지를 요청하지 않았다.

II. 이 사건의 쟁점

- 이 사건에서 쟁점이 된 부분은 ① 택배기사들이 노조법상 근로자에 해당하는지 여부, ② 택배노조의 총파업에 대항한 집배점주의 집화중단조치가 직장폐쇄에 해당하는지 여부, ③ 직장폐쇄 이후 택배기사들의 업무복귀 의사표시에도 불구하고 집화중단조치를 유지한 것이 위법한 직장폐쇄에 해당하는지 여부 등이다. 이 중에서 특히 마지막 쟁점이 대상판결에서의 핵심적인 쟁점이라고 할 수 있다.

III. 대상판결의 판단

1. 원고들이 노동조합법상 근로자에 해당하는지 여부

- 대상판결은 원고들의 사업에 필수적인 노무를 제공함으로써 피고들과 경제적·조직적 종속관계를 이루고 있는 택배기사인 원고들은 노동조합법상 근로자에 해당하고, 집배점주인 피고들은 노동조합법상 사용자의 지위에 있다고 판시하여 원고들과 피고들이 각각 노조법상 노사관계당사자의 지위를 갖는다는 점을 명확히 하였다. 그 근거로 헌법 제33조 제1항의 성격과 내용, 노조법의 입법목적, 노조법상 근로자 정의규정 등을 고려하여 판단하였다.

2. 집화중단조치가 직장폐쇄에 해당하는지 여부

- 대상판결은 원고들과 같은 택배기사들은 소속된 대리점에서 일정한 구역을 할당받고, 해당 구역에 대한 집화코드를 발급받는데, 택배기사에 대한 집화중단조치가 이루어질 경우 해당 택배기사가 담당하는 구역의 택배물품에 대한 집화 자체가 불가능하게 되고, 당연히 위 배송구역을 담당하는 기사는 배송할 물건이 입고되지 않아 배송을 할 수 없게 된다. 결국 피고들의 집화중단조치는 택배노조 조합원인 원고들의 노무수령을 거부하는 결과를 가져오는 측면이 있어 실질적으로 직장폐쇄에 해당한다고 볼 수 있다.고 하면서, 극히 일부 상품의 집화 및 배송이 가능하였다고 하더라도 택배기사인 원고들의 주요배송업무를 불가능하게 하는 집화중단조치는 집단적 노무수령거부에 해당하고, 게다가 총파업에 참가한 택배기사에 대한 노무수령을 거부한 것은 택배노조 조합원의 쟁의행위에 대항하여 이루어진 것이어서 직장폐쇄에 해당한다.고 판시하였다.

3. 업무복귀 의사표시 이후에도 집화중단조치를 유지한 것이 위법한지 여부

(1) 택배기사들이 진정한 업무복귀 의사표시를 하였는지 여부

- 대상판결은 원고들이 조기출차 주장을 유지하면서 업무복귀 의사를 표시하였다고 하여 그 의사가 진정한 것이 아니었다고 볼 수 없고, 피고들이 원고들의 업무복귀 의사의 진정성을 의심할 만한 이유도 없었다.고 판단하였다. 그 근거로, ① 택배기사의 작업시간은 사회적 합의의 주된 내용이었고, 원고들은 총파업 이전에도 조기출차를 통해 작업시간 문제를 개선하려고 했던 것으로 보인다(이는 쟁의행위로 볼 수 있다)는 점, ② 공동합의문에 서비스 정상화에 적극 참여하고 대리점연합과 택배노조는 복귀 즉시 부속합의서 논의를 개시한다는 문구가 있고, 이 공동합의문 작성 경위에 대한 진술에 따르면 택배노조와 대리점연합은 노조원들이 총파업을 중단하고 복귀한 이후에도 사회적 합의에 따른 사항 그중 특히 작업시간 제한을 이행하기 위한 부분파업 또는 태업이 지속될 가능성이 있음을 서로 인지, 확인하면서 공동합의문을 작성하였던 것으로 보이는 점, ③ 총파업 이전부터 원고들은 위수탁계약서상 당일배송의무에도 불구하고 조기출차를 주장하며 이를 실행해왔던 것으로 보이고, 공동합의문 작성 경위와 그 문구의 의미에 비추어 피고들은 원고들이 파업을 종료하고 복귀하여서도 조기출차를 주장할 것임을 예상할 수 있었다는 점 등을 들었다.

(2) 업무복귀 의사표시 이후의 집화중단조치의 위법성 여부

- 대상판결은 피고들이 원고들에게 계속하여 당일배송의 확약을 요구하여 CJ대한통운에 집화중단조치의 해지를 요청하지 않았고, 택배노조 측과의 회의에서 조기출차에 대한 대체배송에 과다한 비용이 소요되고, 다른 택배기사들도 조기출차를 요구하면 감당하기 어렵다고 하는 등의 사정을 고려하면, 오히려 피고들은 이 사건 집화중단조치, 즉 직장폐쇄가 원고들의 총파업에 대항하여 이미 개시되어 있었음을 기화로 당일배송에 관한 피고들의 주장을 관철시키기 위하여 직장폐쇄를 유지하였다고 볼 여지가 있다. 결국 원고들이 이 진정으로 업무에 복귀할 의사를 표시하였음에도 피고들이 이 사건 집화중단조치를 유지한 것은 원고들의 당초의 쟁의행위(총파업)에 대한 방어적인 목적에서 벗어나 공격적 직장폐쇄의 성격으로 변질된 것이고, 원고들의 쟁의행위(조기출차 주장)에 대한 방어수단으로서의 상당성을 갖추었다고 볼 수도 없어 정당성이 없다.고 하면서 원고들이 2022. 3. 7. 이후 업무복귀 의사를 명시적으로 밝혔음에도 피고들이 2022. 3. 7.부터 2022. 3. 22.까지 이 사건 집화중단조치를 해지하지 않고 그대로 유지한 것은 위법한 직장폐쇄에 해당하므로 피고들은 이로 인해 원고들이 입은 손해를 배상할 책임이 있다.고 판시하였다.

IV. 평가

1. 직장폐쇄로서의 집화제한(중단)조치

- 직장폐쇄는 사용자 측의 쟁의행위로서, 노사관계 당사자 일방인 노동조합이 근로조건 개선 등의 주장을 관철할 목적으로 행하는 쟁의행위에 대항하면서 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위이다(노조법 제2조 제6호). 즉 직장폐쇄는 사업장 출입의 금지와 같은 장소적 제한의 개념이 아니라, 쟁의행위가 발생한 경우 이에 대항하여 근로자의 노무수령을 집단적으로 거부함으로써 임금지급의무에서 벗어나는 효과를 얻는 방어적 행위이다.

- 대상판결 이전에도 집화제한조치를 포함한 기간에 사용자인 대리점주가 원청인 택배회사의 지침을 위반한 물품에 대하여 배송거부한 택배기사에게 손해배상청구를 한 사건에서 법원은 택배기사들의 배송거부가 쟁의행위의 정당성을 갖추지 못하였으므로 해당 기간에 대하여 집배계약의 채무불이행을 이유로 손해배상책임을 인정하였다. 그러나 택배회사의 집화제한조치로 인하여 택배기사들이 배송업무를 수행하는 것이 원천적으로 불가능하였던 기간에 대하여는 택배기사들에게 손해배상책임을 인정하지 않았다. 이 사건에서 법원은 택배기사들의 배송거부라는 부분적·전면적 쟁의행위에 대하여 사용자가 실시한 집화제한조치는 집단적 노무수령 거부 즉 직장폐쇄에 해당한다고 명시적으로 판단하지는 않았으나, 근로자 측의 위법한 쟁의행위에 대한 대항적 쟁의행위로서 노무수령거부의 효과로 보수지급의무를 면한다고 보아 택배기사들에게 지급한 집배수수료를 기준으로 손해배상액을 산정하였다.

- 위 사건도 위 판결과 마찬가지로 손해배상청구소송사건인데, 택배기사들이 노조법상 근로자에 해당하며, 이들로 구성된 노동조합의 총파업에 대하여 대응한 대리점주 측의 집화중단조치가 직장폐쇄에 해당함을 명백히 확인하였다.

2. 업무복귀 의사표시 이후 위법한 직장폐쇄로의 전환

- 피고 대리점주들은 총파업 이전에도 작업시간에 대한 쟁점사항이었던 토요일무와 조기출차에 관하여 총파업 및 이에 대한 직장폐쇄를 기화로 하여 사용자 측에 유리하게 해결하려는 목적으로 택배기사들의 업무복귀 의사에도 불구하고 집화중단조치를 해지하지 않았다고 판단되었다. 대상판결은 직장폐쇄의 대항적·방어적 성격에 따라 직장폐쇄 중에 노동조합 측이 진정한 업무복귀 의사를 표시한 이후에는 사용자 측은 직장폐쇄를 해지하고 노무를 수령하여야 한다는 대법원 판결의 법리를 충실하게 재확인하였다.

- 이 사건에서 대리점주 측은 진정한 업무복귀는 조기출차와 같은 부분적 쟁의행위 없는 배송업무의 수행이라고 주장하였으나, 대상판결은 조기출차를 쟁의행위로 평가하되, 대리점주 측의 직장폐쇄인 집화중지조치는 총파업에 대항하는 행위이므로 양자를 구분하여 판단하고 있다. 다시 말하면 대리점주 측의 집화중지조치는 택배노조의 총파업에 대항하여 실시된 직장폐쇄로서 정당성이 인정되고, 택배노조 조합원들이 총파업을 중단하고 총파업 이전과 같이 업무에 복귀하겠다는(이것이 서비스 정상화라고 본 것이다)는 의사를 표명한 이상 대항적 행위로서의 직장폐쇄는 더 이상 지속할 수 없다고 한 것이다.

- 대상판결은 총파업과 별개로 조기출차에 대하여 대리점주 측이 직장폐쇄를 할 수 있는지 여부에 관하여는 명확히 하고 있지 않으나, 노동조합이 총파업 이전에도 토요일무, 조기출차 등의 부분적인 쟁의행위를 행하였음에도 총파업이 발생하기 전까지는 대리점주들이 집화중지조치를 하지 않았다는 사실을 고려하면, 총파업이 중단된 이후 노동조합의 조기출차에 대하여 대리점주 측이 집화중지조치를 하는 것은 직장폐쇄로서 상당성이 인정되기 어려운 상황으로 비추어진다.

- 한편 이 사건 이후에도 택배기사의 작업시간과 관련하여 노사 간에 계속 교섭을 해나갔고, 2022.10. 체결된 위수탁계약서의 부속합의서에는 본인의 차량에 상차하는 시간(인수시간)은 1일 3시간 이내를 원칙으로 하며, 상차작업 종료시간 이후 서버터미널에 화물이 도착한 경우 수탁자는 당일배송을 하지 않을 수 있다는 규정을 두었다. 이에 따라 최근 2025.7.10. 대리점연합과 전국택배노조는 단체협약을 체결하였는데, 동 단체협약은 조합원의 인수시간은 원칙적으로 1일 3시간을 초과할 수 없으며, 각 서버터미널별 인수작업의 기준마감시간은 별도로 정하되, 화물이 기준마감시간을 초과하여 서버터미널에 도착한 경우 조합원은 해당 화물을 당일배송하지 않을 수 있다는 조항을 두고 사용자는 인수마감시간이 12시를 초과하는 각 서버터미널에 대하여 마감시간 단축을 위한 단기·중장기 개선대책을 수립하고, 노사위원회가 이행 여부를 점검하도록 하는 등 택배기사들의 화물 인수시간이 길어져 전체 작업시간이 지나치게 장시간이 되는 것을 막기 위한 노력을 하고 있다.

<단체교섭응낙가처분의 인정 여부> **광주고등법원 2025.02.05. 자 2024라1091 결정**

【판결 요지】

- 채권자가 채무자에게 단체교섭을 요구한 2020. 1. 6. 당시 채권자는 채무자의 유일한 노동조합으로서 채무자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다. 채무자는 채권자의 요구에 응하여 단체교섭 절차를 진행할 의무가 있으므로, 채권자의 이 사건 가처분 신청은 그 피보전권리의 소명이 있다.
- 채무자가 현재까지 채권자와의 교섭을 거부하고 있는 등 기록에 나타난 제반 사정에 비추어 채권자 소속 근로자들에게 현저한 손해가 발생할 염려가 있다고 보이므로 채무자에 대하여 가처분을 명할 보전의 필요성도 소명된다.
- 산업별 노동조합인 채권자는 채무자 회사 근로자들을 대상으로 2020. 1. 5. 지회를 설립하였고, 쟁점 노조는 2020. 1. 7.에, 참가인 노조는 2021. 3. 4.에 각각 설립되었다. 한편 쟁점 노조의 설립이 부당노동행위에 해당한다고 하여 이에 관여한 채무자 회사 임직원들에 대한 유죄판결이 선고되어 2023. 1. 26. 확정되었다.
- 2020. 1.경 채권자와 쟁점 노조는 채무자 회사에 단체교섭을 요구하였고, 채무자는 쟁점 노조가 과반수 노동조합이라는 통지 내용을 공고한 후 쟁점 노조와 2020년 임금 및 단체협약을 체결하였다. 이에 채권자가 이의신청을 하였으나, 전남지방법노동위원회는 채권자의 신청을 기각하고 쟁점 노조를 과반수 노동조합으로 인정하였고, 중앙노동위원회는 채권자의 재심 신청을 기각하였다. 이에 대하여 채권자는 재심 판정 취소소송을 제기하였는데, 서울행정법원은 쟁점 노조의 단체성 결여를 이유로, 서울고등법원은 쟁점 노조가 부당노동행위에서 의해 설립되어 노동조합으로서의 실질적 요건을 갖추지 못하였다는 이유로 쟁점 노조를 과반수 노동조합으로 인정한 재심 판정이 위법하다고 판단하였다. 이에 따라 중앙노동위원회는 채권자의 이의신청을 기각하면서 과반수 노동조합이 존재하지 않는다는 내용의 재처분 판정을 하였다.
- 2022. 10.경 채권자와 쟁점 노조, 참가인 노조는 채무자에게 단체교섭을 요구하였고, 교섭창구단일화 절차를 거쳐 참가인 노조와 채무자는 2022년 및 2024년 임금 및 단체협약을 체결하였다.
- 채권자는 중앙노동위원회의 재처분 판정 확정 후 채무자에게 2020년 단체교섭을 위한 상견례를 요청하였으나, 채무자가 이에 응하지 않자 단체교섭응낙가처분을 신청하였다. 광주지방법원은 2024. 7. 12. 2024카합37 결정에서 피보전권리 및 보전의 필요성이 소명되지 않았다고 하여 신청을 기각하였으나, 대상 결정은 채무자의 단체교섭응낙의무를 인정하고, 이를 이행하지 않는 경우 1일 300만 원을 지급하라는 결정을 하였다.
- 노동조합은 헌법상 단체교섭권을 가지며, 사용자는 노동조합의 단체교섭에 성실하게 교섭할 의무를 부담한다. 쟁점 노조의 설립이 무효라면 2020. 1. 6. 당시 채무자 회사의 유일한 노동조합인 채권자는 채무자에게 단체교섭을 요구할 수 있으므로 가처분을 통해 보호해야 하는 피보전권리가 인정될 수 있다. 1) 대상 사건과 같이 과거의 근로관계에 대한 단체교섭을 청구할 수 있는지가 문제될 수 있으나, 기존의 임금, 근로시간, 퇴직금 등 근로조건 결정 기준을 소급적으로 동의하거나 승인하는 단체협약을 체결하는 것도 가능하므로 2) 과거의 근로관계에 관한 사항에 대한 단체교섭이 불가능하다고 볼 근거는 없다. 또한 단체교섭의 지연에 따라 노동조합의 교섭력 및 단결력이 저하될 수 있고, 이는 조합원에게 유·무형의 손해를 야기할 수 있으며, 위법한 단체교섭의 거부는 노동조합의 존재 의의를 상실하도록 하는 결과가 될 수도 있다는 점에서 보전의 필요성 역시 인정할 수 있다. 대상 결정에서도 위와 같은 이유로 채권자의 가처분 신청을 인용한 것으로 볼 수 있다.
- 가처분과 가압류에서 사실인정은 증명보다 낮은 단계의 개연성으로 충분한 소명에 의하는 것이 원칙이다. 그런데 단체교섭응낙가처분과 같은 만족적 가처분 또는 단행적 가처분은 적극적으로 현상을 변경하여 본안 판결과 동일한 효과를 얻을 수 있다는 점에서 증명에 가까운 고도의 소명이 필요한 것으로 본다. 대상 결정의 원심은 단체교섭응낙가처분에서는 고도의 소명이 요구된다고 하면서 피보전권리와 보전의 필요성이 소명되지 않았다고 하여 신청을 기각하였다. 그러나 고도의 소명이 필요하다는 이유만으로 단체교섭응낙가처분을 인정할 수 없는 것은 아니다. 채권자의 단체교섭권과 채무자의 단체교섭에 응할 의무를 인정할 수 있다면 피보전 권리는 인정된다고 보아야 하고, 단체교섭의 지연으로 인해 노동조합 및 조합원에게 현저한 손해가 발생할 수 있으며, 단체교섭권은 헌법 제33조가 특별히 보호하고 있는 권리인 점, 단체교섭응낙가처분은 사용자가 단체교섭에 응하도록 할 뿐 특정한 내용의 단체협약을 체결하도록 하는 것은 아니라는 점, 교섭을 통한 대화는 집단적 노사관계의 분쟁 해결을 위한 전제가 된다는 점을 고려하면 보전의 필요성을 지나치게 엄격히 해석하는 것은 적절하지 않다.
- 채무자에게 어떠한 작위의무 또는 부작위의무를 명하는 가처분의 경우, 가처분의 실효성 확보를 위해 간접강제를 함께 신청하는 경우가 많다. 간접강제는 채무자가 일정한 기간 내에 가처분에서 명한 의무를 이행하지 않는 경우 일정한 배상을 하도록 함으로써 채무자가 의무를 이행하도록 심리적 압박을 가하는 것이다. 간접강제를 통해 단체교섭응낙가처분이 사용자의 단체교섭 거부에 대한 실효성 있는 구제 수단이 될 수 있으며, 대상 결정에서도 이러한 점을 고려하여 1일당 300만 원의 간접강제를 명하였다. 한편 대상 사건에서 채권자는 간접강제와 함께 집행관 공시 명령도 함께 신청하였는데, 집행관 공시는 통상 부작위를 명하는 가처분의 실효성 확보를 위해 인정되는 것이란 점에서, 대상 결정은 집행관 공시까지 명할 필요성은 없다고 판단을 한 것으로 볼 수 있다.
- 사용자의 위법한 단체교섭 거부에 대하여 단체교섭응낙청구소송을 제기할 수도 있겠지만, 본안 소송의 판결이 확정되기까지는 상당한 시간이 소요될 수밖에 없다. 이러한 점을 고려하였을 때 단체교섭응낙가처분과 같이 신속하고 실효성 있는 구제 수단으로 기능할 수 있는 노동가처분은 노동분쟁을 해결하는 중요한 수단이 될 수 있다.

<차별적 인사고과에 대한 부당노동행위 구제신청기간의 산정기준과 방법(계속하는 행위)> 대법원 2025.04.03. 선고 2023두41864, 41871 판결

【판결 요지】

- 2018년에 인사고과 부여 등을 실시하고, 이를 기초로 2019년 3월부터 2020년 2월까지 임금을 지급한 행위는 같은 단위 기간에 관하여 이루어진 것이므로 하나의 계속하는 행위에 해당한다고 볼 수 있다. 이 사건 구제신청은 2018년의 인사고과 부여 등에 따라 임금이 지급되던 중인 2019.8.30. 제기되었다. 따라서 이 사건 구제신청 중 2018년의 인사고과 부여 등과 2019년의 임금상 불이익에 관한 부분은, 원고들이 이를 노동위원회 구제절차에서 부당노동행위로 주장하였다면, 그 전부가 구제신청기간을 준수한 것이 된다.

I. 사건의 개요, 법적 쟁점과 경과

- 사용자는 2015년부터 2019년까지 근로자에 대해 인사고과를 실시하고 아래의 표와 같이 통보하고, 이를 바탕으로 심사하여 매년 3.1. 승격을 통보하였다. 노동조합 및 조합원들(원고들)은 2019.8.30. 사용자가 2015년부터 2019년 상반기까지 조합원들에게 하위의 인사고과를 부여하고 승격을 누락시킨 것은 불이익취급 및 노동조합 운영 지배·개입의 부당노동행위를 인정한다. 사용자는 해당 고과평가를 취소하여 재실시하고, 재평가 결과에 따라 정기승급 및 승격을 실시하며, 부당한 평가 및 승격 누락으로 지급받지 못한 임금 상당액을 지급하라.는 취지로 구제신청(이 사건 구제신청)을 하였다. 원고들은 사용자가 조합원 임을 이유로 비조합원에 비해 불리하게 인사고과를 하여 승격에서 누락하는 등의 불이익을 받았으며, 불이익취급 및 지배·개입의 부당노동행위를 주장하는 사건(평가에 의한 집단차별의 부당노동행위)이다. 여기서 다루고자 하는 쟁점을 중심으로 사실관계를 축약하면 아래의 표와 같다.

년도	상반기 업적평가	하반기 업적평가	역량평가	승격통보일
2015년	2015.6.말	2016.1.말	2016.1.말	2016.3.1.
2016년	2016.6.말	2017.1.말	2017.1.말	2017.3.1.
2017년	2017.6.말	2018.1.말	2018.1.말	2018.3.1.
2018년	2018.6.말	2019.1.말	2019.1.말	2019.3.1.

■ 인사고과는 업무평가(연 2회, 6월과 12월, 평가항목은 목표달성도, 노력도, 기여도)와 역량평가(연 1회, 12월, 평가항목은 공통역량, 직무역량, 리더십 역량)로 구성. 인사고과 등급은 업적평가 및 역량평가 모두 EX(Excellent, 매우 뛰어남), VG(Very Good, 뛰어남), GD(Good, 보통), NI(Need Improvement, 부족), UN(Unsatisfactory, 매우 부족)의 5단계로 나누어지며, NI와 UN은 하위 인사고과로 평가됨.

■ 승격은 상위 직급으로 진급하는 것으로 매년 3.1. 직급별 표준 체류 연수를 충족하고 최소 인사고과 점수를 취득한 경우 승격대상자로 선정, 승격대상자에 대해 인사고과 점수, 체류 연수, 교육 이수점수, 어학 자격 등 기본항목과 정보화 자격, 상벌 등 가감항목을 심사 항목으로 하여 직군 및 직급별 승격 기준을 내에서 심사하여 실시함. 하위 인사고과(NI와 UN)를 받으면 최소 인사고과 점수를 채우지 못해 승격대상자에서 제외되고, 기본항목에서 낮은 점수를 받게 되어 승격심사에서 탈락하고, 이에 따른 임금상 불이익이 있음.

■ 인사고과는 승급에도 적용되는데, 하위 인사고과(NI와 UN)를 받으면 승급되지 못함. 승급되지 못하면 기준급이 변경되지 아니하여 상여급, 성과급, 각종 수당을 지급받지 못하고, 인사고과에 따라 연봉등급이 부여되어 임금도 변동됨.

- 위 표에서 보았듯이 하위 인사고과(NI와 UN)를 받으면 승격에서 탈락할 뿐만 아니라 승급도 못하고, 연봉도 삭감된다. 제규정을 통해 확인된 사항은 아니나 이 사건 회사의 경우 승격과 승급이 구분되어 있고, 승격이란 상위 직급으로의 진급을 의미하는 것으로 승진과 동일한 성격의 인사조치에 해당하는 것으로 보이고, 승급은 급여의 상상을 의미하는昇給(승급)으로 보인다. 이러한 사실에 비추어 하위 인사고과로 인해 직접적으로는 인사상 불이익(승격 탈락)과 임금상 불이익(승급 누락, 연봉 삭감 등)이 있고, 간접적으로는 승격 탈락으로 인한 임금상 불이익이 있다고 볼 수 있다.

- 이 사건은 원고들이 구제신청한 내용이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 노동조합법) 제82조 제2항(부당노동행위 구제의 신청은 부당노동행위가 있는 날(계속하는 행위는 그終了日)부터 3월 이내에 이를 행하여야 한다.)의 계속하는 행위인지가 쟁점이 된 사안이다. 구체적으로 첫째, 2015~2018년 인사고과 부여 등(각 연도별 상·하반기 업적평가와 역량평가, 이에 따른 매년 3. 1.자 승격 여부 통보를 말한다. 이하 같다) 외에 각 연도별 임금상 불이익을 부당노동행위로 주장하였는지 여부이다. 둘째, (각 연도별 임금상 불이익을 부당노동행위로 주장하였다면) 2015~2018년 인사고과 부여 등과 2016~2019년 임금상 불이익이 계속하는 행위인지 여부이다.

- 초심과 재심 모두 이 사건 구제신청은 승격 탈락만을 구제신청하였다고 보아 인사고과 통보일(2019.1.말)과 승격 통보일(2019.3.1.)로부터 3개월이 지났으므로 부적법하다고 판단하였다. 그러나 대전지방법원은 제척기간을 준수한 것으로 보아 하위 인사고과 부여·승격누락 및 임금 지급 행위 또는 부작위가 불이익취급 및 지배·개입의 부당노동행위에 해당하는지를 심리·판정하여야 한다며 재심판정을 취소하였다. 반면 대전고등법원은 재심과 마찬가지로 제척기간을 경과하였다고 판단하여 1심 판결을 취소하였다.

- 대법원은 원심판결 중 2019.3. 이후 임금상 불이익을 받지 않았거나 이를 부당노동행위의 구체적 사실로 주장하였다고 보기 어려운 일부 원고(별지1 기재 원고들)를 제외한 나머지 원고들(별지2 기재 원고들)의 구제신청에 대해 제척기간을 준수하였다고 판단하여 이 부분을 파기·환송하였다.

II. 대법원의 판단과 평가

1. 원고들은 무엇을 구제신청의 대상으로 삼았는가?

- 원심은, 원고들의 구제신청서 등에 2015년부터 2019.3.1.까지의 하위 인사고과 부여 및 승격 누락만을 부당노동행위로 특정하였을 뿐 임금상 불이익 자체를 부당노동행위로 특정하지 않았으므로 마지막 승격 통보일(2019.3.1.)로부터 3개월이 경과하였다고 보았다. 승격 누락으로 인한 적정 임금의 미지급 행위는 승격 누락이 부당노동행위 인정을 전제로 시정을 구하는 내용일 뿐 부당노동행위로 특정하지 않았다.

- 대법원은, 대법원 2014.5.29. 선고 2011두24040 판결과 대법원 1999.5.11. 선고 98두9233 판결을 관련 법리로 제시하면서 구제신청서의 구제받고자 하는 사항에 구체적으로 특정되지 않더라도 신청의 전 취지로 보아 어떠한 구제를 구하는지를 파악해야 한다고 판시하였다. 이러한 법리에 따라 대법원은 별지2 기재 원고들은 구제신청서의 신청취지에 하위 인사고과를 부여한 것, 승격 탈락과 승격 탈락으로 지급받지 못한 임금 상당액, 임금상 불이익의 내용(정기승급 누락 또는 연봉 삭감)을 기재하였고, 노동위원회에 제출한 신청이유 2 등에서도 인사고과 부여 등으로 인하여 임금상 불이익이 지속되고 있다고 주장한 점을 들어 인사고과 부여 등과 임금 지급을 모두 부당노동행위를 구성하는 구체적인 사실을 주장하였다고 보았다.

- 필자는 대상판결이 나오기 전, 이 사건을 소재로 작성한 글(각주 1의 글)에서 고등법원의 결론이 번복될 가능성이 낮아 보인다고 평가하였다. 그 이유는 원고들이 주장하는 부당노동행위 구제신청 대상은 하위 인사고과 부여 및 승격 탈락으로 보았고, 승격 탈락으로 인한 각종 불이익은 승격 탈락(불이익취급)과 별개의 완결성을 가진 행위가 아니라 승격 탈락으로 파생되거나 수반되는 불리한 효과에 불과하다고 보았다(이러한 불리한 효과는 승격 탈락이 부당노동행위로 인정될 경우 상황에 따라 구제명령의 범위에 포함되어 시정될 수 있거나 차별적인 인사고과의 시정으로 인한 승격 여부에 따른 효과로 시정될 수 있다). 따라서 부당노동행위 성립을 전제로 시정을 구하는 내용을 기준으로 신청기간을 산정할 수 없다고 보았다.

- 그런데 앞서 보았듯이 이 사건의 경우 차별적인 인사고과로 인해 직접적으로 승격에서 탈락되는 인사상 불이익뿐만 아니라 승급도 못하고, 연봉도 삭감되는 임금상 불이익이 발생된다. 필자는 1심·2심 판결문을 기초로 판단한 한계로 구제신청서 및 이유서 등에 임금상 불이익의 내용(정기승급 누락 또는 연봉 삭

감), 인사고과 부여 등으로 인하여 임금상 불이익을 부당노동행위로 주장한 사실을 파악하지 못했다. 따라서 이 사건 구제신청의 전 취지로 보면 하위의 인사고과 부여로 인한 승격 탈락, 승급 누락, 연봉 삭감을 부당노동행위로 구제신청하였다고 본 대법원의 판단은 타당하다.

2. 인사고과와 그 인사고과로 인한 각종 불이익(승격 탈락, 승급 누락 및 연봉 삭감)이 계속하는 행위인가?

- 대법원은 종전의 판례 법리를 전제로 일정한 단위 기간마다 인사고과나 승격 심사를 하고 그 결과에 따라 임금을 결정하는 사업장에서 노동조합 활동을 이유로 근로자에게 하위 인사고과를 부여하거나 승격에서 탈락시키는 부당노동행위를 하는 사용자의 의사에는 통상적으로 그에 따른 임금상의 불이익을 주려는 의사가 포함되어 있다고 볼 수 있다. 따라서 하위 인사고과 부여 또는 승격 탈락은 특별한 사정이 없는 한 같은 단위 기간(예를 들어, 1년마다 인사고과 부여 등이 이루어지는 사업장에서 연초에 실시하는 전년도 근무성적에 대한 인사고과나 승격 심사와 이에 기한 그 연도 동안의 임금 지급은 같은 단위 기간에 이루어진 것이다)에 대한 임금의 지급과 하나의 계속하는 행위를 구성한다.라고 판시하였다. 따라서 이 사건은 일정한 단위의 인사고과와 그로 인한 승격 탈락, 승급 누락과 연봉 삭감의 임금차별은 계속하는 행위에 해당한다.

- 인사고과로 인한 임금 차별의 경우, 임금이 비교주체와 비교집단 간에 차별적으로 지급됨으로써 반조합적 의도가 구체화되어 실현되므로 인사고과와 그에 따른 임금 지급은 하나의 부당노동행위이다. 그리고 계속하는 행위인지 여부는 기간제 및 파견근로자 보호 등에 관한 법률 관련 판례와 일본 최고재판소의 판단을 참조하면, 사용자가 계속되는 근로제공에 대하여 비교주체에게 차별적인 인사고과를 적용하여 비교집단에 비해 차별적으로 임금을 지급하였다면 특별한 사정이 없는 한 계속하는 행위에 해당한다. 따라서 부당노동행위가 있는 날(불이익취급이 있는 날)은 임금 지급일이며, 계속하는 행위에 해당하므로 마지막 임금 지급일로부터 구제신청기간을 산정해야 한다. 따라서 이 사건 구제신청 중 최소한 2018년 인사고과에 따른 2019년의 승격 탈락과 임금 지급(승급 누락 및 연봉 삭감)에 대한 부분은 2019. 8. 30. 구제신청을 하였으므로 제척기간을 준수한 것이 된다.

3. 그렇다면 2015~2017년 인사고과와 그에 따른 2016~2018년의 불이익(승격 탈락, 승급 누락 및 연봉 삭감)은 2018년 인사고과와 그에 따른 2019년의 불이익과 계속하는 행위인가?

- 대법원은 단위 기간을 달리하는 인사고과 부여 등과 이에 기한 임금 지급은 원칙적으로 하나의 계속하는 행위에 해당한다고 보기 어렵다. 주기적으로 행해지는 인사고과 부여 등 사이에 시간적 연속성이 존재한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 여러 단위 기간의 인사고과 부여 등과 임금 지급을 포괄하여 하나의 계속하는 행위로 보게 되면 구제신청 대상이 되는 행위의 범위가 과도하게 확장된다. 이는 노동조합법이 노동위원회에 의한 신속·간이한 행정적 구제절차로서의 성격 등을 고려하여 부당노동행위에 대한 구제신청기간을 3개월의 단기간으로 정한 취지에 반한다.고 판시하였다. 그러나 대법원은 여기서 더 나아가 다만 사용자가 여러 단위 기간 동안 단일한 의사와 유사한 방식으로 미리 수립한 계획에 따라 일련의 부당노동행위를 실행하였다는 등의 사정이 드러난 경우에는 단위 기간을 달리하는 인사고과 부여 등과 임금 지급 사이에서도 계속하는 행위가 성립할 수 있다.라고 판시하였다. 이에 따라 대법원은 2017년 이전의 인사고과 부여 등과 2018년의 인사고과 부여 등이 계속하는 행위에 해당한다고 볼 만한 특별한 사정이 있는지에 관하여 심리·판단하라며 고등법원으로 되돌려 보냈다.

- 대상판결로 원고들은 비로소 인사고과로 인한 승격 탈락과 임금 지급에 사용자의 부당노동행위가 있었는지를 판단 받을 기회를 얻게 되었을 뿐이며, 여전히 해결해야 할 과제가 많이 남아 있다. 향후 부당노동행위의 성립 여부에 대한 사법적 판단 역시 주의 깊게 지켜볼 필요가 있다.

- 대상판결은 평가(인사고과)에 의한 집단차별(승진 탈락, 승급 누락 및 연봉 삭감의 임금차별)에 대한 부당노동행위 구제신청기간의 산정기준과 방법을 제시한 최초의 판단으로서 큰 의의를 지닌다. 대법원의 이러한 판단을 적극 지지하면서도, 차제에 입법적으로 3개월로 규정된 부당노동행위 구제신청기간을 다른 차별시정제도의 시정신청기간과 보조를 맞추어 6개월로 개정할 것을 제안하는 바이다.

<승진 탈락과 이로 인한 임금상 불이익의 부당노동행위> 서울행정법원 2025.08.29. 선고 2024구합65959 판결

【판결 요지】

- [1] 매년 7월 1일부로 1년 단위의 정기 승진을 실시하고 있고, 이를 기초로 직급에 따라 승진이 이루어진 당해 연도 7월부터 다음 연도 6월까지 차등하여 임금을 지급하고 있으므로, 이 사건 승진인사와 이를 기초로 2023.7.1.부터 2024.6.30.까지의 임금을 지급한 행위는 하나의 계속된 행위에 해당한다.

- [2] 근로자들과 비교집단이 전체적으로 보아 동질의 균등한 근로자 집단임에도 불구하고 근무평가 및 이를 토대로 한 승진인사 결과에서 통계적으로 유의미한 격차가 발생한 것으로 보이고, 그러한 격차는 원고 조합의 조합원임을 이유로 하여 비조합원들에 비하여 불이익취급을 한 것으로 판단되나, 원고들이 제출한 증거만으로는, 사용자에게 승진인사를 통하여 원고 조합의 조직이나 운영을 지배·개입하려는 의사까지 있었다고 보기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

- ※ 대법판결이 인용하기도 하고, 대법판결과 유사한 사안인 대법원 2025.4.3. 선고 2023두41864, 41871 판결에 대해 필자가 『월간 노동리뷰』 2025년 6월 호에 평석(이하 지난 평석)을 작성한 바 있다. 그런데 이번에 대법판결에 대한 평석을 준비하는 과정에서 다시 검토한 결과 구체적인 사실관계에 관한 오인으로 인해 일부 잘못된 정보를 전달한 부분이 있었음을 확인하였다. 이에 이를 바로잡고자 하며, 바로잡고자 하는 내용은 승진 탈락과 이로 인한 임금상 불이익이 구제신청기간을 산정함에 있어서 계속하는 행위인지 여부이다.

I. 사건의 개요, 경과 및 법적 쟁점

- A노동조합(원고 조합)은 전국 규모의 산업별 단위노동조합이고, 하부조직으로 광주전남지역지부 D지회 AA분회(이 사건 분회, 이 사건 분회와 원고 조합을 구분하지 않고 원고 조합이라 통칭)를 두고 있다. 사용자(참가인 회사 내지 이 사건 사용자)는 주식회사DD의 하청회사로 철물가공업 및 창고업 등을 영위하는 법인이다.

- 이 사건 사용자는 소속 근로자들에 대해 매년 6월 근무평가를 실시한 후 이를 토대로 매년 7월 정기 승진을 시행하고 있다. 이 사건 사용자는 2023.5.23. 정기근무평가(이 사건 근무평가, 평가 대상 기간 : 2022.6.1.~2023.5.31.)의 실시를 안내하는 공고를 하였고, 위 근무평가를 토대로 2023.6.26. 2023년도 승진인사(이 사건 승진인사)를 각종 인사명령을 알리는 학습동아리 인트라넷에 게시하였다. 그리고 2023.7.1.자 정기 승진인사를 시행하였는데, 근속승진자 2명을 포함하여 총 16명이 승진하였고, 참가인 회사 소속 직원으로 이 사건 분회의 조합원인 근로자 21명(이 사건 근로자들)은 이 사건 승진인사에서 모두 탈락하였다.

- 이 사건 근로자들과 원고 조합(양자를 합하여 원고들)은 이 사건 사용자가 이 사건 근무평가에서 이 사건 근로자들에 대해 비조합원들과 비교하여 낮은 평가점수를 부여함으로써 이 사건 승진인사에서 탈락시킨 행위가 불이익 취급 및 지배·개입의 부당노동행위에 해당한다고 주장하며 2023.9.27. 전남지방노동위원회에 구제신청을 하였고, 전남지노위는 2023.12.5. 원고들의 구제신청을 인용하는 결정을 하였다. 이 사건 사용자는 초심판정에 불복하여 중앙노동위원회에 재심을 신청하였고, 중노위는 2024.3.19. 원고들의 초심 구제신청이 노동조합 및 노동관계조정법(노동조합법) 제82조 제2항의 신청기간을 초과하여 부적법하다는 이유로 초심판정을 취소하고 원고들의 구제신청을 각하하였다.

- 원고들은 재심판정에 불복하여 행정소송을 제기하였고, 서울행정법원은 제척기간 도과의 문제는 발생하지 않는다며(【판결 요지】[1]) 재심판정을 취소하고, 불이익 취급의 부당노동행위에 해당하나, 지배·개입의 부당노동행위에는 해당하지 않는다(【판결 요지】[2])고 판단하였다. 당사자 모두 항소하지 않아 대법판결이 확정되었다.

- 이 사건의 법적 쟁점은 첫째, 승진 탈락과 이로 인한 임금상 불이익이 계속하는 행위인지 여부이고, 이 부분이 서두에서 밝힌 바로잡고자 하는 내용이다. 둘째, (구제신청기간을 경과하지 않았다면) 이 사건 승진인사가 불이익 취급 및 지배·개입의 부당노동행위에 해당하는지 여부이다. 두 번째 부분은 지면의 제약으로 생략하고, 그 가운데 아쉬운 점만 간략히 짚고 넘어가도록 한다.

II. 승진 탈락과 이로 인한 임금상 불이익이 계속하는 행위인지

- 대법판결은 대법원 2025.4.3. 선고 2023두41864, 41871 판결을 관련 법리로 제시하면서, 원고들은 초심 지노위 단계에서 이 사건 승진인사에서 탈락한 것 외에도 이 사건 승진인사에서 발생한 차별로 인하여 임금상의 불이익이 계속하여 발생하고 있다.라고 주장하였으므로 구제신청의 대상은 승진 탈락뿐만 아니라 이로 인한 임금상 불이익이라고 판단하였다. 이에 따라 【판결 요지】[1]에서 보듯이 이 사건 승진인사와 이를 기초로 2023.7.1.부터 2024.6.30.까지의 임금을 지급한 행위는 하나의 계속된 행위에 해당하므로 제척기간이 도과된 것은 아니라고 판단하였다.

- 한편 중노위는 부당노동행위가 있는 날을 이 사건 승진인사를 학습동아리 인트라넷에서 공고한 2023.6.26.로 보아 이로부터 3개월이 지난 2023.9.27. 구제신청하였으므로 신청기간을 초과하였다고 판단하였다. 그리고 중노위는, 원고들이 초심지노위에 제출한 이의서2를 통해 승진 누락에 따른 임금 손실을 주장한 사실이 있지만 초심지노위에서 사건이 종결될 때까지 이를 신청 취지에 추가한 사실이 없는 점 등을 종합하면, 임금 손실은 승진 누락의 부당노동행위의 후행 결과물에 불과할 뿐 원고들의 직접적인 구제신청의 대상으로 볼 수 없다고 판단하였다.

- 구제신청서의 신청 취지에 구체적으로 특정하지 않더라도 신청의 전 취지로 보면 원고들이 승진 탈락 외에도 이로 인한 임금상 불이익을 부당노동행위를 구성하는 구체적인 사실을 주장하고 있음이 충분히 인정된다.

- 그렇다면 이 시점에서 대법원 2025.4.3. 선고 2023두41864, 41871 판결로 돌아가 보자. 사용자는 2015년부터 2019년까지 근로자에 대해 인사사고과를 실시하고 매년 6월 말에 상반기 업적평가, 다음 해 1월 말 하반기 업적평가와 역량평가를 통보하고, 이를 바탕으로 심사하여 매년 3.1. 승격을 통보하였다. M노동조합 및 조합원들이 2019.8.30. 사용자가 2015년부터 2019년 상반기까지 원고 조합원들에게 하위의 인사사고과를 부여하고 승격을 누락시킨 것은 불이익 취급 및 지배·개입의 부당노동행위임을 주장하며 구제신청하였다. 원심이 하위 인사사고과 부여와 승격 탈락만을 구제신청하였다고 보아 인사사고과 통보일(2019.1.말)과 승격 통보일(2019.3.1.)로부터 3개월이 지났으므로 부적법하다고 판단하였다. 그러나 위 대법원은 원심판결 중 2019년 3월 이후에 임금상 불이익을 받지 않았거나 이를 부당노동행위의 구체적 사실로 주장하였다고 보기 어려운 일부 원고(원고들B)를 제외한 나머지 원고들(원고들A)의 구제신청에 대해 제척기간을 준수하였다고 판단하여 이 부분을 파기·환송하였다.

- 대법원은 일정한 단위 기간마다 인사사고과나 승격 심사를 하고 그 결과에 따라 임금을 결정하는 사업장에서 노동조합 활동을 이유로 근로자에게 하위 인사사고과를 부여하거나 승격에서 탈락시키는 부당노동행위를 하는 사용자의 의사에는 통상적으로 그에 따른 임금상의 불이익을 주려는 의사가 포함되어 있다고 볼 수 있다. 따라서 하위 인사사고과 부여 또는 승격 탈락은 특별한 사정이 없는 한 같은 단위 기간(…생략…)에 대한 임금의 지급과 하나의 계속하는 행위를 구성한다.라고 판시하였다. 즉 노동조합 활동을 이유로 하위 인사사고과를 부여하거나 승격에서 탈락시키는 것은 그로 인한 임금상의 불이익을 주려는 의사가 포함되어 있으므로 하위 인사사고과 부여, 승격 탈락과 이로 인한 임금상의 불이익은 하나의 계속하는 행위에 해당한다고 보았다.

- 필자가 사실관계를 오인하여 지난 평석에서 잘못 전달한 부분은, 승소한 원고들A와 패소한 원고들B가 주장한 부당노동행위를 구성하는 구체적 사실에 관한 내용이다. 구체적으로 어떤 부분에 오류가 있었는지를 일일이 밝히기보다는, 판결문만으로 확인이 어려우나 소송 당사자 등을 통해 파악한 사실관계를 바탕으로 바로잡는 데 중점을 두어 다시 서술하고자 한다.

- 대법원은, 원고들A는 구제신청서의 신청취지에 하위 인사사고과를 부여한 것, 승격 탈락과 승격 탈락으로 지급받지 못한 임금 상당액, 임금상 불이익의 내용(정기승급 누락 또는 연봉 삭감)을 기재하였고, 노동위원회에 제출한 신청이유2 등에서도 하위 인사사고과 부여 등으로 인하여 임금상 불이익이 지속되고 있다

고 주장한 점을 들어 하위 인사고과 부여, 승격 탈락과 이로 인한 임금상 불이익 등을 모두 부당노동행위를 구성하는 구체적인 사실을 주장하였다고 보았다. 그리고 대법원, 위와 같은 법리를 제시하면서 원고들A는 2018년 하위 인사고과 부여 등(2018년 상·하반기 업적평가와 역량평가, 2019.3.1.자 승격 탈락)에 따른 임금상 불이익은 2019년 3월부터 2020년 2월까지 계속하는 행위이므로 2019.8.30. 구제신청한 이 사건은 제척기간을 준수한 것으로 보았다.

- 대상판결도 이러한 취지에서 이 사건 승진인사와 이로 인한 2023.7.1.부터 2024.6.30.까지의 임금상 불이익을 하나의 계속하는 행위에 해당된다고 보아 제척기간이 도과된 것은 아니라고 판단한 것이다.

- 한편 위 대법원은 원고들B에 대해 2019년 3월 이후에 임금상 불이익을 받지 않았거나 이를 부당노동행위의 구체적 사실로 주장하였다고 보기 어렵다.고 보아 제척기간을 도과하였다고 패소 판결을 하였다. 이들은 2018년 이전에 하위 인사고과를 받아 2016~2018년 기간 중 또는 매년 승격에서 탈락되었으나 2019년에 승격되어 임금상 불이익이 발생하지 않거나, 2018년 하위 인사고과를 받았으나 직군에 따라 승격에서 탈락하지 않고 임금상 불이익도 없는 경우 등이다.

- 필자는 승격 탈락으로 인한 임금상 불이익은 승격 탈락과 별개의 완결성을 가진 행위가 아니라 승격 탈락에 수반되는 불리한 효과에 불과하다고 보았다(이러한 불이익은 승격 탈락이 부당노동행위로 인정될 경우 구제명령의 내용에 포함되어 시정될 수 있다). 그래서 부당노동행위 성립을 전제로 시정을 구하는 내용을 기준으로 신청기간을 산정할 수는 없다고 보았다.

- 그러나 위 대법원의 판시 내용과 같이 하위 인사고과를 부여하거나 승격에서 탈락시키는 부당노동행위를 하는 사용자의 의사에 임금상의 불이익을 주려는 의사도 포함된 것으로 볼 수 있다면, 하위 인사고과 부여나 승격 탈락은 성격상 임금차별로 보는 것이 타당하다. 그렇다면 사용자가 계속되는 근로제공에 대하여 비교주체에게 차별적인 평가를 적용하여 비교집단에 비해 차별적으로 임금을 지급하였다면 특별한 사정이 없는 한 계속하는 행위에 해당한다고 보아야 한다. 따라서 하위 인사고과 부여, 승격 탈락과 이로 인한 임금상 불이익은 하나의 계속하는 행위이다. 대상판결이 위 대법원 판단을 좇아 이와 같이 판단한 것은 타당하다(이로써 위 견해를 수정한다). 그리고 부당노동행위의 구제신청기간의 산정은 계속하는 행위를 기준으로 삼지 않고, 일회성의 제재적 불이익 처분을 대상으로 하는 근로기준법(제23조 제1항 및 제28조 제2항)과 다르고, 오히려 비교집단 간의 차별을 대상으로 하는 성·비정규차별의 시정신청기간의 계속되는 차별과 유사하다.

- 결론적으로 평가에 의한 집단차별의 부당노동행위에서 직접적인 임금차별 또는 임금상의 불이익을 주려는 의사로 행한 승진 탈락의 구제신청은 계속하는 행위의 종료일(대상판결의 경우 2024.6.30.)로부터 3월 이내에 구제를 신청하면 된다.

❖ 아쉬운 점

- 대상판결은 불이익 취급의 부당노동행위를 인정하면서 사용자에게 승진인사를 통하여 원고 조합의 조직이나 운영을 지배·개입하려는 의사까지 있었다고 보기 부족하다고 보아 지배·개입의 부당노동행위는 기각하였다. 그러나 특정 노동조합에 대한 승진 탈락과 이로 인한 임금상 불이익은 반조합적 의도로 행한 차별적 평가의 결과로 볼 수 있고, 이러한 불이익을 줌으로써 조합탈퇴나 분열을 조장하여 특정 노동조합의 무력화 또는 약체화를 도모하는 행위로 지배·개입의 부당노동행위에도 해당한다고 보아야 한다. 무엇보다도 개인에 대한 차별이 아니라 조합원 집단 또는 특정 노조원 집단에 대한 차별이기 때문이다. 즉 이 사건 승진인사는 소속 조합을 이유로 한 불이익 취급이 됨과 동시에 노동조합 간에 차별적 취급을 통해 원고 조합의 약체화를 도모하는 행위이므로 지배·개입이라고 보아야 한다.

<산업안전보건법상 건설공사발주자와 도급인의 구별 기준> 대법원 2024.11.14. 선고 2023도14674 판결

【판결 요지】

- 건설공사를 도급하는 사업주가 도급인에 해당하는지는 도급 사업주가 자신의 사업장에서 시행하는 건설공사 과정에서 발생할 수 있는 산업재해 예방과 관련된 유해·위험요소에 대하여 실질적인 지배·관리 권한을 가지고 있었는지를 중심으로, 도급 사업주가 해당 건설공사에 대하여 행사한 실질적 영향력의 정도, 도급 사업주의 해당 공사에 대한 전문성, 시공능력 등을 종합적으로 고려하여 규범적인 관점에서 판단하여야 한다.

I. 사실관계

- 항만의 관리, 운영에 관한 사업 등을 목적으로 설립된 A공사는 강구조물 공사업을 영위하는 B, C 주식회사에게 갑문 정기보수공사를 도급하였다. B주식회사 소속 근로자인 피해자는 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전대 부착설비가 설치되지 않고, 중량물 작업계획서도 작성되지 않았으며, 중량물 하역 작업에 대한 안전교육 및 세부적인 작업지시를 받지 않은 상태로 갑문 상·하부 가이드장치 분리 작업을 위해 갑문 상부에서 윈치를 이용하여 18m 아래 갑문 하부 바닥으로 H빔을 내리는 작업을 진행하던 중, 윈치프레임이 전도되어 갑문 아래로 추락하면서 윈치프레임의 컨트롤러 및 H빔에 연결된 가이드 줄을 잡고 있던 피해자도 프레임과 함께 추락하여 사망하였다.

II. 하급심의 판시 내용

1. 제1심의 판시 내용

- 이 사건의 제1심은 건설공사발주자의 의미는 규범적으로 평가하여 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 지위에 있는 자에 해당하는지에 의해 판결해야 한다고 하면서, 이 사건 갑문을 유지·보수하는 업무는 A공사의 기본적인 업무로 평가해야 한다는 점, 이 사건 사고는 A공사가 직접 관리하는 사업장에서 발생하였다는 점, A공사 사장은 A공사의 안전보건관리총괄책임자인 점, 이 사건 갑문 정기보수공사는 A공사의 핵심적이고 본질적인 사업의 하나인 점, 사장 직속의 재난안전실, 건설본부 산하의 갑문 관리실을 갖추고 있는 점, 이 사건 공사의 실질적 수급인인 B주식회사에 비해 A공사의 인력, 자산규모, 시설규모가 월등히 우월한 지위에 있는 점에 비추어 보면 A공사는 갑문 정기보수공사의 시공을 총괄·관리하는 지위에 있다고 판단하고, A공사 및 A공사의 전 사장(이 사건 사고 발생 당시 사장)에게 유죄판결을 선고하였다.

2. 항소심의 판시 내용

- 항소심은 건설공사발주자에 해당하는지 여부는 규범적인 관점에서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리할 지위에 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다고 하면서, 해당 건설공사의 직접 수행할 자격이나 능력이 없이 건설공사를 다른 사업주에게 도급할 수밖에 없는 자인 경우에는 산안법상의 책임을 회피하기 위하여 임의로 이러한 외관을 야기하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 같은 법상 건설공사발주자에 해당할 뿐 도급인에는 해당하지 않는다고 봄이 타당하다는 법리를 제시하고, A공사는 강구조물공사업을 수행할 수 있는 건설업자의 자격을 가지고 있지 않았고, 갑문 보수공사를 직접 시공할 수 있을 정도의 인력이나 전문성을 갖추고 있지 못하였으며, 이 사건 공사에 있어 발주자인 A공사의 지배하에 있는 특수한 위험요소가 있어 B주식회사 등이 실질적으로 안전 및 보건조치를 이행하는 것이 현저히 곤란하였다고 볼 만한 사정도 없다는 이유로 A공사를 건설공사발주자로 판단하고, A공사 및 전 사장에 대해 무죄판결을 선고하였다.

III. 대법판결의 판시 내용

- 대법판결은 건설공사를 도급하는 사업주가 자신의 사업장에서 사망한 관계수급인 근로자와 관련하여 개정 산안법(이하 산안법) 제167조의 형사 책임을 부담하는 도급인에 해당하는지는 도급 사업주가 자신의 사업장에서 시행하는 건설공사 과정에서 발생할 수 있는 산업재해 예방과 관련된 유해·위험요소에 대하여 실질적인 지배·관리 권한을 가지고 있었는지를 중심으로, 도급 사업주가 해당 건설공사에 대하여 행사한 실질적 영향력의 정도, 도급 사업주의 해당 공사에 대한 전문성, 시공능력 등을 종합적으로 고려하여 규범적인 관점에서 판단하여야 한다는 법리를 제시하였다.

- 이어서 갑문의 유지 및 관리는 A공사의 주된 설립 목적 중 하나로, A공사가 갑문 보수공사의 설계, 시공, 감리 등 준공까지의 전 과정을 기획하고, 설계도면도 직접 작성하였으며, 수급업체의 보수공사 공정률을 매주 점검하면서 수급인의 공정상황을 고려하여 설계도면을 직접 변경하기도 하였던 사실, A공사가 철강구조물공사업 등록을 한 것으로 보이지는 않으나 그 산하에 갑문 운영·관리 및 갑문시설물 유지보수를 주 업무로 하는 전담부서를 두고 있었고, 위 부서의 직원들은 갑문의 일상점검, 중간점검, 분기별 점검, 반기별 점검을 수행한 사실, 대한민국과의 위탁계약상 갑문시설의 안전성 확보를 위한 유지보수가 위탁계약의 내용으로 포함되어 있고, A공사는 4개년 사업으로 매년 갑문시설의 정비·보수 계획을 수립·시행하여 왔던 사실, A공사는 자본금이 5조 원에 달하는 거대 공기업인 반면 B주식회사는 자본금 10억 원, 상시 근로자 수 약 10명에 불과한 소규모 기업인 사실, A공사의 위험성평가표에는 사고 이전부터 중량물 취급과 관련된 사고 위험이 지적되어 있었고 A공사의 현장감독인 D는 사고 발생 일주일 전쯤 이미 현장에 H빔 내리는 작업에 사용된 윈치프레임이 놓여 있는 것을 목격하기도 한 사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 갑문 유지 및 관리를 주된 사업 목적으로 하는 A공사는 핵심시설인 갑문의 유지·보수에 관한 전담부서를 두고 있으면서, A공사의 사업장에서 진행된 갑문 정기보수공사 과정에서 발생 가능한 산업재해의 예방과 관련된 유해·위험요소에 대하여 실질적인 지배·관리 권한을 가지고 있었고, 갑문 정기보수공사에 관한 높은 전문성을 지닌 도급 사업주로서 수급인에게 실질적인 영향력을 행사하였다고 보아야 하므로, A공사는 건설산업기본법에 따른 건설공사 시공자격 보유 여부와 관계없이 갑문 정기보수공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자로서 단순한 건설공사발주자를 넘어 산안법상 도급인에 해당한다고 판단한 후 원심 판결을 유죄 취지로 파기 환송하였다.

IV. 대법판결의 의의

- 개정 산안법은 건설공사발주자란 건설공사를 도급하는 자로서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니하는 자라고 규정하면서 관계수급인의 근로자에 대한 안전 및 보건조치 의무를 부담하는 도급인의 범위에서 건설공사발주자를 제외하였는데, 건설공사발주자와 도급인의 구별에 관한 확립된 기준이 존재하지 않아서 하급심 판결마다 다른 기준을 제시하는 등 적지 않은 혼란이 야기되어 왔다. 대법판결은 건설공사발주자와 도급인의 구별 기준을 제시한 최초의 대법원 판결이다.

- 대법판결은 ① 도급 사업주가 자신의 사업장에서 시행하는 건설공사의 유해·위험요소에 대하여 실질적인 지배·관리 권한을 가지고 있었는지, ② 도급 사업주가 해당 건설공사에 대하여 행사한 실질적 영향력의 정도, ③ 도급 사업주의 해당 공사에 대한 전문성, 시공능력을 종합적으로 고려하여 규범적으로 판단한다는 법리를 제시하면서, 세 가지 요건 중 ① 요건 즉 유해·위험요소에 대한 실질적 지배·관리 권한이 중심이 되는 요건이라고 적시하였다.

- 대법판결이 주요 요건으로 제시한 실질적 지배·관리는 산안법 제10조 제2항의 도급인의 사업장 인정 요건인 지배·관리, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조의 안전 및 보건 확보의무의 요건인 실질적 지배·운영·관리에서 용례를 찾을 수 있는데, 대법판결은 실질적 지배·관리를 시공을 주도하여 총괄·관리하는 것을 사실상 동일하게 여기는 것으로 보인다.

- 건설공사발주자인지 도급인인지 여부는 범죄의 객관적 구성요건 요소 중 행위의 주체에 관한 것으로서, 죄형법정주의에서 파생되는 명확성의 원칙상 산안법 제167조 제1항에 따라 그 위반을 처벌하는 같은 법 제63조의 수범자인 도급인이 누구인지를 예견할 수 있어야 한다. 그런데 대법판결은 유해·위험요소에 대한 실질적 지배·관리 권한, 실질적 영향력이라는 추상적인 구별 기준을 제시하고 있을 뿐, 실질적 지배·관리 권한, 실질적 영향력이 인정되기 위한 구체적

인 요건을 제시하고 있지 않아서, 대상판결을 통해 건설공사발주자와 도급인의 구별에 관한 혼란이 해소될 수 있을지 의문이다. 결국 건설공사발주자와 도급인의 구별 기준에 관한 판결례가 상당 수준 집적되어야 건설공사발주자/도급인 해당 여부에 대한 예측 가능성이 높아질 것으로 예상된다.

<안전 의무 위반으로 인한 근로자 사망 사고에서의 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반 판단> 대법원 2025.09.26. 선고 2025도10267 판결

【판결 요지】

- 원심 판결 이유를 관련 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반(산업재해치사)죄의 안전확보의무 위반, 산업안전보건법위반죄의 안전조치의무 위반, 업무상과실치사죄의 주의의무 위반, 인과관계 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

I. 개 요

1. 중대산업재해 개요

- H회사[도급인]는 C회사[수급인]에 선박수리 공사 일부를 도급을 주어 C회사 소속 근로자에게 H회사 내에 있는 K선박에서 핸드레일(안전난간) 교체 등의 작업을 수행하게 하였다. 2022.2.19. C소속 근로자 M(이하 '재해자'라 한다)이 핸드레일 교체가 필요한 구간을 확인하던 중 화물창 갑판 하(下) 2층 핸드레일 소실 구간으로 추락하여 사망하는 이 사건 재해가 발생하였다.

2. 피고들의 주장 및 쟁점

- 피고들은 1심과 원심에서 재해 발생 장소는 추락방호망 설치가 불가능하여 안전대 결착이 최선의 안전조치였단바, 안전조치의무 위반이 없다고 주장하였다. 또한 피고들은 이 사건 사고는 재해자가 안전대를 착용했음에도 스스로 결착하지 않았고, 사고 당시 갑판 상부에서 진행된 중량물 낙하의 위험이 있는 해치커버 이동 작업으로 인해 작업이 중단되었음에도 재해자가 돌발적으로 작업을 준비하다가 발생한 것이라고 주장하였다. 이에 피고들의 산업안전보건법 및 중대재해처벌법상의 제반 의무 위반과 이 사건 재해 발생 사이 인과관계가 문제 되었다. 이하에서는 이와 관련하여 판결의 주요내용과 그 시사점을 검토한다.

II. 산업안전보건법 위반 판단

1. 관련 법 규정

- 산업안전보건법 제38조제3항제1호는 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위한 조치를 취하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 그 구체적 예방조치로서 산업안전보건 기준에 관한 규칙(이하 '안전보건규칙'이라 한다) 제43조제1항은 작업발판이나 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락 방망 등의 방호 조치를 하여야 한다고 규정하고 있다. 동 규칙 동 조 제2항은 난간 등을 설치하는 것이 매우 곤란하거나 작업의 필요상 임시로 난간 등을 해체하여야 하는 경우에는 추락방호망을 설치하여야 하며, 다만 추락 방호망을 설치하는 것이 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락의 위험을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있다.

2. 판결의 내용

(1) 안전조치 의무 위반과 재해 발생의 인과관계

- 피고들은 추락방호망 설치가 불가능했고 안전대 결착이 최선의 안전조치였기에 안전조치의무 위반이 없다고 주장하였으나, 원심은 설사 일정한 안전조치가 이루어졌다 하더라도 그것이 예견 가능한 산업재해를 예방할 수 있을 정도의 실질적인 안전조치인가를 기준으로 안전조치 의무 위반을 판단하여야 함을 전제하고 피고들의 산업안전보건법 위반을 판단하였다.

- 그 전제하에 구체적으로 설사 이 사건 재해가 핸드레일 보수를 위한 사전점검 중에 발생하였다 하더라도 (i)핸드레일 소실구간에 그 보수작업 전까지 사용할 가설안전난간을 용이하게 설치할 수 있었던 점, (ii)화물창의 구조, 규격 등을 고려할 때 기술상 수직형 방망 등 추락방호망 설치가 가능하였고, 핸드레일 보수를 위한 용접 시 발생하는 불꽃으로 인한 화재의 위험 또한 화재방지포를 추락방호망 위에 덮는 방식으로 용이하게 해결이 가능하였던 점, (iii)이처럼 기술적으로 가능함에도 피고인들이 수지탄산이 맞지 않는다는 판단하여 추락방호망 설치를 아예 처음부터 고려조차 하지 않은 점 등을 볼 때 피고들에게 안전조치의무 위반이 있고, 그 안전조치의무 위반과 이 사건 재해 발생 사이의 인과관계가 있다고 판단하였다. 대법원 또한 이러한 원심의 판단에 법리를 오해한 잘못이 없다고 판단하였다.

(2) 재해자의 부주의한 작업행동에 기인한 산업재해라는 피고들의 주장에 대한 판단

- 재해자가 안전대를 착용하였으나 이를 결착하지 않아 발생한 재해라는 피고들의 주장에 대하여, 1심과 원심 모두 (i)사고 발생 통로에 설치된 핸드레일이 그 구조상 중간 중간이 막혀 있어 통로 이동 중에는 안전대를 결착하고, 푸는 행위를 반복해야 하는 번거로움이 있어 평소 근로자 대부분이 이동 시 안전대 고리를 결착하지 않은 점, (ii)그와 같은 사실을 안전보건관리책임자 등의 관리자들이 알고 있었음에도 이를 묵인·용인해 온 점, (iii)그와 같은 구조를 고려하여 근로자들이 작업 중뿐만 아니라 이동 중에도 상시 안전대를 결착할 수 있도록 라이프라인 등의 설비를 갖춘 수 있었음에도 그러한 조치를 하지 않은 점 등을 근거로 이유가 없다고 판단하였다.

- 또한 이 사건 재해는 해치커버 이동 작업으로 작업이 중단된 상태에서 재해자가 작업 준비를 행한 돌발행동에 기인한 것이라는 피고들의 주장에 대해, 1심과 원심 모두 (i)H의 안전보건관리책임자 등이 사고 발생 당일 해치커버 이동작업이 진행될 것이라는 점을 알고 있었음에도 동시에 핸드레일 보수 작업을 승인하였던 점, (ii)시간 절약을 위해 틈틈이 핸드레일 보수 작업을 진행할 것을 명시적·묵시적으로 요구해온 점, (iii)부득이 동시 작업이 이루어질 경우, 도급인 H, 해치커버 이동 작업을 수행한 협력업체, 핸드레일 보수 작업을 수행한 C 소속 관리자들이 두 작업의 구체적 진행 일정, 상호 간 작업제개·중단, 신호·연락 체계를 조율하여 소속 근로자들에게 알려야 했음에도 그렇게 하지 않은 점 등을 근거로 피고들의 주장을 받아들이지 않았다.

III. 중대재해처벌 등에 관한 법률 위반

- 1심과 원심 모두 H회사[도급인]의 대표이사가 중대재해처벌법 제4조제1항제1호, 동법 시행령 제4조제5호, 제7호, 제9호가 규정하고 있는 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 하지 않음으로써 이 사건 재해에 이르게 되었다고 판단하였다. 구체적으로 H의 대표이사가 (i)안전보건관리책임자 등에 대한 업무를 평가하는 기준과 절차를 마련하지 않음으로써 안전보건관리책임자 등이 사건 산업재해를 방지하기 위한 현장 관리·감독 및 안전조치 업무를 제대로 이행하지 않았고(시행령 제4조제5호 관련), (ii)수급인을 포함한 전체 종사자의 의견을 듣는 절차를 마련하지 않음으로써, 종사자의 의견을 들어 추락방호망 및 라이프라인 설치 등의 조치를 취하지 않아(시행령 제4조제7호 관련) 이 사건 재해에 이르게 되었다고 판단하였다.

- 또한 (iii)H의 대표이사가 제3자에게 업무를 도급할 때 그 종사자의 안전·보건을 확보하기 위한 수급인의 안전·보건관리비용에 대한 기준을 마련하였더라도, 추락방호망이나 라이프라인 등 추락방호장치를 설치할 수 있는 관리비용을 고려하지 않고 견적을 제출한 C회사에 공사를 하도급하지 않거나, 최소한 관리비용에 대한 기준에 맞는 관리비용을 계상하지 않은 상태에서는 하도급을 하지 않았을 것이라는 점을 들어(동법 시행령 제4조제9호 관련), H의 대표이사의 중대재해처벌법상의 제반 의무의 불이행과 이 사건 사고 사이에 상당 인과관계가 있다고 판단하였다.

IV. 시사점

1. 안전조치 의무 위반 판단의 기준으로서 실질적인 안전조치의 이행과 그 중요성

- 원심은 안전보건규칙과 관련한 일정한 조치가 있었다 하더라도 해당 산업 현장의 구체적 실태에 비추어 예상 가능한 산업재해를 예방할 수 있을 정도의 실질적인 안전조치에 이르지 못할 경우, 안전보건규칙을 준수하였다고 볼 수 없다.는 판결(대법원 2022.5.31. 선고 2020도3996 판결)을 인용하면서 안전대 결착이 가능했던바, 안전조치 의무 위반이 없다는 피고들의 주장은 이유가 없다고 판시하였다.

- 이는 산업안전보건법 제38조 및 제39조가 사업주의 의무로서 정하고 있는 안전·보건조치는 최소한의 안전·보건조치의 이행을 의미하는 것이 아니라 실제 산업재해를 예방할 수 있을 정도의 실질적인 안전·보건조치임을 재확인하는 것이다. 이는 산업안전보건법이 산업재해 예방, 쾌적한 근무 환경의 조성, 안전 및 보건의 유지·증진에 있다는 점에서 당연한 해석이다.

- 그럼에도 불구하고 여전히 산업 현장에서는 이 사건 사업장과 같이 수지타산이 맞지 않는다는 등의 이유로 실질적인 안전조치를 고려조차 하지 않은 채 최소한의 안전조치만을 이행함으로써 산업재해가 빈번하게 발생하고 있다. 법원이 산업안전보건법 위반을 판단할 때뿐만 아니라 각 사업장에서부터 어떤 안전·보건 조치가 실질적으로 산업재해를 예방할 수 있는가를 기준으로 안전·보건 조치를 이행한다면 많은 산업재해를 예방할 수 있을 것이다.

2. 산업재해 발생 원인의 일부가 근로자의 부주의한 작업행동일지라도 그 이면의 구체적 사실의 판단 필요

- 이 사건 재해는 근로자가 안전대를 걸착하지 않은 점, 작업중지 중 근로자가 작업을 개시하였다는 점에서 일면 근로자의 부주의한 작업행동에 기인한 것으로 볼 수 있다. 그러나 이 사건 판결은 단순히 그러한 사실뿐만 아니라, 그 사실의 이면에 있는 왜 근로자가 그러한 부주의한 작업행동을 할 수밖에 없었는가를 사실까지 구체적으로 살펴 판단하였다.

- 이러한 법원의 판단은 많은 산업재해가 근로자의 부주의한 작업행동과 사업주 등의 안전조치 의무 미이행이 결합하여 발생한다는 사실의 반영일 것이다. 또한 근로자의 부주의한 작업행동 그 자체가 이 사건과 같이 작업 기간의 단축, 높은 생산성 요구와 같은 구조적 원인, 그리고 안전조치를 취했을 때 더 큰 불편을 초래하여 실질적인 안전조치가 되지 못하는 상황 등에 기인한다는 사실의 반영이기도 할 것이다.

- 이 사건 판결은 설사 재해 발생 원인의 일부가 근로자의 부주의한 작업행동일지라도 (i)평상시 작업자들의 작업행동 및 방식, (ii)부주의한 작업행동의 원인, (iii)부주의한 작업행동에 대한 관리자 등의 인지 여부, (iv)개선 조치의 이행 여부 등을 면밀하게 살펴 사업주 등의 산업안전보건법 위반을 판단할 필요가 있음을 시사한다.

- 나아가 이 사건 판결은 실제 산업 현장에서 사업주 등이 안전조치를 함에 있어서도 근로자의 부주의한 작업행동의 원인을 살펴 이를 개선함으로써 실질적으로 산업재해를 예방할 수 있는 안전조치를 하여야 함을 시사한다. 또한 산업재해 예방에 있어 그러한 실질적인 안전조치의 중요성을 시사한다.

<육아휴직급여 사후지급금 제도(고보법 시행령) 위헌 여부> 헌법재판소 2025.04.10. 선고 2021헌마1362 결정

【판결 요지】

- 육아휴직 급여수급권은 재산권의 성격을 일부 지니고 있으나, 사회보험원리에 입각한 사회보장적 급여로서의 성격 역시 가지고 있으므로, 입법자가 그 구체적인 내용을 형성함에 있어서는 일반적인 재산권보다 상대적으로 폭넓은 재량이 허용된다. 그러므로 사후지급금 조항은 그 내용이 현저히 불합리하여 입법형성권의 범위를 벗어난 경우에 한하여 헌법에 위반된다고 할 수 있다.

- 육아휴직제도의 도입 취지 및 원 직장과의 근로관계 유지 필요성, 현재까지도 육아휴직 종료 후 원 직장에 복직하지 아니하는 자들이 상당 부분 존재하는 점 등을 고려하면, 사후지급금 제도가 필요하다고 본 입법자의 판단이 현저히 불합리하다고 평가하기 어렵다.

I. 사후지급금의 배경

- 육아휴직 급여는 2001.8.14. 개정된 고용보험법에서 고용보험 기금을 재원으로 도입되었다. 그런데, 육아휴직 종료 후 직장에 복귀하지 않는 경우가 많아지자 육아휴직 급여수급권자의 원 직장 복귀 및 계속 근로를 유도하여 이들의 고용유지율을 개선하기 위한 조치가 도입되었다. 즉, 2010.12.31. 개정된 고용보험법 시행령에서는 육아휴직 급여의 85%에 해당하는 금액을 육아휴직 중에 월별로 지급하고 15%에 해당하는 금액은 육아휴직 종료 후 해당 사업장에 복직하여 6개월 이상 근무한 경우에 한하여 일시불(이하 사후지급금이라고 한다)로 지급하도록 하였다. 이와 같이 사후지급금은 육아휴직 종료 후 원 직장에 복귀하여 6개월 이상 계속 근무한 경우에 사후지급금을 지급함으로써 육아휴직 급여수급권자의 원 직장 복귀 및 계속 근로를 유도하여 이들의 고용유지율을 개선하고자 하는 데 그 목적이 있다. 사후지급금 도입 이후에도 육아휴직 사용 직후 근로자의 노동시장 이탈은 빈번하게 관찰되었다. 이에 정부는 2015. 6. 30. **고용보험법 시행령**을 개정하여 사후지급금의 지급 비율을 25%로 인상하여 육아휴직 사용 직후 근로자의 원 직장에 복귀하는 유인을 강화하였다.

- 그런데 사후지급금에 대해서는 도입 당시부터 다음과 같은 비판이 있었다. 첫째, 사후지급금 제도가 육아휴직 급여의 낮은 소득대체율을 더욱 저하시켜 육아휴직 기간 중 발생하는 생계 불안을 악화시키고, 오히려 육아휴직 사용을 위축시킬 가능성이 있다는 것이다. 둘째, 사후지급금 제도가 육아휴직 급여수급권자의 고용유지율을 개선하는 데 실효성이 있는지 확인하기 어렵고, 사후지급금 수령을 이유로 복귀한 육아휴직 급여 수급권자가 사후지급금 수령 이후까지 근로관계를 유지할지 여부 역시 보장하기 어렵다는 것이다. 이러한 비판이 지속되자 정부는 2024.12.24. 고용보험법 시행령을 개정하여 사후지급금 조항을 삭제하였다. 이에 따라 2025.1.1.부터는 2025.1.1. 전에 육아휴직을 시작한 육아휴직 급여수급권자라 하더라도 육아휴직 급여액의 100분의 100을 매월 지급받을 수 있게 되었다.

II. 헌법재판소의 판단

- 이 사건 헌법소원은 2024.12.24. 고용보험법 시행령 개정으로 사후지급금 조항이 삭제되기 전에 이루어진 것으로서 청구인은 육아휴직을 종료함과 동시에 원 직장을 퇴사하고 다음 날 다른 직장에 취직하였기에 **고용보험법 제95조 제4항**에 따라 사후지급금을 지급받지 못하였다. 청구인은 사후지급금 조항이 청구인의 재산권과 인간다운 생활을 할 권리를 침해한다고 주장하였다. 이에 대해서 헌법재판소 재판관 8인 중 4인은 기각 의견을, 4인은 인용 의견을 냈기에 위헌으로 판단되기 위한 인용 의견 6인에 미치지 못하여 청구인의 헌법소원은 기각되었다.

- 기각 의견과 인용 의견은 동일한 심사기준을 사용하여 재산권과 인간다운 생활을 할 권리 침해 여부를 함께 판단하고 있다는 점에서는 차이가 없다. 인용 의견 4인의 심사기준을 보면, 입법목적 달성을 위하여 가능한 여러 수단들 가운데 구체적으로 어느 것을 선택할 것인가의 문제는 기본적으로 입법재량에 속하고, 입법목적 달성을 위한 수단으로 반드시 가장 합리적이고 효율적인 수단을 선택하여야 하는 것은 아니지만, 그렇다고 하더라도 현저하게 불합리하고 불공정한 수단을 선택하는 것은 허용될 수 없다고 하고 있다. 입법자가 선택한 수단, 즉 사후지급금이 입법목적 달성을 데 현저하게 불합리하고 불공정한 수단인지를 판단하겠다는 것이다. 이는 입법자의 입법재량이 현저히 불합리하여 입법형성권의 범위를 벗어났는지를 판단하겠다는 기각 의견도 동일한 것이다. 또한, 기각 의견과 인용 의견은 재산권과 인간다운 생활을 할 권리 침해 여부를 각각 판단하지 않고 위 심사기준을 적용하여 함께 침해 여부를 판단하고 있다.

- 이와 같은 기준을 적용하여 기각 의견은 다음과 같은 두 가지 논거를 들어서 재산권 및 인간다운 생활을 할 권리의 침해를 부정하고 있다. 첫째, 사후지급금이 육아휴직 급여의 소득대체율을 더욱 저하시킨다는 문제 제기에는 이러한 문제는 육아휴직 급여 자체의 낮은 소득대체율에서 기인한 것이지, 육아휴직 급여수급권자의 근로를 유지하고 사업주의 신뢰를 보호하고자 하는 사후지급금 제도의 문제에서 비롯되었다고 평가할 수 없다. 둘째, 사후지급금 제도가 고용유지율 개선에 효과가 없다는 문제 제기에는 사후지급금 제도가 육아휴직 급여수급권자의 고용유지율 개선에 명백히 효과적이지 아니할 것이라고 단정하기 어렵고, 육아휴직 급여수급권자가 원 직장에 복귀하여 일정 기간 이상 근로관계를 유지하면서 사직 등의 의사를 단념할 가능성 역시 배제하기 어렵다는 점을 고려할 때, 사후지급금 지급을 통하여 육아휴직제도가 본래 입법취지에 부합하게 운용될 수 있도록 정한 입법자의 정책적 판단을 존중할 필요성이 있다.

- 이에 대해서 인용 의견은 사후지급금 제도로 말미암아 고용유지율이 개선되었다는 실증적인 자료가 없고, 오히려 사후지급금 제도가 도입된 이후에도 육아휴직 종료 후 원 직장에 복귀하지 않는 사람들이 상당 부분 존재한다는 것은 사후지급금 제도가 고용유지에 효과가 없음을 방증한다고 하여 사후지급금 제도는 근로자가 육아휴직 종료 후 원 직장에 복귀하는 데에 실질적인 영향력을 미친다고 보기 어렵다고 한다. 그렇다면 결국 사후지급금 제도의 실질적인 목적은 근로자가 육아휴직제도를 이직 등 다른 목적으로 악용하는 것을 방지하기 위한 것이라고 볼 수 있는데, 이를 위해 사후지급금 제도를 활용하는 것은 육아휴직 급여제도를 그 내용으로 하는 육아휴직제도의 목적에 반한다고 한다. 육아휴직 급여제도는 육아휴직 중인 근로자에게 생계비를 지원하여 경제적인 생활 안정을 보장하는 것을 목적으로 하는데, 사후지급금 제도는 육아휴직 급여의 소득대체율이 충분하지 못한 상황에서 육아휴직 중의 소득대체율을 더욱 떨어뜨려 육아휴직의 사용을 주저하게 만드는 주된 요인될 수 있다는 점을 들고 있다. 특히 이와 같은 문제는 상대적으로 저임금근로자에게 더 심각하게 발생할 수 있다. 이와 같이 사후지급금 제도는 그 내용이 현저히 불합리하여 입법형성권의 한계를 일탈한 것으로 보아야 한다는 것이다.

- 기각 의견과 인용 의견의 가장 큰 차이는 사후지급금 제도의 고용유지율 개선 효과에 관한 판단이라고 할 것이다. 기각 의견은 사후지급금 제도가 육아휴직 급여수급권자의 고용유지율 개선에 명백히 효과적이지 아니할 것이라고 단정하기 어렵다면, 이에 관해서는 육아휴직제도가 본래의 목적대로 운영될 수 있도록 사후지급금 제도를 도입한 것에 관한 입법자의 정책적 판단을 존중할 필요성이 있다고 한다. 이에 반하여 인용 의견은 사후지급금 제도는 고용유지율을 개선하는 데 실질적인 영향을 미치지 않고, 그렇다면 사후지급금 제도는 육아휴직제도의 목적에 반한다는 논리를 전개하고 있다. 그런데, 기각 의견과 인용 의견 모두 재산권과 인간다운 생활을 할 권리의 침해 여부 판단을 위한 심사에서 입법자의 입법재량을 매우 넓게 인정한다는 데 일치하고 있다는 점에서, 인용 의견의 논리가 과연 입법자의 입법재량을 매우 넓게 인정하는 태도와 일치하고 있는지 다소 의문이다. 인용 의견은 사후지급금 제도가 육아휴직 급여수급권자의 고용유지율 개선에 명백히 효과적이지 않다는 점에 관해서 직접적인 논거를 제시하지 못하고, 이를 방증하는 논거만을 제시하고 있다. 입법자의 입법재량을 폭넓게 인정한다면, 목적과 수단의 관계에서 효과적인 수단이 아니라는 점은 방증만으로 증명될 수 없기 때문이다. 즉, 수단의 효과성에 관해서 효과가 없다고 단정할 수 없다면 기각 의견처럼 입법자의 판단을 존중할 수밖에 없을 것이다. 인용 의견은 심사의 강도를 대폭 완화하는 기준을 취하고 있으면서도 실제로는 심사의 강도를 강화하고 있다고 비판될 수 있을 것이다.

<직접 고용된 파견근로자의 퇴직금 기산일에 관한 합의의 법적 성격과 효력> 서울고등법원(춘천재판부) 2024.12.12. 선고 2024나1090 판결

【판결 요지】

- 이 사건 퇴직금 합의는 원고들의 피고에 대한 퇴직금의 새로운 기산일을 정하고, 그 전까지 발생한 퇴직금을 피고가 원고들에게 미리 정산하여 지급하기로 하는 내용이라 할 것이므로, 이는 근로자퇴직급여 보장법 제8조 제2항에서 정한 퇴직금 중간정산에 대한 합의라고 봄이 상당하다. 이 사건 퇴직금 합의가 근로자퇴직급여 보장법 시행령 제3조 제1항 6호에 정하고 있는 사용자가 기존의 정년을 연장하거나 보장하는 조건으로 단체협약 및 취업규칙 등을 통하여 일정한 나이, 근속시점 또는 임금액을 기준으로 임금을 줄이는 제도를 시행하는 경우에 따른 퇴직금 중간정산 합의에 해당한다고 인정하기 부족하고, 나아가 근로자퇴직급여 보장법 시행령 제3조 제1항 나머지 각 호에 해당한다고 인정하기도 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 퇴직금 합의는 그 요건을 갖추지 않은 퇴직금 중간정산 합의이므로, 무효라 할 것이고 결국 피고가 원고들에게 이 사건 퇴직금 합의에 따라 지급한 퇴직금도 유효한 중간정산 퇴직금이라고 할 수 없다.

I. 사건의 개요

- 원고들은 타 업체 소속으로 피고의 사업장에서 근무하다가 피고와의 합의(이하 이 사건 합의)에 따라 피고에 직접고용된 후 2020. 12. 31. 내지 2021. 12. 31. 퇴직하였다. 이 사건 합의는 원고들 등이 피고를 상대로 제기한 근로자지위확인 및 임금 청구 소송(이하 이 사건 소송)이 항소심 계속 중이던 2017. 9.18. 이루어졌는데, 그 주요 내용은 다음과 같다. ① 피고는 이 사건 판결에 의거하여 고용간주임 및 고용의무임(이하 직접고용임)을 인정한다. ② 피고는 직접고용임로부터 직급, 호봉, 근속연수를 비롯한 직접고용임으로부터의 근속에 따른 권리를 모두 인정한다. ③ 원고들 등은 피고에 복직하고, 이 복직에도 불구하고 위에서 인정된 직급, 호봉, 근속기간에는 영향을 미치지 않으며 직접고용임을 최초 입사일로 본다. ④ 피고는 이 사건 판결의 취지에 따라 임금 및 퇴직금 등과 소송비용 지원금을 산정하고, 퇴직금 차액 지급에도 불구하고 직접고용임을 기준으로 직급, 호봉, 근속연수는 그대로 승계된다. ⑤ 피고는 단체협약에 따라 원고들 등의 고용기간은 만 60세가 되는 해의 12. 31.을 정년으로 하고, 만 57세부터 임금피크(기본급 70%)를 적용한다. 이에 따라 원고들 등은 2015.2.28.까지의 퇴직금을 지급받았다.

II. 쟁점

- 원고들은 이 사건 합의가 퇴직금청구권의 사전포기로서 강행규정인 근로자퇴직급여 보장법 제8조 제2항에 위반되어 무효라고 주장하면서, 피고를 상대로 이 사건 합의가 없었더라면 원고들의 고용간주임로부터 근속기간을 산정하여 받았을 퇴직금에서 이 사건 합의의 중간정산금 및 기지급 퇴직금을 공제한 차액의 지급을 구하였다. 이에 피고는 이 사건 소가 부제소합의인 이 사건 합의에 위반하여 부적법하다고 다투는 한편, 이 사건 합의에 따른 원고들에 대한 피고의 금원 지급은 원고들의 퇴사 및 피고로의 재입사를 전제로 한 것으로서 퇴직금 중간정산에 해당하지 않고, 설령 해당한다고 하더라도 근로자퇴직급여 보장법 시행령 제3조 제1항 6호에 정하고 있는 임금피크제도의 도입에 따른 퇴직금 중간정산 합의로서 유효하다고 항변하였다. 또한 피고는 원고들의 청구가 신의칙 또는 금반언의 원칙에 반한다고 주장하였다.

III. 제1심의 판단(원고들 패소)

- 제1심 법원은 이 사건 합의 체결 경위나 이익 귀속, 제반 사정에 비추어 실질적으로 근로자에게 불리하다고 볼 수 없어 강행규정에 저촉되지 않아 유효하다고 판단하고, 원고들의 의사와 이익을 반영하여 이 사건 합의에서 정한 내용과 다르게 기산일을 정하여 퇴직금을 구하는 원고들의 주장을 받아들일 수 없다고 하였다.

- 제1심 판결의 주요 논거는 다음과 같다. ① 이 사건 합의는 구체적으로 정산일을 특정하여 퇴직금 정산을 적극적으로 요구한 당사자가 원고들 등 근로자와 그들이 속한 노동조합이고 피고는 이를 수용한 것에 불과하다. ② 원고들 등은 소속업체로부터 이미 퇴직금을 수령한 경우 이 사건 판결의 취지에 따라 피고에 직접 고용된다면 기수령 퇴직금을 피고에 반환하여야 하는 상황에 있었기 때문에 묵묵으로 반환에 부담이 되는 기수령 퇴직금을 보유하되 새롭게 퇴직금 정산시기를 정하는 것이 이익이라고 판단하고 퇴직금 정산을 먼저 제의한 것으로 보인다. 이는 근로자퇴직급여 보장법 시행령 제3조 제1항에서 퇴직금의 중간정산 사유로 열거한 사유들과도 관련이 있는 긴급한 자금 수요에 부합하는 측면이 있다. ③ 이러한 제의는 원고들의 노동조합 관계자 및 이 사건 판결을 이끌어낸 원고들 소송대리인의 법률적인 검토를 통하여 선제적·자발적으로 이루어졌다. ④ 이 사건 합의의 나머지 내용도 이 사건 판결에서 피고에 대한 근로자지위를 확인받고 일부승소한 원고들에게 전반적으로 유리하게 이루어졌다. ⑤ 당시 언론과 노동계 역시 이 사건 합의를 직급, 호봉, 근속연수를 비롯한 직접고용임으로부터의 근속에 따른 권리를 사측에서 처음으로 모두 인정한 긍정적인 사례로 받아들였고, 적어도 근로자에게 불리하거나 위법한 퇴직금 중간정산이라는 지적이나 문제 제기는 없었던 것으로 보인다(이 사건 합의에 직접 관여한 노동조합 관계자들에 대한 언론 인터뷰도 마찬가지이다). ⑥ 이 사건 합의는 강행규정이 근로자의 보호를 위하여 금지하고자 하는 행위, 즉 사용자가 근로자와의 합의라는 외관하에 근로자에게 불리하게 퇴직금 총액을 감액하는 수단으로 중간정산을 이용한 것으로는 보이지 않는다.

IV. 항소심의 판단(원고들 승소)

- 항소심 법원은 이 사건 합의의 법적 성격에 관하여, 이 사건 퇴직금 합의는 원고들의 피고에 대한 퇴직금의 새로운 기산일을 2015.3.1.로 정하고, 그 전까지 발생한 퇴직금을 피고가 원고들에게 미리 정산하여 지급하기로 하는 내용이라 할 것이므로, 이는 근로자퇴직급여 보장법 제8조 제2항에서 정한 퇴직금 중간정산에 대한 합의라고 인정한 다음, 이 사건 합의는 근로자퇴직급여 보장법 시행령 제3조 제1항 각 호의 퇴직금 중간정산 합의에 해당하지 않아 그 요건을 갖추지 않은 퇴직금 중간정산 합의이므로 무효라고 판단하였다.

- 항소심 법원이 이 사건 합의가 퇴직금 중간정산 합의로서 무효라고 판단한 주요 논거는 다음과 같다. ① 이 사건 판결에 관한 항소심 계속 중 피고가 원고들에게 이 사건 판결 기준 복직 전일까지의 기준으로 보상금 안을 제시하였다. 그 후 원고들 측과 피고 측 사이에 2017. 8. 30. 실무협의 회의 결과에 따르면, 이 사건 합의에 포함된 이 사건 퇴직금 합의는 임금피크제와는 관계없이 피고가 원고들에 대한 복직 조치를 하면서 직접고용임을 둘러싸고 언제부터 그 직접고용일을 정할 것인지, 이에 따라 퇴직금을 중간정산할 것인지 여부에 관하여 논의가 이루어졌던 것으로 보인다. ② 실무 협의가 재차 이루어졌는데, 원고들이 속한 노동조합은 보상금으로 이 사건 판결 금액을 수용, 2015.2.28. 기준으로 퇴직금을 정산하여 줄 것, 이와 별도로 임금피크제 적용을 받을 근로자들에 대하여는 만 57세부터 기본급 70%를 적용하는 것을 피고에게 제시하였고, 피고는 수용 의사를 표시하였다. ③ 그 후 원고들과 피고가 각각 수정합의서를 제시하였는데 각각의 합의서에는 퇴직금 중간정산금(또는 퇴직금 차액)을 주고받을 것을 전제로 직접고용임 기준 직급, 호봉, 근속연수를 그대로 승계한다는 기재만 있을 뿐, 피고가 작성한 수정합의서에도 원고들에 대한 임금피크제가 적용됨을 전제로 퇴직금 중간정산을 한다는 기재는 없다. ④ 최종 실무 협의에서도 원고들이 임금피크제가 적용될 근로자임을 전제로 이 사건 퇴직금 합의가 이루어진 것은 아닌 것으로 보인다. ⑤ 원고들은 이 사건 합의에 기재된 퇴직금 기산일인 2015.3.1. 당시 피고가 주장하는 임금피크제 적용 연령인 만 57세에 해당한다고 보기도 어렵다(원고들은 당시 만 54세 또는 55세이다).

- 항소심은 원고들의 청구가 신의칙 및 금반언 원칙에 반하는 것도 아니라고 판단하였다. 이 사건 합의는 근로자퇴직급여 보장법이 정한 중간정산 제도의 취지에 반하여 이루어진 것으로, 이 사건 합의의 효력을 인정하지 아니하게 됨으로써 피고는 원고들에게 그 퇴직금 미달액 등의 지급 의무를 부담하는 반면 원고들은 이 사건 퇴직금 합의 당시에는 예상치 않았던 이익을 얻는 불가피한 결과가 발생하기는 하지만 원고들은 정당한 임금으로서의 퇴직금을 수령하게 되는 것일 뿐 이를 두고 원고들이 부당한 이익을 누리는 것이라고 볼 수 없는 점, 이 사건 퇴직금 합의가 원고들과 피고 사이의 자발적인 의사에 따른 것이더라도 이는

강행법규인 근로자퇴직급여 보장법 제8조의 취지를 회피하기 위한 행위일 뿐인 점, 원고들이 지급을 구하는 퇴직금의 금액이 불합리하거나 현저하게 과다하다고 보이지 않고, 원고들의 청구로 인하여 피고에게 중대한 경영상의 어려움이 초래되거나 기업의 존립이 위태롭게 된다고 보기 어려운 점 등을 이유로 들었다.

V. 검토

- 제1심과 항소심은 부제소합의를 이유로 한 피고의 본안 전 항변을 모두 배척하고 실체 판단을 하였다. 다만, 이 사건 합의의 효력 여하에 관한 제1심과 항소심의 결론은 상반되었다. 제1심 법원은 이 사건 합의의 법적 성격에 관하여 명시적인 판단을 하지 않은 채, 이 사건 합의의 체결 경위 특히 원고들이 속한 노동조합 측이 먼저 제의하여 이 사건 합의에 이르게 된 사정을 고려하여 합의의 유효성을 인정하였다. 반면에 항소심 법원은 이 사건 합의가 근로자퇴직급여 보장법상 제한적으로 허용되는 퇴직금 중간정산 합의에 해당함을 명확히 하고, 이를 전제로 퇴직금 중간정산의 법령상 요건을 충족하고 있는지 판단하는 단계로 나아가 이 사건 합의가 해당 요건을 갖추지 못하여 무효라고 판단하였다. 퇴직금 중간정산 합의의 효력에 관하여 제1심은 완화된 기준을, 항소심은 엄격한 기준을 적용한 모양새다.

- 퇴직금 중간정산은 중간정산이 없었더라면 최종 퇴직 시 받을 수 있는 퇴직금보다 통상 적은 퇴직금을 받게 되므로 퇴직금의 일부 사전 포기과 실질이 유사하다. 퇴직금 사전 포기의 예외적 허용이라고 평가할 수 있다. 퇴직금 중간정산은 판례에 의하여 그 유효성이 인정되어 오다가, 1996.12.31. 근로기준법 개정으로 법제화된 것으로, 근로자가 퇴직하기 이전이라도 필요한 시기에 자금을 융통할 수 있도록 하고, 사용자는 누적되는 퇴직금의 부담에서 벗어날 수 있게 하여 퇴직금 제도가 탄력적으로 운영되게 하려는 데 그 취지가 있다. 제도 도입 이래 근로자의 요구가 있는 경우를 줄곧 유효한 중간정산의 요건으로 규정하고 있었으나, 중간정산의 남용으로 인해 근로자의 퇴직 후 생활보장적 기능이 약화된다는 비판에 따라 2012.7.26. 시행된 개정 퇴직급여법에서부터는 중간정산 사유를 제한하게 되었다. 개정법에 따른 퇴직금 중간정산 사유는 주택 구입, 주택임대차 보증금 부담, 근로자와 배우자 등 생계를 같이하는 부양가족의 요양, 근로자의 파산 및 개인회생, 임금피크제 실시로 인한 임금 감소 등으로 열거되어 있다.

- 퇴직금 중간정산제도의 취지와 달리 소송으로 이어지는 분쟁은 대부분 집단적으로 이루어지는 퇴직금 중간정산으로, 대부분 사용자의 특정 행위가 매개가 되어 사용자의 주도로 중간정산이 모든 근로자에게 일괄적으로 시행되고, 결국 그 당부에 다툼이 생기는 경우가 많다. 하지만 이 사건과 같이 근로자 측의 요구로 중간정산이 이루어지는 경우도 있고, 어느 경우에도 개별 근로자의 자유로운 의사에 따른 중간정산 합의 및 법령이 정한 중간정산 사유가 존재하여야 한다. 직접고용이 간주되거나 직접고용 의무 발생 후 계속 근로한 파견근로자의 경우에도 이는 마찬가지이다. 이들에 대한 퇴직금 중간정산을 널리 허용하면 사용자업주가 직접고용 파견근로자에 대한 퇴직금 지급의 경제적 부담을 개별 합의 또는 노사 합의를 통해 회피하려는 유인이 커지게 되고, 이는 실제 퇴직일까지의 퇴직금을 후불적 임금 및 퇴직 후 생활보장 수단으로 온전히 보호하기 위해 중간정산 사유를 제한한 개정 퇴직급여법의 취지 및 강행규정성에 반한다. 노사 합의를 반복하고 퇴직금 차액을 구하는 근로자들의 청구를 신의칙 및 금반언을 들어 쉽게 배척할 수 없는 이유도 여기에 있다.